



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

박 사 학 위 논문

임금의 개념과 임금체계의
노동법적 쟁점에 관한 연구

고 려 대 학 교 대 학 원

법 학 과

이 수 정

2024년 2월

박 지 순 교수 지도

박 사 학 위 논 문

임금의 개념과 임금체계의
노동법적 쟁점에 관한 연구

이 논문을 법학박사 학위논문으로 제출함.

2023년 10월

고 려 대 학 교 대 학 원

법 학 과

이 수 정 (인)



이 수 정의 법학박사 학위논문 심사를 완료함.

2023년 12월

위원장	박 종 희	⑩
위 원	하 경 효	⑩
위 원	이 정	⑩
위 원	김 희 성	⑩
위 원	박 지 순	⑩



임금의 개념과 임금체계의 노동법적 쟁점에 관한 연구

이 수 정

법학과

지도교수: 박지순

초 록

이 논문은 경영성과급의 임금성에 관한 법적 분쟁이 증가하면서 임금개념의 재정립 문제가 쟁점이 되고 있다는 점과, 최근 저출산고령화에 의한 인구구조 변화와 글로벌 차원의 사회경제환경 변화로 임금체계 개편 필요성이 확대되고 있다는 점을 배경으로 작성되었다.

첫 번째 쟁점과 관련하여, 대법원이 다루는 임금성에 관한 판결의 상당수는 평균 임금 산입 범위가 문제되는 사건들이고, 대법원은 평균임금에 산입되어야 할 임금의 범위를 정하기 위해 평균임금의 특성을 반영하여 임금 개념을 해석하고 있다. 임금의 개념과 평균임금 산입 범위를 정하는 지표가 달라 두 개념은 분리가 필요한데, 대법원이 지금까지 임금의 개념요소로 활용한 지표는 실제로는 평균임금의 산입 범위를 결정하는 기준이라고 할 수 있다. 대법원은 평균임금이 문제되는 사례에서 해당 임금이 평균임금에 산입되는 것이 타당한지 현실적인 고려를 하면서 평균 임금 개념 해석이 아닌 임금 개념 해석을 통해 그 범위를 조정하려다 보니, 임금의 개념이 축소될 수밖에 없었다.



본 논문은 이러한 문제의식에 터잡아 임금과 평균임금 문제를 해결하기 위해 두 개념의 상호관계를 연구하고, 이를 통해 각 개념의 해석론을 재정립함으로써 임금의 범위가 축소되지 않도록 하고, 근로자의 통상적인 생활임금을 보장하는 취지에 맞게 평균임금의 적정한 산입 범위를 정하는 방법을 검토하였다. 평균임금의 취지에 맞게 임금 개념과 분리하여 개념요소를 정립하면, 임금은 근로제공의 대가로 근로자에게 마땅히 지급되어야 할 금품으로서의 본래적 의미를 찾을 수 있게 될 것이다. 이는 임금법제의 재정립이라는 관점에서 매우 중요한 의미를 갖는다. 이렇게 함으로써 근로자보호라는 임금법제의 목적에 충실하고, 근로기준법상 임금의 정의에 규정된 법문언에도 충실한 해석이 될 뿐만 아니라 앞으로 전개될 새로운 노무제공 형태에 따른 다양한 보상 방식에 대한 분쟁이 발생하였을 때도 신속하고 적절한 해결 방안을 도출할 수 있게 될 것이다.

경영성과급의 임금성에 관한 논쟁에서도 ‘근로의 대가’에 대한 다양한 해석론이 제시되었다. 이에 따라 본 논문은 법원 판결을 대상으로 근로의 대가에 대한 해석론을 검토하면서 그 의미를 분석하고, 앞서 분석한 임금과 평균임금의 개념을 경영성과급에 적용해 보았다. ‘경영성과급’이 임금인지, 구체적으로는 평균임금에 산입되는지 여부에 대해 지금도 계속해서 하급심 판결이 내려지고 있으나, 각 재판부마다 다른 판단이 내려지는 등 논란이 지속되고 있다. 경영성과급은 기업마다 그 지급조건이나 지급방식, 산정방법이 다양하기 때문에 일률적으로 그 임금성을 평가하기 어렵다. 그간의 임금성에 관한 대법원 판례법리에 따르면 경영성과급의 지급이 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 가지고 있어야 하므로 임금으로 인정되기는 어려울 것이다. 본 연구는 경영성과급에서 근로의 대가에 대한 새로운 해석론을 제시하고, 경영성과급의 임금성이 인정되더라도 통상적인 생활임금으로서 평균임금 산입 범위에 포함되는 임금으로 볼 수 있는지 여부를 검토하였다.

그리고 새로운 보상방식으로서 주식보상제의 임금성에 관해 다루었다. 주식보상이 임금에 해당할 경우 근로기준법상 통화지급원칙의 개정문제, 주식보상의 상한 설정의 문제 그리고 평균임금 산입 여부 등 노동법적 쟁점을 연구하였다.

두 번째 쟁점과 관련하여, 우리나라의 상당수 기업들은 근속기간에 따라 자동으



로 임금이 올라가는 호봉제(연공급)를 주된 임금결정 방식으로 활용하고 있다. 다른 나라와 비교하면 우리 기업의 임금체계에서 ‘연공급’의 영향은 압도적이다. 그런데 직무와 성과 중심으로 인적자원관리를 하게 되면 임금도 직무와 성과를 바탕으로 결정될 수밖에 없을 것이다. 노무제공형태와 일하는 방식이 다양화되고 있는 추세를 고려하더라도 임금체계 변경은 불가피해 보인다. 연공형 임금체계가 노동의 가치에 대한 공정한 보상이라는 목적과 괴리가 있다는 내재적 요인도 그 배경 중 하나이다. 그러므로 임금체계 개편의 주된 과제는 연공형 임금체계를 직무와 성과 중심의 임금체계로 변경하는 데 있다. 원래 임금체계의 변경 자체는 노동법 영역에 속한다고 보기 어렵다. 하지만 직무와 성과 중심의 임금체계를 운영하는 과정에서 노동법적 분쟁이 확산될 수밖에 없다. 예를 들어 배치전환이나 인사평가의 경우 임금상승 및 하락과 직접 연결되기 때문에 그 정당성과 관련하여 복잡하고 다양한 노동분쟁이 증가할 것이다. 본 연구는 임금체계 변경으로 인한 노동법적 분쟁에 미리 대비한다는 관점에서 임금체계 변경과 그 운영과정에서 발생하게 될 노동법적 쟁점을 집중적으로 다루었다.

주제어

경영성과급, 근로기준법, 근로의 대가, 단체협약의 효력확장, 취업규칙의 변경, 성과급, 스톡그랜트, 스톡옵션, 스톡퍼처스, 양도제한조건부주식, 연공급, 임금, 임금개념, 임금체계, 주식보상, 직무급, 통상임금, 평균임금



A Study on the Wage Concept and Labor Law Issues of the Wage System

by Lee Soo-Jung

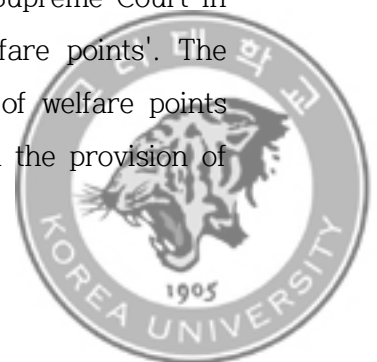
Department of Law

under the supervision of Prof. Park Ji-Soon

Abstract

This thesis is written against the backdrop of two main issues: firstly, the increasing legal disputes over the wage nature of performance-based pay, raising questions about the redefinition of the concept of wages; and secondly, the urgent need for wage system innovation as a major reform agenda in response to the rapid changes in demographic structure due to low birth rates and aging populations, coupled with the rapid globalization of companies.

Regarding the first issue, various interpretations of 'remuneration for labor' have been presented, focusing on the debate over the wage nature of performance-based pay. The conflict of opinions on the criteria for determining remuneration for labor intensified after the Supreme Court in 2019 denied the wage nature of what is known as 'welfare points'. The Supreme Court in this decision denied the wage nature of welfare points because there is no 'direct or close relationship' between the provision of



labor and the employer's payment of money or goods.

In private companies, the widespread practice of what is known as 'management performance pay' is the subject of ongoing debate. Specifically, the controversy revolves around whether it should be considered as wages and included in the calculation of average wages. Despite continuous rulings from lower courts, the issue remains contentious as different judgments are being made by each judicial division, further fueling the debate.

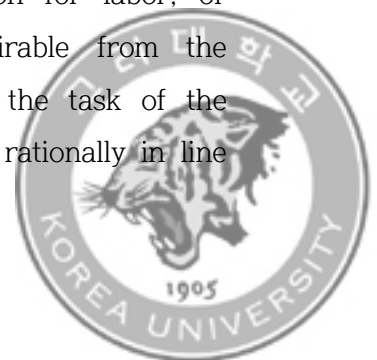
The issue of the wage nature of management performance pay is linked to the policy challenge of improving the regulations and systems of the Labor Standards Act concerning traditional wages and average wages. In other words, with the globalization of companies, there is a demand for a rational compensation system for workers to enhance corporate competitiveness. This requires a new understanding of the existing concepts of wages and average wages. This study addresses the general theory of the wage concept and the wage nature of management performance pay and stock compensation as new forms of remuneration from this perspective.

Regarding the second issue, many companies in Korea utilize a seniority-based pay system (or salary scale system), where wages automatically increase with the length of service. This system's influence in Korean wage structures is overwhelmingly strong compared to other countries. However, if human resource management shifts towards a focus on job responsibilities and performance, wages inevitably need to be determined based on these factors. Considering the diversifying trends in the forms and methods of labor provision, changes in the wage system become inevitable. This is because a seniority-based wage system can



diverge from the objective of providing fair compensation for the value of labor. Therefore, the main task of wage system reform lies in transitioning from a seniority-based system to one centered on job responsibilities and performance. However, changing the wage system itself is not easily seen as belonging to the realm of labor law. Yet, in the process of operating a wage system based on job and performance, labor law disputes are bound to spread. For instance, disputes over labor-management increase due to issues like job reassignments or performance evaluations, as they are directly connected to wage increases or decreases. This study focuses on labor law issues arising from the change and operation of the wage system, preparing in advance for labor law disputes that may result from wage system reform.

The purpose of this study is to re-examine the concept of wages, particularly by reinterpreting the relationship between wages and average wages in light of the objectives and intentions of labor law. Legal disputes over the concept of wages, especially as seen in cases involving management performance pay, are closely related to the system of average wages. Therefore, this study views the key issue as how the interrelationship between the concept of wages and the scope of inclusion in the average wage is understood; in other words, whether the concept of wages and the scope of inclusion in average wages are the same or should be distinguished. In employment relationships, the wages actually received by workers can vary greatly in terms of their eligibility, amount, and method of payment, based on the agreement between the parties. Hence, strictly interpreting the concept of remuneration for labor, or narrowly defining the scope of wages, is not desirable from the perspective of worker protection. On the other hand, the task of the average wage system is to adjust its scope of inclusion rationally in line



with the intent of providing a regular living wage for workers, thereby balancing the interests of employers and workers and enhancing equity among workers. The recent interpretation by the Supreme Court's En Banc session regarding the wage nature of welfare points should more accurately be viewed as an interpretation centered on the scope of inclusion within average wages, rather than relating to the broader general concept of wages.

Keywords

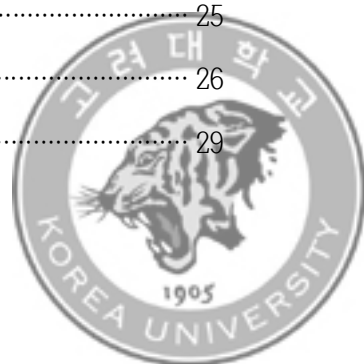
Management Performance Pay, Labor Standards Act, Remuneration for Labor, Extension of Collective Agreement's Effect, Modification of Employment Rules, Performance Bonus, Stock Grant, Stock Option, Stock Purchase, Restricted Stock Unit, Seniority-Based Pay, Wage, Wage Concept, Wage System, Stock Compensation, Job-Based Pay, Ordinary Wage, Average Wage.



목 차

초 록

제1장 서론	1
제1절 연구배경 및 목적	1
제2절 연구의 구성	5
제2장 임금 개념 일반론	7
제1절 근로기준법상 임금의 의미	7
I. 임금청구권의 발생	7
1. 임금청구권의 법적 근거	7
2. 임금지급의무의 주체	11
3. 사용자 지급 금품의 임금성 유무	11
II. 임금 개념의 특징	13
1. 임금의 법률상 정의	13
2. 근로계약의 목적	14
3. 임금의 기본요소	17
4. 임금의 법적 규제와 그 범위	19
III. 임금과 유사한 법률상 개념	21
1. 다른 법령에서 사용하는 용어	22
2. 경영학적 관점에서 보상체계의 구조	24
제2절 “근로의 대가”를 둘러싼 해석론	25
I. 임금의 요건으로서 “근로의 대가”	26
II. 임금의 법적 성질에 관한 학설	29



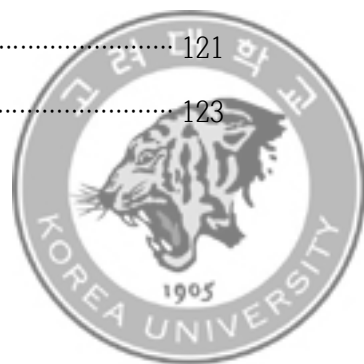
1. 학설 개관	29
(1) 근로대가설	29
(2) 노동력대가설	30
(3) 근로관계보상설	31
(4) 검토	31
2. 이른바 임금이분설과 “근로의 대가”의 의미	32
Ⅲ. “근로의 대가”의 해석에 관한 판례의 태도	35
1. 종래 이론적·실무적 태도	35
2. 근로의 대가로 인정되지 않는 급여의 예시	36
(1) 임의적·은혜적 급여	37
(2) 실비변상적 급여	37
(3) 복리후생급여	38
(4) 근로자에게 지급되는 특별한 형태의 금품	38
3. 판례의 태도	39
(1) 근로제공과의 직접 또는 밀접한 관련성을 강조한 사례	40
(2) 계속적·정기적 지급 여부를 강조한 사례	43
4. 판례에 대한 평가	45
제3절 비교법적 검토	48
Ⅰ. 독일	48
1. 계속적·정기적 임금과 특별급여의 구분	48
2. 특별급여의 경우 지급일 재직 요건의 유효성	50
3. 소결	51
Ⅱ. 일본	52



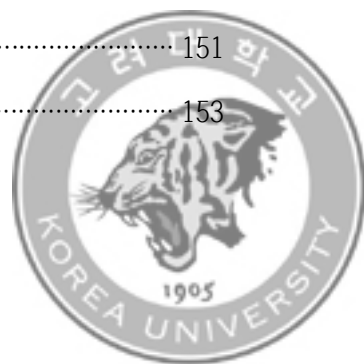
1. 노동의 대상(對償)	52
2. 평균임금의 산입 범위	53
3. 일본의 상여금제도	54
(1) 상여금에 대한 기본적 태도	54
(2) 지급일 재직 요건의 유효성	55
Ⅲ. 그 밖의 참고 사례	57
1. ILO 협약상 임금의 정의	57
2. 미국	58
3. 프랑스	60
Ⅳ. 시사점	62
제4절 임금의 형태와 법적 규제	63
Ⅰ. 임금의 형태와 법적 규제의 방향	63
1. 임금의 형태와 그 전개과정	63
2. 임금형태에 대한 법적 규제의 방향	66
Ⅱ. 평균임금의 의의와 임금 개념의 관계	67
1. 평균임금의 개념과 쟁점	67
2. 현행법상 임금과 평균임금의 관계	69
3. 검토	72
4. 토론: 평균임금 산입 범위에 관한 최근 쟁점	76
(1) 네트제 임금계약에서 평균임금의 범위	76
(2) 근로기준법 제57조 보상휴가제 실시와 평균임금 산정 방법	82
Ⅲ. 통상임금과 임금 개념의 관계	84
1. 통상임금의 개념과 쟁점	85



2. 지급일 재직 요건의 유효성	86
3. 임금 개념과의 관계	89
제5절 소결	91
 제3장 임금이 논란이 되는 보수 형태	94
제1절 경영성과급의 임금성	94
I. 경영성과급의 개념	94
1. 경영성과급의 의의	94
2. 경영성과급의 유형	96
3. 성과배분으로서 경영성과급의 의의	97
II. 성과배분의 형태와 법적 성격	99
III. 경영성과급 임금성 판단에 관한 하급심 판결 분석	100
1. 임금을 인정한 하급심 판결	101
2. 경영성과급의 임금을 부인한 하급심 판결	105
IV. 판결에 대한 검토 및 경영성과급의 임금성 여부	109
1. 판결의 검토	109
2. 경영성과급의 임금성 여부	115
제2절 주식보상제도	119
I. 주식보상의 의의	119
II. 주식보상제의 유형	120
1. 우리사주제도	120
2. 스톡옵션	121
3. 스톡그랜트 등 협의의 주식보상제도	123



(1) 스톡그랜트	123
(2) 스톡퍼처스 제도	125
(3) 양도제한조건부 주식제도 (RS, Restricted Stock)	125
4. 스톡옵션과 RS의 비교	128
5. RS의 활용 가능성	130
II. 주식보상제의 노동법적 쟁점	131
1. 주식보상의 임금성	131
2. 주식보상과 임금지급의 원칙(통화지급의 원칙 위반 문제)	133
3. 전체 임금에서 주식보상의 범위(지급액의 제한)	136
4. 주식보상과 평균임금 산정 방식	137
제3절 소결	139
 제4장 임금체계의 노동법적 쟁점	143
제1절 서설	143
제2절 임금체계 개선의 방향과 내용	144
I. 임금체계의 변천과 특징	144
1. 의의	144
2. 연공형 임금제도의 특징	145
3. 임금제도 개선의 배경과 방향	147
II. 임금체계 변경과 임금 구성의 변화	150
1. 기본급의 구성요소와 변경	150
2. 수당제도의 재편 및 폐지	151
3. 상여금제도 및 성과급제도의 개선	153



제3절 임금청구권의 변동과 소멸	155
I. 논의 필요성	155
II. 승급과 노동법적 쟁점	156
III. 임금의 감액(감급)	159
1. 집단적 임금 감액	159
(1) 취업규칙의 변경에 의한 임금감액	161
(2) 단체협약에 의한 임금감액	162
(3) 집단적 임금감액으로서 임금피크제의 유효성	164
2. 개별적 임금감액	166
(1) 직무와 직위, 등급의 변동에 의한 감급	166
(2) 능력과 성과의 평가에 기한 감급의 경우	167
(3) 동의 여부	168
3. 징계처분으로써 임금감액	170
IV. 임금청구권의 소멸	171
V. 소결	172
제4절 직무급제의 도입과 노동법적 쟁점	173
I. 서설	173
II. 직무급의 법적 의의	175
1. 직무급의 뜻	175
2. 직무급과 인사제도의 변화	175
3. 직무급제도의 해석을 둘러싼 법적 관점	177
III. 인사평가제도	178
1. 문제의 소재	178



2. 직무급제도와 인사평가	179
(1) 제도설계 및 절차의 정비	179
(2) 인사평가의 공정성	181
3. 능력개발 및 교육훈련	181
4. 배치전환, 승진 및 강등	183
(1) 배치전환	183
(2) 승격	186
(3) 강등(降等), 강급(降級), 강격(降格)	188
5. 해고	190
(1) 서설	190
(2) 직무급제에서의 해고의 판단	190
제5절 성과주의 임금제와 노동법적 쟁점	191
I. 성과주의 임금제도 및 연봉제의 의의	192
1. 성과주의 임금제도의 의의	192
2. 연봉제의 의의와 법적 쟁점	192
II. 인사평가의 공정성	194
1. 인사평가의 근거와 요건 및 효과	194
2. 공정한 평가의 법적 구조	196
III. 연봉제와 근로계약	199
1. 고용기간과 임금결정기간	199
2. 연봉청구권의 발생	200
3. 연봉액의 결정	201
제6절 임금체계 변경 절차에 관한 쟁점	202



I. 개설	202
II. 근로계약의 변경을 통한 임금체계 변경	203
III. 취업규칙을 통한 임금체계 변경	205
1. 불이익 변경의 일반원칙	205
2. 불이익 변경 원칙의 예외	207
3. 성과주의 임금체계 도입과 “사회통념상 합리성”	208
4. 집단적 동의권 남용이론의 적용	209
5. 동의의 주체	210
6. 소결	212
IV. 단체협약의 변경을 통한 임금체계 변경	213
1. 과반수노조의 단체협약 체결의 효력	213
2. 단체협약, 취업규칙, 근로계약의 불일치와 효력관계	214
 제5장 요약 및 결론	 217
 [참고문헌]	 222



제1장 서론

제1절 연구배경 및 목적

최근 임금제도와 관련하여 크게 두 가지 과제에 직면하고 있다. 그 첫 번째는 경영성과급의 임금성에 관한 법적 분쟁이 늘어나면서 임금의 개념에 대한 재정립 과제가 등장한 것이다. 경영성과급의 임금성 논쟁은 특히 2018년 말 대법원의 ‘공공기관 경영평가성과급’ 임금성 판결¹⁾에서 비롯되었다. 대법원은 이 판결에서 임금의 개념을 근로자에게 정기적·계속적으로 지급되고 단체협약, 취업규칙, 근로계약, 노동관행 등으로 사용자에게 지급의무가 있는 것이라고 판시하였다. 즉, ‘사용자의 지급의무’ 및 ‘계속성·정기성’을 기준으로 집단성과급의 임금성을 인정하는 판결을 내린 것이다. 이 판결은 민간기업 집단성과급인 경영성과급의 임금성과 관련된 다수의 소송을 촉발시키는 계기가 되었다.

이 사건을 계기로 학계 및 실무에서도 경영성과급의 임금성에 관한 논쟁을 중심으로 ‘근로의 대가성’ 판단 기준에 관한 다양한 해석론이 제시되었다.²⁾ 근로의 대가에 대한 개념과 판단 방법에 관한 견해의 대립은 2019년 대법원 전원합의체가 이른바 ‘복지포인트’에 대한 임금성을 부정하면서 더욱 심화되었다.³⁾ 대법원은 이 판결

1) 대법원 2018.12.13 선고 2018다231536 판결.

2) 이수정/박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 임금성”, 「노동법포럼」, 제28호, 2022 참고. 그 밖에도 권혁, “임금의 개념으로서 근로 대가성 판단에 관한 소고”, 「노동법포럼」, 제28호, 2019; 심재진, “공공기관 경영평가성과급의 임금성”, 「산업관계연구」, 제29권 제3호, 2019; 유성재, “경영평가성과급의 임금성”, 「월간 노동법률」, 343호, 2019; 이정현, “공공기관 경영평가성과급의 임금성 여부”, 「월간 노동법률」, 343호, 2019; 정종철, “변동성과급은 평균임금에 포함되어야 하는가?”, 「월간 노동법률」, 340호, 2019; 이정, “상여금(경영성과급)의 법적 성격에 관한 연구”, 「외법논집」, 제44호 제2권, 2020; 임상민, “성과상여금의 (평균)임금성”, 「사법」, 55호, 2020; 박지순/이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 「노동법논총」, 제49집, 2020; 권오성, “경영 성과급의 임금성”, 「월간 노동법률」, 346호, 2020.; ; 박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 「노동법포럼」, 제38호, 2023.

3) 대법원 2019.8.22 선고 2016다48785 전원합의체 판결. 이에 관해서는 박종희, “복지포인트의 임금성”, 「노동법포럼」, 제28호, 2019; 한광수/김희성, “복지포인트의 임금해당



에서 ‘공공기관 경영평가성과급’ 사건과 달리 복지포인트에 대해서는 근로제공과 사용자의 금품 지급 간에 ‘직접 또는 밀접한 관련성’이 없다는 이유로 그 임금성을 부인하였기 때문이다.

이와 같은 이유로 민간기업에서 확산되고 있는 이른바 ‘경영성과급’이 임금인지, 구체적으로는 평균임금에 산입되는지 여부에 대해 지금도 계속해서 하급심 판결이 내려지고 있으나 각 재판부마다 정반대의 결론이 내려지는 등 논란이 지속되고 있다. 심지어 동일한 회사의 경영성과급 임금성 사건임에도 각각 다른 법원에 소송이 제기되고 같은 사실관계임에도 상반된 결론이 내려짐에 따라 문제가 확산되고 있다.⁴⁾ 이러한 사법부의 혼선은 노사 모두에게 상당한 혼란을 초래하고 있으며, 임금제도 전반에 대한 법적 불안정성도 증폭시키고 있다.

하지만, 경영성과급의 임금성 문제는 단순히 경영성과급이 임금이나 아니냐라는 이분법적 논리나 관점이 아니라 과거 임금시스템에 맞춰진 임금과 평균임금에 관한 근로기준법의 규정과 제도를 개선해야 한다는 정책과제와 맞물려 있다. 즉, 기업의 글로벌화에 따른 기업경쟁력 향상을 위해서는 근로자에 대한 합리적 보상체계가 마련되어야 한다는 요청이 있고 이를 위해서는 기존의 임금 및 평균임금 개념에 대한 수정이 필요하다는 것이다.⁵⁾

두 번째 과제는 최근 저출산고령화의 인구구조 변화와 기업의 글로벌화가 급속히 진행하면서 임금체계를 개혁해야 한다는 것이다. 2022년 12월 고용노동부에 설치된 미래노동시장연구회의 권고문은 임금체계 개편을 노동개혁의 핵심과제로 제시하였

성”, 「노동법논총」, 제48집, 2020 등 참고.

4) S사의 경영성과급에 대해 임금성을 인정한 판결: 서울중앙지법 2021.6.17. 선고 2019가합542535 판결. 같은 회사의 경영성과급에 대해 임금성을 부인한 판결: 수원고등법원 2021.6.17. 선고 2020나26085 판결. 이와 관련된 기사로 광용희, “삼성전자 퇴직금 소송, 법원에서 판단 엇갈렸다…수원고법선 “근로자 패소”, 「월간 노동법률」, 362호, 2021, 70면 참고.

5) 임금제도 전반에 대한 개선이라는 관점에서 논의하고 있는 것으로 김희성/성대규, “성과배분으로서 경영성과급의 임금성에 대한 고찰”, 「노동법포럼」, 제35호, 2022; 김희성/이준희, “경영성과급의 근로 대가성 인정요건에 관한 판례 검토”, 「노동법논총」, 제54집, 2022; 신동윤/성대규, “경영성과급의 임금성 판단기준에 관한 고찰”, 「사회법연구」, 제46호, 2022; 조상욱, “경영성과급 임금성의 법적 쟁점”, 「월간 노동법률」, 367호, 2021; 최진수, “임금의 양대 요건으로 본 경영성과급”, 「월간 노동법률」, 371호, 2022.



다. 그에 따르면 우리나라의 상당수 기업들은 해가 바뀌면 자동으로 임금이 올라가는 호봉제(연공형제)를 중요한 임금결정 방식으로 활용하고 있다. 100인 이상 사업체의 약 55.5%, 300인 이상 사업체의 60.1%, 1,000인 이상 사업체의 70.3%가 이러한 임금체계를 유지하고 있다. 다른 나라와 비교하면 우리 기업의 임금체계에서 연공의 영향이 압도적이며 이는 임금의 하방경직성을 강화하여 기업의 신규채용 기회를 축소하고 있다. 특히 연공급제는 중고령 근로자들의 고용유지에도 부정적 효과를 낳고 있으며, 남녀 간 임금격차를 초래하는 원인으로 지적되기도 한다.⁶⁾ 또한 연공형 임금체계(연공급제)는 노동시장의 이중구조를 촉진·고착화시키는 주된 원인으로 지목되고 있다. 연공급은 근속기간의 안정적 축적이 가능한 계층(우리는 이를 일반적으로 “정규직”이라고 부른다)에게만 배타적으로 유리하기 때문이다. 즉, 대기업 유노조 사업장에 종사하는 정규직 남성의 임금이 높은 이유는 근속기간 축적이 가능한 사실상 유일한 계층이기 때문이다. 반면에 이직이 잦아 연공을 누적시키기 어려운 계층들, 즉 비정규직, 중소기업소속 근로자, 여성 등의 경우 상대적으로 임금의 안정적 인상 효과를 누릴 수 없게 된다.

그 결과 2021년 고용노동부 고용형태별 근로실태조사에 따르면, 대기업 대비 중소기업 근로자의 임금은 56.3%, 남성 대비 여성 근로자의 임금은 69.6%, 정규직 대비 비정규직 근로자의 임금은 72.4%에 불과하다. 이처럼 연공형 임금체계는 고용경직성 및 고비용구조의 원인이 되었고, 그 결과 노동시장 이중구조를 확산·심화시키고 있으며, 과도한 연공주의는 세대 간 및 고용형태 간에도 임금격차를 확대시키는 원인이라고 할 수 있다.

임금체계 개혁의 핵심과제는 연공 중심의 임금체계를 직무, 역할, 공헌도(기여도 또는 성과)를 중심으로 하는 임금체계로 전환하는데 있다고 할 수 있다.⁷⁾ 후자의 임금체계는 각 근로자의 ‘직무’와 ‘역할’의 복잡성·난이도·책임의 정도를 기준으로 임금을 결정하는 방식을 말한다. 다시 말해 임금은 각 근로자가 만들어낸 부가가치·성과(공헌도)에 의하여 결정된다. 따라서 제도 설계 시 각 근로자의 직무와 역할의 복잡성, 난이도 및 책임 정도를 명확히 하고, 그 상대적 가치서열을 등급(자격)

6) 고용노동부, “미래노동시장연구회 권고문”, 2022.12.12., 3면.

7) 고용노동부, “미래노동시장연구회 권고문”, 2022.12.12., 6면.



화하는 인사제도를 마련하는 것이 절대적으로 필요하다. 따라서 임금체계의 개혁은 인사제도와 하나의 패키지로 인식되어야 그 목적이 달성될 수 있다. 인사평가시스템이 임금제도에 미치는 영향을 분석해야 하는 이유이다. 그런데 이 두 가지 과제는 서로 연결되어 있다. 임금제도와 인사제도가 하나로 연결된다면 이것이 임금 개념에 어떤 영향을 미치게 될 것인지 검토가 필요하다.

특정 금품의 임금성 판단이 어려운 이유 중 하나는 전통적 방식의 임금결정 및 지급방법이 변화하고 있기 때문이다. 특히 성과주의 임금제도가 그 변화의 중심에 있으며, 그 주요 지급형태는 기업의 성과나 실적에 기반한 단기적, 중장기적 인센티브라고 할 수 있다. 경영성과급이 단기의 현금 인센티브라면, 주식보상제는 중장기적 인센티브제도라고 할 수 있다. 물론 성과주의 임금제도에서는 근로자 개인의 성과측정(평가)이 주된 구성요소라고 할 수 있지만 기업의 성과(실적, 주식가치 등)도 중요한 요소로 반영된다. 하지만 이러한 보상방식이 가진 높은 변동성으로 인하여 이를 전통적인 임금 또는 평균임금 개념에 포함하여 설명하는 것이 타당한지 의문이 제기될 수 있다. 평균임금이나 통상임금과 같이 각종 법정수당을 산정하는 기준임금은 어느 정도 예측가능한 통상적 생활임금을 전제로 하는 것이다. 하지만 임금의 변동성이 크다면, 또는 변동성이 큰 임금항목은 그와 같은 기준임금의 산입대상으로는 부적절할 것이다. 그렇지만 근로기준법은 이 점에 대한 적절한 고려가 없는 것으로 보인다. 따라서 임금 개념 및 그와 관련된 제도(평균임금, 통상임금)의 구조와 새로운 임금체계 및 보상방식을 연결시키는 것이 과제가 될 것이다. 이것이 본 연구의 문제의식이라고 할 수 있다.

임금의 개념 문제는 사용자가 근로자에게 지급하는 금품의 법적 성격을 판단하기 위한 것으로, 이는 임금에 관한 근로자의 법적 권익 보호의 범위가 어디까지 미치는지, 어떤 금품까지 임금으로 설정하는 것이 타당한지에 관한 문제이다. 임금성을 넓게 해석할 경우 임금에 관한 법제가 강행규정성을 가지고 있음을 고려하면 법적 안정성에 반하게 되며 반대로 임금성을 좁게 해석할 경우 근로자의 임금 보호라는 합목적성에 반하게 된다. 이러한 이유로 인해 각 관점에 따라 임금의 개념과 범위를 다르게 정의하고 판단하는 다양한 견해가 제기될 수밖에 없다. 따라서 임금 개념



념의 명확한 정립과 그 범위에 관한 합리적 판단은 매우 중요한 문제이다.

한편, 임금체계 개편의 당위성을 인정하더라도 임금체계 개편이 어떤 내용과 방식으로 이뤄지는지, 그에 따른 노동법적 쟁점이 무엇인지 검토가 필요하다. 왜냐하면 임금체계의 변경이 특정 금품의 법적 성격에 일정한 영향을 미칠 수도 있으며, 임금체계의 개편은 임금 구성 및 임금액 결정에 관한 기술적 문제로 그치는 것이 아니라 인사관리 등 고용관계 전반에 영향을 미치기 때문이다. 따라서 임금체계 개편의 방향과 내용을 검토하면서 동시에 그로 인해 야기될 수 있는 인사관리의 문제가 함께 논의되어야 합리적인 선택이 가능하게 된다. 이와 같이 임금체계 개편에 따른 노동법적 쟁점을 검토하는 것도 중요한 과제라고 할 수 있다.

제2절 연구의 구성

본 연구는 임금의 개념을 근로의 대가라는 법률상 정의의 관점에서만 분석하기 보다는 임금청구권의 구조와 임금체계론의 관점에서 현실적이고 체계정합적으로 이해하고자 한다. 최근 논란이 되는 임금 개념은 특히 경영성과급의 임금성 관련 분쟁에서 보듯이 평균임금제도와 밀접하게 관련되어 있다. 따라서 임금 개념과 평균임금제도를 어떻게 이해하느냐, 달리 말하면 임금의 범위와 평균임금 산입 범위가 일체적인 것이냐, 아니면 이원적 구조로 이해될 수 있느냐가 화두가 될 것이다. 또한 직무급 및 성과주의라는 새로운 보상시스템에 걸맞는 인사제도와 임금제도의 유기적 관련성을 토대로 임금의 개념과 임금제도의 내용을 현실에 맞게 재해석하고 그 입법정책적 과제를 도출하는데 목적이 있다. 이와 함께 근로관계에서 근로자가 수령하는 임금은 당사자 간의 합의에 의하여 그 지급 여부 및 지급액 그리고 지급 방법(지급형태)이 얼마든지 다양하게 구성될 수 있으며, 노동법은 최소한의 강행적 규율을 통해 당사자의 합의가 근로자에게 불합리한 결과가 발생하지 않도록 통제하고, 인간다운 생활을 위하여 필요한 기본적 사항을 규율하는데 목적이 있음을 확인



하고자 한다.

본 연구는 이러한 관점에서 다음과 같이 구성한다. 먼저 제2장에서는 임금의 개념 일반론을 노동법체계적 관점에서 재구성해 본다. 특히 근로기준법상 임금의 가장 핵심 개념인 ‘근로의 대가’의 의미와 판단요건 그리고 판단기준을 재확인하고, 이를 바탕으로 현실적 관점에서 임금 개념을 해석한다.

제3장에서는 임금 개념론에서 가장 논란이 되고 있는 구체적 사안인 경영성과급과 최근 대기업을 중심으로 확산되고 있는 주식보상제의 의의 및 법적 성격과 노동법적 쟁점도 함께 검토한다. 이를 통해 임금 개념과 평균임금의 정의를 이원화하는 것이 복잡하고 어려운 임금 개념 문제를 해결하는 방법이라는 점을 확인한다. 평균임금의 산정방식은 임금의 개념에 관한 본질적 문제라기보다는 어느 수준에서 근로자에게 합리적 보상정책이 될 수 있는지 입법정책적 결정의 문제이므로 다양한 보상제도와 평균임금의 관계를 현실화하는 문제와도 관련된다.

제4장에서는 임금체계 개편은 결국 현재의 연공형 임금제도를 직무급 또는 성과주의 연봉제로 변경하는 문제이므로 그로 인한 노동법적 쟁점(특히 인사제도와와의 관계)을 다루고 이와 연결된 임금 개념의 문제를 제시하며 이를 통해 노사 당사자간에 법적 안정성을 도모하고 임금에 관한 노동법제의 발전에도 기여할 수 있도록 한다. 또한 임금 개념의 법체계적 이해를 위해서는 “근로의 대가”에 대한 문언적 해석만 가지고 분석할 것이 아니라 임금체계 및 임금구성 내용도 검토대상이 되어야 한다.



제2장 임금 개념 일반론

제1절 근로기준법상 임금의 의미

I. 임금청구권의 발생

1. 임금청구권의 법적 근거

근로계약상 임금청구권의 성립에 관하여는 민법상 고용계약의 규정 및 계약의 일반규정이 적용된다. 민법 제655조에 따르면 당사자일방(노무자)이 상대방(사용자)에게 “노무 제공”을 약정하고 상대방은 그 반대급부로 “보수 지급”을 약정함으로써 고용계약이 성립한다. 즉, 노무를 제공할 것과 보수의 지급은 대가관계에 있다. 또한 보수는 당사자가 약정한 시기에 지급되어야 하고 시기의 약정이 없으면 관습에 의하고 관습이 없으면 약속된 노무제공을 종료한 후 지체없이 지급하여야 한다(민법 제656조 제2항). 다시 말해 민법에 따르면 임금과 근로는 동시이행의 관계에 있는 것이 아니라 임금이 후불되는 관계에 있으므로 당사자의 합의(특약)가 없으면 근로자가 약속한 노무를 종료한 후에야 보수를 청구할 수 있다.

이와 같이 임금청구권의 성립근거는 그 지급에 관한 “당사자의 합의”이며, 그 지급시기도 당사자의 합의가 우선하지만, 합의가 없는 경우에는 후불되는 것이 원칙이라고 할 수 있다. 물론 노무제공에 대하여 보수를 지급하지 않는다는 취지의 약정(예컨대 무상위임)도 원칙적으로 가능하다. 다만, 무상의 노무제공관계는 고용 또는 근로계약이라고 할 수 없다. 또한 반대로 노무를 제공하지 않은 기간에 대하여도 각종 수당 등의 금품을 지급하기로 하는 당사자의 특약(예를 들어 주택수당이나 가족수당의 경우 근로제공이 없어도 지급한다는 당사자의 약정)도 가능하다. 물론



그 경우 보수지급의 근거는 노동관계법이 아니라 당사자의 합의이다. 합의가 없으면 법률상 특별한 규정이 없는 한 무노동무임금이 적용되므로 그와 같은 보수지급 의무는 발생하지 않기 때문이다.

고용계약상 임금청구권은 사용자가 근로자에게 보수(임금)를 지급한다는 당사자의 합의를 그 법적 근거로 한다. 그렇지만 사용자가 지급의무를 부담하는 보수라고 해서 언제나 “근로의 대가”, 즉 임금이라고 할 수는 없다. 근로기준법에 따르면 특정 금품이 임금이기 위해서는 “근로의 대가”로 지급된 것이어야 하기 때문이다(근기법 제2조 제1항 제5호). 결국 합의(사용자의 지급의무)와 “근로의 대가”와의 관계를 어떻게 이해해야 하는지가 관건이다.

임금청구권을 성립시키는 “합의”는 계약당사자 간의 근로계약뿐만 아니라 단체협약 및 취업규칙을 통해서도 형성될 수 있다. 현실적으로는 단체협약보다 취업규칙에 의한 약정이 더 일반적이라고 할 수 있다. 물론 법률에 의하여 그 지급이 의무화된 금품은 이른바 법정수당이므로 합의에 의한 임금청구권과 구별된다. 그 밖에도 사실인 관습 등 고용계약(근로계약)의 내용이 될 수 있는 모든 형태의 법원(法源)에 의하여 임금청구권이 성립될 수 있다. 예를 들어 채용공고에 임금액이나 특정 항목의 수당지급을 기재하였는데, 채용과정(예를 들어 면접)에서 그 기재된 내용을 다시 한번 확인해 주었거나, 적어도 기재된 것과 다른 내용으로 설명하지 않았다면 채용공고의 기재내용을 청구권의 근거로 인정할 수 있을 것이다. 퇴직하는 임원에게 퇴직위로금을 지급하는 관행이 있다면 그 관행을 청구권의 근거로 인정할 수 있다.⁸⁾ 반대로 그러한 취지의 합의도 없고, 사실인 관습도 인정되지 않는다면 해당 금품에 대한 청구권은 성립하지 않는다.

임금청구권의 성립시기도 기본적으로 당사자의 합의(또는 개별 계약의 해석)에 따라 정해진다. 개별 계약의 해석에 의해서도 구체적인 합의 내용이 확정될 수 없는 경우에는 임금의 지급시기(이행기)에 관한 민법상의 임의규정에 따라 노무제공 또는 보수지급의 단위기간(월, 주, 일)이 경과하면 지체 없이 임금청구권이 발생한다고

8) 水町勇一郎, 「詳解勞働法」, 2019, p.586. 이때 퇴직위로금이 근로의 대가로서 임금이라고 할 수 있는지가 문제된다. 이 퇴직위로금은 근로의 대가라고 할 수 없으므로 임금으로 보기 어려울 것이다.



해석된다(민법 제656조 제2항).⁹⁾

일본 최고재판소 판결 중에는 임금청구권은 노무급부와 대가적 관계에 서있으며, 일반적으로는 근로자가 현실적으로 노무를 제공해야 비로소 발생하는 후불적 성격을 가진다고 판시하고 있다.¹⁰⁾ 다만, 이는 당사자 간 합의가 없는 경우에 대한 임의적 해석준칙을 서술한 것이고, 강행적인 법원칙으로서 임금은 취업(노무제공) 후에 비로소 발생한다는 점을 판시한 것은 아니다. 예를 들어 “무노동무임금 원칙”은 쟁의행위의 경우를 제외하고(노조법 제44조 제1항 참조),¹¹⁾ 당사자 간에 합의가 없는 경우에 적용되는 임의적인 해석준칙에 지나지 않는다. 예를 들어 월급제의 경우 월의 도중에 급여지급일이 있더라도(예를 들어 매달 10일 또는 25일)급여지급일에 그 달의 임금 전액이 지급되는 것이 실무상 일반적인 현상이면서 그와 같은 합의(아직 근로제공이 없는 부분의 임금도 발생한다는 취지의 합의)는 당연히 유효하다.

또한 근로계약에서 근로와 임금의 대가관계를 고려하면, 근로제공에 대하여 임금을 지급한다는 명시적 합의가 존재하지 않는 경우에도 근로계약의 합리적 의사해석에 의하여 근로제공에 대응하는 임금지급에 관한 묵시적 합의의 존재를 인정할 수 있다. 통상 유상쌍무계약에서 반대급부에 대한 약정이 없는 경우 그 계약은 무효가 되지만(이른바 “불합의”), 근로계약에서는 당사자의 계약의사를 적극적으로 추단함으로써 쉽게 근로계약을 무효화하지 않도록 하여 근로자의 보호를 도모할 수 있다.

근로와 임금의 대가관계는 근로계약의 법적 성격을 밝히는 본질적 부분이므로, 근로기준법상 근로시간에 해당하면 실제로 근로제공이 없더라도(예컨대 대기시간) 통상 근로계약상 임금 지급의 대상이 되는 시간으로 해석하는 것이 합리적이다. 따라서 근로제공이란 노동력이 실제로 투입되고 있는지가 아니라 일정시간 동안 노동력의 처분을 사용자에게 맡겨둔 상태이면 충분하다.

근로자는 채무의 내용에 따라 근로를 제공해야 하고, 근로자가 채무의 내용에 따

9) 김형배, 「노동법」, 제26판, 2018, 343면.

10) 最高裁判所 昭和 63.3.15 民集 42卷 3号 p.170.

11) 쟁의행위의 경우는 노사 간 합의의 대등성이 중요한 전제조건이므로 노조법 제44조 제1항은 강행규정이고, 따라서 쟁의기간 중 지급해야 할 임금에 관한 당사자의 합의는 쟁의대등성 원칙에 따라 부인된다고 해석된다.



라 근로를 제공하지 아니하여 사용자가 그 노무 수량을 거절할 경우 사용자는 근로자의 임금지급 청구를 거절할 수 있다고 해석된다. 채무의 내용에 따른 이행의 제공이 없기 때문에 사용자가 그 수량을 거절하였다면 이에 수반하는 노무제공 불능에 대한 책임을 사용자에게 물을 수 없다고 해석되기 때문이다. 반대로 근로자가 채무의 내용에 따른 이행의 제공을 하였음에도 사용자가 노무수량을 거절하는 경우에는 사용자의 귀책사유로 노무제공의 이행이 불가능하게 된 것이므로 사용자는 근로자의 임금청구를 거절할 수 없다.

또한 근로자가 채무의 내용에 따른 이행의 제공을 하고 있지 않은 상황이라도 사용자가 그 근로제공을 수령하고 있다면 그 시간은 사용자의 지휘명령에 따른 근로시간이므로 임금청구권이 발생한다고 해석된다. 예를 들어 종업시간 후와 같이 소정근로시간 외에 근로자가 직장에 남아 사용자의 지시 등을 받지 않고 자유로이 초과근로한 시간에 대해서는 사용자의 지휘명령(사용자의 노무수령)에 따라 근로를 제공하고 있다고 할 수 없으므로 별도의 합의 등이 없는 한 임금청구권은 발생하지 않지만 사용자가 그 근로제공을 수령하였다면 임금청구권이 발생한다.

요약하면 근로자가 임금청구권을 보유하고 있는지 그리고 어떠한 내용의 청구권을 가지는지는 단체협약 또는 취업규칙을 포함한 근로계약의 내용에 의하여 결정된다. 다만, 임금의 최저액 보장을 위하여 제정된 최저임금법과 도급 근로자에 대한 일정액의 임금보장(근기법 제47조)과 같은 강행적 규제가 마련되어 있으므로 이를 준수하면서 위에서 서술한 바와 같이 노사의 자율적 합의에 의하여 임금이 결정되는 구조라고 할 수 있다. 따라서 당사자의 합의가 임금 개념 및 임금의 범위에 대하여 중요한 의미를 갖는다고 볼 수 있다. 당사자의 합의는 임금 개념에서는 사용자의 지급의무로 구체화된다. 다시 말해 사용자가 지급하는 금품이 임금이기 위해서는 적어도 당사자 합의에 의하여 사용자에게 지급의무가 있는 것이어야 한다.¹²⁾ 다만, 당사자 합의에 의하여 사용자에게 지급의무가 있다고 해서 모두 임금인지 여부가 논란이 된다(이에 대해서는 아래 3.에서 다시 설명한다).

12) 물론 사용자의 지급의무는 당사자 간 합의에 의해서만 발생하는 것은 아니다. 법률도 사용자의 지급의무를 발생시키는 중요한 법원(法源)이라고 할 수 있다.



2. 임금지급의무의 주체

임금지급의무를 부담하는 주체는 근로계약의 당사자인 사용자이다.¹³⁾ 근로자가 근로계약의 당사자가 아닌 외부 기업(제3자)에서 (근로자파견, 전출, 사내하도급 등의 방법으로) 근로를 제공하는 경우에도, 원칙적으로 임금지급의무의 주체는 근로계약의 상대방(고용주)인 파견사업주, 전출회사, 하도급회사이다.

다만, 예외적으로 근로계약의 상대방이라고 할 수 있는 회사들이 사실상 실체를 가지고 있지 아니하고(形骸化), 근로를 제공받는 제3자인 기업이 임금을 실질적으로 결정하고 있는 경우에는 묵시의 근로계약법리 또는 법인격부인 법리에 따라 현실적으로 근로를 제공받는 회사가 임금지급의무를 부담할 수 있다. 다시 말해 해당 근로자에 대한 실질적인 사용자는 임금지급의무를 부담하고 있는 기업이라고 할 수 있다.

3. 사용자 지급 금품의 임금성 유무

이처럼 사용자는 근로자와 합의에 의하여 다양한 형태의 금품을 지급할 의무를 부담한다. 하지만 사용자가 근로자에게 지급의무를 부담하는 모든 금품이 근로기준법상 보호대상인 “임금”인지 여부에 관하여는 다툼이 있다. 여기서 유의해야 할 점은 고용(근로)계약상 사용자의 지급의무가 있다고 해서 곧바로 임금에 해당하는 것은 아니라는 점이다. 해당 금품은 근로의 대가로서 지급의무가 발생해야 하기 때문이다. 물론 근로자의 임금지급청구권이 특정 금품의 지급 그 자체를 다투는 경우에는 그와 같은 금품의 지급에 대한 약정이 있는지 여부가 관건이므로 임금의 의미를 넓게 이해해도 무방할 것이다. 그렇지만 특정 금품이 임금인지 여부를 넘어 다시

13) 김형배, 「노동법」, 342면.



평균임금 산입 여부를 판단하고 그에 따라 평균임금을 재산정하여 미지급된 부분에 대한 추가지급을 요구하는 것이 청구내용이라면, 다시 말해 해당 금품이 평균임금 산입 범위에 포함되는지 여부가 쟁점이라면, 이 경우에는 포괄적 임금 개념이 아니라 평균임금 산입에 합당한 임금 개념(협의의 임금)이 중요한 의미를 갖게 된다.

해당 금품의 임금성을 판단함에 있어서는 위에서 본 바와 같이 일차적으로 근로자가 사용자에게 근로계약을 근거로 그 지급을 청구할 수 있는지 여부를 본다. 일반적으로 문제시되는 것은 계속적·정기적으로 지급하는 금품이 아니라 임시로, 우발적으로 지급하는 금품이다. 이 경우 근로계약의 해석을 기초로 하면서, 당해 급여의 성격(근로제공에 대한 대가성 여부)과 이에 대한 노사의 합의내용(확정적 급여인가 아니면 임시적 급여인가)을 기준으로 판단하게 된다.

예컨대 판매실적에 따라 지급되는 개별실적급(이른바 커미션)이 사용자의 재량에 따라 임의로 그 지급액이 결정되는 것이 아니라 미리 정해진 소정의 산식에 따라 실제 매출액을 기초로 자동적으로 확정되는 것이라면 이 금품은 임금이라고 보아야 한다. 통근수당의 경우 근로제공 그 자체에 대한 대가는 아니지만 오랜 기간 노사 관행에 의하여 계약내용으로 인정된다면 임금에 해당한다고 볼 수 있다. 또한 금융회사에 있어서 이른바 영업실적에 따른 성과급도 근로계약상 합의한 것이라면 임금이라고 보아야 한다. 그 밖에도 사용자가 부여하는 주식보상에 대해서도 그것이 보수(상여급)에 포함되는 것이 고용계약상 명시되어 있다면 임금청구권을 긍정할 수 있을 것이다(이에 대해서는 다음 제3장 제3절 참고).¹⁴⁾

그런데 출장비의 경우 근로자가 사용자와 근로계약에 기하여 그 지휘명령에 따를 의무를 수행하기 위해 요구한 비용이고, 사용자의 업무에 필요한 비용은 특단의 사정이 없는 한 사용자가 부담해야 할 것이므로 사용자의 지급의무가 인정된다. 다만, 이 출장비는 근로의 대가로서 임금이 아니라 비용정산을 위한 실비변상적 성격의 금품이라고 할 수 있다.¹⁵⁾ 또한 기업이 근로의 대가가 아니라 종업원의 복지를 위하여 부가급여로 지급하는 복리후생적 금품¹⁶⁾이나 경조사에 대하여 지급하는 은혜

14) 日本 東京地判 平成 24.4.10 勞判 1055号 p.8.

15) 김형배/박지순, 「노동법강의」, 제12판, 2023, 신조사, 287면.



적·호의적 성격의 금품도 원칙적으로는 임금으로 보기 어려울 것이다. 이처럼 은혜적 성격의 금품이나 실비변상적 금품 또는 복리후생적 금품은 근로의 대가로 볼 수 없으므로 사용자가 그에 대하여 지급의무를 부담하더라도 이를 “임금지급청구권”으로 이해할 수는 없다.

II. 임금 개념의 특징

1. 임금의 법률상 정의

근로기준법에 따르면 임금은 “사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품”을 말한다(근기법 제2조 제1항 제5호). 다시 말하면 어떤 금품이 임금이기 위해서는 금품수수의 당사자인 사용자와 근로자가 존재할 것, 그리고 근로의 대가로 지급할 것 등이다.

먼저 사용자가 지급하는 금품이 임금으로서의 법적 성질을 가지려면 일차적으로 근로계약의 당사자 사이에 주고받는 것이어야 한다. 따라서 어떤 금품이 임금이기 위해서는 일차적으로 금품의 지급 및 수령 주체가 근로관계 당사자인 근로기준법 제2조 제1항의 사용자(제2호) 및 근로자(제1호)이어야 한다. 임금은 근로기준법상 근로계약에 특유한 급부로서, 임금의 지급주체는 근로기준법상 사용자여야 하며 계약당사자(사용자)가 아닌 제3자가 근로자에게 지급한 금품은 원칙적으로 근로기준법상 임금이 아니다. 예를 들어 고객이 직접 근로자에게 주는 금품(팁)은 임금이 아니다.

또한, 임금 수령 주체는 근로기준법상 근로자이다. 금품의 수령 주체가 근로기준법상 사용종속관계¹⁷⁾에 있는 근로자로 인정될 수 없다면 해당 금품은 임금이라는

16) 異見: 박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 「노동법포럼」, 제38호, 295-296면. 이에 따르면 복지포인트와 같은 복리후생적 급여도 사용자가 지급하는 반대급부로서 성격을 갖는다면 임금성이 인정된다고 한다.



법률개념에 해당하지 않는다. 따라서 업무집행권을 가진 등기이사,¹⁷⁾ 사용종속관계가 없거나 인적 종속성 없이 경제적 종속성만 인정될 수 있는 보험설계사, 학습지 교사 등에게 지급되는 “보수”는 근로기준법상 임금이 아니다. 이들은 근로기준법상 근로자로 인정되지 않기 때문이다. 이들에게 지급되는 반대급부는 통상 “보수”라고 부르거나 “수수료”라고 부르기도 한다.

다음으로 근로기준법에 따르면 그 명칭이 무엇이든 “근로의 대가”로 사용자가 근로자에게 지급해야 하는 금품이어야 임금이라고 할 수 있다. 노동관계법에서 사용하는 임금의 다른 명칭에는 “봉급” 외에도 “급료”(노조법 제2조 제1호 참조)가 있다. 실무적으로는 그 밖에도 급여, 월급 등 다양한 명칭이 사용될 수 있지만 이러한 명칭은 법적으로 아무런 의미가 없으며, 사용자가 근로자에게 “근로의 대가”로 지급하는 금품은 모두 임금이다.

2. 근로계약의 목적

근로계약이란 “근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약”이다(근기법 제2조 제1항 제4호). 근로계약의 목적으로써 사용자에게 제공되는 근로는 근로자가 종속적 지위에서 사용자의 지휘명령하에서 제공하는 노무를 말한다. 또한 근로기준법은 위 조항 제4호 근로계약에 이어 제5호에서 임금을 “근로의 대가”로 명확히 정의하고 있다. 이와 같은 규정 체계로부터 임금의 기본개념은 다음과 같이 설명될 수 있다.

근로계약은 근로자와 사용자의 권리·의무에 관한 법적 기초이다. 근로계약에 관

17) 근로기준법상 근로자이기 위해서는 인적 종속성이 인정되어야 하며 경제적 종속성만으로는 근로기준법상 근로자로 볼 수 없다. 물론 이 경우에는 노조법상 근로자성이 인정될 여지는 남아 있다(이에 관해서는 김형배/박지순, 「노동법강의」, 35면 이하 참고). 그렇지만 근로기준법상 근로자가 아닌 노조법상 근로자(예를 들어 특수형태근로종사자)가 수령하는 금품은 근로기준법상 임금이라고 할 수 없다. 이는 도급계약 또는 위임계약에 기초한 ‘보수’이다.

18) 김형배/박지순, 「노동법강의」, 34면 참고.



한 근로기준법의 정의 규정은 근로계약이 쌍무계약으로서 “근로제공과 임금의 교환”을 목적으로 하는 채권관계를 성립시키는 법률행위임을 확인하고 있다. 근로제공과 임금이라는 근로자와 사용자의 주된 급부의무는 쌍무적으로 서로 결부되어 있다. 다시 말하면 근로자는 임금을 얻기 위하여 근로를 제공하고, 사용자는 자신의 목적을 위하여 근로자가 제공하는 근로를 이용한 대가로 임금을 지급한다. 이와 같은 “대가적 견련관계”가 임금 개념의 법적 기초가 된다.¹⁹⁾

근로계약의 정의는 민법 제655조가 정하고 있는 고용계약의 의미와 사실상 동일하다. 민법 제655조에 따르면 “고용은 당사자 일방이 상대방에 대하여 노무를 제공할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.”라고 규정하고 있다. 즉, 고용계약과 근로계약은 노무(근로)의 제공과 그에 대한 보수(임금) 지급을 당사자가 합의함으로써 성립하는 것이다. 즉, 민법의 고용계약과 근로기준법의 근로계약은 모두 당사자의 “주관적 합의”에 의하여 보수(임금)를 정하고 사용자는 당사자 간 합의된 보수를 지급할 의무를 부담한다. 여기서 사용자가 지급의무를 부담하는 보수(임금)는 당사자가 합의하여 지급하기로 정한 것이므로 사용자가 근로자의 근로제공과 관련하여 지급의무를 부담하는 것이고, 그 보수가 계속적 계약관계인 근로관계의 특성을 감안할 때 일회적이거나 일시적 급부가 아니라 계속적이고 정기적으로 지급되는 것일 때 ‘일용’²⁰⁾ 임금으로서의 성질을 가진다고 볼 수 있다.

다시 말하면 고용계약 및 근로계약상 보수(임금)청구권은 당사자의 합의를 법적 근거로 한다. 민법상 고용계약에서는 특정 노무제공에 대하여 보수를 지급하지 않는 합의도 법적으로 가능하므로 고용관계상의 보수(임금)청구권은 근로 자체로부터

19) 사용자의 임금지급은 근로자의 근로제공을 전제로 하는 것이며, 근로제공 없이 임금을 대신하는 급여(임금대체 급여)를 지급하는 것은 대가적 견련성에 대한 예외로서 특별히 법률상 근거를 필요로 한다(대표적으로는 연차휴가기간 중의 임금, 주휴수당, 휴업수당 등). 물론 당사자가 합의한 경우에는 당사자의 의사를 기초로 근로제공 없이 임금대체 급여를 지급할 수 있을 것이다.

20) 특정 금품이 계속적·정기적으로 지급될 경우 대부분 근로제공의 대가이므로 임금으로 볼 수 있으나, 복지포인트 사건에서 대법원이 판시한 것처럼 그렇다고 언제나 곧바로 모든 금품이 근로제공에 대한 반대급부라고 단정할 수는 없으므로 여기서는 ‘일용’이라고 전제한다.



발생하는 것이 아니라 근로제공의무를 지고 있는 근로자에 대하여 일정액의 보수(임금)를 지급한다는 당사자의 합의에서 그 법적 근거를 찾을 수 있다. 일반적으로 근로관계에서는 단체협약이나 취업규칙이 임금의 구성 및 임금액 결정 요소를 구체적으로 규율하는 처분문서이므로 실무에서는 근로계약과 취업규칙 또는 단체협약이 결합되어 구체적인 청구권의 내용이 확정되는 것이 일반적이다.

그런데 근로계약의 정의에서 이미 근로자의 근로제공에 대한 반대급부가 임금이라는 일반적 정의가 행해지고 있음에도 근로기준법이 “임금”에 대한 독립된 정의규정을 두고 있는 이유는 무엇일까?

근로기준법은 임금에 대하여 임금지급의 원칙(제43조)을 비롯한 다양한 임금보호규정을 두고 있으며 그 위반에 대하여 벌칙을 두고 있다.²¹⁾ 즉, 임금은 범죄의 구성요건 요소로서 의의를 가지고 있다. 또한 임금은 근로기준법상 근로자성 판단요소로 작용한다(제2조 제1항 제1호, “임금을 목적으로”). 나아가 임금에 해당하는 금품은 통상임금과 평균임금에 산입되어 여러 법정수당의 산정기초가 된다.

이와 같이 고용계약에서 “보수”는 그 지급방식과 지급범위가 당사자의 합의에 맡겨져 있지만, 근로자보호를 위하여 형사처벌을 전제로 강행적 보호규정을 두고 있는 근로기준법은 당사자의 합의에 관계없이 특별한 규제대상으로서 임금의 범위를 객관적으로 명확히 하고, 이를 통해 법정수당의 산정 기준을 구체화하기 하기 위하여 임금의 개념을 정의한 것이라고 볼 수 있다. 그러한 이유로 근로기준법상 임금은 객관적으로 판단되어야 하는 것이다. 이 경우 당사자의 합의는 특정 금품의 객관적 의미가 임금인지 명확하지 아니할 때 보충적으로 고려될 것이다.

따라서 근로기준법 제2조 제1항 제5호가 임금을 정의하면서 사용하고 있는 “근로의 대가”는 임금에 대한 핵심 요건(임금 개념의 본질적 요소)이라고 할 수 있으며, 그 의미는 근로기준법 전체 체계를 고려하여 해석되어야 한다. 사용자가 근로자에게 계속적·정기적으로 지급하고, 근로계약이나 취업규칙 또는 단체협약에 그 지급

21) 임금체불이 발생하면 해당 사업장에 대해 각종 규제 및 고율의 지연이자 부과되고(근기법 제37조, 제43조의2 이하 참조), 도산이나 그에 준하는 사안에서 우선변제의 대상이 되는 임금채권에 포함된다(근기법 제38조, 특히 제2항 참조).



근거가 정해져 있는 금품은 일반적으로 사용자가 근로자의 근로제공의 대가로 지급하는 보수(임금)로서의 성격을 가지고 있다고 할 수 있다. 다만, 경우에 따라서는 경조비나 실비변상비 또는 복리후생비처럼 근로관계에서 발생하는 금품 중에는 근로기준법 제2조 제1항 제5호가 규정하고 있는 “근로의 대가”로 보기 어려운 항목도 있을 수 있다.²²⁾ 근로의 대가에 대한 해석은 임금성 판단에 있어 본질적인 요소이므로 그 의미를 객관적으로 명확히 해야 한다.

3. 임금의 기본요소

임금의 체계나 수준을 결정할 때는 일반적으로 생활보장적(생활안정적) 요소, 직무 및 능력과 관련된 요소, 성과관련적 요소 등이 중점적으로 고려될 수 있다. 이와 같은 요소들 중 어떤 요소를 우선시 또는 중시할 것이냐에 따라 임금의 체계나 수준이 달라질 것이다.²³⁾²⁴⁾ 이하에서는 이러한 기본요소의 구체적 내용에 대해 설명하기로 한다.

첫째, 임금은 근로자에게는 가장 중요한 생활자원이므로 임금을 통해 근로자의 생활을 안정시킬 수 있어야 한다. 이는 주로 임금에 관한 근로자 측의 관점을 말하는 것인데, 사용자의 입장에서조차 종업원인 근로자의 생활이 제대로 보장되지 않는다면 노동력의 안정적 확보에 문제가 발생할 수 있으므로 역시 중요한 문제라고 할 수 있다. 또한 높은 기술이나 전문지식을 얻기 위해서는 양질의 직업훈련교육을 받아야 한다. 근로자는 자기 자신뿐만 아니라 자녀의 양육에 대해서도 마찬가지로 관심을 가질 수밖에 없다. 따라서 자신이 받는 대가는 육아 및 자녀의 교육비용을 충

22) 대법원 2019.8.22 선고 2016다48785 전원합의체 판결은 이 점을 명확히 하였다고 볼 수 있다.

23) 高原暢恭, 「賃金、賞與制度の教科書」, 2014, p.17 참고.

24) 노사정위원회, 「2016 임금보고서」, 129면 이하는 임금을 이들 중 어느 하나의 요소에 의하여 결정할 것이 아니라 여러 요소를 조합하여 노사의 이해관계를 조정할 수 있는 종합급이라는 대안을 제시하고 있다. 그렇지만 결국 이 중에서 어느 요소에 비중을 두느냐에 따라 근속급, 직무급(능력급), 성과급 등 임금형태 및 체계가 결정될 것이다.



당할 수 있는 수준이어야 한다. 사용자의 입장에서 높은 기술과 전문지식은 사업 경영에 없어서는 안 될 요소이기 때문에 이를 감안하여 인건비(임금)를 설정하게 될 것이다(이점을 강조할 경우 연공형에 가까운 임금체계가 될 것이다).

둘째, 임금은 근로(직무수행)의 대가이므로 임금지급 방식 및 임금액의 결정은 근로(직무)와 직접적 관련성이 있다. 사용자는 보수를 지급하고 근로자의 노동력을 활용할 수 있는 권리를 갖기 때문에 누구나 쉽게 할 수 있는 일이라면 상대적으로 낮은 비용을 지급하고자 할 것이고, 난도(難度)가 높은 업무를 수행할 수 있는 사람에 대해서는 높은 임금을 지급하지 않을 수 없다. 근로자의 입장에서 높은 임금을 받기 위해서는 가능한 다른 사람과 차별화되는 높은 기술이나 전문지식을 습득하고 이를 사용자에게 주장할 수 있어야 한다(이점을 강조할 경우 직무급에 가까운 임금체계가 될 것이다).

셋째, 임금액이 결정되더라도 사용자의 입장에서는 사업경영이 어렵거나 지급능력에 문제가 발생할 경우에는, 목표 이익수준에 맞는 임금을 지급하거나, 실적과 연동된 임금을 지급하여 균형을 맞추려 할 것이라는 점도 고려할 수 있다(이점을 강조할 경우 성과주의 연봉제에 가까운 임금체계가 될 것이다).

임금결정을 둘러싸고 근로자와 사용자 사이에 이해의 일치가 있는 동시에 근본적인 이해대립이 일어날 수도 있다. 사용자는 사업경쟁적인 제반 사정이나 근로자의 생활에 대한 배려를 도모하면서도 목표로 삼은 이익을 내기 위해서는 가능한 낮은 임금을 유지하고 싶고, 반대로 근로자는 당연히 받을 수만 있다면 높은 임금을 받고 싶어한다. 이러한 근본적인 이해대립이 노동쟁의를 발생시키는 원인의 하나가 되고 있다.

한편, 근로자와 사용자 사이에는 많은 공통적인 이해관계도 존재한다. 기업이 수익을 높이지 않으면 높은 임금을 줄 수 있는 자금을 확보하기 어렵고, 근로자들도 당연히 이 사실을 알고 있다. 또한 회사에 적자가 발생할 정도로 근로자가 임금을 지급받으려고 하면 회사가 도산해서 일자리를 잃게 되어 결국 아무런 생활보장을 받을 수 없게 된다는 사실도 알고 있을 것이다. 이처럼 공통의 이해와 또는 이해대립의 균형을 위해 사업장별로 임금제도를 구축해 나가게 된다. 이러한 점들의 임금



체계 개선을 위한 노사의 노력에도 반영될 수밖에 없을 것이다.

이와 같이 임금은 근로자의 중요한 생활자원이기 때문에 국가가 어느 정도 필요한 개입을 하되, 다른 한편 노사의 이해대립과 공통이익을 조정하기 위해 노사합의 방식으로 결정할 수 있도록 하는 것이 가장 바람직하다. 임금액에 대해서는 사용자가 일방적으로 결정 또는 변경할 수 없다. 기본적으로는 근로자와 사용자가 근로계약을 통해 임금액 등 결정을 하게 되지만, 취업규칙이나 단체협약의 방식으로 변경될 수 있다. 다만, 이러한 경우에도 법적 규제 및 내재적 제한을 받게 된다.

그 중에서 법적 규제에는 근로기준법, 최저임금법뿐만 아니라 근로자에게 근로3권을 인정하여 대등하게 교섭할 수 있는 권리도 포함되어 있다. 이는 임금을 중심으로 근로자와 사용자 사이에 이해대립이 불가피하다는 점을 전제로 근로자측의 교섭력을 높여 사용자와 대등한 입장에서 합의 형성을 도모하기 위한 것이다. 임금 등 근로조건을 이와 같은 합의 방식에 맡기기로 한 것을 노사자치의 원칙(협약자율의 원칙)이라 할 수 있다.

지금까지의 역사를 되돌아보면, 그리고 우리와 비교되는 다른 산업국가의 경험을 보면, 20세기 중반 자본주의가 안정화되는 단계에서는 생활보장을 중시하는 연공급 임금제도가 널리 보급되었다. 그러나 경제규모가 확대되고 경제위기가 일상화되면서 직무 중심의 임금결정 비중이 확대되기 시작하였고, 나아가 기업과 근로자의 성과와 실적을 적극 반영하는 성과주의 임금제도가 확산되고 있다.

4. 임금의 법적 규제와 그 범위

임금의 개념을 해석하는데 있어서는 임금에 관한 노동법상 보호를 위한 규제가 중요한 영향을 미치고 있다. 노동법상 보호규정의 강행성을 고려하면 임금의 개념, 임금범위 등은 근로관계 당사자 간의 합의나 인식에만 맡길 수 없는 특수한 쟁점이 발생할 수 있을 것이다.



임금에 대한 법적 규제에 대해서는 다음과 같은 논리구조가 존재한다. 임금을 ① 어떠한 형태로 계산하고, ② 어느 정도의 금액으로 할 것인지는 기본적으로 근로관계의 당사자가 자유롭게 결정할 수 있는 것이고, 법률상의 규제에 위반하지 않는 한 협약자유(Tarifautonomie)과 계약자유(Vertragsfreiheit)의 원칙에 맡겨지게 된다.

예를 들면 우리나라의 경우 시간급, 일급, 월급, 연봉 등 어떤 기간을 임금의 결정 단위로 할 것인지는 기본적으로 당사자의 자유에 맡긴다. 반대로 프랑스의 경우에는 근로자의 경제생활의 안정화를 위하여 각 월의 일수에 관계없이 매월 동일액의 임금지급을 보장하는 월급제 지급방식이 법률로 규정되어 있다.²⁵⁾ 이에 비하여 우리나라에서는 매월 1회 이상 정기지급의 원칙만이 법제화되어 있다(근기법 제43조 제2항).

또한 임금결정의 방법과 관련하여, 시간을 단위로 하여 결정하는 정액급(시간급, 일급, 월급, 연봉 등)으로 할 것인가 아니면 업무 및 작업의 결과나 성과(실적, 매출, 성과 등)를 근거로 도급제 방식으로 할 것인가도 기본적으로 당사자의 자유에 맡긴다. 물론 도급제 방식으로 임금을 결정하는 경우에도 연장근로나, 휴일근로 또는 야간근로를 수행하는 경우에는 해당 근로시간 수에 상응하는 가산임금이 지급되어야 하고(근기법 제56조 참조), 또한 도급제 근로자에게도 근로시간에 따라 일정액의 임금(고정급)이 보장되어야 한다(근기법 제47조 참조). 위반시 벌칙이 적용된다(근기법 제114조, 500만원 이하의 벌금).

도급제 근로자에 대한 최소한의 보장급은 해당 근로시간에 상응하는 최저임금액이 된다는 견해가 있다.²⁶⁾ 그렇지만 도급제 근로자들의 경우 대체로 근로시간 산정이 어려운 경우가 많으므로 구체적으로 근로시간을 산정하여 그에 대해 최저임금액을 보장하는 것도 쉽지 않다. 그 때문에 근로기준법 제58조 제1항은 “근로자가 출장이나 그 밖의 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하여 근로

25) 프랑스 노동법전 L. 3242-1조.

26) 하갑래, 「근로기준법」, 제34판, 2021, 425면; 김형배/박지순, 「노동법강의」, 304면 참조.



시간을 산정하기 어려운 경우에는 소정근로시간을 근로한 것으로 본다.”라고 규정하고 있다. 따라서 당사자 사이에는 소정근로시간을 얼마로 할 것인지 사전에 합의되어 있어야 한다. 이때 당사자가 매년 인상되는 최저임금액의 부담을 회피하기 위하여 소정근로시간을 낮추는 합의를 할 경우 최저임금법 위반을 잠탈할 목적이 인정되면 그 합의는 무효가 된다.²⁷⁾ 다만, 그 업무를 수행하기 위하여 일반적으로 소정근로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 본다(근기법 제58조 제1항 단서).

각국의 모든 노동법이 임금에 관하여 구체적으로 규정하고 있는 것은 아니다. 우리와 일본의 경우는 비교적 구체적으로 임금에 대한 법적 규제를 두고 있지만, 유럽 국가들의 경우는 우리만큼 규제를 두는 경우는 거의 없는 것으로 보인다. 오히려 법률이 아니라 단체협약이나 사업장 단위의 노사협정에 맡겨 규율하는 경우가 대부분이다.

또한 임금에 관한 정의를 두고 있는 나라도 우리나라와 일본이 사실상 유일하다. 다른 산업국가의 노동법에서는 임금에 관한 직접적인 정의규정을 두고 있지 않다. 임금에 대한 강행적 규제가 없으니 임금에 대한 법률상 정의가 큰 의미가 없고, 자율적으로 그 범위와 산정방법을 결정하면(주로 단체협약) 그에 따르게 되는 것이다. 임금산정의 단위로서 통상임금과 평균임금을 별개로 규정하고 있는 사례도 매우 드물다. 이러한 점을 감안하여 임금 개념을 해석할 때 평균임금 등 관련규정과 관계를 고려하는 체계적 해석이 중요하다고 할 수 있다.

Ⅲ. 임금과 유사한 법률상 개념

위에서 본 바와 같이 노무제공에 대한 반대급부라는 의미를 가진 가장 일반적인 법률개념으로는 임금 외에 보수(報酬)가 있다. 보수는 민법상 고용계약뿐만 아니라

27) 택시기사의 소정근로시간 변경 사례로 대법원 2019.4.18. 선고 2016다2451 전원합의체 판결. 최저임금법상 도급제 근로자의 최저임금액 결정에 관한 규정(최임법 제5조 제3항) 참고.



도급(민법 제664조), 위임(민법 제686조) 등 자유노무계약에서도 반대급부를 총칭하는 개념으로 사용되기 때문이다. 그 밖에도 사회보험법의 영역에서도 보수, 소득 등 다양한 용어가 사용된다.

한편, 경영학에서는 기업실무적 관점에서 기업이 종업원에게 지급하는 인건비의 총체로써 보상(報償)이라는 개념을 사용하고 있다. 따라서 보상의 내용을 그 성격에 따라 구별하여 체계화함으로써 임금의 개념과 비교해 볼 수 있을 것이다.

1. 다른 법령에서 사용하는 용어

고용보험과 산재보험에 대하여 보험관계의 성립과 소멸, 보험료의 납부와 징수 등에 필요한 사항을 규정하고 있는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」(이하 “보험료징수법”이라 한다)은 임금이라는 용어 대신에 보수라는 용어를 사용한다. 그에 따르면 “보수”는 「소득세법」 제20조에 정한 근로소득²⁸⁾에서 대통령령으로 정하는 금품을 뺀 금액을 말한다.

보험료징수법 제13조 제1항 제1호에 따르면 고용보험료 징수대상인 보수에 대하여 “근로자가 휴직이나 그 밖에 이와 비슷한 상태에 있는 기간 중에 사업주 외의 자로부터 지급받는 금품 중 고용노동부장관이 정하여 고시하는 금품은 보수로 본다”라고 정의하고 있다(보험료징수법 제2조 제3호). 이 규정은 입법정책에 따라 보수 개념을 임금보다도 넓게 사용하고 있음을 보여주고 있다.

국민건강보험법도 보수라는 용어를 사용하고 있는데, 동법 제70조 제3항은 보수를 “근로자 등이 근로를 제공하고 사용자로부터 지급받는 금품(실비변상적인 성격을 갖는 금품은 제외한다)으로서 대통령령으로 정하는 것”이라고 정의하고 있는데, 동법 시행령 제33조 제1항에 따르면 근로의 대가로 받은 봉급, 급여, 보수, 세비(歲

28) 근로소득의 범위는 소득세법 시행령 제38조에서 규정하고 있으며, 근로소득세 부과 대상인 소득은 이 중에서 다시 비과세소득(소득세법 시행령 제12조에 정한 실비변상적 급여가 여기에 해당한다)을 제외한다.



費), 임금, 상여, 수당, 그 밖에 이와 유사한 성질의 금품을 말하며, 퇴직금, 현상금, 번역료 및 원고료, 소득세법에 따른 비과세 근로소득 등은 여기서 제외하고 있다.²⁹⁾

국민연금법은 임금이나 보수를 대신하여 “소득”이라는 용어를 사용하는데, 그에 따르면 근로자의 “소득이란 일정 기간 동안 근로를 제공하여 얻은 수입에서 대통령령으로 정하는 비과세소득을 제외한 금액”이라고 정의하고(제3조 제1항 제3호), 동법 시행령 제3조 제1항은 소득세법 제20조 제1항에 따른 근로소득에서 같은 법 제12조 제3호에 따른 비과세 근로소득을 뺀 소득이라고 한다.

국민건강보험법 및 국민연금법이 보수 및 소득의 정의에서 인용하고 있는 소득세법 제20조 제1항 및 동법 시행령 제38조는 근로기준법상 임금으로 보기 어려운 급여들도 근로소득³⁰⁾에 포함하여 정의하고 있는데, 이는 국민건강보험법상 보수의 개념과 기본적으로 동일하다. 소득세법은 근로소득세를 부과하기 위하여 설정된 조세정책적 관점에서 근로소득을 정의하고 있다. 즉, 여기서 근로소득은 상당한 근로의 대가를 설정하기 위한 것이 아니라 고용계약을 근거로 지급받는 모든 금품으로서 근로소득세의 과세 객체를 정하기 위한 개념이라고 할 수 있다. 마찬가지로 사회보험에서 보험료 산정을 위하여 사용하는 보수의 개념도 이와 같다.

따라서 사회보험료 부과 대상으로서의 보수 개념이든 근로소득세 부과를 위한 근로소득의 개념이든 노동법상 임금 개념과 동일하다거나 직접 관련된다고 보기 어렵다.

근로기준법은 근로계약상의 반대급부로서 임금에 대하여 근로자의 보호 목적과 임금의 기능을 고려하여 그 범위와 대상을 특정하거나 제한할 수 있다. 구체적으로 근로기준법은 위에서 검토한 “임금”에 대한 정의 규정 외에, 제36조 본문에서 “사

29) 퇴직금과 비과세 근로소득(예: 고정적으로 지급되는 식대)은 근로기준법상 “임금”에 해당되지만 국민건강보험법은 이를 보수에서 제외하고 있다.

30) 소득세법 제20조 제1항에 따르면 근로소득은 ① 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급여·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여, ② 법인의 주주총회·사원총회 또는 이에 준하는 의결기관의 결의에 따라 상여로 받는 소득, ③ 「법인세법」에 따라 상여로 처분된 금액, ④ 퇴직함으로써 받는 소득으로서 퇴직소득에 속하지 아니하는 소득, ⑤ 종업원등 또는 대학의 교직원이 지급받는 직무발명보상금 및 ⑥ 동법 시행령 제38조에 정한 범위 등을 모두 포함한다.



용자는 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 그 밖의 모든 금품을 지급하여야 한다.”라고 규정하고 있다. 여기서 보상금은 재해보상금을 가리킨다고 해석하고, ‘그 밖의 금품’은 임금과 재해보상금을 제외하고 사용자가 지급하기로 정한 금품으로서, 근로관계에서 발생한 금품을 의미한다. 또한 근로기준법 제38조 제1항은 임금, 재해보상금 외에도 그 밖에 “근로관계로 인한 채권”을 사용자의 총재산에 대하여 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 할 금품으로 규정하고 있다. 이와 같이 근로관계에서 사용자에게 지급의무가 있는 금품이라도 ‘임금이 아닌 금품이나 채권’으로 인정될 여지가 있다.

2. 경영학적 관점에서 보상체계의 구조

인사관리를 주된 연구분야로 다루는 경영학에서도 근로기준법상 임금구조와 유사한 분류방식을 사용하고 있다. 그에 따르면 임금을 ① ‘기본적 임금’과 ‘부가적 임금’으로 구분하고, 부가적 임금을 다시 ② 기업이윤 및 성과를 배분하는 ‘참여적 임금’과 ③ 복리후생급여를 의미하는 ‘사회적 임금’으로 구분한다.³¹⁾

① 기본적 임금은 경제적 임금이라고도 하며, 근로자가 구체적으로 제공하는 근로의 대가로서 사용자가 지급하는 금품을 말한다. 이러한 기본적 임금은 근로기준법상의 임금 개념과 가장 근접한 개념이다.

부가적 임금 중 ② 참여적 임금은 기업이 거둔 이익에 대한 배당참여를 의미한다. 상당수 기업들은 노동이 경영공동체(기업)의 적극적인 구성요소로서 경영성과에 지속적으로 작용하고 영향을 미친다는 점에 착안하여, 보상관리에 있어서는 전통적인 경제적 거래 관념(기본적 임금)에서 벗어나 좀 더 포괄적이고 공동체적 관점(운영공동체든, 이익공동체든)에서 경영성과를 배분한다는 적극적인 경영참가정책을 마련하고 있다. 이러한 점에서 개별적인 성과에 따라 인센티브를 제공하는 동기부여

31) 최종태, 「현대 인사관리론」, 2008, 265면 이하 참고.



방식이나 단기 경제적 경영정책 차원을 넘어서서 공동체적인 차원에서 참여적 임금 방식(참여적 보수)과 같은 적극적 경영정책이 권장되기도 한다.

참여적 보수 관리전략 실현방안으로는 ‘이익참여’와 ‘자본참여’의 두 가지가 있다. 먼저 ‘이익참여’는 근로자가 기업의 경영성과, 즉 이익배분에 참가하는 제도로써 근로자의 경영참가 실현을 위한 가장 손쉬운 형태이며, 이를 성과참여라고도 한다.³²⁾ 이는 근로자의 기업에 대한 헌신을 촉진할 목적으로 경영성과의 일부를 임금 이외의 형태로 근로자에게 분배하는 방식이다.

‘자본참여’는 근로자가 기업재산(자본)의 소유에 참가하도록 하는 것이다. 즉 근로자들을 자본 출연자로서 기업경영에 참여시키고자 하는 것이다. 자본참여 제도는 근로자의 주인의식과 애사심 고취, 그리고 노사가 같은 운명체라는 경영공동체 의식의 형성에 커다란 역할을 한다.

③ 사회적 임금은 일반적으로는 ‘복리후생’을 의미하는데 이를 간접적 보수라고 부르기도 한다. 복리후생은 공동체 정신에 입각하여 그 틀이 형성된 것인데, 기업 내 구성원의 공동체적 가치를 실현하는 수단으로써 직원의 성과 하락을 방지하는데 기여할 수 있다고 본 것이다. 즉, 기업의 복리후생은 경영의 공동체 원리를 실현하는 제도로써 도입·운영되고 있다. 경제적(기본적) 임금은 직접적 임금으로써 구성원(직원)의 경제적인 성과에 따라 책정되지만, 간접적 임금으로서의 사회적 임금(복리후생)은 전체 구성원이 모두 혜택을 받을 수 있도록 함으로써 경영을 하나의 협동적 공동체로 만드는데 그 취지가 있다. 복리후생은 종업원에게 균형적인 혜택을 누리게 함으로써 직장을 삶의 공동체로 인식하게 하므로 이는 근로자의 구체적인 근로제공과는 관계없이 그 보장내용이 설계될 수 있는 것이다.

이와 같이 경영학의 보상체계 분류도 기본적으로 노동법상의 분류체계와 크게 다르지 않으며, 임금의 강행적 보호를 위한 노동법의 규율체계도 이와 같은 보상제도의 현실을 반영한 것이라고 할 수 있다.

32) 김형배/박지순, 「노동법강의」, 740면.



제2절 “근로의 대가”를 둘러싼 해석론

I. 임금의 요건으로서 “근로의 대가”

임금은 근로자가 근로계약에 터잡아 사용자에게 행한 근로제공에 대한 보상(報償)이라고 할 수 있다. 그런데 근로기준법은 임금을 “근로의 대가”로 정의하고 있으므로 보수에 관한 당사자의 합의가 근로의 대가라는 기본 성격을 벗어나면 “임금”의 범주를 벗어난다. “근로의 대가”라는 문구는 매우 추상적, 포괄적이지만 사용자가 지급하는 금품 중에서 근로자가 이른바 “사용종속관계”에서 수행하는 근로에 대하여 그 보수로 지급하는 것이라고 할 수 있다.³³⁾

근로의 대가라는 문언에서 첫 번째로 도출할 수 있는 규범적 요소는 임금이 근로관계 전체가 아니라 근로제공과 대가적 견련관계에 있다는 점이다. 다시 말하면 근로기준법은 임금이란 “근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.”라고 규정하고 있지만, 이는 근로관계(또는 근로관계의 유지)와 관련하여 지급하는 일체의 금품³⁴⁾을 의미하는 것이 아니다. 즉, 임금은 근로기준법의 취지에 따라 법정책적 측면에서 보호의 대상임을 고려하여 “근로의 대가”로 지급하는 금품만이 근로기준법상 임금임을 의미하는 것이다.

임금은 모든 법권(法圈)에서 통일적으로 이해되는 개념이 아니다. 예컨대 다음에서 살펴보게 될 독일의 경우 임금에 대한 독립된 정의규정을 두고 있지 않으며 당사자의 합의에 터잡아 기본적으로 임금 개념을 넓게 이해한다. 그에 따르면 사용자가 고용계약을 기초로 근로자에게 직접 또는 간접으로 지급하는 모든 금품을 “보

33) 日本 厚生労働省, 「労働基準法(上)」, 2021, p.170.

34) 근로기준법이 “일체의 금품”이라고 한 이유는 근로의 대가임이 객관적으로 분명함에도 당사자의 주관적 합의에 의하여 또는 사용자가 일방적으로 근로자에게 불리하게 임금에서 제외하는 금품을 다시 임금에 포함시키기 위한 것이지 대가적 견련관계에 있지 아니한 금품을 임금으로 보려는 것이 아님에 유의해야 한다.



수”(Vergütung)라고 이해한다. 이러한 의미에서 보수는 근로(노무제공)의 대가가 아니라 근로관계의 대가라고 할 수 있다. 그렇지만 근로자의 보호를 위하여 마련된 특별한 급여(예를 들어 질병수당)를 산정함에 있어서는 근로제공과 대가적 견련관계에 있는 임금을 대상으로 한다(이에 관해서는 다음의 제3절 1. 2. 참조).

한편, 우리와 같이 임금에 대한 독자적인 정의 규정(勞働の對償)을 두고 있는 일본 노동기준법은 이 “노동의 대상”을 포괄적인 개념으로 이해하고, 반면에 평균임금의 산정을 위한 임금총액에는 정기적이고 규칙적으로 제공되며 평균적인 노무급부에 대한 직접적인 대가적 견련성이 있는 임금만을 포함함으로써 임금과 평균임금의 개념을 이원적으로 이해하고 있다. 이와 같이 어느 경우든 관련 법령의 전체 내용을 고려하여 임금의 개념에 대한 체계적 해석론이 전개되어야 한다.³⁵⁾

우리 현행 근로기준법은 임금을 “근로의 대가”로 명시하고 있는데, 대법원은 임금의 법적 성질을 규정하는 핵심적인 요건인 ‘근로의 대가’에 대하여 최근 복지포인트 사건에서 다음과 같이 판시하고 있다. “사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 임금에 해당하려면 먼저 그 금품이 근로의 대상으로 지급되는 것이어야 하므로 비록 금품이 계속적·정기적으로 지급된 것이라 하더라도 그것이 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없다면 임금에 해당한다고 할 수 없다. 여기서 어떤 금품이 근로의 대상으로 지급된 것이냐를 판단함에 있어서는 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있어야 한다.”³⁶⁾ 이와 같은 전원합의체 판결의 견해는 이미 대법원이 1995년 내린 판결로 거슬러 올라간다.³⁷⁾ 그에 따르면 사용자가 지급하는 금품이 임금이기 위해서는 해당 금

35) 일본의 학설은 전통적으로 임금의 법적 성격에 대하여 ‘노동대가설’과 ‘노동력대가설’의 대립으로 소개한다. 이에 관해서는 박지순/이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 171면 참고.

36) 대법원 2019.8.22. 선고 2016다48785 전원합의체 판결. 대법원은 임금과 근로제공의 상호 견련성을 명확히 하기 위해 ‘직접적 관련성’ 또는 ‘밀접한 관련성’이라는 용어를 사용하고 있다.

37) 대법원 1995.5.12. 선고 94다55934 판결(이에 대한 구체적인 사례는 다음 각주 62) 참고). 그 후 대법원은 비교적 일관되게 근로의 대가를 이와 같이 해석하고 있다. 대법원 2019.4.23. 선고 2014다27807 판결; 대법원 2011.7.14. 선고 2011다23149 판결; 대법원 2004.5.14. 선고 2001다76328 판결; 대법원 2003.6.27. 선고 2003다10421 판결; 대법원 2002.5.31. 선고 2000다18127 판결; 대법원 1999.5.12. 선고 97다5015 전원합의



품이 정기적·계속적으로 지급되더라도 그것이 근로의 대상(對償)으로 지급되는 것 이어야 하며, 근로의 대상인지 여부는 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있어야 한다. 이러한 관련성 없이 그 지급의무의 발생이 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의하여 좌우되는 경우에는 그 금품이 단체협약·취업규칙 등에 의하여 지급된 것이라도 ‘근로의 대상’으로 지급된 것으로 볼 수 없다고 하였다. 다시 말해 대법원은 이미 이 판결에서 어떤 금품이 정기적·계속적으로 지급되고, 사용자에게 지급의무가 있다 하더라도 근로의 대가로 지급된 것이어야 하며, 근로의 대가란 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성이 있어야 함을 명시하고 있다. 지급의무가 개별 근로자의 특수하고 우연적 사정에 따라 발생하는 것이라면 근로제공과의 대가적 관련성이 인정되기 어렵다고 보았다.

물론 일부 판결에서는 이와 같이 근로의 대가를 구체적으로 해석하지 아니하고, 근로자에게 정기적·계속적으로 지급되고 단체협약이나 취업규칙(급여규정) 또는 근로계약, 노동관행 등을 근거로 사용자가 그 지급의무를 부담하고 있는 것이면 임금으로 인정된다고 판시하고 있다.³⁸⁾ 해당 판결들은 해당 금품이 근로의 대가임이 객관적으로 명확하기 때문에 굳이 근로제공과 직접성 또는 밀접성을 판단할 실익이 없는 경우라고 할 수 있다. 따라서 사안에 따라 표현이 다를 뿐, 계속적·정기적으로 지급되고 있는 금품이라도 근로제공과의 직접적 또는 밀접한 관련성을 기초로 근로의 대가 여부를 판단하는 대법원의 입장 자체에 대해서는 근본적인 변화가 있다고 보기는 어렵다.

체 판결: 대법원 1999.2.9. 선고 97다56235 판결; 대법원 1997.10.24. 선고 96다33037 판결; 대법원 1997.5.28. 선고 96누15084 판결; 대법원 1996.5.14. 선고 95다19256 판결; 대법원 1996.4.23. 선고 94다446 판결; 대법원 1995.12.21. 선고 94다26721 전원합의체 판결 등.

38) 대표적으로 대법원 2001.10.23. 선고 2001다53950 판결. 그 밖에도 대법원 2018.12.28. 선고 2016다239680 판결; 대법원 2018.10.12. 선고 2015두36157 판결; 대법원 2013.4.11. 선고 2012다48077 판결; 대법원 2005.10.13. 선고 2004다13755 판결; 대법원 2005.10.13. 선고 2004다13762 판결; 대법원 2005.9.9. 선고 2004다41217 판결; 대법원 2004.11.12. 선고 2003다264 판결; 대법원 2003.4.22. 선고 2003다10650 판결; 대법원 2002.10.17. 선고 2002다8025 판결; 대법원 2002.5.31. 선고 2000다18127 판결 등 참고.



이때 근로자에게 지급된 금품이 근로의 대가인지 여부, 즉, 해당 금품이 근로제공과 직접적이거나 밀접한 관련성이 있는지 여부는 해당 금품의 지급목적 및 지급조건, 지급방법과 구체적 산정 방법 등을 통해 판단하게 된다.³⁹⁾ 직접적 관련성이란 근로제공이 금품지급의 최종적 원인 내지 조건이라는 점에서 다른 매개 원인 및 조건이 없다는 것을 의미하고, 밀접한 관련성이란 금품지급의 여러 원인이나 조건 중에서 근로제공이 그 주된 원인이나 조건이 되는 상태로 해석하는 것이 일반적이다.⁴⁰⁾

II. 임금의 법적 성질에 관한 학설

1. 학설 개관

근로의 대가를 해석하는데 있어서, 전통적으로 사용종속관계에서 행하는 구체적 근로의 대가로 좁게 해석하는 견해, 일반적으로 노동력의 처분을 사용자에게 맡기면 된다는 광의의 개념으로 이해하는 견해가 있다. 여기에 더하여 근로관계상 지위에 대한 보상이라고 가장 넓게 이해하는 견해가 주장된다.⁴¹⁾ 여기서는 이와 같은 학설의 내용을 간단히 검토한다.

(1) 근로대가설

39) 김희성/성대규, “성과배분으로서 경영성과급의 임금성에 대한 고찰 - ‘근로의 대가성’ 본질을 중심으로 -”, 「노동법포럼」, 제35호, 2022, 1면 이하.

40) 이에 대하여는 조상욱, “경영성과급 임금성의 법적 쟁점”, 「월간 노동법률」, 367호, 2021; 권혁, “임금의 개념으로서 근로 대가성 판단에 관한 소고”, 「노동법포럼」, 제28호, 2022면 참고.

41) 학설개관은 박지순/이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 171면 이하 참고; 하경효, 「임금법제론」, 2013, 11면 이하 참고; 노동법실무연구회(최은배), 「주해 근로기준법 I」, 제2판, 226면 이하 참고.



근로대가설은 민법상 고용계약과 마찬가지로 근로계약을 근로자의 ‘근로제공’과 사용자의 ‘임금지급’이 서로 교환되는 것으로 본다. 다시 말해 ‘근로제공’과 ‘임금지급’의 대가적 견련성을 바탕으로 임금을 구체적인 근로제공에 대한 대가로 보기 때문에 임금의 범위를 제한적으로 해석하여 법적 안정성을 추구한다. 근로대가설에 따르면 근로자의 임금청구권이 발생하려면 근로자의 구체적인 근로가 현실적으로 먼저 제공되어야 한다. 따라서 현실적으로 근로제공과 관련 없는 금품은 임금에 해당하지 않는다.

이에 관한 일본의 대표적 판결(明星電氣事件)에 따르면 “근로계약은 민법의 고용계약보다 발전하고 노동법을 통해 수정이 이루어졌지만, 고용계약상 ‘노무’와 ‘보수’의 대가적 계약관계로서의 기본적 성격은 근로계약에서 ‘근로’와 ‘임금’의 대가적 관계로 승계되었다고 할 수 있다. 따라서 근로계약상 구체적 근로제공이 있을 때 임금청구권이 발생하는 것이고, 노동력을 사용자에게 맡기는 것만으로는 계약이행(구체적 근로제공)의 과정에 불과하다고 해석해야 한다”고 판시한 바 있다.⁴²⁾

(2) 노동력대가설

노동력대가설(근로관계대가설)에 따르면 근로계약은 근로제공 그 자체가 아니라 노동력의 처분을 사용자에게 맡기는 계약이다. 그리고 임금은 근로자가 자신의 (추상적) 노동력을 사용자의 처분에 맡긴 대가이다. 따라서 단체협약이나 취업규칙에 지급조건이 명확히 규정되어 있고, 사용자에게 지급의무가 있는 금품이라면 구체적인 근로 제공이 없더라도 근로의 대가로 해석하여 임금의 범위를 넓게 인정한다.

따라서 근로자는 근로계약에 따라 자신의 노동력을 사용자가 처분할 수 있는 상태에 두면 근로계약상 임금청구권이 발생하고, 현실적인 근로의 제공이 없더라도 근로자에게 귀책사유가 없다면 임금청구권은 유효하게 발생한다.

42) 前橋地裁 1963.11.14. 判決(明星電氣附勞加民金集請求事件, 勞民集(14권 6호), 1419면)(문무기/윤문희/이철수/박은정, 「임금제도 개편을 위한 노동법적 과제」, 한국노동연구원, 2006, 재인용).



이 학설을 지지하는 일본의 대표적 판결(國鐵室蘭棧橋事件)은 “근로계약이란 근로자가 그 노동력을 사용자의 처분에 맡기고 사용자의 지휘에 따라 근로를 제공할 것을 약정하며, 사용자는 노동력의 대가로서 임금을 근로자에게 지급할 것을 약속함으로써 성립하는 계약이므로 임금청구권은 근로자가 사용자의 지배권 내에 들어가고 그 노동력을 사용자의 처분에 맡기는 것, 즉 직장 편입에 의하여 발생한다고 해석하여야 하며, 직장에 편입된 이상 근로자의 귀책사유가 아닌 사유로 근로자가 현실적으로 노무에 종사할 수 없게 된 경우에는 임금청구권을 상실하지 않는다.”라고 판시한 바 있다.⁴³⁾

(3) 근로관계보상설

이 학설은 임금의 법적 성격에 관한 기존 학설을 비판하면서 우리나라에서 독자적으로 주장되었다. 그에 따르면 근로자는 근로계약에 기하여 노무제공 의무를 부담하고, 임금은 이러한 의무를 부담하는 관계를 유지하는 것에 대한 보상으로 본다. 따라서 임금청구권은 구체적 근로제공이나, 노동력의 처분을 맡긴 시점이 아니라 근로관계의 성립시점부터 발생한다. 즉, 근로계약 체결시부터 발생한다.⁴⁴⁾

(4) 검토

근로대가설은 임금을 구체적인 근로제공의 대가로 보기 때문에 쌍무계약인 근로계약의 성격 및 임금을 근로의 대가로 정의한 근로기준법의 규정(제2조 제1항 제5호)과 가장 가깝다. 근로대가설은 구체적인 근로제공의 대가로 지급되는 금품만을 임금으로 보기 때문에, 주휴수당, 휴업수당 등 구체적인 근로 제공 없이 지급되는 각종 수당들에 대해서는 임금성을 인정하기 어려워 임금의 범위를 지나치게 좁게 해석한다는 비판이 있다.⁴⁵⁾

43) 札幌地裁室蘭支部 1964.4.8. 判決(國鐵室蘭棧橋事件, 勞民集, 15卷 2号, p.232.

44) 이선신, 「임금의 유연성 제고에 관한 법리 연구」, 고려대학교 박사학위논문, 2010. 32면 이하

45) 하경효, 「임금법제론」, 12면.



이에 비해 노동력대가설은 임금을 구체적인 근로제공의 대가로 이해하여 임금의 범위를 좁게 보는 근로대가설과 달리, 구체적인 근로제공이 없더라도 사용자에게 노동력 처분을 맡긴 이상 근로제공이 있다고 보기 때문에 실제 근로 제공과 관계없는 주휴수당, 휴업수당 등 각종 수당 및 대기시간에 대해서도 근로의 대가로서 임금성을 인정할 수 있다는 점에서 장점이 있다. 그러나 사용자에게 노동력의 처분을 맡긴다는 것의 구체적 의미가 명확하지 않으며, 근로제공과의 관계가 모호한 금품에 대해 포괄적으로 임금성을 인정하게 되어 비판의 여지가 있다.⁴⁶⁾

근로관계보상설은 임금의 의미를 가장 넓게 해석하기 때문에, 근로관계에서 발생하는 모든 금품을 임금에 포함시킬 수 있다는 점에서 근로자에게 유리하다는 장점이 있다. 특히 이 견해는 근로의 대가로부터 실용적인 해석 기준을 도출하지 아니하고, 근로관계 이외의 법률관계에 의한 사용자의 급부를 배제하려는 것으로 해석한다.⁴⁷⁾ 그러나 근로자에게 지급하는 금품 중에는 객관적 관점에서 임금으로 볼 수 없는 금품이 포함될 수 있는데, 어떤 구분도 없이 절대적으로 모든 금품을 임금에 포함되는 것으로 해석하여 분쟁을 조장할 소지가 있다는 비판이 있다.⁴⁸⁾

2. 이른바 임금이분설과 “근로의 대가”의 의미

과거 무노동무임금 원칙의 정립 과정에서 임금은 근로자가 근로계약상의 근로 제공에 대한 반대급부인 보수를 의미하므로 현실적 근로제공 없이 오로지 근로자의 지위에 기해 발생하는 생활보장적 성격의 임금의 개념을 인정할 것인가에 대하여 논란이 있었다. 대법원은 한때 쟁의행위 기간 동안의 임금지급청구 문제와 관련하여 일본의 노동력대가설을 보다 구체화 시키면서 등장한 임금이분설을 취하기도 하

46) 하경효, 「임금법제론」, 13면 참고.

47) 西谷民外 編(本久洋一), 「勞働基準法・勞働契約法」, p.42. 일본에서도 근로관계보상설의 설명과 유사하게 노동의 대상이란 그 자체로는 실용적인 임금 확정기준을 도출하기 어려운 설명적 논리에 불과하고, 노동관계 이외의 법률관계에 의한 사용자의 급부를 배제하기 위한 논리라고 한다.

48) 하경효, 「임금법제론」, 14면.



였다.

당시 대법원의 임금이분설에 따르면 “쟁의행위를 이유로 사용자에게 근로를 제공하지 아니한 근로자는 무노동무임금의 원칙에 따라 일반적으로는 근로의 대가인 임금을 청구할 수 없지만, 임금 중 사실상의 근로제공에 대하여 교환적으로 지급받는 것이 아니라, 근로자의 지위 자체에 기하여 지급받는 생활보장적 부분으로서, 당해 근로계약의 해석상 사실상 근로제공이 있었는지의 여부와 관계없이 지급받도록 되어 있는 임금에 관하여는 위와 같은 무노동무임금의 원칙이 적용되지 않는다고 볼 것이다. 이때 어떤 임금이 무노동무임금의 원칙이 적용되지 않는 생활보장적 임금에 해당되는지 여부는, 해당 임금의 명칭과는 관계없이 단체협약이나 취업규칙 등에서 결근·조퇴·지각 등으로 근로를 제공하지 아니한 경우에 당해 임금을 감액하도록 규정하고 있는지 여부 또는 그와 같은 규정이 없더라도 관행에 따라 그와 같은 경우에 해당 임금을 감액하여 왔는지 여부 등을 참작하여 판단하여야 한다.”⁴⁹⁾

그런데 대법원은 1995년 ‘삼척군 의료보험조합 임금청구소송 사건’에서 전원합의체 판결⁵⁰⁾을 통해 근로의 대가를 엄격하게 파악하고 종전까지 임금이분설을 취하던 판례의 입장을 전면 부정하여 무노동무임금 원칙을 적용해야 한다고 판시하였다. 대법원은 모든 임금은 근로의 대가로서 ‘근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 보수’를 의미하기 때문에 현실에서 근로제공 없이 근로자로서의 지위에 기해 발생하는 생활보장적 성격의 임금이란 있을 수 없고, 우리나라의 법제상 임금을 사실상 근로를 제공한 대가로 받는 교환적 성격의 부분과 근로자의 지위에 기해 받는 생활보장적 성격의 부분으로 나눌 근거가 없다고 판시하는 등 그간의 임금이분설에 관한 논의를 일단락 짓고 임금일원설로 판례의 입장을 변경하였다.

그에 따르면 “임금은 근로의 대가로서 ‘근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 보수’를 의미하므로 현실의 근로 제공을 전제로 하지 않고 단

49) 대법원 1992.3.27 선고 91다36307 판결; 대법원 1992.6.23. 선고 92다11466 판결. 이 판결에서는 ‘정근수당’이 생활보장적 임금에 해당되어 무노동무임금원칙의 적용을 받지 않는다고 보았다.

50) 대법원 1995.12.21. 선고 94다26721 전원합의체 판결.



순히 근로자의 지위에 기하여 발생한다는 이른바 생활보장적 임금이란 있을 수 없고, 또한 우리 현행법상 임금을 사실상 근로 제공에 대하여 지급받는 교환적 부분과 근로자의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분으로 이분해야 할 아무런 법적 근거도 없다”고 한다. 기업의 임금 지급 실태를 보더라도 임금은 일차적으로 근로자가 생활하는 데 필요한 생계비와 기업의 지급능력을 고려하여 형성되는데 “임금을 지급항목이나 성질에 따라 사실상 근로를 제공한 데 대하여 지급받는 교환적 부분과 현실의 근로 제공과 관계없이 단순히 근로자의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분으로 나누고 이에 따라 법적 취급을 달리하는 것이 반드시 타당하다고 할 수도 없다”고 판시하였다.⁵¹⁾ 현실적으로도 근로자에게 지급되는 임금 항목을 교환적 부분과 생활보장적 부분으로 구별하는 것은 사실상 어렵고, 임금이분설에서 대표적인 생활보장적 임금으로 분류하는 정근수당, 가족수당, 주택수당 등도 그 지급 내용을 보면 그것이 근로 제공과의 직접성이 약하기는 하지만 실질적으로는 사용자가 요구하는 근로를 제공한 것에 대하여 그 대가로 지급되는 것이므로 밀접한 관련성이 없다고 할 수 없으며, 이러한 수당 등의 지급이 현실의 근로 제공과 관계없이 오로지 근로자의 생활이나 지위를 보장하기 위한 것이라고 할 수도 없다.

대법원은 “근로자의 임금청구권은 특별한 약정이나 관습이 없으면 근로를 제공함으로써 비로소 발생하는 것이고 근로자가 근로제공을 하지 않은 이상 그 대가관계인 임금청구권을 갖지 못한다.”라고 판시하며 임금청구권의 성질에 대해 근로제공을 전제로 한다는 명확한 입장을 취하였다.⁵²⁾ 모든 임금은 근로제공에 대한 교환적 성격의 반대급부이므로 임금에 해당하는 금품 중에는 별도의 보장적 부분이 인정될 수 없다는 점에서 ‘근로의 대가’는 명백히 근로제공과의 직접 또는 밀접한 관련성을 의미한다고 보는 것이 타당한 해석이라고 한다.⁵³⁾ 이러한 입장에서는 근로제공과 관련없이 단순히 근로관계에 있다는 이유만으로 지급되는 것은 임금이라고 할 수

51) 대법원 1995.12.21. 선고 94다26721 판결; 대법원 1996.10.25. 선고 96다5346 판결. 이외에 대법원 1996.2.9. 선고 93다4057 판결; 대법원 1996.2.9. 선고 94다19501 판결; 대법원 1996.2.9. 선고 94다26561 판결; 대법원 1997.3.25. 선고 96다723 판결 등도 같은 취지를 밝히고 있다.

52) 대법원 2002.8.23. 선고 2000다60890, 60906 판결.

53) 박지순/이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 172면



없다고 본다. 특히 근로관계 자체에 대한 대가가 존재할 수 있는지 의문을 제기한다.

물론 어떤 금품이 근로제공에 대한 대가로서 임금에 해당하는지는 당사자 사이의 개별 약정 내용에 대한 해석을 통해 구체적으로 판단할 수 있다. 사용자에게 지급 의무가 있고 계속적·정기적으로 지급되는 모든 금품은 바로 근로의 대가로 인정하여 임금으로 단정하는 것은 명문의 규정이 있는 것도 아니고 이른바 강행적 법원칙이라고 볼 수도 없으며 타당한 해석론이라고 하기도 어렵다. 개별 계약의 해석을 통해 근로제공과 일정한 관련성을 가지고 있는 금품인지 여부가 객관적·구체적으로 판단되어야 할 것이다.

Ⅲ. “근로의 대가”의 해석에 관한 판례의 태도

1. 종래 이론적·실무적 태도

근로기준법은 임금에 관한 정의에서 임금을 “근로의 대가”로 지급되는 것이어야 한다고 규정하고 있다. 이로부터 임금성 판단을 위한 실용적인 해석 기준이 도출되어야 한다. 이러한 관점에서 “근로의 대가”란 사용자의 지휘명령에 따라 제공되는 근로의 대가, 즉 사용종속관계 하에서 행해지는 “근로”의 대가로 해석된다. 이렇게 해석하지 않으면 노무공급을 목적으로 하는 모든 계약, 즉 도급이나 위임도 결국은 수급인, 수임인의 ‘노무’가 투입되어야 하므로 모든 노무공급계약의 대가는 근로의 대가라는 결론에 이르게 된다. 따라서 도급이나 위임과 근로계약을 구별하기 위해서는 근로란 사용종속관계에서 제공되는 노무라고 할 수 있다.

또한 “근로”라는 표현은 근로기준법에서 사용하는 고유의 용어로서, 근로기준법은 제2조 제1항에서 “근로자”는 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람을 말하고, “근로”란 정신노동과 육체노동을 말하며, “근로계약”이란 근로자



가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 말한다고 규정하고 있다. 이와 같이 근로기준법에서 사용하는 “근로”라는 용어는 사용종속관계에서 제공하는 노무를 가리키는 것으로 제한적으로 이해해야 한다.

한편, 근로기준법은 임금을 근로의 대가로 규정하고 있을 뿐, 근로관계상의 지위에 대한 보수라고 정의하고 있지 않으므로, 근로자라는 지위에서 발생하는 모든 금품을 임금으로 넓게 해석하는 것은 “근로”의 대가라고 정의하고 있는 근로기준법의 문언과도 조화되지 않는다.

다만, 실무에서는 지금까지 “근로의 대가”라는 의미를 엄밀하게 정의하거나 그 경계를 구분하기 보다는 사용자가 근로자에게 지급하는 금품 중에서 임의적·은혜적 급여, 복리후생적 급여, 실비변상적 급여(통상 업무추진비, 판공비, 출장비, 실비 등으로 불리는 금품)를 제외한 나머지 금품을 근로의 대가로 넓게 이해하는 경향을 보여주었다. 이를 이른바 네거티브 방식, 소거법적 방법이라고 부른다. 하지만, 최근에는 이와 같은 네거티브 방식이 기업의 보상정책을 정확히 반영할 수 없다는 비판과 함께 근로의 대가를 좀더 구체적이고 명확하게 정의하려는 판례가 등장한 것이다.

2. 근로의 대가로 인정되지 않는 급여의 예시

일반적으로 실무에서는 “근로의 대가”의 의미를 엄밀하게 정의하기 보다는 사용자가 근로자에게 지급하는 금품 중에서, 임의적·은혜적 급여, 복리후생급여, 실비변상적 급여와 같이 명백히 임금성이 부정되는 유형의 금품을 제외한 나머지 금품을 넓게 ‘근로의 대가’에 해당한다고 해석하는 경향을 보여주고 있다. 이른바 소거법적 방법이다.⁵⁴⁾

54) 이러한 견해에 선 문헌으로 박종희, “복지포인트의 임금성 -대법원 2019.8.22. 선고 2016다48785 판결(전합) 중심으로-” 「노동법포럼」, 제28호, 2019, 235면 이하. 그에 따르면 “실질적 관점에서 사용자가 근로자에게 지급하는 일체의 금품 중 특별한 경우를 제



(1) 임의적·은혜적 급여

경조사에 대하여 지급하는 금품(결혼축의금, 사망부의금), 재해위로금 등 사용자가 임의적·은혜적으로 지급하는 금품에 대해서는 원칙적으로 근로의 대가성을 인정하지 않는다.⁵⁵⁾ 하지만 은혜적 성격의 급여라 하더라도 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 의하여 미리 그 지급조건이 명확히 정해져 있는 경우에는 사용자에게 지급의무가 있고 근로자에게는 권리로 보장된 것이기 때문에 근로의 대가인 임금으로 보호되어야 한다는 견해도 있다.⁵⁶⁾ 그러나 이에 동의하기 어렵다. 경조사비처럼 그 지급목적과 지급사유가 명확한 금품은 비록 단체협약이나 취업규칙에 의하여 사용자에게 지급의무가 있다고 하더라도 그 지급사유의 발생이 불확정적일 뿐만 아니라 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 좌우되는 등 그 지급의무의 발생이 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 가진 것으로 볼 수 없으므로 근로의 대가로 인정될 수 없기 때문이다.⁵⁷⁾

(2) 실비변상적 급여

기업이 업무수행을 위하여 필요한 장비(작업복, 작업장비)나 업무비, 출장비 등을 근로자에게 현물 또는 금품으로 지급한 것은 근로의 대가로 지급된 임금이 아니다. 그 현물이나 금품은 원래 업무수행을 위하여 사용자가 부담하는 비용이므로 사용자가 근로자에게 지급하는 형태라 하더라도 임금으로 인정될 수는 없다. 따라서 작업

외하고는 근로자의 근로와 무관한 경우는 없다”고 한다. 근로와 무관한 경우로는 순전한 은혜적·호의적 급부를 생각할 수 있을 것이다. 경조사비 지원은 단체협약 등에 규정되어 있다 하더라도 계속적·정기적으로 지급되는 금품이 아닌 일회성 금품으로, 이는 축하와 위로의 의미를 담은 인간관계에서 연유하는 금품일 뿐이다.

55) 김형배/박지순, 「노동법강의」, 287면.

56) 水町勇一郎, 「詳解労働法」, p.609. 그러나 그에 인용된 일본 실무 사례들은 대부분 퇴직금, 상여금에 관한 것인데, 퇴직금과 상여금이 임의적·은혜적 금품으로 분류될 수 있는 것인지가 의문이다. 물론 일본은 퇴직금이 법률상 규정된 법적 급여가 아니라 노사합의에 의하거나 사용자가 임의로 지급하는 성질의 금품이므로 은혜적 성격을 가진 것으로 볼 수 있다.

57) 이철수, 「노동법」, 현암사, 2023, 148면 참고.



복, 출장비, 업무회식비 등은 실비변상 내지 그에 상응하는 것인 때에는 임금으로 인정될 수 없다.

(3) 복리후생급여

사용자가 근로자의 복리후생을 위하여 지급하는 이익이나 비용(예를 들어 복지포인트, 자금대출, 주택임대, 학자금 지급, 의료비 지원, 회사의 휴양시설이나 운동시설 이용 등)에 대해서는 대체로 근로의 대가로 지급되는 것이 아니므로 원칙적으로 임금에 해당하지 않는다.⁵⁸⁾ 다만, 일정한 형태에 대해서는 예외적으로 임금성을 인정할 수도 있다고 한다. 예를 들어 주택의 대여는 원칙적으로 임금이 아닌 복리후생급여이지만 주택을 대여받지 못하는 근로자에게 정액의 이익균형적 급여(종업원간 이익균형을 위해 주택수당을 지급하는 경우)가 지급되는 경우에는 예외적으로 임금성이 인정될 수 있다고 한다.⁵⁹⁾ 비슷한 사례로 식대(식사비용을 급여로써 지급하는 경우)가 있다. 식대는 일반적으로 복리후생적 급여이지만 단체협약이나 취업규칙에 그 근거(사용자의 지급의무)가 명확히 규정되어 있다면 임금성을 인정할 수 있다고 본다.⁶⁰⁾

(4) 근로자에게 지급되는 특별한 형태의 금품

근로기준법상 임금의 정의에 따르면 임금은 사용자가 근로자에게 지급하는 금품이어야 한다. 이 요건에 대해 가장 전형적으로 문제되는 사례는 식당이나 호텔에서 고객이 직원에게 지급하는 팁이라고 할 수 있다. 팁은 사용자가 지급하는 금품이 아니므로 원칙적으로 임금이라고 할 수 없다. 그러나 고객으로부터 봉사료 내지 서비스료가 일괄 공제되고 이것이 당일 서비스를 직원들에게 일정한 계산식에 따라 분배되는 경우에는 사용자가 지급하는 금품이라고 할 수 있다. 또한 근로기준법상

58) 김형배/박지순, 「노동법강의」, 287면.

59) 이철수, 「노동법」, 150면; 水町勇一郎, 「詳解労働法」, p.610.

60) 가족수당이나 주택수당 외에도 중식대가 단체협약이나 취업규칙에 의하여 정액으로 지급되는 경우에는 명칭에 관계없이 근로의 대가로 지급되는 금품이라고 할 수 있다.



일정한 경우에 사용자에게 지급의무가 있는 법정수당(예를 들어 해고예고수당, 휴업수당, 연차유급휴가기간 중의 급여, 주휴수당 등)이 근로기준법상 임금에 해당하는지 논란이 될 수 있다. 이 중에서 해고예고수당과 휴업수당은 법이 각각 특별한 정책목적(급작스러운 해고에 의한 경제적 불이익의 보상, 휴업기간 중 최저생활의 보장 등)에서 규율된 것이기 때문에 근로의 대가로써가 아니라 특별한 수당지급의무가 부여된 것이라는 견해도 보인다.⁶¹⁾ 이에 반해 연차유급휴가기간 중의 급여, 주휴수당 등은 법이 유급으로 휴가와 휴일을 보장한 것이라는 점에서 넓은 의미에서 근로의 대가로써 임금이라고 할 수 있다고 해석된다. 다만, 근로기준법 제46조의 휴업수당은 원래 사용자의 귀책사유로 인하여 근로자의 근로제공이 불능이 되더라도 사용자의 반대급부의무가 소멸되지 않는다는 일반 원칙에 따른 것이므로 근로 제공이 없이 지급되는 금품이지만 그 법적 성격은 반대급부청구권, 즉 임금으로서의 성격을 인정해야 할 것이다. 그 밖에도 연장근로, 휴일근로, 야간근로에 대하여 지급되는 할증임금도 성질상 근로의 대가이므로 임금이라고 할 수 있다.

3. 판례의 태도

앞서 살펴본 바와 같이 대법원이 제시한 임금의 핵심적인 개념표지는 ‘근로대가성’에 있다고 할 것인데, 판례는 임금성 판단요건으로서 ① 특정 금품에 대한 지급의 계속성·정기성, ② 지급의무의 존부 그리고 그 지급의무의 발생이 ③ 근로의 대가로서 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 가지고 있는지 여부를 들고 있다. 대법원은 특정 금품이 임금이기 위해서는 위의 세 가지 요건을 모두 충족해야 한다고 보고 있다. 특히 1995년 이후에는 ③의 요건을 명시적으로 적용하는 사례가 늘고 있으며, 2019년 복지포인트 사건에서 이 요건을 재확인하였다. 비록 사실관계에 따라서는 ①, ②의 요건만을 적용하고 ③의 요건을 구체적으로 판단하지 않는 경우도 있으나 이는 ③의 요건이 불필요하다는 것이 아니라 사실관계에서 충분히 ③의 요건이 확인될 수 있기 때문으로 이해된다. 특히 지급의무의 발생이 개별근로자의

61) 水町勇一郎, 「詳解勞働法」, p.611



우연하고도 특수한 사정에 기인할 경우에는 근로의 대가성이 인정되지 아니한다.

(1) 근로제공과의 직접 또는 밀접한 관련성을 강조한 사례

대법원은 “사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 평균임금 산정의 기초가 되는 임금총액에 포함되는 임금에 해당하려면 그 금품이 근로의 대가로 지급되는 것이어야 하므로 비록 그 금품이 정기적·계속적으로 지급된 것이라 하더라도 그것이 근로의 대가로 지급된 것으로 볼 수 없다면 임금에 해당한다고 할 수 없다.”라고 한다. 이때 어떤 금품이 근로의 대가로 지급된 것인지 판단할 때에는 “그 금품지급의 무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있어야 하고, 이러한 관련 없이 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 따라 지급의무의 발생 여부가 달려 있는 경우에는 그 금품이 단체협약이나 취업규칙 또는 근로계약이나 사용자의 방침 등에 따라 지급된 것이라도 해당 금품은 근로의 대가로써 지급된 것이라 할 수 없다.”라고 판시하고 있다.⁶²⁾

또한 마찬가지로 어떤 금품이 사용자의 지급의무 없이 은혜적 목적으로 지급되거나 지급의무가 있더라도 근로제공과 관련 없이 근로자가 직무 수행 과정에서 불가피하게 추가적으로 발생된 비용을 충당하기 위하여 지급되는 실비변상적인 성격을 갖는 경우에도 해당 금품은 “개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 따라 지급 여부가 결정되는 것이므로” 근로의 대가로 지급된 것으로 볼 수 없다.⁶³⁾

판례가 임금성 판단에 있어 위와 같은 법리를 들어 근로제공과의 직접적 관련성을 강조하여 판단하는 사례는 대부분 임금성을 부정하는 경향성을 보이는데, 대표적으로 아래와 같은 사례가 있다.

62) 대법원 1995.5.12. 선고 94다55934 판결; 대법원 1996.5.14. 선고 95다19256 판결; 대법원 2011.7.14. 선고 2011다23149 판결; 대법원 2019.8.22. 선고 2016다48785 판결. 이에 관해서는 위 각주 37) 참고.

63) 대법원 1999.2.9. 선고 97다56235 판결; 대법원 2003.4.22. 선고 2003다10650 판결; 대법원 2006.8.24. 선고 2004다35052 판결 등.



가. 자가운전보조비의 임금성

일정 직급 이상 직원 중에서 자기차량 보유 여부에 따라 실제 비용지출 여부를 불문하고 지급된 자가운전보조비의 임금성이 문제된 사안⁶⁴⁾에서, 대법원은 “사용자가 지급하는 금품이 임금에 해당하기 위해서는 그 금품이 정기적·계속적으로 지급 되더라도 그것이 근로의 대상(對償)으로 지급되는 것이어야 하며, 근로의 대상인지 여부는 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있어야 한다”고 보았다. 이러한 관련성 없이 그 지급의무의 발생이 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의하여 좌우되는 경우에는 사용자의 지급의무가 인정되더라도 근로의 대가성을 인정하기 어렵다고 하였다.

대법원은 이러한 법리를 기초로 “자가운전보조비 명목의 금원이 일정 직급 이상 직원 중 자기 차량으로 운전한 자에 한하여 지급되고 있다면 이는 단순히 직급에 따라 일률적으로 지급된 것이 아니고 그 지급 여부가 근로제공과 직접적으로 또는 밀접하게 관련됨이 없이 오로지 일정 직급 이상의 직원이 자기 차량을 보유하여 운전하고 있는지 여부라는 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 달려 있는 것이므로, 그 자가운전보조비 중 회사가 그 직원들에게 자기 차량의 보유와 관계없이 교 통비 명목으로 일률적으로 지급하는 금원(즉, 여기까지는 임금)을 초과하는 부분은 비록 그것이 실제 비용의 지출 여부에 관계없이 정기적·계속적으로 지급된 것이라도 근로의 대가로 볼 수 없다.”라고 보아 임금성을 부정하였다.

나. 선택적 복지포인트의 임금성

선택적 복지포인트의 임금성이 문제 된 사안에서 대법원 전원합의체는 “사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 임금에 해당하려면 그 금품이 근로의 대가로 지급되는 것이어야 하므로 비록 어느 금품이 계속적·정기적으로 지급된 것이라 하더라도 금 품지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 없다면 근로의 대가로 인정되기 어렵다”고 하면서 따라서 임금이 아

64) 대법원 1995.5.12. 선고 94다55934 판결.



나라고 판시하였다.⁶⁵⁾

이러한 관점에서 구체적으로 복지포인트가 임금에 해당하는지 여부에 대하여 전원합의체 판결의 다수의견은 다음과 같은 이유로 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 인정하기 어렵다고 보았다. ① 복지포인트의 임금성 여부를 판단할 때 관련 법률의 규정을 충분히 고려하여 규범조화적 관점에서 판단되어야 한다. 복지포인트의 전제가 되는 선택적 복지제도는 근로복지기본법에서 정한 제도이고, 근로복지기본법의 취지를 고려할 때 선택적 복지제도에 대한 입법자의 의사는 복지포인트가 임금이 아니라는 점을 전제로 하고 있음이 분명하므로 이는 임금성을 인정하기 어려운 중요한 판단요소이다. ② 선택적 복지제도는 복지포인트 사용처를 복지라는 취지에 맞게 한정하고, 근로자의 수요에 따라 복지 효과를 극대화할 수 있도록 근로자의 ‘선 지출’, 회사의 ‘후 정산’ 방식으로 기업복지제도를 새로 변경한 것이며, 종래 임금성을 가진 복지수당 관점에서 벗어나 ‘비임금적 기업복지제도’로 전환시키기 위해 그 형식과 내용을 변경한 것이다. 이와 같은 선택적 복지제도의 도입 경위를 고려하면 복지포인트를 임금으로 해석하는 것은 타당하지 않다. ③ 선택적 복지제도의 취지와 도입 경위의 특수성으로 인해 복지포인트는 여행, 건강관리, 문화생활, 자기계발 등으로 사용 용도가 제한되어 있고, 통상적으로 1년 이내에 사용하지 않으면 차년도로 이월되지 않고 소멸하게 되며, 양도 가능성도 없다. 즉, 재산권으로서 성격도 약하다. 이처럼 복지포인트는 근로자가 근로 제공의 대가로 사용자로부터 지급받아 생계의 기초로 삼는 임금이라고 평가하기에는 적절하지 않은 특징을 상당수 보유하고 있다. ④ 일반적으로 복지포인트는 근로자의 근로제공과 관계없이 매년 초에 일괄적으로 근로자에게 배정된다. 우리 기업 현실에서 이러한 형태의 임금은 일반적이라고 하기 어렵다. 복지포인트의 단순한 특성이라고 이해할 것이 아니라 근로의 대가가 아니라는 적극적인 징표로 이해해야 할 사정이다. ⑤ 선택적 복지제도를 도입한 회사들은 복지포인트를 단체협약이나 취업규칙 등에서 ‘보수’ 또

65) 대법원 2019.8.22. 선고 2016다48785 전원합의체 판결. 이 전원합의체 판결의 다수의견은 “복지포인트는 근로자가 근로를 제공한 대가로 사용자로부터 지급받아 생계의 기초로 삼는 임금이라고 평가하기에는 적절하지 않은 특성을 다수 가지고 있다.”라고 하면서 생계의 기초로서의 임금과 그 밖에 근로자의 재산형성이나 복리후생 등을 위한 금품을 구별하는 듯한 판시를 하기도 하였다.



는 '임금'으로 표현하지 않는 것이 대부분이다. 또한 복지포인트가 근로의 대가가 아니라는 점에 대해서도 근로관계 당사자는 어느 정도 인식하고 있다. 대법원 다수 의견은 이와 같은 이유 등을 들어 선택적 복지포인트의 임금성을 부정하였다.

(2) 계속적·정기적 지급 여부를 강조한 사례

대법원에 따르면 평균임금 산정 기초에 포함되는 임금총액에는 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 일체의 금품으로써, 정기적·계속적으로 지급되고 단체협약이나 취업규칙 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 있으면, 그 명칭에 관계없이 모두 포함되는바, 사용자에게 근로의 대가성이 있는 금품에 대하여 그 지급의무가 있다는 것은 그 지급 여부를 사용자가 임의적으로 결정할 수 없음을 의미하고, 그 지급의무의 발생근거는 단체협약이나 취업규칙(급여규정), 근로계약에 의한 것이든 또는 그 금품의 지급이 사용자의 방침을 근거로 하거나, 노동관행에 의한 것이든 관계없다.⁶⁶⁾

판례가 이와 같이 계속적·정기적 지급여부 및 지급의무의 존재를 강조하여 임금성을 판단한 대표적인 사례는 다음과 같다.

가. 차량운행수당의 임금성

대법원은 “1회당 금 일만원이라는 지급기준을 정하고 운행횟수에 비례하여 계산한 금액을 차량운행수당으로 매월 임금지급일에 정기적·계속적으로 지급해 온 경우, 사용자는 관례에 의하여 1회당 금 일만원의 운행수당을 일률적으로 지급하여야 할 의무가 있었다고 할 것이고, 이러한 운행수당은 장거리 운행으로 인하여 추가로 소요되는 비용을 보전하여 주려는 실비변상적 성격의 금원이라기보다는 근로의 대가로 지급된 것이라고 봄이 상당하다”고 하여 차량운행수당의 임금성을 인정하였

66) 대법원 2018.12.13 선고 2018다231536 판결. 또한 대법원 1997.5.28. 선고 96누15084 판결; 대법원 2001.10.23. 선고 2001다53950 판결; 대법원 2002.5.31. 선고 2000다18127 판결 등.



다.⁶⁷⁾

나. 특별생산격려금의 임금성

대법원은 “특별생산격려금 지급 경위가 노동쟁의 조정 결과 노사 합의에 따른 것이고 당시 조정안에서 이 생산격려금은 전년도 경영성과를 감안한 특별상여금으로서 1회에 한하기로 약정하였다고 하더라도, 이후 회사의 경영실적의 변동이나 근로자들의 업무성과와 관계없이 특별생산격려금을 정기적·계속적·일률적으로 지급해 왔다면 이는 근로계약이나 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그 지급의무가 지워져 있는 것으로서 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 해당한다.”라고 하면서 특별생산격려금의 임금성을 인정하였다.⁶⁸⁾ 다만 이 판결에서 계속성·정기성 외에 지급의 일률성이 임금성 판단에 영향을 미친 것으로 볼 수는 없다. 이는 단지 해당 사안에서 구체적인 생산격려금의 지급방법일 뿐이기 때문이다.

다. 자동차 영업사원의 실적 인센티브의 임금성

자동차 판매회사인 사용자가 영업사원들에게 매월 자동차 판매 대수에 따른 일정 비율의 인센티브를 지급한 것이 평균임금에 포함되는지가 쟁점인 사례에서, 대법원

67) 대법원 1997.5.28. 선고 96누15084 판결.

68) 대법원 2001.10.23. 선고 2001다53950 판결. 이 판결에 따르면 회사가 특별생산격려금을 지급하게 된 경위가 1989년 1월경 시멘트업계 근로자들의 노동쟁의에 대한 조정 결과 350%의 생산격려금을 지급하기로 한 합의에 따른 것이고 당시 조정안에서 이 350%의 상여금은 1988년도의 경영성과를 고려한 특별상여금으로서 1988년도에 한하기로 약정하였다고 하더라도, 이후 피고 회사의 경영실적의 변동이나 근로자들의 업무성과와 관계없이 IMF로 인한 경제위기가 오기 전까지 근로자들에게 정기적·계속적·일률적으로 기본급의 250%에 해당하는 특별생산격려금이 지급되어 왔다면 이는 근로계약이나 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그 지급의무가 있는 것으로서 평균임금 산정에 포함되는 임금에 해당한다고 보았다. 다시 말하면 최초 1회의 생산격려금에 대한 임금성은 차치하고, 그 이후에 같은 이름(특별생산격려금)으로 정기적, 계속적으로 지급된 금품은 사용자에게 지급의무가 인정되므로 임금이라고 보았다. 다만 이 판결은 노사 간에 특별생산격려금을 퇴직금산정에서 제외하기로 하는 묵시적 합의가 있었으며, 당시 그러한 합의가 근로기준법에 반하는 것으로 볼 수 없다고 보아 특별생산격려금이 평균임금에 산입되지 않는다는 취지의 원심 판단을 수긍하였다.



은 “인센티브 지급규정이나 영업 프로모션 등으로 정한 지급기준과 지급시기에 따라 인센티브를 지급하여 왔고, 영업사원들의 차량판매를 위한 영업활동은 자동차 판매회사에 대하여 제공하는 근로의 일부이므로 인센티브는 근로의 대가로 지급되는 것이며, 인센티브의 지급이 매월 계속적·정기적으로 이루어지고, 지급기준 등 요건에 따른 실적을 달성하였다면 사용자는 그 실적에 따른 인센티브 지급을 거절할 수 없다.”라는 점 등을 들어 인센티브의 임금성을 인정하였다.⁶⁹⁾

4. 판례에 대한 평가

각 대법원 판결의 형식적 문언만을 보면 임금성 판단기준을 사안에 따라 달리 적용하고 있는 것처럼 보일 수 있으나, 기본적으로 특정 금품이 근로의 대가인 임금이기 위해서는 계속적·정기적으로 지급되어야 하고, 사용자에게 지급의무가 있어야 하며, 그리고 금품지급이 근로제공과 직접 또는 밀접하게 관련된 것이어야 하고, 금품지급이 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 달려 있는 경우에는 해당 금품은 근로의 대가로 지급된 것으로 볼 수 없다고 판시하고 있다. 즉, 각 대법원 판결은 임금성 판단에 대하여 실질적으로는 동일한 판단구조를 가지고 있다고 할 수 있다. 다만 판결문마다 그 내용이 다른 것은 사실관계의 특성상 ‘근로의 대가’라는 요건을 특별히 강조해야 하거나 아니면 강조하지 않아도 충분히 근로의 대가성을 인정할 수 있다는 차이만이 존재하는 것으로 보인다.

‘근로의 대가’의 의미에 대하여 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 명시적으로 언급하지 아니한 판결은 대체로 임금성 판단기준으로 “임금은 사용자가 근로의 대상(대가)으로 근로자에게 지급하는 금품으로서, 근로자에게 정기적·계속적으로 지급되고 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 있는

69) 대법원 2011.7.14. 선고 2011다23149 판결. 이 판결이 인센티브의 임금성을 인정한 배경에는 인센티브를 전부 임금으로 보지 않는다면 오로지 인센티브만으로 급여를 전액 지급받기로 한 근로자는 근로는 제공하였지만 근로의 대가로서 임금이 없으므로 퇴직금도 전혀 받을 수 없게 되는 불합리한 결과가 초래될 것이라는 점이 고려되었다.



것을 말한다”라고 판시하고 있다. 즉, 이 판결들의 문언은 “근로의 대가로 지급하는 금품”이라는 부분과 “정기적·계속적 지급, 단체협약 등에 의하여 지급의무가 있는 금품”이라는 두 가지 요건으로 판단하는 것처럼 보일 수 있으나, 해당 사례들은 근로제공과 금품지급 사이에 근로의 대가성이 명확히 인정되는 경우로 이에 대해 별도로 판단하지 않은 것으로 보이며, 판례의 입장이 달라졌다고 보기는 어렵다. 즉, 근로제공과 금품지급 사이에 근로의 대가성이 명확히 인정되는 경우에는 각 사안마다 금품의 지급방법(계속성·정기성), 지급의무의 존부 등 문제가 되는 부분에 집중하여 판시한 것으로 보인다.

그러나 계속적·정기적 지급, 지급의무의 존재만으로 근로의 대가성 자체를 판단하기 어려운 사례에 대해서는 다시 “특정 금품지급이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것”인지 여부를 가지고 근로의 대가성 여부를 판단해야 하며, 그러한 관련성이 인정되지 않는다면 해당 금품이 계속적·정기적으로 지급된 것이고 사용자의 지급의무가 인정되더라도 근로의 대가로서 임금에 해당한다고 볼 수 없다고 하였다.⁷⁰⁾ 다시 말해 대법원 판시에 따르면 지급의무의 존재, 계속적·정기적 지급만으로 근로의 대가성을 단정할 수는 없다. 여기에 더하여 해당 금품이 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 가지고 있어야 한다. 이 세 가지 요건을 모두 갖추어야 임금으로 인정된다.

예를 들어 회사가 노사 간 합의에 따라(사용자의 지급의무의 존재) 전체 근로자들에게 정기적·계속적으로 특별성과급을 지급하여 왔으며, 그 금품의 지급이 근로자의 근로제공을 지급사유나 목적으로 한다면(근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성) 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 해당한다.⁷¹⁾ 이와 달리 그와 같은 특별성과급

70) “사용자가 근로자에게 지급하는 임금은 정기적·계속적으로 지급되는 것이 통상적이므로 그 지급사유의 발생이 확정되어 있지 않고 일시적으로 지급되는 것은 근로의 제공과 관련 없이 지급되는 것으로 판단 받을 여지가 많다. 하지만 그렇다고 하여 반드시 정기적·계속적으로 지급되어야만 근로제공과 관련된 것이고 그렇지 않은 것은 근로제공과 무관한 것이라는 논리필연적인 관계가 있는 것은 아니므로, 드물게 정기적·계속적으로 지급되는 것이 아니라 하더라도 다른 사정을 종합하여 사용자가 근로자의 근로제공과 관련하여 지급하는 것으로 볼 수 있으면 임금에 해당한다. 한편, 어느 금품이 정기적·계속적으로 지급되는 것이라 하더라도 근로의 제공과 관련 없이 지급되는 것이라면 그 금품의 지급이 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 의하여 지급의무가 발생한 것이라 하더라도 임금에 포함시킬 수 없다”(대법원 2006.8.24. 선고 2004다35052 판결).



이 일시적으로 1회만 지급된 것이라면 계속적·정기적으로 지급된 것이 아니므로 임금으로 인정하기 어려울 것이다. 또한 특별성과급이 회사의 경영실적 등과 같이 근로자의 근로제공과는 다른 지급사유나 목적을 가지고 있다면 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성이 인정되지 않아 임금으로 인정되기 어려울 것이다. 이처럼 대법원 판결에 따르면 특정 금품이 근로의 대가로서 임금이기 위해서는 지급의무, 정기적·계속적 지급, 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성이 있어야 한다. 그 어느 한 가지가 부족해도 임금으로 인정되기 어렵다.

그런데 이와 같은 임금 개념에 관한 대법원 판결의 상당수는 실제로는 평균임금 산입 범위에 포함되는 임금의 개념을 다투고 있는 사안이다. 즉, 대법원은 특정 금품이 평균임금의 산입 범위에 포함되는지 여부를 판단하기 위하여 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 임금 개념을 적용하고 있는 것이다.

우리 근로기준법은 평균임금을 “산정 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액”이라고 규정하고, 대법원은 임금 총액이 사용자가 근로의 대가로 지급하는 금품을 모두 포함하는 것으로 해석하고 있다. 그런데 평균임금은 그 취지상 근로자의 통상적인 생활임금을 산정하기 위한 개념에 불과할 뿐이다. 따라서 대법원의 판단은 임금의 일반적 개념과 평균임금 산입 범위 간의 본질적 차이를 무시하고 임금 개념의 해석을 통하여 평균임금의 범위를 조정하려는 문제점을 안고 있다. 뿐만 아니라 위에서 본 것처럼 대법원은 임금 개념을 엄격하게 해석함으로써 임금성이 인정되어야 할 금품까지도 임금의 범주에서 제외되는 결과가 발생할 수 있으므로 근로자보호의 관점에서 타당하지 않을 수 있다는 문제점이 있다.

생각건대 근로자보호의 관점에서 임금 개념을 넓게 해석하되, 평균임금의 산입대상인 임금의 범위는 근로자의 통상적 생활보장을 목적으로 하는 평균임금의 취지를 고려하여 합목적적으로 제한될 필요가 있다. 이런 이유로 대법원의 임금 개념에 대한 해석론은 문제가 있다고 판단된다(이에 관해서는 다음 제4절 및 제3장 제2절에

71) 대법원 2001.10.23. 선고 2001다53950 판결. 같은 취지의 판결로 대법원 1982.10.26. 선고 82다카342 판결; 대법원 1982.11.23. 선고 81다카1275 판결; 대법원 1994.5.24. 선고 93다4649 판결 등.



서 다시 설명한다).

제3절 비교법적 검토

I. 독일⁷²⁾

1. 계속적·정기적 임금과 특별급여의 구분

독일 민법 제611조a는 근로계약을 채권계약으로서 그 주된 의무가 쌍무적 견련 관계에 있는 교환계약이라는 점을 확인하고 있다. 그에 따르면 사용자는 근로자의 종속적 노무제공에 대하여 합의된 보수(Vergütung)를 지급할 의무를 부담한다(제 611조a 제2항). 그 밖에 임금에 관한 다른 일반적 정의 규정은 없다. 위 규정에 따르면 근로제공을 목적으로 고용된 근로자에게 지급하기로 당사자 간에 약정된 금품은 보수(임금)이다.

따라서 근로계약을 기초로 사용자에게 지급의무가 있는 금품은 원칙적으로 보수라고 할 수 있다. 다만, 보수는 독일에서도 여러 구성 부분으로 이루어져 있는데, 독일 임금계속지급법(Entgeltfortzahlungsgesetz, EFZG) 제4조a는 근로자에게 지급하는 보수를 구성하는 다양한 구성 부분에 대하여 계속적·정기적 임금(laufendes Arbeitsentgelt)과 특별급여(Sondervergütung 또는 Sonderleistung)라는 용어를 사용하여 양자를 구분한다. 문헌 중에는 계속적·정기적 임금을 ‘좁은 의미의 임금’이라고 하고 특별급여를 ‘넓은 의미의 임금’으로 이해하는 견해도 있다.⁷³⁾

72) 이 부분은 이수정/박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 임금성”, 203면 이하; 권혁, “임금의 개념으로서 근로 대가성 판단에 관한 소고”, 199면 이하 참고



계속적·정기적으로 지급되는 임금에는 기본급, 수당 및 노동의 양이나 질에 따른 성과와 실적을 토대로 지급하는 이른바 개인성과급 등이 포함되는데, 이는 기업의 전체적인 영업실적을 기초로 지급되는 보너스(경영성과급)와는 구별되어 근로제공과 쌍무적 견련관계에 있는 금품을 의미하며, 질병휴가나 휴일에 지급하는 수당 등 법정수당이나 성탄보너스 등의 산정기준이 된다.⁷⁴⁾

이에 비하여 근로제공과는 쌍무적(대가적) 견련성이 상대적으로 약하거나 또는 근로 제공 자체에 대한 대가와 다른 목적으로 지급되는 일회적 급여로서 특별급여(Sondervergütung)가 있다. 위에서 인용한 독일 임금계속지급법 제4조a에 따르면 사용자가 “계속적·정기적 임금에 부가하여 지급하는 급여”를 특별급여라고 정의하고 있다. 특별급여는 공로보상이나 충성심에 대한 격려금, 복리후생, 축하·위로 등 다양한 목적으로 지급된다.⁷⁵⁾ 여기에는 주로 보너스(Gratifikation), 성탄절 특별보너스(Weihnachtsgratifikation), 전체 종업원에게 지급하기로 하는 경영성과급(Jahresabschlussgratifikation), 축의금 및 조의금 등이 포함된다.

특별한 지급사유를 갖는 일회적 급여를 의미하는 특별급여에는 임금성이 인정되는 특별급여와 순수한 보너스가 있다. 먼저 전자의 경우는 계속적·정기적으로 지급되지는 않지만 근로자에게 ‘전형적으로 발생하는 비용’(예를 들어 성탄절보너스, 휴가금 등)을 충당할 목적으로 지급되고, 근로제공에 대하여 지급하는 성격의 급여로서 노무급부에 대한 쌍무적 견련성이 인정될 수 있으므로 임금으로 인정된다. 이와 달리 후자의 경우는 근로제공과 쌍무적 견련성 없이 특별한 목적으로 지급되는 일회적 급여로서 순수한 보너스로서의 성격을 갖는 금품이다. 경영실적을 기반으로 종업원의 계속근로 촉진, 인재유출방지, 기업에 대한 충성심을 높일 목적 등으로 지

73) *ErfK/Preis*, BGB §611a Rn. 389 ff., 527 ff. 참고. 독일 연방노동법원은 최근에는 좁은 의미의 임금과 넓은 의미의 임금이라는 구분보다는 계속적·정기적 임금과 특별급여라는 법률상 명칭을 그대로 사용하는 경향이 있다. BAG NZA 2008, 1173; BAG NZA 2009, 310; BAG NZA 2009, 535(이수정/박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 법적 성격”, 203면 재인용).

74) Reichold, *Arbeitsrecht*, 6. Aufl., 2019, § 8 Rn. 7(이수정/박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 법적 성격”, 204면 재인용).

75) *ErfK/Reinhard*, EFZG § 4a Rn. 5 ff.(이수정/박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 법적 성격”, 204면 재인용).



급되는 경영성과급이 후자의 대표적인 사례이다.⁷⁶⁾ 이처럼 임금성을 갖는 일회성 급여와 순수한 보너스 성격을 갖는 일회적 금품들 모두 독일에서는 특별급여(부가 급여)로 분류된다.

임금에 관한 특별한 정의를 두고 있지 아니한 독일에서는 이와 같은 특별급여도 단체협약이나 사업장협정에 그 지급 근거가 규정되어 있다면 사용자에게 지급의무가 있기 때문에 근로관계에서 발생하는 보수로 분류되지만, 휴가금이나 성탄보너스, 기업연금 등을 산정하는 기준임금(우리의 평균임금에 해당)에는 산입되지 않는다.⁷⁷⁾

계속적·정기적 임금은 근로계약에 그 지급 근거가 있는데 비하여, 특별급여는 사업장협정(Betriebsvereinbarung), 사용자의 일방적 지급약속(Gesamtzusage), 경영관행(Betriebsübung) 등 전체 기업의 보상정책을 기반으로 지급되는 것이 특징이다. 또한 특별급여의 경우 대개는 그 지급여부 및 지급액이 사용자의 재량에 달려 있는 경우가 많으며, 사용자에게 어느 정도 (불이익) 변경 가능성이 인정된다는 점에서 일반적 임금과 구별되기도 한다.

2. 특별급여의 경우 지급일 재직 요건의 유효성

특별급여의 경우 지급일 전에 미리 퇴직한 근로자가 실제 근무일에 따른 일할 계산을 청구할 수 있는지 여부는 당사자의 합의에 대한 해석 문제로 본다.

근로제공의 대가로서 임금성을 갖는 특별급여의 경우에는 도중에 퇴직하더라도 임금청구권을 상실하지 않는다. 임금청구권은 근로관계의 존속을 전제로 하지 않으므로 퇴직한 근로자도 근로를 제공한 기간에 대하여 비율적으로 임금청구권을 갖는다.

76) 상세한 내용은 Salamon, *EntgG-HdB/Salamon*, [B] Rn. 17 이하 참고(이수정/박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 법적 성격”, 205면 재인용).

77) Salamon, *EntgG-HdB/Salamon*, [B] Rn. 27(이수정/박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 법적 성격”, 205면 재인용); 권혁, “임금의 개념으로서 근로 대가성 판단에 관한 소고”, 200면 참고.



반면에 회사에 대한 충성심을 보상하기 위해 지급되는 특별급여에 대하여 재직 요건이 규정되어 있다면, 지급일 당시 재직하고 있지 않거나 해고된 경우에는 청구권기초가 결여되어 있기 때문에 해당 특별급여에 대한 청구권도 배제된다.⁷⁸⁾ 다만, 근로자측의 책임 없는 사유로 근로관계가 종료되는 경영상 해고에 대해서도 마찬가지로 적용되어야 하는지에 대해서는 논란이 있다.⁷⁹⁾

특별급여 중에는 위의 두 성격이 혼합된 경우도 있을 수 있는데, 독일연방노동법원은 이와 같은 혼합적 성격의 특별급여에 대하여 근무일수에 따른 비율적 청구권이 인정되기 위해서는 당사자의 명시적 합의가 필요하다고 본다.⁸⁰⁾ 반면에 혼합적 성격의 특별급여에 대해서도 임금 성격의 특별급여와 동일하게 비율적 청구권을 인정해야 한다는 견해가 있다.⁸¹⁾

3. 소결

이상에서 본 바와 같이 독일은 보수를 대체로 계속적·정기적 임금과 특별급여로 구분하고 있다. 전자는 근로제공에 대한 직접적 관련성을 가진 금품으로 이해되고, 후자는 일회성 급여로서 노무제공과 관련성을 가진 급여도 있고 순수한 보너스의 성격을 가진 급여도 있다고 본다. 그런데 최근에는 특별급여를 임금과 보너스의 혼합적 성격으로 이해하기도 한다. 이는 특별급여가 근로제공을 목적으로 하는 근로관계의 범주를 벗어나지 않는다는 점을 강조하면서도 그 지급사유나 목적이 근로제공과는 직접 또는 밀접한 관련성을 갖지 않는다는 점을 의미하는 것이라고 한다.⁸²⁾

위에서 검토한 바와 같이 독일의 특별급여는 법정수당 산정을 위한 임금(우리나

78) BAG 7.11.1991 EzA § 611 BGB Gratifikation, Prämie Nr. 87.

79) 이를 긍정하는 견해는 BAG 19.11.1992 AP Nr. 147 zu § 611 BGB Gratifikation; BAG 18.1.2012 NZA 2012, 620.

80) BAG 26.10.1994 AP Nr. 167 zu § 611 BGB Gratifikation.

81) Preis, *Indiv. Arbeitsrecht*, S. 417.

82) Preis, *Indiv. Arbeitsrecht*, 4. Aufl., 2012, S. 408.



라의 평균임금에 해당)에 포함되지 않을 수 있다는 점을 알 수 있다.

II. 일본⁸³⁾

1. 노동의 대상(對償)

일본 노동기준법은 우리 근로기준법과 마찬가지로 임금을 “명칭에 관계없이 노동의 대상(對償)으로 사용자가 근로자에게 지급하는 모든 금품”이라고 정의하고 있다. 여기서 노동의 대상이란 널리 사용자가 근로자에게 지급하는 금품 중 근로자가 이른바 사용종속관계 하에서 행하는 노동에 대하여 그 보수로서 지급하는 것으로 이해된다.⁸⁴⁾

따라서 명칭이나 지급방법과 관계없이 노동의 대가로서 지급되는 것이 명확하다면 임금이라고 할 수 있다. 이때 노동의 대가의 의미에 대해서는 구체적인 노동의 결과에 직접 대응하여 지급되는 것이라는 견해와, 사용종속관계에서 노무를 제공하는 지위에 대하여 지급되는 것도 모두 임금이라고 보는 견해가 있다. 전자의 관점을 강조하는 견해를 협의의 임금설(노동대가설)이라고 하고, 후자의 견해를 근로관계상의 지위에 대한 보수라고 넓게 이해하는 광의의 임금설(근로관계대가설)이라고 할 수 있다.⁸⁵⁾ 일본의 판례와 다수설은 대체로 노동의 대가를 엄격하게 해석하지 않고 사용자가 근로자에게 지급하는 것 중에서 임의적·은혜적 성격의 급여, 복리후생급여, 기업설비·업무상 필요경비 등 3개의 유형을 제외한 나머지를 노동의 대가로 해석하는 이른바 소거법(消去法)적 방법을 취하고 있는 것으로 보인다.⁸⁶⁾

83) 이에 관해서는 이수정/박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 임금성”, 205면 이하 참고.

84) 日本 厚生労働省, 「労働基準法(上)」, p.162; 野川忍, 「労働法」, p.597(이수정/박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 법적 성격”, 206면 재인용).

85) 학설의 개요에 대하여는 박지순/이진규, “경영성과급의 임금성 판단”, 171-172면 참고.

86) 水町勇一郎, 「詳解労働法」, 2019, p. 608 참고.



하지만 근로제공과 관련이 없는 급여(상여금, 결혼 또는 출산축의금, 사망조의금 등)라도 그 지급이 단체협약이나 취업규칙에 미리 명시되고 그 조건에 해당하는 자에 대하여 지급의무가 있는 경우에는 그 지급조건이 충족된 근로자에게 권리로서 보장되어 있기 때문에 임금에 해당된다고 한다. 또한 (우리처럼 법률상 규정은 없지만 노사 간 합의에 의하여 지급되는) 퇴직금에 대해서도 지급조건이 정해져 있지 않고 지급 여부나 지급액이 사용자의 재량에 맡겨져 있는 경우에는 임금이 아니지만, 취업규칙이나 단체협약에 지급기준이 명확히 규정되어 있고, 그 기준에 해당하는 자에게 퇴직금 청구권이 발생하면 노동기준법상 임금으로 본다. 특별히 큰 이익이나 성과를 거둔 회사가 임의로 상여금, 보너스라는 이름으로 지급하는 일시금도 임금으로 해석한다.⁸⁷⁾

2. 평균임금의 산입 범위

일본 노동기준법은 근로자를 해고하는 경우의 해고예고수당(제20조), 사용자의 책임 있는 사유에 의한 휴업 시 지급하는 휴업수당(제26조), 연차유급휴가 중의 임금(제39조 제7항), 업무상 재해의 경우의 보상(제76조 이하), 감금의 제재에 대한 제한액(제91조) 등에 대해서는 “평균임금”의 일정 일수 또는 일정 비율로 지급할 것을 규정하고 있다. 일본 노동기준법 제12조는 이와 같은 평균임금의 계산방법을 규정하고 있다.

위에서 열거한 수당이나 보상은 모두 근로자의 생활을 보장하기 위한 것이므로 그 계산 기준인 평균임금 산출 시 근로자의 통상의 생활자금을 있는 그대로 산정할 것이 요구된다.⁸⁸⁾ 이와 같은 관점에서 평균임금 산정방식이 노동기준법 제12조 및 노동기준법 시행규칙 제2조 내지 제4조에 상세히 규정되어 있다. 이 규정에 따르면 평균임금은 산정사유가 발생한 날 이전 3개월간의 총임금액을 그 기간의 총일수로

87) 日本 東京地判 平成 50.10.28 勞判 971号 p.27(모건스탠리 사건)는 지급기준이 사전에 정해져 있지 않다는 이유로 상여금의 임금성을 부정하였다.

88) 菅野和夫, 「労働法」, p.407.



나누어 산정된 것이다.

다만, 그 3개월 동안에 업무상 재해로 인한 휴업기간, 산전산후휴가로 인한 휴업기간, 사용자의 귀책사유에 의한 휴업, 육아 및 간병을 위한 휴업 그리고 시용기간이 포함되어 있는 경우에는 임금의 총액이 극단적으로 낮아질 우려가 있기 때문에 이에 해당하는 일수 및 해당 기간 중의 임금은 평균임금의 계산에서 제외된다(노동기준법 제12조 제3항).

또한 그 3개월 중에 임시로 지급된 임금, 3개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금(상여금 등)이 있는 경우에는 통상의 생활자금과는 동떨어진 것으로 볼 여지가 있으므로 임금총액에서 제외된다(노동기준법 제12조 제4항). 반대로 여기서 제외임금으로 열거되지 않은 통근수당, 정근수당, 연차유급휴가 중의 임금, 식비보조비 등은 산정기초가 되는 임금총액에 포함된다.⁸⁹⁾

또한 일급제·시간급제, 성과 및 실적급제 그 밖의 도급제에서는 산정기간인 3개월 간에 결근일수가 많은 경우에는 평균임금이 현저히 낮게 될 우려가 있으므로 실근로일수 상당 임금의 60%를 최저보장액으로 하도록 규정하고 있다(노동기준법 제12조 제1항 단서).

3. 일본의 상여금제도

(1) 상여금에 대한 기본적 태도

일본 기업들은 하계와 동계 등 연 2회 상여 또는 상여금(일시금, 보너스)을 지급하는 경우가 많다. 그 금액은 통상 기본급 등의 기초액에 지급률(월수)을 곱하여 산정하게 되는데, 개별 근로자의 상여액에 대해서는 주로 출근률, 인사평가 등을 고려하여 구체적으로 확정하게 된다. 근년에는 상여금 중 연령이나 근속연수를 반영하는 부분을 축소·폐지하고, 기업의 업적과 근로자의 성과평가에 의한 업적 및 평가

89) 水町勇一郎, 「詳解労働法」, p.613.



부분을 확대하는 경향을 보여주고 있다. 이를 가리켜 상여금의 유연화 또는 변동비화(變動費化)가 진행되고 있다고 한다.⁹⁰⁾

상여금은 일반적으로 일본 노동기준법상 “3개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금”으로서 평균임금의 산정기초(노기법 제12조 제4항)에서 제외된다. 마찬가지로 상여금에 대해서는 매월 1회 이상 정기지급의 원칙에 대해서도 예외가 인정된다. 이와 같이 일본의 상여금은 기본급과 달리 그 액수를 인상하더라도 해고예고수당, 휴업수당, 연차유급휴가수당 등의 산정기초가 되는 평균임금이나 연장근로나 휴일근로 등에 대해 지급되는 가산임금 산정기초(우리나라의 통상임금)를 인상시키지 않기 때문에 유연하게 그 금액을 설정하거나 변경할 수 있다. 또한 연 2회의 상여금 지급의 기초가 되는 재원(財源)도 기업의 성과나 업적에 따라 그때 그때마다 증감할 수 있고 개별 근로자에 대한 배분도 각자 근무성적 등을 평가하여 결정하고 퇴직금 산정에도 직결되지 않는 등, 고정비인 기본급과 달리 변동비로서 유연하게 운영될 수 있다는 점이 주목된다.⁹¹⁾

일본에서는 상여금을 임금후불적 성격도 있지만 월급(기본급)을 보충하는 생활보전적 성격, 근로자의 공헌에 대한 공로보상적 성격, 장래의 노동에 대한 근로장려적 성격, 기업업적의 수익배분적 성격 등 다양한 성격을 포함하는 것으로 이해한다. 다시 말해 일본의 상여금은 여러 목적이 혼합된 혼합적 성격을 가진 것으로서 기본적으로는 임금후불적 성격이 부분적으로라도 인정된다면 임금성을 인정하고 있다.⁹²⁾

(2) 지급일 재직 요건의 유효성

이 점은 특히 상여금 지급을 정한 취업규칙 등에 “상여금은 지급일에 재직하고 있는 자에 대하여 지급한다.”라는 지급일 재직 요건 또는 지급일 재직 요건이 규정되어 있는 경우에 문제된다. 이 경우 지급일 전에 퇴직한 근로자는 상여금 지급 청구권을 상실하게 되는지가 다투어지고 있다.

90) 水町勇一郎, 「詳解労働法」, p.590.

91) 水町勇一郎, 「詳解労働法」, p.590.

92) 日本 最高裁判所 平成 30.6.1. 民集 72卷 2号 p.202.



일본의 판례 중에는 지급일 재직 요건도 합리성을 가지고 있으며, 지급일 전에 퇴직한 근로자에게는 상여금 청구권이 발생하지 않는다고 한 사례가 있다.⁹³⁾ 다만, 상여금이 당초 예정보다 늦게 지급되고, 그 기간 중에 퇴직한 근로자에 대하여 지급일 재직 요건의 적용을 부정하고 상여금 지급 청구를 인용한 판례, 근로자측에 귀책사유가 없는 퇴직(정리해고)에 의해 지급일에 재직할 수 없게 된 근로자의 상여금 청구에 대하여 지급일 재직 요건 조항이 공서(公序) 위반으로 무효라고 인정한 판례가 있다. 일본의 학설에서는 정년퇴직이나 정리해고 등 회사측 사정으로 퇴직한 근로자로서 퇴직시기를 선택할 수 없는 경우에는 지급일 재직 요건에 의해 상여금을 지급하지 않는 것은 허용되지 않는다고 하는 견해가 유력하다.⁹⁴⁾ 이 경우에는 지급일 재직 요건은 공서 위반으로 무효라고 해석한다.

이와 관련하여 상여금의 구체적인 취지·목적에 비추어 개별적·구체적으로 판단해야 한다는 견해가 있다. 예를 들어 장래 종업원들의 근로장려를 촉진하기 위하여 과거의 근무성적 등에 관계없이 전원에게 일정액을 지급하는 근로장려적 성격이 강한 상여금에 대해서는 지급일 재직 요건이 회사에 계속해서 취업하고 있는 종업원에게 지급범위를 한정할 목적으로 정해진 것이므로 합리적이라고 해석할 수 있다. 그러나 회사의 성과업적과 근로자의 과거 일정기간 근무성적을 고려하여 지급액이 결정되는 경우는 임금후불적 성격과 이익배분적 성격이 혼합된 상여금이므로 상여금의 산정 기초 기간에 취업하여 기업업적(이익획득)에 공헌하였음에도 불구하고 지급일에 재직하지 않았다는 사실만으로 상여금을 지급하지 않는 것은 당해 상여금제도의 취지·목적에 비추어 합리성을 결여하였다고 보는 견해도 있다.⁹⁵⁾

반면에 상여금은 통상의 임금과 달리 사용자의 지급 결정과 노사자치에 의하여 비로소 구체적으로 발생하는 금품이라는 성격을 가지기 때문에 지급요건을 어떻게 정하는가는 당사자의 자유라고 할 수 있다. 또한 상여금은 임금의 후불적 성격뿐만 아니라 기업의 이익배분, 과거 공헌에 대한 공로보상, 장래 계속 근무에 대한 기대와 장려, 생활비 보전이라는 다양한 성격을 가지고 있으므로, 지급일 재직 요건이

93) 日本 最高裁判所 昭和 57.10.7 集民 137号 p.297

94) 佐々木宗啓/伊藤由紀子, 「労働関係訴訟の實務 I」, 2021, p.47

95) 水町勇一郎, 「詳解労働法」, p.593.



마련된 상여금은 소정의 전체 기간을 계속근무한데 대한 보상뿐만 아니라 장래의 기대와 계속근무의 장려를 중시한 것으로 인정될 수 있으므로 지급일 재직 요건은 실질적으로 노동기준법 제24조에 위반하지 않고 공서(公序)에도 반하지 않는다고 하는 견해도 있다.⁹⁶⁾

다만, 상여금이 임금후불적 성격을 가지고 있다는 점이 부정될 수 없다면 지급일 재직 요건을 일률적으로 유효하다고 보기는 어려운 측면도 있다. 그 때문에 정년퇴직자나 해고된 근로자 등 스스로 퇴직일을 선택할 수 없는 근로자에 대해서는 합리성이 없어 무효가 된다면, 임금부분과 장려부분을 구분하여 임금부분의 지급에 대해서는 지급일 재직 요건을 배제하고 일할(日割) 계산하는 것이 유효하다고 하는 견해도 있다.⁹⁷⁾

원칙적으로 임금의 발생요건을 어떻게 정할지는 당사자의 자유라는 전제에서 검토하면 지급일 재직 요건은 개별 계약의 해석 문제라고 할 수 있다. 다만, 형식은 상여금이지만 그 실질은 사용자의 결정이나 노사의 별도 합의를 필요로 하지 않는 정기상여금에 대하여 통상의 상여금(보너스)에 해당하는 것을 제외하고 지급일 재직 요건을 인정하는 것은 신중한 고려가 필요하다고 본다.

Ⅲ. 그 밖의 참고 사례

1. ILO 협약상 임금의 정의

ILO 제95호 협약 제1조는 “임금”이란 “그 명칭이나 계산방법을 불문하고 금전의 형태로 표현될 수 있고 상호간의 계약 또는 국가의 법이나 법률 등으로 정해지며 고용계약에 의하여 제공되었거나 또는 제공될 근로자의 근로 또는 서비스에 대하여

96) 佐々木宗啓/伊藤由紀子, 「労働関係訴訟の實務 I」, p.47; 東京地判 昭和 63.6.27 勞經速 1334号 p.3

97) 菅野和夫, 「労働法」, p.439, 土田道夫, 「労働契約法」, p.276



지급될 수 있는 보수 또는 수입”을 의미하는 것이라고 정의하고 있다.

ILO 제95호 협약이 임금의 정의규정을 둔 이유는 임금 개념을 어떤 국가의 법체제 내에서 특정 금품의 임금성을 판단하기 위한 기준을 제시하고자 하는 것이 아니라, 근로에 대한 보수로서 가능한 모든 다양한 형태와 구성요소들을 포괄하는 통칭적인 의미로서 사용하고자 한 것으로 보인다.⁹⁸⁾ 이 협약의 적용과 관련하여 제시된 전문가위원회의 의견 가운데 주목할 만한 것은, 임금의 총액에 영향을 미치지 않으면서 임금의 개념에서 벗어나는 복지혜택이나 다양한 수당 등을 도입하는 이른바 비임금화(desalarization) 정책의 문제점에 관한 것이다. 즉, 전문가위원회는 비임금화 정책으로 임금에 포함되지 않는 급여의 증가 자체는 사실상 제95호 협약의 취지에 위반되는 것은 아니지만, 이러한 비임금화 정책이 임금제도를 통해 보호되는(예를 들어 임금체불로부터의 보호 등) 급여액 자체를 줄여 근로자에게 사실상 경제적 불이익이 발생할 수 있다는 점을 지적한다.⁹⁹⁾

이에 따라 ILO는 비임금화 정책을 사용하고 있는 국가의 정부에 대하여 해당 국가의 법제 하에서 비임금적 성격을 띠는 수당이 제95호 협약을 적용함에 있어서 임금에 관한 법적 보호의 범위에 포섭될 수 있도록 하는 조치를 행해줄 것을 요구하였다.¹⁰⁰⁾ 즉, 비임금적 수당을 인정하지 않고 이를 모두 ‘임금’이라고 정의하라는 것이 아니라 근로자에게 지급되는 비임금적 수당이라도 임금과 마찬가지로 보호받을 수 있도록 하라는 것이다.

2. 미국¹⁰¹⁾

미국의 경우 연방법인 공정근로기준법에 임금의 정의는 규정되어 있지 않고, 일

98) ILO, *Protection of Wages*, 2003, p.19.

99) ILO, 위의 책, p.25.

100) ILO, 위의 책, p.26.

101) 신동윤/성대규, “경영성과급의 임금성 판단기준에 관한 고찰 - 미국법과의 비교·검토를 중심으로 -”, 『사회법연구』, 제46호, 2022, 375면 이하.



부 주법에서 예외적으로 정의규정을 두고 있다. 그에 따르면 임금은 근로자가 제공한 근로나 서비스에 대하여 시간, 업무, 작업량, 수수료 또는 그 밖의 계산방법으로 정해지는 것으로서, 근로자가 지급받을 것이라는 합리적인 기대를 가지고 있는 모든 임의적이지 않은 대가라고 한다.¹⁰²⁾ 이러한 정의는 임금을 매우 폭넓게 이해하는데, 질병수당(sick pay), 휴가수당(vacation pay), 해고수당(severance pay), 연장근로수당(overtime pay), 수수료, 상여금 및 그 밖에 근로자와 사용자 간에 지급하기로 약정된 금액과 함께 사용자가 이에 대한 지급방침이나 관행을 가지고 있는 경우로서 의료, 보건, 병원, 복지, 연금 등에 대한 지급과 같이 근로자의 복지를 위한 근로자 또는 기금에 대한 지급까지도 모두 임금에 포함된다.¹⁰³⁾ 그렇지만 수수료(Commissions), 보너스(Bonuses), 인센티브(Incentives), 이익배분(Profit Sharing) 같은 명칭에도 불구하고 특정 금품이 일반급(Regular Rate of Pay)에 포함되는지 여부에 대해서는 여전히 판단이 필요하다. 일반급은 초과근로수당(Overtime Pay) 등의 산정기초가 되기 때문이다.¹⁰⁴⁾ 즉, 미국에서도 임금 자체의 개념은 넓게 이해하되, 특정 수당의 지급을 위한 기준임금 산정에 필요한 임금의 범위는 제한될 수 있다.

한편, 균등임금법(The Equal Pay Act)은 임금(Wage)의 정의를 규정하고 있는데, 임금은 일반적으로 고용상의 보수로서 근로자에게 지급되거나 근로자를 위하여 지급되는 모든 급여를 포함한다. 즉, 지급 시기에 관계없이, 정기적으로 지급하든 나중에 지급하든, 임금, 봉급, 이익배분, 비용계정, 월별 최저급여, 보너스, 유니폼 세탁수당, 호텔숙박비용, 회사차량 사용료, 가솔린 수당, 기타 명칭에 관계없이 모든 형태의 보상을 포함하고 있다. 추가로 지급하는 부가적인 혜택(Fringe benefits)도 고용상 보수로서 간주됨을 알 수 있다. 따라서 균등임금법상 임금은 공정근로기준법 제3조(m)에 따라 최저임금에 포함되지 않는 급여가 포함될 수 있다는 점에서 광

102) ILO, 위의 책, pp.20-21.

103) ILO, 위의 책, p.21. 특히 캘리포니아 주 노동법(Labor Code)에 따르면, 임금은 어떤 형태의 근로자이든 간에 해당 근로자에 의해 수행된 노동에 대한 모든 금액을 포함하고 그 모든 금액은 확정되어 있거나 시간, 업무, 작업량, 수수료 또는 기타 계산 방법에 따라 정해지는 것을 불문한다. 위의 신동윤/성대규, “경영성과급의 임금성 판단기준에 관한 고찰”, 379면.

104) 신동윤/성대규, “경영성과급의 임금성 판단기준에 관한 고찰”, 377면.



의의 임금 개념을 사용하고 있음을 알 수 있다. 이와 같이 미국에서는 각각의 연방 법률에 따라 임금의 정의나 범위 등이 다를 수 있으나, 공정근로기준법상 임금의 범위는 균등임금법상 임금의 정의 및 범위와 달리 초과근로수당의 산정기초가 되는 일반급으로 한정하고 있음을 알 수 있다.¹⁰⁵⁾

그중에서 미국에서는 특히 보너스가 일반급에 포함되는지 여부에 대하여 논란이 있다. 보너스는 수수료(Commission), 인센티브(Incentives) 등 명칭 여하에 관계없이 근로자가 받는 정기적 소득에 부가하여 지급되는 급여인데, 공정근로기준법에서는 일반급에서 제외하고 있다. 이 경우 일반급에 포함되지 않는 보너스를 통상 “재량적 보너스”(Discretionary Bonuses)라고 한다. 반대로 일반급에 포함되는 보너스를 “비재량적 보너스”(Non-discretionary Bonuses)라고 부른다. 일반급에서 배제되는 재량적 보너스는 다음과 같은 3가지 요건을 모두 충족해야 한다. 첫째, 사용자는 보너스 지급 여부를 결정하는 단독 재량권을 지급기간 종료일 또는 그 직전까지 가지고 있을 것, 둘째, 근로자에게 정기적으로 지급될 것이라고 예상할 수 있는 합의(계약)에 따라 보너스가 지급되지 않을 것 등이다. 이에 반하여 비재량적 보너스는 재량적 보너스의 법적 요건을 충족하지 못한 보너스로서 근로자가 사전 계약, 합의 또는 약속에 따라 그 지급을 예상할 수 있는 것이다. 이와 같이 근로자들이 보너스를 받는 것이 예측 가능하고 그 결과를 기대할 수 있기 때문에 임의적인 것이 아니라고 할 수 있다. 비재량적 보너스에는 미리 정해진 지표에 따라 개인 또는 단체의 생산성을 보상하는 것, 업무의 질과 정확성을 보상하기 위한 것, 효율적 근무를 유도하기 위해 근로자에게 사전에 공표된 것과 그 밖에도 출석 보너스, 안전 사고가 없는 일수에 따라 지급되는 안전보너스 등이 포함된다. 따라서 사용자는 보너스의 성격과 목적을 명확히 설명하는 자료를 작성할 필요가 있으며, 이를 통해 해당 보너스가 일반급에 포함되는지에 대한 논란을 불식시킬 수 있다고 한다.¹⁰⁶⁾

3. 프랑스

105) 신동윤/성대규, “경영성과급의 임금성 판단기준에 관한 고찰”, 378면 이하.

106) 신동윤/성대규, “경영성과급의 임금성 판단기준에 관한 고찰”, 385면 이하.



프랑스에서는 임금에 관한 일반적인 정의규정은 없다. 다만 기본급과 함께 지급되는 상여금이나 각종 수당 또는 은혜적 급여 등에 대해서는 개별 판례를 통해 임금성이 판단되고 있다.

먼저 상여금이나 각종 수당 등에 대하여 프랑스 법원은 “근로계약에 따라 근로자에게 지급하기로 약정된 모든 급여는, 실비변상의 경우를 제외하고 임금에 해당된다”고 판시하고 있다.¹⁰⁷⁾ 이러한 원칙에 따라 교통수당이나 여비 또는 주택수당 등 실비변상금품은 임금에 해당하지 않게 되고, 반면에 인센티브나 생산수당, 원자재 절약수당, 우수품질수당, 야간근로수당과 같이 근로 제공시 특별한 노무환경이나 조건으로 인하여 발생한 수당, 위험수당, 혹한기 또는 혹서기 수당 그리고 그 밖에 장기근속수당이나 정근수당 등은 임금으로 간주된다.¹⁰⁸⁾

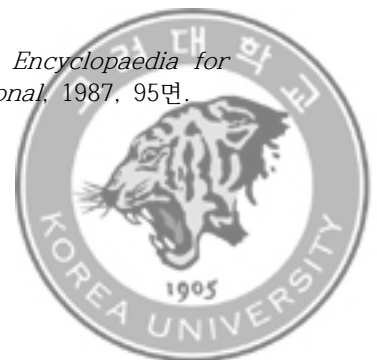
프랑스에서는 은혜적 급여의 임금성 여부가 주로 문제시되는데, 이에 대해서는 그 급여가 순수하게 사용자의 임의적 ‘선물’로 주어진 것인지 아니면 임금을 보전하는 하나의 수단으로 주어진 것인지에 따라 판단되고 있다. 어떤 경우에 급여가 순수한 은혜적 급여인지에 대하여, “호의적이면서 미리 정해지지 않은 것으로서 근로자가 정기적인 급여의 요구를 할 수 없는 경우”라고 하고 있다.¹⁰⁹⁾ 이러한 은혜적 급여에 대해서는 임금에 대하여 제공되는 법적 보호가 행해지지 않는다. 즉 임금으로 인정되지 않는다. 그런데 프랑스에서도 이러한 은혜적 급여의 비중이 점차 커짐에 따라 이를 법적 보호 대상에 포함하도록 하는 흐름이 있는 것으로 보인다. 다만, 프랑스에서도 우리나라와 마찬가지로 어떤 급여가 순수한 은혜적 급여이냐 아니냐를 판단하는 것은 무척이나 어려울 수밖에 없을 것이다. 프랑스 법원은 대체로 다음과 같은 두 요건에 따라 은혜적 급여의 임금성을 판단하고 있는 것으로 보인다.

은혜적 급여 해당성이 논란이 되는 급여가 ① 넓은 의미에서 노사 간 계약적 성

107) Michel Despax and Jacques Rojot, *"France", International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Kluwer Law International, 1987, 95면.*

108) Michel Despax and Jacques Rojot, 위의 책, p.95.

109) Michel Despax and Jacques Rojot, 위의 책, p.95.



질을 가지는 합의(즉, 단체협약, 고용계약 등에 의한 규정, 관습 또는 노동관행 등)로부터 발생하는 것이고, ② 그 계약이 급여의 이행에 강제력을 부여하고 있다면, 그것은 단순한 은혜적 급여가 아니라 임금의 성질을 가진 것으로 인정하고 있다. 다만 이러한 경우에 이 두 요건에 대한 증명책임은 근로자가 부담한다. 예를 들어 근로자는 특정 금품의 지급에 대한 관습이 해당 사업장에 형성되었다는 사실(예를 들어 은혜적 급여가 수년간 정기적으로 지급되어 왔다는 사실), 일률적이라는 사실(예를 들어 은혜적 급여가 해당 사업장에서 일하는 모든 근로자 또는 일정한 조건을 충족하고 있는 모든 근로자에게 관행적으로 지급되어 왔다는 사실), 고정적이라는 사실(예를 들어 은혜적 급여가 정률·정량 등으로 정해져 있다는 사실) 등을 증명해야 한다.¹¹⁰⁾

IV. 시사점

사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 임금에 해당하려면 근로의 대가이어야 한다. 근로의 대가에 해당하려면 해당 금품이 근로제공과 관련된 금품이어야 한다. 근로제공과의 직접적 관련성이 결여되어 있거나 충분하지 않은 경우라도 사용자는 근로자와 합의를 통해 그 지급의무를 부담하게 된다. 계속적·정기적으로 지급되는 통상적인 임금에 더하여 추가로 지급되는 이러한 급여를 독일에서는 특별급여 또는 부가급여라고 한다. 일본에서도 그 지급여부 또는 지급액이 ‘기업업적(경영성과)에 연동되는 상여금’이 존재하는데 이는 우리나라의 경영성과급과 유사한 형태라고 할 수 있다. 다만 일본의 업적연동형 상여금은 기업의 업적(경영성과)에 따라 상여금의 액수가 증감되면서 동시에 각 근로자의 근무성적 등을 평가하여 배분하고 있다는 점에서 근로제공과 어느 정도 관련성이 인정된다. 프랑스에서는 이러한 범주의 급여를 은혜적 급여라고 부르고 그 성격이 문제되고 있다. 그런데 이와 같은 급여의 비중이 최근 점점 증가하는 추세라고 할 수 있다. 기업의 인건비가 고정급에서 점

110) Michel Despax and Jacques Rojot, 위의 책, p.95.



차 변동급으로 전환되거나 비임금화 경향이 확산되고 있다는 말이다. ILO는 이러한 금품의 비중이 증가함에 따라 법적 보호대상인 임금의 비율이 축소되는 결과를 우려하고 그 대책으로 임금이 아닌 금품에 대해서도 보호조치를 강구할 것을 각국 정부에 요구하고 있다. 일본에서는 평균임금 산정 기준임금에 3개월을 초과하는 기간에 대해 지급되는 상여금은 제외하고 있다. 독일에서도 보너스와 같은 특별급여에 대해서는 특별수당의 산정기초임금에서 제외할 수 있는 가능성을 열어두고 있다. 이와 같이 기업의 경영실적을 기반으로 종업원에게 배당하는 금품인 경영성과급 또는 집단성과급을 평균임금 산정에서 제외한다면 이를 광의의 임금으로 이해하고 보호대상으로 삼는 것은 얼마든지 가능할 것이다. 그런데 현행 근로기준법은 임금과 평균임금의 개념을 사실상 일체적으로 이해함으로써 사용자가 지급하는 금품의 성격을 복잡하게 만드는 부작용이 발생하고 있는 것이다.

제4절 임금의 형태와 법적 규제

I. 임금의 형태와 법적 규제의 방향

1. 임금의 형태와 그 전개과정

임금은 보수, 급여, 급료, 봉급, 노임, 수당 등 다양한 이름으로 불리고 있으며, 다양한 형태를 가지고 있다. 임금이 어떤 기간을 단위로 하여 결정되는지에 따라 시간급, 일급, 월급, 연봉 등의 형태가 있다. 이와 같은 기간과 상관없이 일회적으로 보너스나 성과급, 퇴직금 등 특별한 목적으로 지급되는 일시금이 있다.

근로자에게 구체적으로 지급되는 임금의 구성항목이 기재된 임금명세서(임금내



역)¹¹¹⁾을 보면, 월급의 경우 대체로 기본급과 제수당(직책수당, 직무수당, 자격수당 등 업무관련 수당과 가족수당, 주택수당, 교통비, 식비 등 생활지원적 수당) 그리고 정기상여금 등이 소정근로시간에 대응하는 임금항목(소정 내 임금)으로 제시되어 있고, 연장근로나 휴일근로 또는 야간근로와 같이 특별한 근무에 대하여 지급되는 소정 외 임금으로 구성된 항목이 있다.

기본급은 그 금액의 결정요인이라는 관점에서 보면 ① 실적·성과 등 업무의 결과를 근거로 결정되는 이른바 개수급(성과급)과, ② 시간급, 일급, 월급, 연봉 등 시간을 단위로 하여 결정되는 정액급으로 크게 구별될 수 있다. 과거 산업국가들은 대체로 제조업의 생산직 근로자(직공)에 대해서는 ①의 방식이, 사무관리직(직원)의 경우에는 ②의 방식이 널리 사용되었으나 점차 직공과 직원의 구별 및 차별이 없어지면서 시간을 단위로 하는 ②의 방식으로 통일되었다. 물론 여전히 영업사원 등에 대해서와 같이 도급제 방식의 임금결정 방식을 유지하고 있는 사례도 있는데, 근로기준법은 이들을 도급근로자로 표현하면서 “사용자는 도급이나 그 밖에 이에 준하는 제도로 사용하는 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하여야 한다.”라고 규정하고 있다(근기법 제47조).

시간 단위의 정액급을 기본급으로 정하고 있는 경우라 하더라도 단위시간에 해당하는 금액을 결정하는 요소는 다양할 수 있다. 그 중에서 직무내용을 주된 요소로 결정하는 임금형태를 ‘직무급’, 연령이나 근속기간 등 근로자의 속성에 의하여 결정되는 임금형태를 ‘연공급(속인급)’, 근로자의 직무수행능력에 의하여 결정하는 임금형태를 ‘직능급’ 등으로 나누고 있다.¹¹²⁾

우리나라는 전통적으로 근로자의 직급, 근속기간 등을 기준으로 결정하는 연공급 방식의 기본급이 일반적이었으나, 최근에는 직무급제로 변경해야 한다는 주장이 확산되고 있다(제1장 제1절 참고).

111) 근로기준법 제48조 제2항: 사용자는 임금을 지급하는 때에는 근로자에게 임금의 구성 항목·계산방법, 제43조 제1항 단서에 따라 임금의 일부를 공제한 경우의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항을 적은 임금명세서를 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조 제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 교부하여야 한다(시행일 2021.11.19.).

112) 노사정위원회, 「2016 임금보고서」, 2016, 47면 이하 참고.



우리나라의 임금체계에 큰 영향을 미친 일본에서도 2차 세계대전 직후 일찍이 각 근로자의 직무내용과 범위가 불명확하고, 직무 간 이동이 빈번하게 행해지는 당시 인력운영 방식을 고려할 때 진정한 의미의 직무급은 정착되기 어렵다고 보았고, 그 대신에 근로자의 생활안정을 주된 목적으로 하는 연공급(숙인급) 방식의 임금제도가 널리 보급되었다.¹¹³⁾ 그러나 산업구조가 고도화되고 세계적 차원에서 기업간 경쟁 관계가 격화되면서 1960년대부터 일본의 기업들도 전통적인 연공급보다는 동일노동 동일임금 원칙, 직무급제로의 전환이라는 슬로건을 내걸고 임금체계의 근대화를 추진하기 시작하였다.¹¹⁴⁾ 그렇지만 대표적인 전략목표인 직무급제는 당시 일본에서는 정착되기 어려웠다. 우선 직무급제는 장기고용관행 하에서 빈번하게 행해지고 있는 배치전환(인사이동)의 관행과 조화되기 어려웠다. 배치전환으로 임금이 내려갈 경우 근로자의 반발로 원활한 인력배치가 어렵기 때문이다. 또한 직무와 자격에 따른 임금결정이라는 사회적 기반이 당시 일본에서는 아직 일반화되지 않았다. 그후 1970년대 들어 능력주의 임금제도라는 이름 하에 직무수행능력을 평가하여 근로자에게 자격을 부여하고 이를 기초로 임금을 결정하는 이른바 직능급(직능자격제도)이 도입되었다. 직업수행능력의 평가는 연공(근속)과 실적(인사평가)를 결합시키는 방식이 활용되었다.

이에 대해 1990년대 이후 장기적인 불황(임금인상요인의 정체), 세계적 경쟁체제의 격화(비용절감 압력의 증대), 중고령 근로자의 증가(인건비 증가로 연공형 임금제도 유지 곤란), 업무성격의 변화(전문성, 창의성의 중시 및 그에 걸맞는 보상의 필요성) 등을 배경으로 연공적 성격을 가진 직능급 제도를 대신하여 임금의 성과주의화가 촉진되었다. 구체적으로는 관리직과 전문직에 대해서는 매년 평가(목표달성도)를 기반으로 기본급(연봉)을 결정하는 연봉제를 도입하고, 일반 직원에 대해서는 근로자가 종사하는 직무에 대해 책임의 내용 및 비중을 등급화하고 그 등급 범위 중에서 각년도의 공헌도(성과)를 가미하여 기본급(직무급)을 결정하는 직무등급제와, 근로자가 담당하는 역할을 그 중요도에 따라 등급화하여 그 등급범위 중에 각 년도 목표달성도의 평가를 고려하여 기본급(역할급)을 결정하는 역할등급제도 등을 도입

113) 菅野和夫, 「勞働法」, p.411.

114) 이하 水町勇一郎, 「詳解勞働法」, p.583 참고.



하는 경향이 확산되었다. 이와 같은 임금의 직무급화 및 성과주의화, 다시 말해 직무와 성과중심의 임금체계가 확산되면서 임금내용의 합리성과 평가의 공정성에 대한 법적 쟁점이 증가하게 되었다(이에 대해서는 다음 제4장에서 자세히 다룬다).

이와 같은 일본의 임금체계 변화는 우리나라에서도 직무급, 역할급으로의 임금체계 개편론에 큰 영향을 미치고 있다. 다만, 우리나라에서는 이러한 임금체계 개편이 적용되는 정규직 일반직원과 달리 종전의 임금결정방식이 유지되는 비정규직 근로자에 대해서는 여전히 임금은 시간급으로 계산·지급되고 있으며 그마저도 정규직과 격차가 확대되면서 차별 및 이중구조의 문제가 부작용으로 나타나고 있다는 특징이 있다.

2. 임금형태에 대한 법적 규제의 방향

임금을 어떤 형태로 지급하고 그 금액을 계산할지는 기본적으로 당사자가 자유롭게 결정할 수 있는 영역에 해당하고, 법률상 규제에 위반되지 않는 한 노사자치 및 계약자유의 원칙에 맡겨진다. 예를 들어 시간급, 일급, 월급, 연봉 등 어떤 기간을 결정 단위로 하는 임금제도를 선택할 것인지는 당사자의 자유이다. 그러나 위에서 본 프랑스의 사례에서는 매월의 일수에 관계없이 매월 동일금액의 임금지급을 보장하여 근로자의 경제생활의 안정을 도모하기 위하여 월급제가 법률에 규정되어 있다. 우리나라에서는 이와 같은 규제가 없지만, 매월 1회 이상 정기지급의 원칙이 존재한다.

또한 임금의 결정요인으로서 시간을 단위로 하는 정액급(시급, 일급, 월급, 연봉 등)으로 할 것인지 아니면 실적(성과) 등 업무결과를 기반으로 결정하는 실적급(성과급)을 채택할 것인지도 기본적으로 당사자의 자유에 맡겨져 있다. 다만, 실적급이라 하더라도 근로기준법은 도급제¹¹⁵⁾ 방식의 실적급을 채택하고 있는 근로자에 대

115) 근로기준법 제47조가 규정하고 있는 “도급 근로자”란 임금의 산정 방법의 하나일 뿐, 계약유형으로서의 도급계약을 의미하는 것이 아니다.



해서도 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하도록 규정하고 있다(제47조). 도급제 방식의 임금체계에서는 고객의 부족이나 경기 상황 등과 같이 근로자의 귀책사유 없이도 실수입이 감소할 가능성이 있기 때문에 근로자 보호를 위해 근로시간을 고려한 최소한의 급여(예를 들어 최저임금)를 고정급으로 보장하도록 하고 있는 것이다. 또한 연장근로나 휴일근로 등이 발생한 경우에는 근로시간수에 상응한 할증임금을 지급하도록 규정하고 있다. 이와 같이 실적급이라 하더라도 법률규정에 의하여 시간을 단위로 한 급여가 지급될 수 있다.

II. 평균임금의 의의와 임금 개념의 관계

1. 평균임금의 개념과 쟁점

근로기준법은 제2조 제1항 제6호에서 평균임금을 “산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 지급된 임금 총액을 그 기간의 총 일수로 나눈 금액”으로 정의하고 있다. 평균임금은 「근로자퇴직급여 보장법」 제8조, 제13조에 따라 퇴직금과 확정급여형 퇴직연금, 근로기준법 제46조에 따라 휴업수당, 동법 제60조 제5항에 따라 연차휴가수당, 근로기준법 제79조, 제79조, 제80조, 제82조, 제83조, 제84조에 따라 휴업·장해·유족보상과 장례비, 일시보상, 산업재해보상보험법 제36조, 제52조, 제57조, 제62조, 제67조, 제71조, 제74조에 따라 휴업·장해·유족급여, 상해보상연금, 장의비, 직업훈련수당 등 보험급여 등의 지급기준이 된다.

이와 같이 평균임금은 법정수당을 산출하기 위한 기준임금이며, 평균임금을 통하여 법정수당을 지급하는 기본 취지는 근로자의 통상적인 생활을 보장하려는 데 있다. 그러므로 평균임금은 근로자의 통상적인 생활임금을 사실대로 산정하는 것을 기본원리로 한다.¹¹⁶⁾

116) 노동법실무연구회(최은배), 「근로기준법 주해 I」, 278면.



법령에 따라 평균임금을 산정하였다 하더라도¹¹⁷⁾ 그 산정기간 중에 특수하고 우연한 사정으로 임금액의 변동이 발생하였고 이를 포함하여 산정된 평균임금이 근로자의 전체 근로기간, 임금액 변동 기간, 임금액 변동의 정도 등을 종합적으로 평가할 때 통상의 경우보다 현저하게 많거나 적게 산정되는 등 예외적인 상황으로 인정된다면 위에서 말한 평균임금의 기본 취지와 부합하지 아니하는 결과가 발생할 수 있다. 이 점을 고려하여 근로기준법 시행령 제2조 제1항은 근로자의 책임 없는 사유로 임금액 등에 변동이 큰 기간에 대해서는 근로자가 손해를 보지 않도록 해당 기간과 금액을 임금의 총액에서 빼도록 하고 있다. 또한 동법 시행령 제4조는 법령에 따라 평균임금을 산정할 수 없는 경우에는 고용노동부장관이 정하는 바에 따르도록 정하고 있는데, 아직 관련 규정이 마련되지 않아 법원이 산정기간을 달리 정하는 등 사실관계에 따라 판단하고 있다.

위와 같은 법령을 적용하면서 대법원도 “법령에 따라 평균임금을 산정하였다 하더라도 평균임금 산정 사유가 발생한 시점에 특수하고 우연한 사정으로 임금액의 변동이 발생하였고, 그로 인해 산정된 평균임금이 근로자의 전체 근로기간, 임금액 변동 기간, 임금액 변동의 정도 등을 종합적으로 평가할 때 통상의 경우보다 현저하게 많거나 적게 산정된 것으로 예외적인 상황으로 인정된다면 근로기준법상 평균임금의 취지와 맞지 않으므로 근로자의 통상적인 생활임금을 반영하여 산정해야 한다.”고 하여, 통상적 생활임금 산정이라는 평균임금의 취지를 확인하고 있다.¹¹⁸⁾

한편, 대법원이 다루는 임금성에 관한 판결의 상당수는 퇴직금청구소송과 같이 평균임금 산입 범위가 문제가 된 사건이라고 할 수 있다. 그런데 대법원은 사용자가 지급하는 특정 금품이 평균임금 산입 범위에 포함되는 금품인지 여부를 판단함에 있어서 ‘근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 사용자에게 그 지급의무가 지워져 있고, 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성이 있어야 한다’고 판시하고 있다. 즉, 임금 개념의 해석을 통해 평균임금의 산입 범위를 결정하는 법해석을 한 것으

117) 근로기준법 제2조 제1항 제6호에 따라 산출된 금액이 통상임금보다 적으면 그 통상임금액을 평균임금으로 한다(근기법 제2조 제2항).

118) 대법원 2009.5.28. 선고 2006다17287 판결; 대법원 2015.6.11. 선고 2014다87496 판결 등 참조.



로 보인다.

그러나 근로기준법상 임금 개념은 평균임금 산입 범위와 관계없이 근로자에게 지급되는 금품 중 법령상 강행규정에 의하여 보호되어야 할 금품의 범위를 정한 것이고, 평균임금은 근로자의 통상적인 생활임금을 산출하기 위한 개념이라는 점에서 양자는 구별된다. 임금과 평균임금은 서로 다른 법개념임에도 불구하고 임금 개념의 해석을 통해 평균임금의 산입 범위를 정하고 있는 것이다. 이렇게 되면 임금 개념은 평균임금 산정을 위한 도구개념이 되고, 결과적으로 임금의 범위가 축소되는 문제가 생긴다. 이하에서 이러한 문제를 살펴보고 향후 나아갈 방향을 검토해본다.

2. 현행법상 임금과 평균임금의 관계

대법원은 평균임금이 아닌 “임금성만 문제 되는 사안”, 예를 들어 부당해고 시 임금상당액 지급, 쟁의행위 시 무노동·무임금 적용 등의 사건에서도 ‘계속성·정기성’을 판단지표로 삼고 있어 임금성 요건과 평균임금 요건을 별도로 구분하지 않는 태도를 취하고 있는 것으로 보인다.

예를 들어 대법원은 사용자의 부당한 해고처분이 무효이거나 취소된 때에는 그 기간 동안 해고된 근로자는 단절 없이 근로자 지위를 유지하고 있었던 것이고, 근로자가 그동안 근로 제공을 하지 못한 것은 사용자의 귀책사유로 인한 것이므로 해당 근로자는 민법 제538조 제1항에 따라 “계속 근로하였을 경우에 받을 수 있는 임금 전부의 지급”을 청구할 수 있다고 보았다. 그러나 여기서 근로자가 지급을 청구할 수 있는 임금에 대해 “근로기준법 제2조 제1항 제5호에서 규정하는 임금을 의미하므로, 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 일체의 금품으로써, 근로자에게 정기적·계속적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약이나 취업규칙, 근로계약 또는 노동관행 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 있다면 그 명칭에 관계없이 모두 포함한다고 보아야 한다.”¹¹⁹⁾ 라고 하여, 임금 전부를 지급해야 한다고 하면서

119) 대법원 2012.2.9 선고 2011다20034 판결; 대법원 2002.5.31 선고 2000다18127 판결.



도, 평균임금이 문제가 된 소송에서와 다를 바 없이 정기적·계속적 지급 요건을 제시하고 있어(정기적·계속적으로 지급하지 않더라도 임금일 수 있다) 임금성 요건과 평균임금 요건을 별도로 구별하지 않는 태도를 취하고 있다.

그 밖에 대법원은 쟁의행위 관련 사례에서도 “상여금이 단체협약에 의거하여 정해진 시기에 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다면 근로의 대가로써 임금에 해당하고, 쟁의행위 기간 중에는 임금 지급이 정지되는 것이 원칙이므로 쟁의행위로서 태업이 발생한 경우 사용자는 근로자들에게 그 태업시간에 상응하는 상여금을 지급할 의무가 없다”고 판시하기도 했다.¹²⁰⁾

이처럼 대법원은 임금 개념에서 근로의 대가를 “근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성이 있는 경우”로 좁게 해석하고, 이를 기초로 평균임금에 산입되는 임금의 범위를 판단하고 있다. 즉, 임금 개념과 평균임금의 개념을 별도로 구별하고 있지 않다. 그 결과 임금의 실체적 의미를 설명하는 임금 개념이 급여 산정을 위한 도구 개념인 평균임금의 영향을 받아 좁게 설정되는 문제가 발생한다. 다시 말해 근로자가 지급받는 전체 임금 중에서 평균임금의 산입에 포함되는 임금을 정하는 것이 아니라, 평균임금에 산입되어야 할 임금의 범위를 정하기 위해 평균임금의 특성을 반영하여 임금 개념을 해석하고 있는 것이다.

하지만 평균임금은 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 임금과 당연히 다른 개념이다. 임금은 근로의 대가라는 실체적 개념으로서 근로자가 받는 보수의 본질에 관한 개념인데 비하여 평균임금은 특정 사안에 대하여 지급되는 수당의 산정방식을 정한 것으로 양자는 서로 구별되는 개념이다. 두 개념 간 차이는 다음과 같은 점에서도 확인된다. i) 근로기준법 시행령 제2조 제2항에서 ‘임시로 지급된 임금 및 수당’ 등을 평균임금에서 제외한다고 규정하고 있는 점,¹²¹⁾¹²²⁾ ii) 통상적 생활임금 보장

120) 대법원 2013.11.28. 선고 2011다39946 판결.

121) 임금과 평균임금의 개념을 동일시하는 입장에서도 이 규정을 근거로 제시할 수 있으나, 오히려 임금성이 인정되는 임금 중에서 평균임금의 산정범위에 포함되지 않는 임금 항목이 있다는 점에서 양자의 차별성을 근거지우는 규정으로 보는 것이 타당하다고 생각된다.

122) 같은 내용의 규정을 두고 있는 일본의 경우에는 임시로 지급된 임금이란 임시적 또는 돌발적 사유에 기하여 지급된 임금으로, 일회적이거나 우연적인 사유로 지급된 임금을



이라는 평균임금 취지에 부합하지 않는 임금은 산출 시 배제한다는 점, iii) 특수하고 우연한 사정으로 통상의 경우보다 현저하게 많거나 적은 경우 평균임금의 취지를 반영하여 산정해야 한다는 점, iv) 부당하고 시 임금상당액 청구 등과 같이 평균임금이 문제되지 않고 임금성만 문제되는 사례¹²³⁾도 있다는 점 등만 보더라도 평균임금과 임금의 판단 요건은 구별될 수 있고, 임금과 평균임금은 서로 다른 개념이라고 할 수 있다.

평균임금이 문제되는 사례에서 각 사안마다 문제되는 임금이 평균임금에 산입되는 것이 타당한지, 감당할 수 있는지 현실적인 고려를 하면서 평균임금 개념 해석이 아닌 임금 개념 해석을 통해 그 범위를 조정하려다 보니, 임금의 개념이 축소될 수밖에 없다. 예를 들면, ‘정기적·계속적 지급’이나 ‘근로제공과 금품 지급 사이의 직접 또는 밀접한 관련성’ 등의 지표는 실체적 개념인 임금 자체에 대한 해석이라기보다, 통상의 생활임금 수준 산정을 위한 도구인 평균임금 개념에 대한 해석에 가깝다고 생각된다.

근로기준법상 평균임금의 정의에 따르면 평균임금은 근로자에게 실제로 지급된 임금의 총액을 의미하므로 근로기준법상 임금은 거의 모두 평균임금에 포함된다. 다만, 근로기준법 시행령 제2조 제2항에서는 임시로 지급된 임금 및 수당과 통화 이외의 것으로 지급된 임금에 대해서만 평균임금 산정 시 임금의 총액에 포함하지 않도록 규정하고 있을 뿐이다.

혹자는 이 규정에 근거하여, 임금의 의미를 먼저 해석하여 임금성이 인정되는 금품을 먼저 특정하고 평균임금의 도구적 기능을 활용해 3개월치만 정하면 된다고 생각할 수도 있다. 임금의 개념을 먼저 해석하고 평균임금에 포함되는 임금을 거기서 3개월치 취하는 것은 평균임금 산정으로서 별 문제가 없다고 할 수 있다.

말하거나, 지급조건은 미리 확정되어 있지만 그 지급사유의 발생이 불확정적이거나 특별히 희박하게 발생하는 경우를 말한다. 이에 관해서는 西谷民外 編(本久洋一), 「勞働基準法・勞働契約法」, p.48 참고. 일회적·우연적·돌발적 근로제공에 대하여 지급된 임금은 정기적·계속적 근로제공에 대한 대가와 구별되므로 평균임금의 요건과 임금의 요건을 구별하는 것은 기본적으로 타당하다.

123) 이 사례에서는 평균임금을 산정하여 그 지급액을 정하는 것이 아니라 해당 기간 중 근로를 제공했다면 지급해야 할 임금 전액을 지급해야 한다.



하지만 통상의 생활임금에 해당되는 임금만을 목적으로 임금의 개념을 해석하고 정의하면, 평균임금 산정에는 아무 문제가 없을지 모르나, 그 때문에 임금의 개념과 범위가 축소되어 근로기준법상 임금으로 인정되어 보호받을 수 있는 금품의 범위도 좁아지는 문제 등이 발생한다.

3. 검토

임금 개념은 평균임금 산입 범위와 관계없이 근로자 보호를 위하여 합리적으로 해석되어야 하므로 근로의 대가를 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성으로 좁게, 엄격하게 해석할 것은 아니다. 현행 근로기준법 제2조 제1항 제5호는 “근로의 대가”라고만 규정하고 있으므로 근로제공과 어느 정도 관련성이 있는 금품이라면 근로의 대가성을 인정하는 것이 법문과 근로자 보호라는 노동법의 목적에 부합한다고 본다.

근로기준법은 임금을 근로의 대가라고 정의하고 있는데, 이를 직접 또는 밀접한 관련성으로 한정적으로 해석하는 것은 근로의 대가의 의미를 법문보다 좁게 해석하는 것이다.

특정 금품이 평균임금에 산입되지 않더라도, 임금성이 인정된다면 근로기준법상 임금 관련 규정들의 보호(임금지급원칙의 적용, 소멸시효, 미지급임금에 대한 지연이자 적용, 도산 시 최우선변제대상 등)를 받을 수 있으므로 임금보호의 관점에서 근로자에게 유리하다. 또한 평균임금과의 개념적 차이를 두지 않고, 좁게 한정되었던 임금의 개념을 재정립하면서 평균임금과의 차이를 명확히 함으로써, 향후 새롭게 등장하거나 변화할 다양한 보수 형태나 지급방식 등에 대한 혼란 및 분쟁을 예방할 수 있으므로 임금과 평균임금의 개념을 구분하고, 근로제공과 포괄적 관련성이 있다면 임금으로 인정하여 노동법적 보호를 받을 수 있도록 하는 것이 근로자 보호의 취지에 부합할 것이다.



한편, 평균임금에 대해서는 근로자의 통상적 생활임금인지 여부를 기준으로 임금 개념에 비해 좀 더 엄격하게 판단하는 것이 노사의 이익균형성은 물론 근로자 간 형평성에도 부합한다고 본다. 평균임금의 산정이 근로자 간 형평성을 가지려면, 산입 대상 임금에 대한 판단기준이 어느 정도 객관성과 예측가능성을 가지고 있어야 할 것이다. 예를 들어, 우연적, 일회적 상황에서 발생한 금품 등을 모두 평균임금에 포함시킨다면 근로자 간 형평성에도 문제가 발생하고, 기업으로서도 우발채무로 인한 부담이 매우 커질 수 있다. 이로 인한 부작용은 기업 전체와 근로자에게도 미친다.

평균임금은 법정수당을 산출하기 위한 기준임금이며, 임금의 개념 본질에 충실한 제도라기보다는 그 취지에 따라 합리적 적용이 필요한 개념이다. 평균임금을 통하여 법정수당을 지급하는 기본 취지는 근로자의 통상적인 생활을 보장하려는 데 있다. 즉, 근로자의 통상적인 생활임금을 사실대로 산정하는 것이 평균임금의 기본원리라고 할 수 있다. 이와 같은 평균임금의 취지를 실현하려면 임금성을 가진 금품 중에서 산입 범위를 좀 더 세밀하게 설정하는 것이 필요하다고 판단된다.

근로기준법 시행령 제2조 제2항에서 이러한 취지를 반영하여 평균임금 산정 시 임시로 지급된 임금 및 수당과 통화 외의 것으로 지급된 임금을 포함하지 아니한다는 규정을 두고 있는 점(다만, 시행령 제2조 제2항이 평균임금과 임금을 구분하기 위한 취지로 규정된 조항이라고 보기는 어렵고 통상의 생활임금이라는 평균임금의 취지만을 반영한 조항이라고 할 수 있다)을 고려하면 임금성이 긍정되더라도 평균임금에는 산입하지 않는 것이 적합하다고 인정되는 임금이 있을 수 있다.

임금의 개념과 평균임금 산입 범위를 정하는 지표는 다르므로 분리가 필요한데, 대법원이 지금까지 임금의 개념요소로 활용한 지표는 사실은 평균임금의 산입 범위를 결정하는 기준이라고 해야 할 것이다. 왜냐하면 법원에서 다투어지고 있는 임금 관련 소송은 대부분 평균임금의 산정이 문제가 되는 소송이었기 때문에 법원으로서 당연히 평균임금을 어디까지 인정해야 할 것인지 현실적인 고려를 하지 않을 수 없었기 때문이다. 그에 따라 대법원은 임금 개념을 가지고 해당 목적에 맞는 범위를 설정하였던 것이다. 그 결과 대법원이 정립한 현재의 임금의 개념요소는 평균임



금에 산입되어야 할 임금의 개념요소와 비슷하게 전개되어 왔다.

그렇다면 평균임금이 통상적 생활임금으로서 작동하기 위하여 필요한 판단기준으로는 무엇이 있는지 검토할 필요가 있다. 가산수당과 같은 수당을 미리 산정할 수 있도록 하기 위한 사전적 개념인 통상임금과 달리 평균임금은 사후적 개념으로 근로자가 산정 사유 발생 전 3개월간 실제로 어느 정도의 임금수준을 가지고 일상적인 생활을 해왔는지가 중요하다. 이러한 관점에서 대법원이 임금의 개념요소로 제시한 계속적·정기적 지급, 근로제공과 밀접한 관련성 등의 판단기준은 평균임금의 통상적 생활임금을 파악하는데 적합한 개념요소라고 할 수 있다.

통상적으로 지급되어 근로자의 생활에 기반이 된 임금은 계속적·정기적으로 지급된 임금일 것이다. 또한 근로제공과 밀접한 관련 없이 우연적 요소에 의하여 지급된 임금도 근로자의 통상적 생활임금으로서 기능했다고 보기는 어려울 것이다.

그리고 변동성이 매우 큰 임금은 통상적 생활임금이라는 평균임금의 성격과 부합되기 어려우므로 평균임금에서 제외하는 것이 필요하다. 이 경우 특히 고점에서 근로자들이 퇴직함으로써 퇴직금 지급액을 높이려는 기회로 활용할 수 있으므로 기업으로서는 큰 재정적 부담이 리스크로 작용하고, 근로자들 사이에도 퇴직시점에 따라 평균임금액이 크게 차이가 발생할 경우 형평성을 상실할 수밖에 없다.

임금과 평균임금 문제를 풀기 위해 두 개념을 분리하여 재정립함으로써 임금의 범위가 축소되는 것을 방지하는 한편, 평균임금의 적정한 산입 범위를 정해야 할 것이다. 평균임금을 통상적 생활임금의 보장이라는 취지에 맞게 임금 개념과 분리하여 개념요소를 정립하면, 임금은 근로제공의 대가로 근로자에게 응당 지급되어야 할 금품으로서의 본래적 의미를 찾을 수 있게 될 것이다. 이는 임금법제의 재정립이라는 관점에서 매우 중요한 의미를 갖는다. 이렇게 함으로써 근로자보호라는 임금법제의 목적에 충실하고, 근로기준법상 임금의 정의에 규정된 법문언에도 충실한 해석이 될 뿐만 아니라 앞으로 전개될 새로운 노무제공형태에 따른 다양한 보상 방식에 대한 분쟁이 발생하였을 때도 신속하고 적절한 해결 방안을 도출할 수 있게 될 것이다.



이 두 개념을 분리하여 재정립하기 위해서는 먼저 입법을 통한 개선을 생각해 볼 수 있다. 예를 들어 일본의 경우처럼 법률로 3개월을 초과하여 지급되는 임금(상여금, 성과급)은 통상의 생활임금으로 보지 아니하여 평균임금에서 제외하는 방법 등을 생각해 볼 수 있을 것이다. 하지만 입법적 해결방법은 이해당사자들의 반발과 노동입법의 어려움을 고려할 때 가까운 시일 내에 실현되기는 어려워 보인다.

다음으로 법해석을 통해 이 문제를 해결하는 방안도 있다. 법원이 임금의 개념과 관련하여 근로제공과 어느 정도의 관련성만 인정되면 근로대가성을 인정함으로써 비교적 넓게 해석하고, 평균임금은 통상적 생활임금 보장이라는 취지를 고려하여 사안에 적합하게 합목적적으로 산입 범위를 결정해야 할 것이다. 근로의 대가라는 본질적 문제를 탐구하는 임금 개념과는 달리, 평균임금은 본래 산정을 위한 도구적 개념이므로 충분히 시도할 수 있는 방법이라고 생각한다. 대법원은 이미 택시 근로자의 초과운송수임금이 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 산입되는지 여부에 관한 판결에서 근로자의 통상적인 생활임금이라는 평균임금의 취지와 부합하지 않는다는 이유로 평균임금 산입 범위에서 제외하는 판단을 내린 바 있다.¹²⁴⁾

이 판결은 초과운송수임금이 근로의 대가임은 분명하지만 모든 근로의 대가가 평균임금 산입 범위에 포함되는 것이 아니라는 점을 보여주고 있다. 즉, 대법원이 평균임금에는 포함되지 않지만 임금성이 인정되는 경우가 있음을 판시하고 있어 의미가 있다. 이는 법원이 법해석을 통해 임금성 판단 요건과 평균임금 판단요건을 구별할 수 있다는 점을 보여 준다.

경영성과급과 같이 대외적 경영환경 변화에 의하여 그 지급 여부나 지급액에 대한 예측이 쉽지 않은 성과급에 대해 임금으로 인정할 수 있는지, 그리고 나아가 임금으로 인정되더라도 평균임금 산입 대상으로 볼 수 있는지 판단하는데도 이 판결이 참고가 될 수 있다고 본다.

앞으로 노무제공형태와 일하는 방식이 더욱 다양화 되고 있는 상황에서 근로대가성이 명확히 판단되기 어려운 사례가 더욱 증가할 것으로 예상된다. 일하는 방식

124) 대법원 2007.9.20. 선고 2007다32993·33002 판결.



의 다양성은 필연적으로 당사자 간의 보상 방식의 다양화로 귀결될 수밖에 없으므로 근로제공에 대한 반대급부의 범위와 내용에 대한 당사자의 사전적·명시적 합의가 있다면 이를 존중하여 근로대가성 판단에 있어서 당사자의 의사(합의)를 보충적으로 고려해 줄 수 있을 것으로 생각된다.

4. 토론: 평균임금 산입 범위에 관한 최근 쟁점

(1) 네트제 임금계약에서 평균임금의 범위

가. 네트제 근로계약과 실태

네트제 근로계약이란 근로자에게 부과되는 근로소득세, 사회보험료 등 제세공과금을 사용자가 부담하기로 하고, 그에 따라 근로자는 위 제세공과금의 액수와 관계없이 약정한 실수령액을 급여로 받기로 하는 계약방식을 말한다. 실무상으로는 네트제(Net)로 부른다.¹²⁵⁾ 네트(Net)제 계약에서는 근로자가 실수령할 금액만이 근로계약시 미리 정하고 나머지 세금이나 4대 보험료는 사용자가 부담하는 임금체계를 말한다. 네트제 임금계약은 주로 의료업계에서 많이 사용되는 관행인데, 세금은 병원이 대신 내주고, 의사는 그 나머지 금액을 받는다는 의미이다. 일반적인 연봉계약(Gross Pay)이라면, 세전금액기준으로 계약하고, 그 중 세금을 빼면 실수령액은 계약서에 적힌 급여보다 적어질수 있지만, 네트제로 계약하면 계약서상 적힌 금액을 온전히 받게 되고, 이것의 본질적 의미는 “실수령액 기준으로 급여를 맞춰 준다”, “실수령액 + 세금 만큼의 급여를 보장받는다”라고 할 수 있다.

네트제를 단순화해서 예시하면 다음과 같다. 이 표에 따르면 근로자에게는 ②가 보장되고, 실제 임금대장(임금명세서)에는 ①의 금액이 기재된다. 즉, ①은 근로자에게 그 지급이 보장된 ②의 금액을 역으로 산정한 제세공과금이 포함된 명세표라고

125) “네트제”란 단어는 영문으로 Gross Pay와 Net Pay에서 따온 것인데, Gross Pay란 세전 급여로 부르고 통상 근로소득세, 사회보험료 공제전 금액, 즉 근로계약서에 들어가는 연봉액을 말한다. Net Pay는 세금, 4대보험료를 제외한 실수령액을 의미한다.



할 수 있다.

세부 내역				
지 급			공 제	
임금 항목		지급 금액(원)	공제 항목	공제 금액(원)
매 월 지 급	기본급	10,000,000	소득세	2,651,570
	직책수당	3,204,600	지방소득세	265,150
			고용보험	105,630
			건강보험	74,340
			장기요양보험	7,610
			국민연금	100,300
지급액 계		① 13,204,600	공제액 계	3,204,600
			실수령액(원)	② 10,000,000

네트제 근로계약의 정확한 실태는 파악된 바 없으나 주로 보건의료분야(의사, 간호사, 약사 등)에서 많이 활용되고 있는 것으로 추정된다. 예컨대 한 언론보도에 따르면 “병원규모가 작고 의사 구하기가 어려운 지방일수록 네트계약이 많이 활용된다. 의사는 더 많은 급여를 보장받기를 원하고 병원은 안정적인 인력을 수급해야 하는 이해관계가 맞아 떨어진 결과라고 하면서 동시에 일부병원들은 세금탈루를 목적으로 개인소득 축소신고 등 잠재적 세금탈루 가능성이 높다고 보도한 바 있다.¹²⁶⁾

나. 네트제의 쟁점

126) 2022. 8. 8.자 의협신문

<https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=145616>



네트제 근로계약에서 사용자가 부담하기로 한 근로소득세와 사회보험료 등 제세공과금이 평균임금에 해당하는지 여부가 쟁점이다.

판례는 사용자에게 지급의무가 지워져 있으므로 임금에 해당한다고 본다. 그에 따르면 평균임금 산정에 포함되는 임금총액에는 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 모든 금품으로서, 근로자에게 정기적·계속적으로 지급되고 그 지급에 관하여 사용자에게 지급의무가 있으면 그 명칭에 관계없이 모두 포함하는데,¹²⁷⁾ 병원(사용자)이 매달 의사(근로자)의 실수령액에 대한 근로소득세 등을 대신 납부하기로 하였다면 그 명칭에 관계없이 병원이 대신 납부하기로 한 해당 근로소득세 등 상당 금액은 평균임금 산정 기초가 되는 임금총액에 포함되어야 한다. 따라서 병원이 의사에게 지급할 퇴직금을 산정할 때 그 기초가 되는 평균임금에 해당 의사의 퇴직 전 3개월 동안 병원이 부담하기로 한 근로소득세 등의 금액도 합산되어야 한다는 것이 대법원의 입장이다.¹²⁸⁾

이에 비하여 행정해석은 사용자가 부담하는 세금, 사회보험료, 공과금 등은 임금으로 보기 어렵다고 해석해 왔다. 그에 따르면 일반적으로 사용자가 근로자에게 지급하는 임금 중 법령을 근거로 그 일부를 공제하여 원천징수하는 경우에는 원칙적으로 공제 전 금액까지 평균임금에 산입되는 임금으로 봄이 타당하다. 그러나 근로자와 사용자 간에 근로계약을 체결할 때 일정 금액으로 한다는 명확한 약정이 있고, 근로자에게 납부의무가 있는 사회보험료 및 각종 세금 납부 등을 사용자가 부담하기로 한 경우에는 해당 금품을 근로의 대가로 지급되는 임금으로 보기 어려워 평균임금 산정에 포함될 수 없다고 보았다.¹²⁹⁾

다. 검토

네트제 근로계약에서는 사용자가 부담하기로 한 제세공과금을 포함하여 평균임금이 산정되어야 한다고 본다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 평균임금 등 계산은 세

127) 대법원 2011.7.14. 선고 2011다23149판결 등 참조.

128) 대법원 2021.6.24. 선고 2016다200200 판결.

129) 임금근로시간정책팀-120, 2007.1.9. 등.



후 임금이 아닌 세전 임금을 기준으로 산정하는 원칙을 견지해 왔으며, 넷제 근로계약은 노사자율로 세후 임금액을 보장한 것에 불과할 뿐이므로, 평균임금 산정 원칙의 근간까지 달리할 수 없다. 둘째, 대법원도 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 사용자에게 지급의무가 있으면 평균임금 산정의 기초가 된다고 보았고¹³⁰⁾ 이 판결 이후 하급심도 사업주가 부담하는 제세공과금에 대해 임금으로 판단하는 경향을 보여준다. 셋째, 유사한 형태인 사업주가 대신 납부하는 개인연금보험료, 직장단체보험료 등이 정기적·일률적으로 지급되었다면 임금에 해당한다.¹³¹⁾ 넷째, 넷제 근로계약이라고 하더라도, 임금을 지급하지 않은 이상 사용자에게 보험료 원천징수 의무가 발생한다고 할 수 없어 보험료 공제금액이 아닌 미지급 임금 전부(사회보험료 포함)에 대해 책임이 있다.¹³²⁾

라. 연말정산 환급금의 평균임금 해당성 여부

일반적으로 근로소득세를 근로자가 직접 부담한 경우 소득세법 제137조에 따른 근로소득세액의 연말정산에 의한 환급금은, 당해 연도에 미리 원천징수하여 납부한 소득세가 당해 종합소득 산출세액에서 소득세법 제134조 제4항 각 호의 세액공제한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 당해 근로소득자에게 소득세법 시행령이 정하는 바에 따라 환급하는 것으로서, 근로기준법 제36조에서 정한 ‘근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에 사용자가 그 지급사유가 발생한 때부터 14일 이내에 지급하여야 할 임금, 보상금, 그 밖에 일체의 금품’에 해당한다는 것이 대법원의 태도이다.¹³³⁾ 즉, 사용자가 근로자의 임금에서 매월 각종 세금을 원천징수한 경우에는, 연말정산 환급금은 근로자의 임금에서 공제한 세금을 정산하여 돌려받는 것이므로 근로기준법 제36조 소정의 ‘그 밖에 일체의 금품’에 해당하여 근로자에게 귀속되어야 할 것이다.

이에 비하여 하급심에서는 넷(Net) 계약과 같이 근로자에게 납부의무가 부여된

130) 대법원 2021.6.24. 선고 2016다200200 판결.

131) 대법원 2013.12.18. 선고 2012다94643 판결.

132) 대법원 2014.12.12. 선고 2014도13983 판결.

133) 대법원 2011.5.26. 선고 2009도2357 판결.



각종 세금, 사회보험료 등을 액수에 관계없이 그 전액을 사용자가 부담하기로 약정하고 사용자가 이를 납부한 경우에는, 그 환급금 또는 추징금은 모두 사용자의 회계처리상 과다납부 또는 과소납부로 인한 것으로서 사용자가 이를 지급받거나 부담하기로 한 약정이 있다고 보아야 할 것이므로, 이는 근로기준법 제36조 소정의 '그 밖에 일체의 금품'에 해당하지 아니한다고 보는 견해가 대부분이다.¹³⁴⁾ 구체적으로는 첫째, 사용자가 적정한 금액을 계산하여 소득세를 납부하였다면 근로자가 환급받을 연말정산 환급금이 존재할 수 없는 점, 둘째, 연말정산 환급금은 네트 계약에 따라 당초 사용자가 부담하여야 할 금액이 환급된 것으로서 이는 사용자가 부담할 금액의 감액에 해당하는 점, 셋째, 연말정산 결과 기왕에 납부한 소득세보다 더 많은 소득세를 내야 하는 것으로 정산이 되면, 근로자가 아니라 사용자가 그 소득세 차액을 납부하여야 하는 점 등에 비추어 보면, 다른 특별한 사정이 없는 한 사용자와 근로자 사이에 연말정산 환급금이 발생하면 이를 사용자에게 귀속시키기로 하는 합의가 있다고 봄이 타당하다고 본다.¹³⁵⁾

행정해석도 네트제 근로계약에 따라 사용자가 부담한 경우 임금이 아니라고 본다. 즉, 근로계약 체결시 임금액을 정하고 사용자가 관련 법령에 따라 그 임금액에서 매월 각종세금 등을 원천징수한 경우에는 연말정산 환급금은 근로자의 임금에서 공제한 세금을 정산하여 돌려받는 것이므로 기타금품에 해당하지만, 해당 금품은 그 액수와 관계없이 그 전액을 사용자가 부담하기로 하였고, 추징금이 발생한 경우 이는 사용자의 회계처리상 과소 납부로 인한 것으로서 사용자가 부담해야 하는 것이라면 환급금도 마찬가지로 사용자의 회계처리상 과다 납부로 인해 발생한 것이므로 근로기준법 제36조에 따른 기타금품에 해당한다고 보기 어렵다.¹³⁶⁾

이처럼 네트제 계약을 체결한 경우 사용자의 회계처리상 과부족으로 인해 발생한 세액의 환급금 또는 추징금의 귀속주체는 근로기준법으로 규율할 수 있는 사안이

134) 부산지법 2018.10.5. 선고 2017가단306187 판결; 수원지법 2020.7.23. 선고 2020가단 503391 판결; 대구지법 2021.9.8. 선고 2021나300713판결 등.

135) 부산지법 2018.10.5. 선고 2017가단306187 판결, 대구지법 2021.9.8. 선고 2021나 300713 판결, 대전고법 2022.5.19. 선고 2021나15473 판결, 서울중앙지법 2022.6.14. 선고 2020가단5287818 판결, 전주지법 2022.8.25. 선고 2021나12752 판결 등 다수.

136) 근로기준정책과-1340, 2015.4.6.



아니라고 보아야 한다.¹³⁷⁾

마. 임금명세서의 기재 내용

근로기준법 제48조 제2항에 따르면 사용자는 임금 지급 시 근로자에게 임금의 구성항목·계산방법, 동법 제43조 제1항 단서에 따라 임금의 일부를 공제한 경우의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항을 적은 임금명세서를 서면(전자문서 및 전자거래 기본법 제2조 제1호에 따른 전자문서 포함)으로 교부하여야 한다고 규정하고 있다. 그런데 이 경우 임금명세서에 기재되어야 할 임금의 범위가 문제되는데, 이에 대한 직접적인 판례가 아직 없으나 사업주가 부담하는 제세공과금을 포함하여 임금명세서를 산출해야 한다고 해석할 수 있다. 그에 따르면 국세기본법 제21조 제2항 제1호에 따라 원천징수하는 소득세 등에 대한 징수의무자의 납부의무는 원칙적으로 그 소득금액을 지급하는 때에 성립하고 이에 대응하는 지급자의 수인의무 성립시기도 그와 같으므로, 지급자가 소득금액의 지급시기 전에 미리 원천세액을 징수·공제할 수는 없고, 원천징수의 대상이 되는 소득이라고 하여 소득의 범위 그 자체가 당연히 원천세액만큼 감축되는 것도 아니다.

이에 반하여 행정해석은 실수령액을 기준으로 임금명세서를 작성해야 한다고 보았다. 즉, 근로자와 사용자 간에 근로계약 체결시 고정 지급액을 약정하고, 근로자에게 납부의무가 있는 사회보험료 등을 사용자가 부담하기로 하고 보험징수기관에 대신 지급한 경우에는 해당 금품을 근로의 대가로 지급되는 근로기준법상 임금으로 보기 어렵다고 전제하고,¹³⁸⁾ 따라서 근로자가 부담하여야 할 세금 및 사회보험료를 사용자가 부담하기로 하고 근로자에게 지급하는 실수령액을 기준으로 근로계약을 체결하였다면 근로계약상의 실수령액을 근로기준법상 임금으로 보아야 할 것이고, 실수령액을 기준으로 임금대장 및 임금명세서에 임금에 관한 사항을 작성해야 한다고 보았다.¹³⁹⁾

137) 근로기준정책과-1218, 2021.4.22; 근로기준정책과-1970, 2022.6.24.

138) 근로조건지도과-598, 2008.4.1.

139) 근로기준정책과-631, 2022.2.23.



생각건대, 임금명세서 교부제도가 임금의 구성항목, 계산방법, 공제내역 등의 정보를 근로자에게 확인토록 하여 분쟁을 예방하는 취지인 점을 고려할 때, 실수령액으로 교부할 경우, 사실상 근로자가 정확한 공제내역을 알 수 없어 임금명세서 교부제도가 형해화될 우려가 있으므로, 임금성을 가진 금품은 반드시 임금명세서에 포함되어야 한다. 따라서 사업주가 부담하기로 한 제세공과금도 임금으로서 임금명세서에 기재되어야 한다. 네트제 근로계약이라고 하더라도 ‘세전 금액’으로 임금명세서를 교부해야 공제내역을 정확히 알 수 있어 포괄임금, 퇴직금 중간정산 등 임금체불 관련 갈등을 예방하고 불확실성을 해소할 수 있다.

(2) 근로기준법 제57조 보상휴가제 실시와 평균임금 산정 방법

가. 문제제기

근로기준법 제57조(보상휴가제)는 사용자가 근로자대표와의 서면합의에 따라 연장근로, 야간근로 및 휴일근로 등(이하 ‘연장근로’로 통칭)에 대하여 임금을 지급하는 것에 갈음하여 휴가를 줄 수 있도록 규정하고 있다. 보상휴가제는 노사가 정한 서면합의에 따라 일반적으로 연장근로에 대해 보상휴가의 부여기준, 부여방법, 미사용시 임금지급 등 세부적인 사항을 정하여 실시하고 있다.

고용노동부는 그동안 “보상휴가 미사용수당”에 대해서는 “연차유급휴가 미사용수당”의 평균임금 산정방식을 준용하여 보상휴가제 사용단위에 따라 (예를 들어 1년 단위의 보상휴가제인 경우 3/12 등) 평균임금에 산정토록 행정해석을 해왔다.¹⁴⁰⁾

그러나 최근 보상휴가제를 도입한 사업장에서 평균임금 산정방식에 둘러싸고 노사 간 견해가 대립하면서, 종전 행정해석에 따른 평균임금 계산(미사용수당의 3/12를 포함)이 적절한지, 아니면 평균임금은 퇴직 등 산정사유 발생일 이전 3개월 동안 행해진 실제 연장근로에 따라 받을 수 있었던 수당을 반영하는 것이 적절한지에 대한 논란이 발생하고 있다.

140) 근로개선정책과-370, 2014.1.24.



나. 쟁점 및 검토

쟁점은 보상휴가제 도입 사업장에서 보상휴가 미사용에 따라 사용자에게 지급의 무가 발생한 수당(통칭 “보상휴가 미사용수당”)을 평균임금 산정시 어떻게 반영할 것인가 하는 점이다.

이에 대해서 아직 판례는 없다. 다만, 정부의 행정해석에 따르면 평균임금 산정기간 중 발생한 연장근로가 아닌 보상휴가 미사용수당이 평균임금 산정기간에 반영되어야 한다고 본다. 그 근거를 다음과 같이 설명하고 있다.¹⁴¹⁾

보상휴가제는 연장·야간 및 휴일근로에 대해 임금을 지급하는 대신 유급휴가를 부여하는 제도이며 근로자대표와의 서면합의가 전제된다. 노사합의 사항에는 보상휴가 사용 단위(예를 들어 1년간 또는 6개월간 등), 휴가청구권과 임금청구권을 선택적으로 인정할 것인지, 아니면 임금청구권은 배제하고 휴가청구권만 인정할 것인지 등도 포함된다.

보상휴가제에서는 임금청구권 발생시기가 노사합의에 따라 달라질 수는 있으나 연차휴가 미사용수당의 평균임금 반영방식을 고려할 필요가 있다. 연차휴가 미사용수당의 경우, 평균임금 산정사유 발생일 이전에 발생한 연차휴가 미사용수당액의 3/12을 평균임금 산정 기준임금에 포함하고 있다. 보상휴가제의 경우에도 노사합의로 사용단위 기간을 1년으로 한 경우 평균임금 산정사유 발생일 이전에 발생한 보상휴가 미사용수당액의 3/12을 산입하여 평균임금 계산에 산입하는 것이 타당하다는 것이 행정해석의 취지이다.

그러나 이러한 해석은 타당하지 않다. 연장근로에 대한 임금을 보상휴가제에 따라 휴가를 사용하든 또는 보상휴가 미사용수당으로 지급받든 관계 없이 평균임금 산정기간에 실제로 발생한 연장근로에 대한 수당을 반영하는 것이 평균임금의 정의 및 취지에 부합하기 때문이다. 구체적인 근거는 다음과 같다.

141) 근로기준정책과-2273, '22.7.19.



평균임금이란 원칙적으로 사유발생 직전 3개월 동안에 근로제공의 대가로 근로자에게 지급되어야 할 임금이 그 산정범위에 포함된다. 그런데 보상휴가제는 임금과 휴가에 대한 선택의 폭을 넓혀주고 실근로시간 단축에 기여하고자 하는 취지로 도입된 제도일 뿐이고,¹⁴²⁾ 평균임금 산정방식에 영향을 미치는 예외 기준이 될 수는 없다. 또한, 근로자의 임금청구권은 근로를 제공하면 발생하는 것이므로, 연장·야간·휴일근로의 제공에 대해 임금 지급 대신에 보상휴가를 부여하기로 한 사정만으로 특별히 임금청구권 자체의 발생시점이 변경되었다고 보기 어렵다.

한편, 연차유급휴가와 보상휴가의 성격상 차이도 고려되어야 한다. 먼저 연차유급휴가는 전년도 출근율에 따라 산정되지만 보상휴가는 연장근로에 따라 발생하고, 연차휴가 미사용수당은 직전 1년이라는 기간에 대한 대가이므로 평균임금 산정기간(3개월)에 정확히 일치시키기 어려운 반면, 평균임금 산정기간(직전 3개월)에 포함되는 연장근로는 명확히 반영할 수 있으므로, 연차휴가 미사용수당과 같은 평균임금 산정방식(3/12)을 준용하여 보상휴가 미사용수당을 평균임금 산정에 적용할 필요가 없다. 다시 말해 평균임금 산정기간 중 연장근로 실적은 명확히 산출될 수 있으므로 평균임금 산정 사유 발생 당시 통상의 생활임금을 사실대로 반영할 수 있는 합리적이고 타당한 방법이라고 할 수 있다.

보상휴가는 외형상으로는 연차휴가와 유사하게 보이지만 이미 근로제공의 대가로 발생한 연장근로에 대한 임금의 지급시기와 방법(휴가사용 및 미사용시 수당지급)을 변경한 것에 불과할 뿐이므로 보상휴가 사용 여부나 지급 시기와 관계없이 평균임금 산정기간에 실제로 발생한 연장근로를 가지고 평균임금을 산정하는 것이 타당하다. 평균임금 산정기간 동안 ‘지급된’ 임금은 그 기간에 실제로 제공된 근로에 따라 당연히 지급받을 임금을 의미하기 때문이다.¹⁴³⁾

Ⅲ. 통상임금과 임금 개념의 관계

142) 대법원 2002.8.23.선고 2000다60890,60906 판결.

143) 이점은 보상휴가제를 실시하는 사업장과 실시하지 않는 사업장을 평균임금 산정과 관련하여 달리 취급할 필요가 전혀 없다는 점에서도 타당하다.



1. 통상임금의 개념과 쟁점

통상임금은 연장근로, 야간근로, 휴일근로시 가산임금, 해고예고수당 등을 산출하는 기준임금으로서 퇴직금, 휴업수당, 재해보상금 등의 산출 기준인 평균임금과 구별된다. 또한 평균임금은 법 소정의 산정 사유 발생을 전후하여 근로자가 통상적인 생활을 유지하도록 하는데 산정 목적이 있으므로 사후적 개념인데 비해, 통상임금은 임의의 근로를 제공하기 이전에 연장근로 등에 대한 가산임금을 미리 산정할 수 있도록 하기 위한 사전적 개념이라는 점에서 양자는 구별된다.

그런데 근로기준법은 평균임금과 달리 통상임금에 대해서는 별도의 정의규정을 두지 않고 동법 시행령 제6조 제1항에서 정하고 있을 뿐이다. 동법 시행령에 따르면 통상임금은 근로자에게 정기적, 일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급 금액 등이라고 규정하고 있다.

대법원은 법률에 정의규정이 없고 시행령에서만 정의하고 있는 통상임금의 개념에 대하여 전원합의체 판결을 통해 구체적인 개념정립을 시도하였다. 그에 따르면 통상임금은 근로자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하는 근로(소정근로)의 대가로 지급하기로 약정한 금품으로서 정기적, 일률적, 고정적으로 지급되는 임금이라고 한다.¹⁴⁴⁾ 이에 따르면 통상임금에서는 평균임금과 달리 임금 개념 자체가 문제될 가능성은 거의 없다. 평균임금의 경우 임시로 지급된 임금 및 수당과 통화를 제외하고는 임금성이 인정될 경우 평균임금 산정 시 거의 모두 산입하는 것으로 규정되어 있는데 비하여 통상임금의 경우에는 소정근로의 대가와 고정성을 통해 최소한 근로의 대가성 여부가 명확히 판단되기 때문이다. 그런데 통상임금의 경우 정기, 일률, 고정적으로 지급된 금품으로서 시급 단위로 산정되는 것이므로 시간비례적 임금체계

144) 대법원 2013.12.18. 선고 2012다189399, 2012다94643(병합) 전원합의체 판결; 대법원 2014.5.29. 선고 2012다116871 판결 참조.



간비례적 임금산정이 아니라 ‘직무가치’와 ‘일의 결과’(성과)를 중심으로 임금이 결정된다는 점에서 종래 통상임금의 개념과 정합성을 가지는지 의문이 제기될 수 있다. 따라서 평균임금의 경우 근로제공의 결과로써 근로자에게 사후적으로 지급되는 금품 중 임금에 해당하는 금품을 어디까지 포함시킬 수 있는지가 쟁점이라면, 통상임금은 임금체계의 변화에 따라 합리적인 산정방법을 둘러싸고 논란이 제기될 수 있다는 점에서 검토를 요한다.

대법원이 정립한 통상임금의 개념 중에서 특히 고정성 요건을 둘러싸고 논란이 제기되고 있다. 대법원에 따르면 고정성이란 임금의 명칭에 관계없이 어떤 날(임의의 날)에 소정근로시간을 근무한 근로자가 그 다음날 퇴직한다 하더라도 그 하루의 근로에 대한 대가를 당연하고도 확정적으로 지급받게 되는 최소한의 임금이라고 정의된다.¹⁴⁵⁾ 따라서 급여 지급일 당시에 재직할 것을 조건으로 하는 상여금이나 복리후생비, 명절상여금, 하계휴가비 등은 임의의 날에 연장근로, 휴일근로 등을 제공하는 시점에서 재직 여부가 확정될 수 없는 불확실한 조건에 따라 지급되는 금품이므로 고정성이 부인되어 통상임금에 해당하지 않게 된다.¹⁴⁶⁾

2. 지급일 재직 요건의 유효성

대법원은 지급일 재직 요건 자체의 유효성 여부에 대해서는 아직 직접적으로 판단하지 않았다.¹⁴⁷⁾ 다만, 통상임금의 고정성 판단에 중요한 기준의 하나로 사용함으로써 간접적으로 그 유효성을 인정하고 있다고 볼 수 있다.¹⁴⁸⁾ 이와 관련하여 위에서 검토한 독일과 일본의 논의를 참고할만하다.

145) 대법원 위 전원합의체 판결 참조.

146) 위 전원합의체 판결 외에 대법원 2017.9.26. 선고 2017다232020 등 참조.

147) 서울고법 2018.12.18. 선고 2017나2025282 판결(이른바 세아베스틸 사건)은 “정기상여금에 설정된 지급일 재직 조건은 무효이고, 정기상여금은 소정근로를 제공하기만 하면 그 지급이 확정된 것으로서 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금이므로 통상임금에 해당한다.”라고 판단하였다. 이 사건은 현재 대법원에 계류중이다(사건번호 2019다204876).

148) 대법원 위 전원합의체 판결 참조(각주 145)



위 독일의 논의에서 보듯이 임금의 성격을 갖는 특별급여의 경우에는 도중에 퇴직하더라도 임금청구권을 상실하지 않는다. 왜냐하면 임금청구권은 근로관계의 존속을 전제로 하지 않기 때문이다. 즉, 근로를 제공한 기간에 대해서 비율적으로(즉, 일할 계산하여) 임금청구권을 갖는다.

반면에 예를 들어 회사에 대한 충성심을 보상하기 위해 지급되는 특별급여는 지급일 당시 재직하고 있지 않거나 해고된 경우에는 청구권기초가 결여되기 때문에 해당 특별급여에 대한 청구권도 배제된다는 것이 일반적 견해이다.¹⁴⁹⁾ 물론 이 경우에도 경영성과급과 같은 특별급여의 경우 지급일 전에 미리 퇴직한 근로자가 실제 근무일에 따른 일할 계산을 청구할 수 있는지 여부는 당사자의 합의에 대한 해석 문제로 본다. 특히 특별급여가 근로제공에 대한 대가적 관련성과 회사에 대한 충성심에 대한 보상으로서의 성격을 함께 가지고 있는 경우(이를 혼합적 성격이라고 한다)에는 당사자의 합의로 지급비율이 결정될 수 있다고 본다.¹⁵⁰⁾ 다만, 혼합적 성격의 불명확성에 대한 위험은 사용자가 부담해야지 근로자가 부담해서는 안된다는 관점에서 계속적·정기적으로 지급되는 급여와 동일하게 취급해야 한다는 견해도 있다.¹⁵¹⁾

일본에서도 특히 상여금 지급을 정한 취업규칙 등에 “상여금은 지급일에 재직하고 있는 자에 대하여 지급한다.”라는 지급일 재직 요건 또는 지급일 재직 요건이 규정되어 있는 경우가 적지 않다. 이 규정에 의하여 급여지급일 이전에 퇴직한 근로자는 상여금을 전혀 지급받지 못하게 되는지 여부에 대하여 논란이 있었다.

일본의 판례 중에는 지급일 재직 요건이 합리성을 가지고 있으면, 지급일 전에 퇴직한 근로자에게는 상여금 청구권이 발생하지 않는다고 한 사례가 있다.¹⁵²⁾ 다만, 정년퇴직이나 정리해고 등 회사측 사정으로 퇴직한 근로자는 스스로 퇴직시기를 선택할 수 없으므로 지급일 재직 요건에 의해 상여금을 지급하지 않는 것은 허용되지

149) BAG 7.11.1991 EzA §611 BGB Gratifikation, Prämie Nr. 87.

150) BAG 26.10.1994 AP Nr. 167 zu §611 BGB Gratifikation.

151) Preis, *Indiv. Arbeitsrecht*, S. 417.

152) 日本 最高裁判所 昭和 57.10.7 集民 137号 p.297



않는다고 하는 견해가 있다.¹⁵³⁾ 이 경우에는 지급일 재직 요건은 공서(公序) 위반으로 무효라고 해석한다.

생각건대 특정 상여금에 설정된 지급일 재직 요건의 유효성은 해당 상여금제도의 구체적인 취지·목적에 비추어 개별적으로 판단해야 한다고 본다. 다시 말해 급여의 성격이나 발생경위 및 지급조건 등을 고려하여 재직 요건의 유효성을 달리 판단하는 것이 합리적이라고 할 수 있다. 예를 들어 근로자들의 계속근로(장기근속)를 장려하기 위하여 개별적 근무성적 등에 관계없이 지급일 당시 재직중인 근로자 전원에게 일정액(기본급의 일정 비율)을 지급하는 상여금의 경우에는 재직 요건을 합리적이라고 볼 수 있다. 그러나 일정기간 근무성적(실적)을 토대로 지급액이 결정되는 상여금은 임금후불적 성격임을 인정할 수 있으므로 상여금 산정기간에 업무를 수행하여 성적(실적)을 발휘하였음에도 불구하고 지급일에 재직하지 않았다는 사실만으로 상여금을 지급하지 않는 것은 당해 상여금제도의 취지·목적에 비추어 볼 때 합리성을 인정하기 어려울 것이다.¹⁵⁴⁾

또한 기업의 전체적인 경영성과(영업이익)의 일부를 근로자에게 배당하는 의미에서 마련된 경영성과급에 대하여 지급일 재직 요건을 두는 것은 기업마다 자율적으로 결정할 문제라고 할 수 있다.

이와 같이 상여금은 통상의 임금(예를 들어 월급으로 지급되는 고정적 임금)과 달리 사용자의 지급 결정과 노사자치에 의하여 비로소 구체적으로 발생하는 금품이라는 성격을 가지며, 지급조건을 어떻게 정하는가는 당사자의 자유(계약자유의 원칙)라고 할 수 있다. 또한 상여금은 소정 기간 동안의 근무성적이나 실적을 바탕으로 지급되는 임금의 후불적 성격을 가지는 경우도 있고, 기업의 영업이익을 주주뿐만 아니라 직원에게 배당하는 측면도 있으며, 과거 공헌에 대한 공로보상이나 장래 계속 근무에 대한 기대와 장려, 생활비 보전이라는 직접적 근로제공의 대가와와는 다른 목적으로 지급되는 경우도 있다. 따라서 이름만 상여금일뿐 실질은 기본급으로 봐도 무방한 경우에는 지급일 재직 조건을 유효하다고 할 수 없을 것이다.¹⁵⁵⁾ 반면에

153) 佐々木宗啓/伊藤由紀子, 「労働関係訴訟の實務 I」, p.47

154) 水町勇一郎, 「詳解労働法」, p.593.



그 지급이 소정의 기간을 계속 근무한데 대한 공로보상적 성격과 향후에도 계속해서 근로할 것을 장려하기 위한 성격으로 인정될 수 있는 경우에는 해당 상여금에 대한 지급일 재직 요건을 위법이라고 할 수 없다는 견해도 있다.¹⁵⁶⁾ 하지만 지급일 재직 조건이 유효하다고 하더라도 일본의 사례에서 소개한 것처럼 정년퇴직자나 사용자에 의하여 해고된 근로자와 같이 스스로 퇴직일을 선택할 수 없는 근로자에 대해서는 합리성이 없어 무효가 될 수 있다. 또한 혼합적 성격을 가진 상여금 중에서 임금부분(순수한 근로의 대가 부분)과 장려부분(부가적 목적)을 구분하여 전자의 지급에 대해서는 지급일 재직 요건을 배제하고 일할(日割) 계산하는 것이 유효하다고 하는 견해도 있다.¹⁵⁷⁾

원칙적으로 임금의 발생요건을 어떻게 정할지는 당사자의 자유라는 전제에서 검토하면 지급일 재직 요건의 유효성 여부는 개별 계약의 해석 문제라고 할 수 있다. 다만, 형식은 상여금이지만 그 실질은 순수한 근로의 대가로서 임금후불적 성격을 가지고 있어 사용자의 지급결정이나 노사의 별도 합의를 필요로 하지 않는 정기상여금에 설정된 지급일 재직 조건은 유효성이 인정되기 어려울 것으로 보인다.

3. 임금 개념과의 관계

우선 통상임금의 경우 임금성이 인정된다고 하더라도 앞서 살펴본 바와 같이 대법원이 판시한 통상임금의 요건인 ‘고정성’과 ‘소정근로의 대가’에 해당되지 않는다면 통상임금에 산입될 수 없다. 따라서 임금성과 통상임금의 개념은 구별될 수밖에 없으며 이를 부정하는 견해는 보이지 않는다. 통상임금에 해당하려면 특정 금품이 기본적으로 근로기준법상 임금에 해당되어야 하고, 동시에 그 금품의 지급이 소정

155) 박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 325면 참조. 이에 따르면 사실상 기본급의 성격을 가진 상여금(순수한 근로의 대가)에 대해서는 지급일 재직 조건을 유효하다고 볼 수 없다.

156) 佐々木宗啓/伊藤由紀子, 「労働関係訴訟の實務 1」, p.47; 東京地判 昭和 63.6.27 勞經速 1334号 p.3

157) 菅野和夫, 「労働法」, p.439, 土田道夫, 「労働契約法」, p.276



근로의 대가이면서, 정기성, 일률성, 고정성을 갖춘 경우이어야 한다.

통상임금과 관련하여 특정 임금항목에 대하여 지급일 재직 조건이 설정된 경우 그 효력이 문제된다.¹⁵⁸⁾ 임금 자체가 근로제공의 대가인데, 임금지급일(월급일) 시점에 재직하고 있지 않다는 이유로 해당 금품 전액을 지급받지 못한다는 것은 임금의 성격과 부합하지 않기 때문이다. 그러나 임금은 본질적으로 국가가 직접 결정하는 것이 아니며 근로자와 사용자라는 사인 간의 합의에 의하여 지급조건, 지급방법, 지급액이 결정된다는 점을 고려하면 지급일 재직 조건을 설정하는 것은 당사자의 계약자유의 문제라고 할 수 있다. 다만, 그 계약자유에 대한 한계로서 민법 제103조가 고려될 수 있으며, 이 경우 근로제공의 대가라는 임금의 개념과 근로자에게 절대적 생활자원이라는 임금의 기능을 고려하여 무효 여부를 판단하는 것이 타당하다.

이 점은 임금의 개념이나 법적 성격을 이해하는데 충분히 고려되어야 한다. 다시 말해 임금은 계약당사자의 합의를 법적 기초로 한다는 점, 합의를 통해 다양한 목적이 혼합된 금품이 존재할 수 있다는 점, 이 경우 지급일 재직 조건 등 다양한 지급조건이 부가될 수 있다는 점, 그 지급일 재직 조건의 존부에 따라 임금성 판단이 좌우되는 것은 아니라는 점 등은 향후 임금의 개념과 법적 성격을 이해하는데 중요한 요소라고 할 수 있다.

당사자가 지급조건과 지급액, 지급방식에 대해 합의하였다면 그 합의는 임금성을 판단하는데 중요하게 고려되어야 한다. 지급조건을 어떻게 합의하느냐에 따라 근로제공의 대가로서 당연히 지급되어야 한다는 임금지급의 원칙과 상충되는 결과가 발생할 수도 있으나, 그 또한 합의의 대상과 내용이 된다는 점에서 그것이 민법 제103조나 제104조를 위반하지 않는 한 당연히 무효라고 할 수는 없다.¹⁵⁹⁾ 다만, 민법 제103조 등을 적용하는데 있어서 해당 금품의 지급목적과 임금보호에 관한 기본

158) 그와 같은 부가조건이 설정된 경우에는 고정성이 부인되어 통상임금에 해당하지 않기 때문에 이 조건의 유효성 여부가 중요한 쟁점이 되고 있다.

159) 대법원 2013.12.18. 선고 2012다189399, 2012다94643(병합) 전원합의체 판결이 정기상여금에 대해 지급일 재직 조건의 유효성을 전제하고 통상임금 여부를 판단한 것도 같은 맥락으로 이해될 수 있다.



원칙과 강행법률을 감안하여 그 유효성을 해석해야 한다. 결국 근로의 대가이지만 ‘지급일 재직할 것’과 같은 조건을 부가하더라도 그것이 대등한 당사자의 합의(즉, 단체협약)에 기초한 것이라면 이를 임금인 아니라고 할 수 없다. 다시 말해 지급일 재직 요건이 부가되더라도 근로의 대가성을 인정하는데 장애가 되는 것은 아니다.

다른 한편, 통상임금의 요건으로서 고정성을 어떻게 이해해야 하느냐가 임금체계 개편과 관련하여 논란이 될 수 있다. 예를 들어 임금이 기본급과 수당, 상여금으로 구성되어 있다고 하자. 이 때 기본급만 고정급을 지급하고 수당이나 상여금을 개인 성과나 실적에 따라 지급액이 변동될 수 있도록 설계되어 있다면(이른바 변동성과 고정급제), 통상임금에는 변동성을 가진 임금은 제외하고 고정성을 가진 기본급만 포함될 것이다. 그런데 기본급의 비중이 낮아지고 변동급의 비중이 높아진다면 통상임금액이 낮아지게 되어 할증임금 등 법정수당의 금액도 함께 낮아지게 될 것이다. 따라서 변동급 부분의 비중이 커지는 임금체계에서는 통상임금 산정 방식을 유연하게 하지 않을 수 없을 것이다. 예를 들어 변동급 부분을 근로기준법 시행령 제6조 제2항 제6호의 도급금액으로 정한 경우로 인정하고, 당사자의 합의를 적극적으로 인정하는 것도 고려해 볼 수 있을 것이다.¹⁶⁰⁾ 이러한 점을 미리 대비하지 않는다면 통상임금 규정이 유연한 임금체계 개편에 걸림돌이 될 수 있을 것이다. 경영환경 변화를 반영한 유연한 임금체계 개편을 위해서는 통상임금의 개념과 산정 방식도 그에 맞춰 유연하게 변경되어야 할 것이다.¹⁶¹⁾ 여기서도 당사자의 합의(또는 노사합의)가 중요한 역할을 담당할 수밖에 없을 것이다.

제5절 소결

본장의 내용을 요약하면 다음과 같다.

160) 박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 324면.

161) 박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 325면.



먼저 고용계약상의 일반적인 보수개념은 당사자 간 합의에 의하여 반대급부로 지급하기로 한 모든 금품이라고 할 수 있지만, 임금에 대해 강행적 보호규정을 규율하고 있는 근로기준법은 반대급부 중 특별히 ‘근로의 대가’로 지급하는 것을 임금이라고 정의함으로써 근로관계에서 사용자의 지급의무가 발생하는 모든 금품이 모두 다 임금에 해당하는 것은 아니라고 할 수 있다. 즉, 고용(근로)계약상으로는 당사자 간 합의에 의하여 사용자의 지급의무가 있는 금품이 정해지지만, 근로기준법상 임금은 당사자 간 합의가 있더라도 다시금 근로의 대가인지 여부가 객관적으로 판단되어야 한다.

특정 금품이 근로의 대가로서 임금에 해당하는지 여부를 판단해야 할 경우에는 근로기준법 등 노동법적 보호의 특성을 반영한 해석론이 요청된다. 특히 임금성에 관한 당사자의 분쟁은 특정 금품이 평균임금에 해당하는지 여부와 직결된다는 점에서 임금성 자체에 대한 판단과 평균임금 산입 대상으로서의 임금에 대한 판단이 실질적으로 동일한지 아니면 달라야 하는지가 문제된다.

생각건대 근로자의 통상의 생활을 보장하기 위한 기준임금으로서 평균임금제도의 취지를 고려하면, 근로자가 사용자로부터 지급받는 임금 중에는 평균임금 산입이 부적합한 임금에 대해서는 이를 제외하고 평균임금을 산정하는 것이 타당할 것이다. 그러나 현행 법령은 이를 충분히 반영하고 있지 않다. 근로기준법 시행령 제2조 제2항은 평균임금 산정 시 특별히 임시로 지급되는 임금과 수당을 제외하도록 정하고 있을 뿐이다. 그렇기 때문에 법원은 근로기준법상 평균임금제도의 취지를 고려하면서 근로자의 임금지급 내역을 종합적으로 고려하여 통상적인 생활임금의 보장이라는 관점에서 사례별로 구체적 타당성을 판단하고자 하였다. 그렇지만 해석론에만 맡길 경우 법적 불안정성을 피하기 어렵다는 점에서 평균임금 산입대상 및 범위에 대하여 입법적 개선이 필요하다.

외국입법례를 통해서도 이러한 취지와 유사성을 어느 정도 발견할 수 있었다. 독일의 경우에는 우리나라처럼 일반적인 임금의 정의를 두고 있지 않지만, 일부 법령에서 계속적·정기적 임금과 부가급여(특별급여)를 구별하고 있다. 일본의 경우에는 임금에 대한 정의규정은 우리와 유사하게 노동기준법에 두고 있으나, 평균임금



의 정의에서 산입 제외 임금을 비교적 구체적으로 규정함으로써 임금과 평균임금을 이원적으로 규정하고 이를 통해 이해관계를 합리적으로 조정하고 있다. 이렇게 규정한다면 임금 개념을 굳이 좁게 해석할 필요도 없을 것이다.

종래 임금에 관한 논란과 법적 논쟁은 임금 그 자체보다는 평균임금·통상임금을 중심으로 이루어졌고 2013년 대법원은 전원합의체 판결을 통해 통상임금의 외연을 넓히면서도 그 요건을 명확히 하였지만, 임금의 개념(요건)과 판단 방법에 대해서까지 명확한 입장을 밝히지는 않았다. 특히 평균임금과 임금의 관계를 어떻게 이해하고 있는지도 불분명하다. 관련 법령은 임금 정의 규정과 별도로 평균임금과 통상임금을 규정하고 있는데 평균임금과 통상임금은 특정 급여 산출을 위한 도구적 개념으로 각 목적에 맞게 산출되어야 한다.

따라서 임금·평균임금·통상임금의 요건 및 범위는 개념적으로 일치될 수는 없다. 평균임금의 경우 앞서 살펴보았듯이 우리 법제는 임시로 지급된다는 제한 조건 외에 ‘임금’과 ‘평균임금 산정 시 임금 총액에서의 임금’을 명확히 구분하지 않고 있다. 이로 인해 근로기준법상 임금의 개념(요건) 및 판단 방법은 근로기준법상 평균임금을 기본개념으로 활용하고 있는 근로기준법 및 다른 법령의 적용에도 영향을 미칠 수밖에 없다. 결론적으로 임금, 평균임금·통상임금에 관한 우리나라의 법령 간의 관계를 고려하면 임금의 개념(요건)과 판단방법을 정립함에 있어 법적 안정성과 합목적성의 적절한 균형이 더욱 요구된다고 할 수 있다.

이와 관련하여 평균임금제도는 법정 급여나 수당 산정을 도구적 성격을 가진다는 점을 충분히 고려하면서 임금의 일반적 개념과 분리하여 그 산입대상 임금을 정할 필요가 있다.



제3장 임금성이 논란이 되는 보수 형태

본장에서는 최근 가장 논란이 되고 있으며, 임금의 개념에 대한 법리 논쟁을 야기한 경영성과급의 임금성에 관한 문제와, 최근 대기업과 IT기업을 중심으로 임금의 구성 항목으로 널리 활용되고 있는 주식보상제의 유형과 임금성에 관한 문제를 중심으로 검토하기로 한다. 이들은 모두 임금의 개념과 임금체계에서 상당한 비중을 차지하는 이슈라고 할 수 있다.

제1절 경영성과급의 임금성

I. 경영성과급의 개념

1. 경영성과급의 의의

경영성과급이란 전형적인 집단적 성과급으로써 통상 기업 내 특정 조직이나 전체 기업이 달성한 성과 또는 이익을 기초로 산정된 일정한 재원을 가지고 사용자가 일정한 기준을 정하여 직원들에게 지급하는 금품을 의미한다. 경영성과급은 근로자 개인이 제공한 구체적 또는 개별적인 근로의 내용이 기업 내 조직 또는 기업전체가 달성한 성과나 이익에 어떤 영향을 끼쳤는지 판단하기 어렵다는 특징이 있다. 기업 내 조직 또는 전체 기업이 달성한 이익에는 개별 근로자가 제공한 근로 및 그 실적 뿐만 아니라 경영환경 등 다양한 대내외적 상황들이 영향을 미치기 때문이다.¹⁶²⁾

경영성과급은 미국의 성과배분제도를 중심으로 발전되었다. 역사적으로 집단성과

162) 김도환, “경영성과급의 임금성”, 『중앙법학』, 제24집 제1호, 144면.



배분제(Gain sharing)은 1896년 미국의 Henry Towne에 의해 종업원에 대한 집단적인 보너스 제도(과실을 분배하기 위한 제도)로 도입되었으며, 종업원들의 경영참여를 통한 생산비 절감 및 생산성 향상을 목표로 하였다.¹⁶³⁾ 이익분배제(Profit sharing)의 경우 1980년대 미국경제가 어려워지자 조합원을 해고하지 않기 위한 대책으로 도입된 제도로 매출액이나 이익의 증대를 목표로 한다.¹⁶⁴⁾ 집단성과배분제의 경우 종업원의 참여를 요소로 하는 반면 이익배분제는 종업원의 참여를 요소로 포함하고 있지 않기 때문에 이익분배제와 집단성과배분제는 임금성을 달리 볼 수 있다. 즉, 집단성과배분제의 경우 종업원 참여를 전제로 하여 종업원의 근로제공을 통한 절감비용을 배분하는 것으로 집단성과배분제는 근로제공과 성과배분간의 관련성이 이익배분제보다 더 밀접하다고 할 수 있다.

성과배분제도가 우리나라에서 본격적으로 도입된 것은 1987년 이후 노동운동이 활발하게 전개되면서 정부가 과거 권위주의시대에 행하였던 민간부문의 임금결정에 대한 개입을 자제하고 노사에 의한 임금교섭의 자율성을 인정하면서부터라고 할 수 있다. 이어서 성과배분제도에 대한 사회적 관심이 높아지고 본격적 논의가 시작된 것은 1991년 정부가 평균임금 대신 총액임금제라는 새로운 개념을 제시하고 성과배분제도의 도입을 권고하기 시작하면서부터이다. 정부는 임금인상액의 기준을 각종 수당을 포함한 총액임금으로 하고(이른바 '총액임금제'), 성과급은 이 총액임금의 범위에 포함시키지 않을 것이라며 도입을 적극적으로 권고하고 홍보하였다. 그 결과 3년이 지난 1994년 조사 당시 성과배분제도를 도입하였거나 한 적이 있는 기업은 528개의 조사대상 기업 중 96개로 18.2%에 달하였고, 이중 1991년 이후에 도입한 기업의 비중은 72.9%에 달하였다.¹⁶⁵⁾ 특히 도입 동기와 관련하여 임금인상의 편의적 활용이라는 응답은 전체의 9.4%에 불과하였고 근로의욕 고취 및 생산성 향상이

163) 김동원/유규창, 「집단성과배분제도」, 1면, 4면 참조

164) 이영면, “이익분배제에 대한 노사의 입장 변화 : 미국의 경험과 시사점”, 「산업관계연구」 제12권, 한국고용노사관계학회, 2002.

165) 박영범, 「주요 선진국의 성과배분제도」, 한국노동연구원, 1994, 1~3면 참조. 가장 최근에 조사된 것으로 보이는 한국직업능력개발원의 2017년 자료에 따르면 이익배분제를 도입하고 있다고 응답한 경우는 조사대상 474개 기업 중 106개 기업으로 도입률은 24.2%에 이른다. 이에 관해서는 이장원/김동배/이상준, 「성과배분제도 실태와 발전방안」, 한국노동연구원, 2020, 45면 참고.



라는 응답이 전체의 81.3%에 해당하였고, 성과배분제도의 기준은 대부분이 이익분배제의 유형인 매출액 기준(30.2%), 이익 기준(26.0%), 매출액 및 이익기준(30.2%)이었다.

이처럼 우리나라에 도입된 경영성과급은 임금인상의 편의적 활용이 아닌 근로의욕 고취 및 생산성 향상을 위한 제도였고 그 도입 형태도 매출이나 영업이익 등을 중심으로 도입된 것을 알 수 있다.

2. 경영성과급의 유형

경영성과급은 기업의 보상실무에서는 다양한 모습으로 지급되고 있어, 전체 모습을 개관하려면 다음과 같이 일정한 유형별 기준을 적용하여 분류할 수 있다.

① 지급여부 및 지급액이 실질적으로 집단의 경영성과에 따라 결정되는지 여부에 따라, i) 기업의 순수한 경영성과에 따라 성과급이 결정되는 진정 경영성과급과 ii) 기업의 경영성과와 무관하게 지급해야 하고 이름만 경영성과급인 ‘가장(假裝) 경영성과급’으로 구분할 수 있다.

② 지급여부 및 지급액 결정에 집단의 경영성과 외에 개인성과도 반영되는지 여부에 따라 i) 집단의 경영성과만으로 성과급 지급여부 및 지급액을 결정하는 순수 경영성과급과 ii) 집단의 경영성과와 개인성과를 모두 반영하여 성과급 지급여부 및 지급액을 결정하는 혼합형 경영성과급으로 구분할 수 있다.

③ 성과 평가의 단위인 ‘집단’이 무엇이나에 따라, i) 기업단위 경영성과급, ii) 사업부 단위 경영성과급, iii) 부서 단위 경영성과급으로 구분할 수 있다.

④ 경영성과의 산정기준이 무엇이나에 따라, i) 이익을 기준으로 하는 이익배분제(profit sharing)와 ii) 생산성 향상이나 원가 절감을 기준으로 하는 성과배분제(gain sharing)로 구분할 수 있다.

⑤ 경영성과급의 지급 근거에 따라, i) 취업규칙, 단체협약 등에 경영성과급 지급



에 관한 근거규정이 없고 회사가 임의로 지급하는 경우, ii) 취업규칙, 단체협약 등에는 경영성과급을 지급할 수 있다는 추상적인 규정만 있고 구체적인 지급률이나 금액은 회사가 일방적으로 정하는 경우, iii) 취업규칙, 단체협약 등에 경영성과급의 지급사유와 지급기준까지 구체적으로 정하고 있는 경우 등으로 구분할 수 있다.¹⁶⁶⁾

이중에서 ①- ii)의 경우에는 근로기준법상 임금으로서의 성격을 인정할 수 있고,¹⁶⁷⁾ ⑤- i)과 ⑤- ii)는 임금성을 인정할 수 없다는 점은 일응 분명해 보인다. 그 밖의 경우에는 경영성과급이 ‘근로의 대가’로서 근로제공과 어느 정도 “관련성”을 가지고 있는지에 따라 개별 사례별로 임금성이 판단될 것이다.

3. 성과배분으로서 경영성과급의 의의

‘이익배분’(Gewinnbeteiligung) 또는 ‘성과배분’(Erfolgsbeteiligung, 실무에서는 ‘성과배분’을 더 빈번하게 사용하는 것으로 보인다)이라는 용어는 회계상의 이익 또는 성과의 산출기초와 관련된다. ‘성과배분’은 기업의 보상체계에서도 다양하게 활용되고 있다. 즉, 사용자가 근로제공과 직접 관련 없는 다른 목적을 가지고 전체 종업원에게 일정한 급여를 지급하는 경우에 사용하거나 임원들과 보수계약에서 일정한 경영상 실적을 토대로 보상을 결정하는데 사용하기도 한다.¹⁶⁸⁾

성과배분은 일단 종업원의 자본참가와는 구별된다. 종업원의 자본참가는 주로 중

166) 경영성과급의 지급 여부가 순수한 사용자의 재량에 맡겨져 있거나(⑤- i), 사실상 임의적·재량적 급여(⑤- ii)의 경우에는 그 지급의무가 없으므로 임금이라고 할 수 없다. 물론 ii)의 경우 형식은 재량급여이나, 실질은 의무라고 볼 수 있다면 iii)과 같은 유형으로 볼 수도 있을 것이다. 이처럼 ⑤-iii)과 같이 명확히 사용자에게 지급의무가 있는 경우에만 근로의 대가로 볼 수 있는지 여부가 논의의 대상이 된다.

167) 근로기준법은 근로의 대가로 지급되는 것이라면 명칭은 아무런 관계가 없다는 점을 명확히 하고 있으므로, 경영성과급이라는 용어를 사용하더라도 그 실질과 부합하지 않는다면 여기서 말하는 이윤배분, 성과참여로서의 경영성과급이라고 할 수 없다.

168) Schaub/Vogelsang, *Arbeitsrechts-Handbuch*, 18. Aufl., § 76 Rn. 1. 특히 후자의 경우는 주로 집행임원을 대상으로 연간 단위의 성과보너스 형태로 지급된다. 이를 단기 인센티브(short-term incentive)라고 부르기도 하며, 그 산출기초로 기업의 영업이익, EVA(Economic Value Added) 등을 활용하기도 한다.



업원지주제(우리사주제)와 같이 자본출연을 의미한다. 또한 성과배분은 근로자의 구체적인 노무제공의 성과(실적 또는 업적)에 연결되는 성과급(Leistungsentgelt)과도 구별된다. 즉, 성과배분제도는 근로자가 근로의 양이나 질을 단위로 임금을 계산하여 지급받는 성과급(실적급)과는 구별된다.¹⁶⁹⁾

주로 외근 영업사원들의 임금산정 방식인 실적급(Provision)이 가장 오래된 성과급 방식이라고 할 수 있다. 실적급에서는 그 급여 산정기준이 개별 근로자마다 어느 정도 구체화된 노무제공의무와 연결되어 있다. 영업직원 외에 이러한 보수지급의 방식은 주로 기업 임원들이나 고도의 전문성을 가진 직원과의 보수계약에서 나타난다.

회사법상 이사의 보수에 관한 규정은 일반적으로 근로관계에 있는 직원에 대해서 직접 적용되지는 않지만, 관리자의 지위에 있으면서 경영결과에 대해 직접 책임을 부담하는 근로자인 임원에게도 성과배분 성격의 보수약정이 가능하다. 이와 같은 성과배분은 근로자인 임원에게 요구되는 양적 또는 질적 업무수행 결과를 근거로 기업의 경영성과에 대하여 책임을 부담하는 임직원에게 기업의 이익 일부를 배분하는 별도의 보수약정을 기초로 지급되는 것이므로, 회사의 대차대조표상 확인되는 기업 이익의 일정 비율을 전체 종업원에게 생산성 향상 등을 독려하기 위해 배분하는 것과는 다르다.¹⁷⁰⁾ 전자의 경우에는 이익을 발생시키는데 필요한 효율적인 경영관리능력과 실적이 근로계약 또는 위임계약의 내용(즉, 업무의 내용)이기 때문이다. 이는 형식상 성과배분 방식을 취하고 있더라도 내용상으로는 성과급(Leistungsvergütung)의 일종으로서 근로의 대가로 보아야 하기 때문이다. 즉, 일반적으로 주식회사의 이사 또는 특정 임원에게 보수의 일부로 보장하고 있는 특수한 성과급제도(이를 “Tantieme”라고 부른다)는 이러한 의미로 이해된다.

결국 성과배분의 법적 성격(임금인지 여부)은 노무급부(근로제공)와의 관련성에

169) 이러한 성과급을 독일에서는 Akkordlohn 또는 Prämienlohn이라고 부른다. 우리나라에서는 급여의 본질에 따른 구체적 분류체계 없이 성과급이라는 용어를 범용적으로 사용하고 있는 것으로 보인다. 따라서 성과급이라는 용어를 사용하더라도 그 실질이 근로의 양과 질에 따라 임금으로 지급되는 것인지, 기업의 전체 영업실적을 토대로 그 성과(이익)를 종업원에게 배분하는 의미로 사용하는 것인지 구분되어야 한다.

170) Ricken, NZA 1999, 236, 237.



달려 있다. 진정한 의미의 성과배분은 ‘이익’의 크기가 구체적인 근로관계로부터 (어느 정도) 벗어나 있는 독자적인 가치를 의미한다. 독일 연방노동법원은 회사가 지급하는 경영성과급이 근로제공으로부터 벗어난 가치나 이익을 대상으로 하는 것이라면 임금이 아닌 순수한 보너스(Gratifikation)에 해당한다고 보았다. 이러한 이유로 영업실적 기반의 경영성과급은 그 법적 근거에 관계없이 근로의 대가로 지급 되는 임금과 동일시하기 어렵다고 보았다.¹⁷¹⁾

이와 달리 간부직원(관리직 직원)의 경영성과급 지급 청구 사건에서 관리직 직원들에게 비교적 낮은 고정급을 지급하고 그 대신에 구체적인 조건을 명시하면서 특별성과급(Tantieme)의 지급을 약정하였다면 이는 근로소득에 포함되어야 한다고 판단하였다. 고정급 부분만으로는 해당 근로자가 충분히 보상받았다고 보기 어렵고 경영성과를 산출 근거로 한 추가적인 보수약정을 한 것으로 보았기 때문이다.¹⁷²⁾

II. 성과배분의 형태와 법적 성격

경영성과급이 임금인지 여부는 노무제공에 대한 반대급부, 즉 대가적 견련관계의 구조로 설명될 수 있는지가 쟁점이라고 할 수 있다. 물론 어떤 급부를 쌍무적 급부 의무의 대상으로 할 것인지는 근로관계의 당사자 의사에 맡겨져 있으며, 당사자는 근로계약의 본질에서 벗어나지 않는 한 다양한 방법으로 반대급부의 형태를 정할 수 있다. 따라서 경영성과급의 약정이 대가적 견련관계를 전제로 하는지 여부는 당사자 합의의 전체적인 내용(근로자의 직무/업무의 내용, 지위, 지급기준과 지급액 등 보상구조 등)을 토대로 판단할 수밖에 없다. 물론 전체 근로자를 대상으로 영업 실적에 기반하여 일률적으로 금품을 배분하는 방식도 단체협약이나 취업규칙 등에서 지급의무와 지급조건이 명시되어 있다면 근로제공과의 대가적 견련성을 인정할 수 있을 것이다.

171) BAG BB 1974, 695.

172) BAG AP Nr.1 zu §74 HGB; Moll/Hexel, *Münchener Anwaltshandbuch Arbeitsrecht*, 4. Aufl., § 20 Rn. 40.



근로자가 소액의 고정급을 받거나 전혀 고정급을 받지 아니하고 경영성과급을 주된 소득원으로 하는 보수지급방식은 매우 드물다. 하지만 임원 또는 관리자의 경우 고정적인 급여 부분이 없거나 축소하는 대신에 거래실적에 기초한 수수료를 보수로 약정하거나 기업의 경영성과를 토대로 보수를 산정하는 방식의 합의는 실무상으로 큰 문제가 없다. 임원인 근로자에 대하여 현행법상 성과급으로 보수약정을 하는 것은 얼마든지 가능하지만 성과배분 방식의 보수는 기본적으로 도급계약(민법 제664조) 또는 조합계약(민법 제703조)의 성격¹⁷³⁾도 가지고 있으므로 ‘고용과 도급’ 또는 ‘고용과 조합’의 혼합적 성격을 가진 계약관계라고 볼 여지도 있을 것이다.

이와 같이 현행 노동법에서는 근로시간에 대한 일정액의 고정급을 보장하고 최저임금을 준수하는 이상 얼마든지 경영성과에 연동된 성과급제의 약정이 가능하며, 이 경우에는 임금으로서의 성질이 인정된다. 이를 위해서는 개별 근로자의 보수약정의 내용, 계산방법, 지급을 등이 합의되어야 한다(근기법 제17조 제2항 참고). 즉, 당사자 간에 경영성과급을 보수(임금)의 구성부분으로 하는 합의가 전제되어야 한다.

반면에 기업의 임의적, 재량적 급여일 경우에는 임금이 아니라 임금액을 보충하는 목적을 갖는 성과배분이라고 할 수 있다. 재직 중인 모든 종업원에게 순수한 경영성과를 기반으로 성과배분적 차원에서 골고루 상여금이 지급되고 있는 등 성과배분이 근로자의 재산형성을 위한 보충적 급여의 성격을 가진다고 할 수 있는 경우에는 그 경영성과급이 근로제공과 대가적 견련관계에 있는 임금으로서의 실질을 가진다고 보기 어려울 것이다.

Ⅲ. 경영성과급 임금성 판단에 관한 하급심 판결 분석

173) 민법상 조합(組合)은 여러 사람이 자금이나 노력을 모아 공동으로 사업을 경영하기 위하여 단체를 만드는 계약이다. 조합은 사업경영이라는 공동목적을 위하여 여러 사람의 당사자(조합원)가 결합하여 단체를 형성하는 계약이다. 조합원간에 이익과 손실의 분배는 조합계약에 특약이 있는 경우에는 그에 따르며, 특약이 없는 경우에는 각 조합원의 출자액에 따라 정해진다.



최근 하급심판결 중에는 경영성과급의 임금성을 부인한 것이 다수지만 반대로 임금성을 인정한 사례도 있다. 이하에서는 임금으로 인정한 근거와 부인한 근거를 비교하고 임금 개념의 해석과 비교하여 검토·평가한다.

1. 임금성을 인정한 하급심 판결

(가) 서울중앙지방법원은 경영성과급에 대하여 ‘근로 대가성 여부’(근로와의 밀접한 관련성 여부), ‘지급조건의 확정성 여부’, ‘평균임금 제도 취지에 대한 부합 여부’에 대한 다른 판결들의 법리를 반박하는 형태로 경영성과급의 임금성을 인정하고 있다.¹⁷⁴⁾

첫째, ‘근로 대가성 여부’와 관련하여서는 ① 회사의 급여규정(HR규정)에 ‘인센티브’를 ‘임금’ 및 ‘부가급여’의 한 항목으로 규정하고 있는 점,¹⁷⁵⁾ ② 인센티브를 지급하면서 근로소득세를 원천징수 하였다는 점,¹⁷⁶⁾ ③ 대법원에서 임금성이 인정되었던 개수급 체계의 성과급과 비교할 때 이러한 경영성과급 또한 근로의 품질을 향상시킨 것에 대한 대가이므로 근로자들의 근로제공 및 생산성 향상을 위한 노력에 대한 대가라는 측면에서 개인의 실적에 따른 개수급 체계의 성과급과 본질적 성격이 다르지 않다는 점, ④ 단지 개별 근로자들의 근로제공이 인센티브에 미치는 영향이 어렵다는 사정만으로 근로의 대가가 아니라고 단정할 수 없고, 근로자들이 집단으로 제공한 근로가 기업의 경영실적에 기여한 가치를 인정하여 종업원들에게 그 몫(배당)을 지급하는 것이라면 근로의 양과 질에 밀접한 관련이 있고, ⑤ 근로자들이 집단적으로 협업하고 근로의 양과 품질을 높이기 위해 노력하였으나 시장 상황

174) 서울중앙지법 2021.6.17. 선고 2019가합542535 판결.

175) 독일에서도 임금과 부가급여로서 특별급여를 구별하고 있으며, 경영학에서도 기본임금과 부가임금을 구별하고, 근로기준법도 임금과 그와 유사한 금품을 구별하고 있는 점 등을 고려할 때, 임금과 부가급여의 구별이 근로의 대가성을 인정하는 근거가 될 수 있는지는 의문이다.

176) 근로소득세는 소득세법상 근로소득의 정의를 바탕으로 하는 것이므로 임금 개념과는 구별된다.



등 대외적 요인으로 인센티브가 적게 지급되거나 지급되지 않을 수 있는데, 이러한 사정을 이유로 실제 지급된 인센티브까지 근로의 대가가 아니라고 볼 수 없다고 본다.

둘째, ‘지급조건의 확정성 여부’에 있어서도 ① 이 사건 인센티브는 지급 대상기간 동안 1개월을 초과한 근로자에게 지급되고 지급 대상기간 동안 근무하지 않은 기간은 월할로 금액을 차감하고 있어 근로자가 제공한 근로의 양과 인센티브 액수가 직접 관련되어 있고, ② 이미 HR규정 등에 그 지급에 대한 내용이 구체적으로 규정되어 있는 이상 단순히 인센티브의 지급률을 결정할 재량권이 사용자에게 있다는 이유만으로 회사가 인센티브를 지급할 의무가 없다거나, 해당 인센티브가 돌발적·임시적으로 지급된 은혜적 금품이라고 볼 수 없다고 판단하였다.

셋째, ‘평균임금 제도 취지에 대한 부합 여부’에 있어서도 ① 실제 근로자들에게 매년 지급된 인센티브의 규모가 근로자들이 지급 받은 전체 금액에서 상당한 비중을 차지하고 있는 점, ② 재직중인 근로자에게 지급되는 것이라는 점은 통상임금의 고정성 요소에 불과하므로 평균임금 산정과 무관한 점 등을 고려하면 이를 평균임금에서 배제하는 것이 오히려 통상의 생활임금을 산정한다는 평균임금 제도의 취지를 몰각시킨다고 판단하고 있다.¹⁷⁷⁾

(나) 서울고등법원은 경영성과급이 정기적·계속적으로 지급되고, 그 지급에 관하여 회사와 근로자 간에 그 지급에 관한 노동관행에 따라 회사에게 지급의무가 있다고 인정되면 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 해당한다고 보았다.¹⁷⁸⁾

첫째, 경영성과급이 근로복지기본법을 근거로 하여 근로자복지 차원에서 기업의 경영성과 중 일부를 근로자에게 분배한 것이고, 지급기준과 재원이 되는 당기순이익은 회사 자산의 규모, 시장상황, 경영판단 및 경영전략 등의 영향을 받을 뿐, 개

177) 대법원은 공공기관 경영평가성과급이 전체 급여에서 차지하는 비중을 임금 판단 요소 중 하나로 들었는데, 이는 급여에서 차지하는 비중이 큰 경우 근로자의 기대와 의존성이 크고, 사용자도 주요 지출로 예측하고 있다는 점을 고려한 것으로 보인다(대법원 2018.12.13. 선고 2018다231536 판결).

178) 서울고법 2022.1.21. 선고 2021나2015527 판결.



별 근로자의 근로제공과 관계없으므로 ‘근로의 대가’가 아니라는 회사측의 주장을 다음과 같이 반박하고 있다.

① 회사가 2003년부터 15년 이상 매년 계속해서 기준연도의 당기순이익 달성에 관한 사업목표를 제시하고 일정한 당기순이익 달성시 일정율의 경영성과급 지급을 내용으로 하는 지급기준을 작성하였고, 결산 후 지급기준을 달성하면 그 기준에 따라 연 1회씩 지급되었으므로 정기적·계속적 급여이다. 또한 지급원인인 사업목표의 달성은 근로제공의 결과라고 볼 수 있고 전체 직원(비상근임원 제외)에게 지급하였으므로 이를 임의적·은혜적 성질의 금품이라고 할 수도 없다. 오히려 지급대상 기간 동안의 근무기간에 비례적으로 지급율이 정해졌다는 점에서 근로의 대가성이 인정된다.

② 근로기준법상 임금성 판단에 대하여 다른 법령과 규범조화적 해석이 요청되긴 하지만 근로복지기본법의 관련 규정은 근로자복지 향상을 위한 규율대상을 정한 것으로 보일 뿐 노동복지의 한 유형인 성과배분을 언제나 임금에서 배제하려는 입법자의 의사가 반영된 것이라고 단정할 수 없다. 또한 독자적인 보호법익에 기초하여 판단되어야 할 근로기준법상 임금 개념의 해석이 근로복지기본법의 해석에 좌우되어서는 안된다. 다시 말해 어떤 급여의 임금성 여부는 근로기준법 자체의 관점에서 그 실질에 비추어 임금으로 보호할 필요성 여부를 고려하여 판단해야 한다.

③ 회사는 손해보험업, 자산운용을 목적으로 하는 법인이고, 이 사건 성과급의 지급요건이 되는 당기순이익은 근로자의 근로제공을 발생원인으로 하기 때문에 근로제공과의 관련성을 인정할 수 있고, 원래의 업무수행 이외의 사유로 지급하는 은혜적 성격의 급여가 아니라면 근로제공과 밀접한 관련성을 인정할 수 있다.

④ 실제로 지급된 경영성과급의 변동폭(이 사건의 경우 0%에서 716%)이 크다는 이유만으로 임금성을 부정할 수는 없다. 최저 지급기준에 미달하여 특정 연도에 경영성과급이 실제로 지급되지 않는 경우가 있다고 하더라도 성과급이 전체 급여에서 차지하는 비중, 지급 실태와 평균임금 제도의 취지에 비추어 근로의 대가로 지급된 임금에 해당할 수도 있다. 이 사건 경영성과급은 지급기준상 원고들의 연간 총급여에서 4.2% - 26%의 비중을 차지하고 매년 일정한 시기에 지급되고 있다면 근로자



에게 통상의 생활임금으로 볼 여지가 있다는 점에서 근로대가성을 인정할 수 있다.

둘째, 임금으로 인정되기 위해서는 사용자에게 단체협약, 취업규칙, 근로계약, 노동관행 등에 의하여 지급의무가 있어야 한다. 특히 노동관행이란 객관적으로 반복된 관행에 규범력을 부여하는 것인데, ‘법적 확신’이란 ‘관행의 계속이 당연하다고 여겨지는 것’ 정도를 의미하는 것으로 보면 충분하고 규범의 적용을 적극적으로 의도할 것까지 요구하는 것은 아니다(특히 노사 간 대립을 기본으로 하는 근로관계의 영역에서 노사 간 내심의 의사가 전적으로 일치하는 경우를 찾기가 쉽지 않다는 점도 고려해야 한다). 이러한 관점에서 이 사건 판결은 지급의무성의 존재에 대해 다음과 같이 판단하고 있다.

① 지급의무가 있다는 것은 임의로 배제하거나 발생 여부가 불분명한 조건에 좌우되지 않는다는 것을 말한다. 이 사건 회사는 지급기준이 충족되면 임의로 이 사건 경영성과급의 지급을 거절할 수 없었고, 지급기준 미충족으로 실제 지급되지 않은 경우가 있다고 하더라도 이는 지급될 구체적인 액수가 사후에 확정된다는 의미일 뿐 지급의무성 자체가 부인되지 않는다. 회사가 해마다 미리 당기순이익에 관한 구체적인 경영성과급 지급기준을 마련하고 결산 이후 그 기준에 따라 경영성과급을 지급하여 왔다면 이를 불분명한 조건이라고 할 수 없다.

② 처음 경영성과급 도입 당시에는 지급의무 여부가 불분명하였더라도 그때부터 15년 이상 경영성과급 지급기준을 작성하고 그에 따라 지급하여 왔고, 지속적으로 경영성과급 지급기준을 마련하고 그에 따른 경영성과급 지급을 예정하고 있었다면 ‘관행의 계속이 당연하다고 여겨질 정도’의 인식(법적 확신)에 이르렀다고 보인다.

③ 회사가 해마다 해당연도 경영성과급 지급기준에 관하여 ‘당해연도에 한하여 지급되는 것이고, 경영실적에 따라 지급여부와 지급금액이 달라지며, 지급사유의 발생이 불확정적·일시적이므로 평균임금 산정 항목에서 제외된다’는 취지를 밝힌 사실이 있다. 그러나 이는 해당연도 지급기준과 그 적용이 당해연도에 한한다는 시간적 적용범위를 명시한 것일 뿐, 이 급여가 1회성이고 앞으로는 지급의무가 없다는 의사표시라고 볼 수 없다. 실제로 회사는 위 문구에도 불구하고 15년간 해마다 경영성과급 지급기준을 마련하여 실제로 경영성과급을 지급하여 왔다. 또한 “경영실적



에 따라 지급여부와 금액이 달라진다는 것”은 경영성과급 지급기준의 적용 결과 지급조건에 해당하지 않는 경우 경영성과급 지급율이 0%가 될 수 있다는 의미일 뿐, 지급요건 충족에 따라 지급여부와 액수가 달라지거나 심지어 지급되지 못할 수 있다는 사정만으로 지급의무가 없다고 할 수 없다.

④ 지급조건이 사용자가 일방적으로 정하는 수의조건(隨意條件)이 아닌 이상 제반 사정에 비추어 지급의무를 인정할 수 있는 바, 이 사건 경영성과급은 지급여부(회사가 임의로 경영성과급을 지급하지 않거나 지급기준을 배제할 수 없었던 것으로 보인다) 및 지급대상이 명확하게 확정되어 있었던 점, 구체적인 지급액수까지 정하여져 있지 않더라도 당기순이익을 기초로 기준월급여에 지급율을 곱하는 지급방식이 개괄적으로 정하여져 있었던 점에서 지급의무를 인정할 수 있다.

2. 경영성과급의 임금성을 부인한 하급심 판결

(가) 서울남부지방법원은 회사가 기본적으로 근로자들 개인의 성과가 아닌 회사의 집단적 경영성과를 기준으로 경영성과급을 지급하였고, 그 지급 여부 및 수준 또한 사전에 노사합의 혹은 취업규칙 등에 정해져 있는 것이 아니라, 회사가 임의로 해당 내용을 결정한 사례에서 그 경영성과급의 임금성을 부인하였다.¹⁷⁹⁾ 구체적인 판단근거는 다음과 같다.

첫째, 지급사유 및 조건의 확정성 여부와 관련하여 단체협약, 취업규칙, 급여규정 등에 경영성과급의 지급 근거가 명시되어 있지 않고 회사가 경영성과급의 지급 여부 및 구체적 지급조건을 결정하여 왔다는 점.

둘째, 근로의 대가(근로제공과의 밀접한 관련성)와 관련하여 경영성과급 지급시에는 그 구체적인 지급 범위 및 기준이 개별 근로자가 통제할 수 없는 요인¹⁸⁰⁾에 의

179) 서울남부지법 2021.8.20. 선고 2020나72056 판결.

180) 당해 연도 사업계획목표, 이전 연도 실적 대비 재무성과(재무제표상 매출, 영업이익, EBITDA 등) 및 경쟁성과(시장점유율, 영업이익률, EBITDA 등) 등의 경영실적을 고려하여 경영성과급 지급 여부 및 지급률 등을 결정하였다. 여기서 EBITDA는 Earnings



해 결정되고 근로자의 근로제공 그 자체와 직접적이거나 밀접하게 관련되지 않은 점,

셋째, 경영성과급이 지급조건과 무관하게 계속적, 정기적으로 지급된 것은 아닌 점,

넷째, 경영성과급의 지급 실태 및 전체 급여에서 차지하는 비중이 일률적이지 않으므로, 이를 포함하여 평균임금을 산정해야 근로자의 통상의 생활임금을 사실대로 산정하는 평균임금 제도의 취지에 부합한다고 보기도 어려운 점,

다섯째, 근로자 간의 형평성이나 사기 진작 등을 고려한 경영진의 재량으로 경영성과급이 지급되어 회사에 지급 의무가 지워져 있다고 보기 어려운 점,

여섯째, 경영성과급 지급 목적이 근로자들에 대한 동기부여를 통하여 회사 전체의 성과 향상을 도모하는데 있고, 이와 같은 경영상 목적을 위해 주주의 이익을 일부 희생하여 경영성과를 근로자에게 배분한 것인 점 등을 근거로 경영성과급이 퇴직금 산정 근거가 되는 평균임금에 해당한다고 볼 수 없다고 평가하였다.

본 판결에서 가장 중요하게 고려한 내용은 경영성과급의 구체적인 지급 여부 및 조건, 내용 등을 근로자의 근로제공과 관련하여 결정하거나 근로자가 통제하고 있는지 아니면 사용자의 자의적인 기준에 따라 경영성과급의 지급을 결정하는지 여부라고 판단된다. 근로제공과의 직접 또는 밀접한 관련성의 존부를 판단함에 있어서는 경영성과급이 개별 근로자의 통제 하에서 제공되는 근로(노무)의 수준, 정도 등을 기초로 지급되는 것이 아니라, 기업의 경영성과에 따라 사용자의 재량에 의해 경영성과급이 결정되어 지급되고 있다면, 이를 개별 근로자의 노무 제공에 따른 대가로서 지급되는 금품이라고 보기 어렵다고 판단하였다.

(나) 서울중앙지방법원은 위의 (가)의 사례와 달리 그 지급 기준에 대한 내용(지급

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization의 약자로, 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 현금창출 능력을 나타내는 수익성 지표. 이자(Interest), 법인세(Taxes), 감가상각비용(Depreciation and Amortization)을 빼기 전의 순이익을 의미한다.



대상 인원, 지급 대상기간, 지급 일자, 지급 금액 계산 방식 및 지급률 등)이 회사가 정한 취업규칙(인사규정)에 구체적으로 명시되어 있는 사례에 대해서도 다음과 같은 이유를 들어 경영성과급의 임금성을 부인하였다.¹⁸¹⁾

첫째, 지급기준일 현재 재직자 및 일부 휴직자만 경영성과급을 지급받을 수 있는데, 이는 ‘특정 시점에 재직중일 것’이 지급 요건이므로 경영성과급이 근로의 대가로서 지급된 것이 아니라는 점(근로 대가성 여부),

둘째, 개별 근로자들이 경영성과급의 지급 여부나 지급액수에 영향을 미칠 수 없고, 개별 근로자들이 통제할 수 없는 요인에 의해 경영성과급의 지급이 영향을 받는 점,

셋째, 인사규정이나 연봉계약서 등이 경영성과급의 지급과 관련된 규정들이 있긴 하나, 경영성과급의 구체적 액수를 정하기 위한 기초금액 등이 정해져 있지 않고 지급률에 대한 결정에 있어 경영진에게 광범위한 재량권이 부여되어 있어 경영성과급의 지급 조건 등이 확정되어 있다고 볼 수 없는 점(지급 조건의 확정성 여부),

넷째, 매년 특정 시점에 지급되고 그 시점에 재직하지 않으면 받을 수 없으므로, 평균임금 계산 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안의 임금 총액을 그 기간의 총 일수로 나눈 것이 평균임금이라는 점을 고려하면 경영성과급을 지급할 무렵에 퇴직하였는지 여부에 따라 평균임금이 달라지게 되므로 통상적인 근로자의 생활임금을 기준으로 퇴직급여를 계산하는 노동관련 법령에도 부합하지 않는 점(평균임금 제도 취지에 대한 부합성 여부),

다섯째, 회사 취업규칙에는 급여에 경영성과급을 언급하지 않고 있고 매년 거의 빠짐없이 지급했다는 사실이 경영성과급을 임금으로 하기로 하는 노동관행을 형성

181) 서울중앙지법 2021.1.12. 선고 2019가단5199298 판결. 이 사건 사례는 경영성과급을 ‘목표 인센티브’와 ‘성과 인센티브’로 구분하는데, ‘목표 인센티브’는 각 사업부문 및 사업부의 재무성과, CEO 미션, 공통항목(환경안전, 컴플라이언스, 조직문화)로 구성된 조직목표를 정하고 평가를 거쳐 등급을 나누고 소속 근로자들에 대해 차등하여 지급률을 정한다. ‘성과 인센티브’의 경우에는 각 사업부의 EVA(Economic Value Added: 경제적 부가가치로서, 세후 영업이익에서 자본비용을 뺀 금액)의 20%를 재원으로 하여 각 사업부의 업적 고과에 따라 정해진 지급률을 계산기초금액에 곱한 금액을 지급하며, 각 사업부별로 근로자들에게 연봉의 50%를 상한으로 지급된다.



했다고 보기도 어려운 점(취업규칙 및 노동관행의 존재 여부) 등을 근거로 경영성과급이 퇴직금 산정 근거가 되는 통상임금에 해당한다고 볼 수 없다고 평가하였다.

이 판결에서도 경영성과급의 임금성 여부를 판단함에 있어 개별 근로자들의 근로(노무) 제공에 의해 경영성과급의 지급이 통제되거나 결정되는지 여부가 핵심적인 요소로 작용한 것으로 보인다. 그런데 이 판결은 경영성과급의 임금성을 판단함에 있어 대법원에 의해 확정된 통상임금의 판단 징표(특정 시점에 재직중인 자에 대해서만 지급되는 점)가 사용되었는데, 소정근로에 대한 대가성 및 고정성 판단 징표를 가지고 ‘근로의 대가성’ 자체를 판단하는 것이 타당한지 의문이다. 근로의 대가성이 인정되는 금품에 대해서도 경우에 따라서는 재직요건의 유효성을 인정할 수 있기 때문이다(이에 대해서는 앞의 제2장 제4절 III. 2. 참고).

(다) 수원고등법원은 경영성과급의 지급 기준에 대한 내용(지급 대상 인원, 지급 대상기간, 지급 일자, 지급 금액 계산 방식 및 지급률 등)이 회사가 정한 취업규칙(HR규정 및 급여·복리후생·근태 기준)에 구체적으로 명시되어 있는 경우로서 구체적인 지급액 및 지급률을 제외한 나머지 지급 조건이 사전에 결정되어 있는 사례에서 경영성과급의 임금성을 부인하였다.¹⁸²⁾

구체적인 판단근거도 위의 (나) 판결과 마찬가지로 ① 근로와의 밀접한 관련성 여부, ② 지급 조건의 확정성 여부, ③ 평균임금 제도 취지에 대한 부합성 여부, ④ 근로 대가성 여부, ⑤ 취업규칙 및 노동관행의 존부 등 다섯가지가 제시되었다.

다만, 판결 내용 가운데 (나) 판결과 일부 차이가 나는 부분은 다음과 같다. 먼저 ② 지급 조건의 확정성 여부와 관련하여 (나) 판결과 달리 이 사건의 경우 인센티브 계산을 위한 지급률이 구체적으로 규정되어 있다는 점에 대해서는 그것만으로는 어떤 근로자에게 어떤 지급률을 적용할 것인지에 대해서 특정할 수는 없고 결국 경영진에게 재량이 부여되어 있다는 것은 동일하다고 판단하였다. 또한 ④ 근로 대가성 여부와 관련하여 (나) 판결의 내용에 더하여 이 사건 경영성과급의 경우 근로복지기

182) 수원고법 2021.6.17. 선고 2020나26085 판결. 이 사건 사례는 위의 (나)와 유사하다.



본법 제84조 규정에 따른 사업주의 성과 배분에 해당하고 따라서 임금성을 긍정하기 어렵다고 판단하여 임금성을 부정하는 법률상의 근거를 추가로 제시하였다.

IV. 판결에 대한 검토 및 경영성과급의 임금성 여부

1. 판결의 검토

위의 하급심 판결들 중에 경영성과급의 임금성을 인정한 판결은 가능한 사용자의 지급의무가 인정되고 계속적·정기적으로 지급되고 있다면 포괄적으로 근로의 대가로서 인정될 수 있다는 태도를 보여주고 있다. 지급의무와 관련하여 노동관행으로도 지급의무를 인정할 수 있는데 노동관행의 요건으로서 ‘법적 확신’에 관해서도 완화된 기준을 적용하여 노동관행에 의한 지급의무를 적극적으로 인정하고 있다.¹⁸³⁾

반면에 경영성과급의 임금성을 부정하는 판결들은 주로 대법원이 복지포인트 사건 판결에서 판시한 바와 같이 근로의 대가성을 “근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성”에서 찾고, 경영성과급은 시장 상황, 경영자의 경영판단에 따른 경영전략, 회사의 재무상태 등의 요소에 따라 결정이 된다는 점에서 기본적으로 ‘근로제공 관련성’을 인정하기 어려울 것이라는 태도를 취하고 있다.

한편, 경영성과급의 임금성을 인정한 하급심 판결들은 이 경영성과급이 평균임금 계산에 산입되어야 한다는 입장을 제시하고 있는바, 매년 일정한 시점에 지급되고, 근로자가 받는 연간 총급여에서 차지하는 비중이 높다면 통상의 생활임금으로 보아야 한다는 입장을 제시하고 있다.

하급심 판결에서 다루어진 주요 논점을 개관하면 다음과 같다.

183) 서울고법 2022.1.21. 선고 2021나2015527 판결 참고. 그에 따르면 노동관행이란 객관적으로 반복된 관행에 규범력을 부여하는 것인데, ‘법적 확신’이란 ‘관행의 계속이 당연히 있다고 여겨지는 것’ 정도를 의미하는 것으로 보면 충분하고 규범의 적용을 적극적으로 의도할 것까지 요구하는 것은 아니다.



첫째, 위 하급심 판결들은 경영성과급의 지급대상이 사전에 특정되어 있는지 여부와 지급사유 및 지급방식을 경영성과급의 임금성 판단의 요소로 보고 있다. 예를 들어 영업직 근로자에 대한 실적급과 같이 근로자 개인의 업무 성과(근로의 양과 질)에 따라 지급되는 성과급의 경우, 그 자체로 성과급의 지급대상이 ‘실질적인 근로의 결과에 따라 성과가 달라지고 그 보상이 이루어지는 경우’이므로 근로제공과의 직접 또는 밀접한 관련성을 인정할 수 있다.¹⁸⁴⁾ 이와 달리 기업이 자신의 영업이익의 일부를 모든 근로자들에게 지급하는 집단적 경영성과급의 경우에는 지급조건 등을 추가로 고려하여 근로제공과의 관련성을 판단하고 이를 토대로 임금인지 여부를 결정하게 될 것이다.

대법원 복지포인트 사건 판결¹⁸⁵⁾에 따르면 임금은 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 가지고 있어야 한다고 본다. 개인성과급의 임금성이 인정되는 이유는 근로자의 근로제공과 금품 지급 간에 직접적인 관련이 있기 때문이다. 다만, 경영성과급을 개인성과급과 집단성과급으로 이원화하여 ‘근로제공 관련성’ 인정 여부를 일률적으로 판단하는 것(예를 들어 개인성과급은 임금, 집단성과급은 비임금)은 주의해야 한다. 집단성과급은 근로계약에 따라 수행하는 직무 및 역할과 관계없이 회사의 순수한 경영실적에 따라 지급되는 경우도 있지만 근로자의 직무 및 역할을 반영하여 지급되는 경우도 있다. 후자의 경우에는 근로제공과의 관련성이 인정될 수 있을 것이다.

예를 들어 판매조직의 경우 개인의 판매 실적에 따라서 인센티브를 지급할 수도 있지만 조직 단위별 협업을 통해서 실적을 달성할 수 있는 경우도 있기 때문에 부서 판매 실적, 기업 판매 실적 등에 따라 다양한 급부를 판매조직의 성과급의 발생

184) 실제 판결 사례에서도 개인 성과급의 경우 임금성이 인정되는 사례가 더 빈번하게 발생하는데, 이는 개인의 업무 실적이 곧바로 성과급으로 연결되는 직종의 경우 실제 성과급이 전체 임금에서 차지하는 비중이 크다는 점도 크게 작용하는 것으로 보인다(대법원 2002.5.31. 선고 2000다18127 판결; 대법원 2011.3.10. 선고 2010다77514 판결; 대법원 2011.7.14. 선고 2011다23149 판결 등). 다만, 개인 성과급의 임금성이 부정된 판결도 존재(대법원 2004.5.14. 선고 2001다76328 판결)하는데, 이 경우에는 하급심에서 그 구체적인 지급률 및 지급일이 노사 합의에 의해 결정되는 것으로 판시한 바 있어 사실상 개인 성과급이 아닌 집단적 성과급으로 보아야 한다는 견해도 존재한다.

185) 대법원 2019.8.22. 선고 2016다48785 판결.



단위로 삼을 수 있다. 이 경우 개인 실적과 부서 판매 실적 및 기업 판매 실적의 ‘근로제공 관련성’을 다르게 볼 수 있을지 의문이다. 효율적인 판매를 위해 실적 측정의 단위가 개인, 부서, 기업이 될 뿐 결국 판매직원에게 지급되는 성과급은 모두 판매행위를 대가로 하여 지급되는 것이다. 따라서 판매직원들에게 판매행위를 통해서 달성될 수 있는 목표를 부여하고 그 달성 여부나 달성 정도에 따라 지급되는 성과급이라면 근로제공과 성과급 지급 간에는 밀접한 관련성이 있기 때문에 ‘근로제공 관련성’을 부인할 수 없다. 또한 경영에 대한 책임을 부담하는 관리자에게 자신이 관리하는 조직의 성과에 따라 기본급 외의 성과급을 약정한다면 이는 관리자가 관할하고 있는 조직의 관리업무를 통해서 달성될 수 있는 것이고 관리자로서의 근로제공과 성과급 지급 간에는 밀접한 관련성이 있기 때문에 이 역시도 ‘근로제공 관련성’을 인정할 수 있다. 따라서 측정단위가 개인이나 집단이나에 따라 ‘근로제공 관련성’이 다르게 판단되는 것은 아니다.

한편, 당기순이익 및 EVA(경제적 부가가치, 기업이 영업활동을 통해 창출한 순가치의 증가분)만을 기준으로 산정되는 경영성과급(집단성과급)은 근로자의 직무나 역할에 따른 ‘근로제공’과 관련 없이 오직 회사의 수익만을 기준으로 한다. 이러한 경영성과급은 근로자의 근로제공 외에도 시장의 상황, 경영자의 경영판단에 따른 경영전략, 회사의 재무상태 등 다양한 요소에 따라 결정된다는 점을 들어 ‘근로제공 관련성’을 인정하기 어렵다는 입장도 있다. 반면에 근로자들이 집단으로 제공한 협력이 회사의 경영성과에 기여한 가치를 인정하여 근로자들에게 그 몫(배당)을 지급하는 것이므로 근로의 양과 질에 밀접한 관련이 있다고 평가하는 하급심판결도 있다.¹⁸⁶⁾

둘째, 경영성과급의 임금성 여부를 판단함에 있어 핵심 기준은 그것이 근로자들이 제공하는 근로제공과 어떤 관련성을 갖고 있는가 하는 점이다. 다시 말하면 경영성과급이 어떠한 요소에 의하여 결정·지급되는가 하는 점이다. 만약 성과급의 결정·지급에 있어서 ‘근로자들의 근로제공과 직접 또는 밀접하게 관련된 사항’들이 상당한 영향을 미친다면 이는 의심의 여지 없이 근로의 대가로 인정될 가능성이 높

186) 서울중앙지법 2021.6.17. 선고 2019가합542535 판결.



다. 예컨대 위에서 검토한 개인성과급의 경우¹⁸⁷⁾나 공공기관의 경영평가성과급 판결¹⁸⁸⁾에서 이 점이 확인될 수 있다. 경영성과급의 법적 성격에 대한 논란의 계기가 되었던 공공기관의 경영평가성과급은 원래 공공기관의 상여성 인건비에 포함되어 있던 재원을 바탕으로 성과급으로 전환시켜 공공기관 간의 경쟁과 생산성 향상을 촉진하기 위해 정부의 경영평가 방법을 통하여 지급되고 있는 것이다. 즉, 경영평가 성과급의 뿌리는 인건비라고 할 수 있다.

공공기관은 법령과 정부의 지침에 따라 근로자들이 어떤 항목들을 중심으로 업무를 수행하여야 더 나은 평가를 받을 수 있는지가 구체적으로 정해져 있고, 특히 이 윤추구만을 목적으로 하지 않고 공공서비스 제공이나 정부 사업목표 달성 등 복합적인 내용을 목적으로 하는 공공기관의 특성상, 그 평가의 대상이 사기업의 영업이익이나 경영지표 등과 같은 예측 불가능한 내용이 아니라 경영계획(경영비전 실행 전략, 실행력 제고 노력 등), 고객관리(고객만족도, 고객관리 활동), 사회적 가치 구현(윤리경영, 사회책임성 제고 노력, 일자리 창출 등), 조직 및 인적자원 관리(조직 관리 효율성, 인적자원 및 역량 관리), 보수 및 복리후생 관리(인건비 인상률, 노사 관리 등), 국정과제 관리(공공정보 개발 및 활용, 정부정책 협력도), 재무예산 관리 등 과업별로 구체화되어 정해진 항목을 달성하는 것을 내용으로 하고 있다.¹⁸⁹⁾ 근로자들 또한 매년 그러한 내용을 숙지하고 더 나은 평가 결과를 만들어 내는 방향으로 근로를 제공¹⁹⁰⁾하고, 경영평가성과급 또한 그러한 정부의 경영평가 결과에 따

187) 개인성과급은 그 지급 여부나 지급액에 대하여 근로자 개인의 근로제공의 양과 질이 실질적인 영향을 미친다. 특히 그 구체적인 지급조건(업무성거나 실적 및 지급액을 어떤 방식으로 산정할 것인지)이 미리 단체협약이나 취업규칙 등에 정해져 있는 경우라면 사실상 이는 근로제공의 결과에 연동하여 자동적으로 그 지급액이 정해지고 사용자가 그 지급의무를 부담하게 되므로 근로대가성을 쉽게 인정할 수 있다. 예를 들어, 자동차 판매 딜러가 판매하는 차종의 가격에 따라 얼마의 성과급을 받을지가 미리 정해져 있다면, 이는 그 자체로 근로의 대가이거나 혹은 근로제공과 밀접한 관련성이 있는 임금에 해당한다고 평가될 수 있다.

188) 대법원 2018.12.13. 선고 2018다231536 판결.

189) 한승준, “공공기관의 특성에 따른 경영실적 평가의 합리성 제고 방안 - 문체부 소관 기타공공기관 및 단체를 중심으로”, 「현대사회와 행정」, 제30권 제1호, 90면 참조.

190) 실제 일부 공공기관들의 경우 경영실적 평가에 있어 ‘고객만족도’ 등과 같은 항목에 더 나은 평가를 받기 위해 실제 고객에 대한 만족도 설문조사에 직원들이 답변하도록 조직적으로 활동을 하기도 하였다. https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202005131036170105 참조.



라 기계적으로 정해진 비율을 곱하여 일괄적으로 사용자가 지급하여야 한다¹⁹¹⁾.

이에 비하여 민간기업의 경영성과급에 대해서는 근로제공과의 “직접 또는 밀접한 관련성”을 인정하기 어렵다는 견해가 있다. 물론 민간기업의 경우에도 미리 단체협약이나 취업규칙에서 기업의 영업이익, 당기순이익 등의 일정 비율을 경영성과급으로 지급한다는 나름의 지급기준과 지급액 산정방식 등이 사전에 구체적으로 정해져 있을 수 있다. 하지만 기업의 전체 영업실적이 경제 및 시장상황, 동종업계의 동향, 회사의 영업상황과 재무상태, 경영진의 경영전략적 판단 등 개별근로자로서는 통제하거나 관리할 수 없는 요소에 의하여 좌우되는 것이고, 경영진의 판단과 노사협회의 결과에 따라 지급 여부가 결정되므로 지급이 확실하다고 단정하기 어렵다고 보기 때문이다. 하지만 근로제공이 없다면 기업의 영업실적이 발생할 수 없다는 이유로 근로제공의 관련성을 인정하는 견해도 있다.¹⁹²⁾ 이처럼 민간기업의 경영성과급이 근로의 대가인지 여부에 대해서는 여전히 논란이 되고 있다.

셋째, 경영성과급의 임금성 여부를 판단함에 있어 구체적인 지급 동기나 배경도 검토대상이 되고 있다. 이와 관련하여 참고할 수 있는 법령이 근로복지기본법과 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」이다. 2001년 제정된 근로자복지기본법은 제20조 제1항에서 사업주에게 초과 달성된 경영성과를 근로자에게도 배분하도록 노력할 의무를 규정하였고, 현행 근로복지기본법 제84조는 “성과배분”이라는 표제로 동일한 내용을 규정하고 있다. 이는 사업주로 하여금 성과배분 제도를 도입할 것을 노력하거나 촉구하도록 규정한 것이라고 할 것이다. 그리고 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제20조 제1항 제1호는 “생산성 향상과 성과배분”을 노사협의회의 협의사항으로 명시하고 있다.¹⁹³⁾

경영성과급이 이와 같은 ‘성과배분’의 목적을 포함하고 있다면 그 임금성 판단에 어떤 영향을 미치는지 검토를 요한다.¹⁹⁴⁾ 즉, 단순히 근로자들이 경영성과급의 형성

191) 권혁, “임금성 판단에 관한 연구”, 한국경영자총협회, 2020.10., 44면 참조.

192) 대표적으로 박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 319면 이하.

193) 박지순/이진규, “경영성과급의 임금성 판단”, 183면.

194) 복지포인트의 임금성에 관한 대법원 전원합의체의 다수의견은 근로복지기본법상 선택적 복지제도의 근거 법령에 비추어 복지포인트를 임금으로 볼 수 없다고 판시한 바 있다(대법원 2019.8.22. 선고 2016다48785 전원합의체 판결). 그에 따르면 복지포인트의 근



에 기여하거나 영향을 미칠 수 없다는 것에서 나아가, 사용자가 그러한 경영성과급을 지급하기 위한 목적이 애초에 개별 근로자가 제공한 근로의 양 또는 질과 관련성이 없다는 점이 명확하다면 이는 그 자체로 근로제공과 밀접한 관련성을 부인할 수 있는 근거가 될 수도 있을 것이다. 예를 들어, 경영성과급 지급이 장래에 대해 근로자들의 사기와 동기부여의 목적에서 이루어졌음을 명확하게 확인할 수 있다거나, 노사 간의 분쟁 발생을 방지하며 노사화합을 도모하려는 목적에서 그러한 경영성과급이 지급된 것이라면 그것이 매년 계속적으로 지급되었다 하더라도 근로대가성을 부인할 수 있는 사정으로 인정될 수 있는 것이다. 하지만 근로복지기본법은 그 규정이 임금성 판단의 강행적 기준이 되는 것은 아니다. 반대로 성과배분도 그것이 당사자 사이에 보수약정의 대상이라면 당연히 노무제공의 반대급부로 인정될 수 있다. 즉, 임금성이 인정될 수 있는 것이다. 따라서 단순히 성과배분이라는 사실만으로 임금성 여부를 판단하는 것은 한계가 있다.

넷째, 경영성과급이 단순히 전체 지급된 총급여 중에서 차지하는 비중이 상당하다는 이유만으로 이에 대한 ‘근로대가성’을 인정하는 것은 타당하지 않다. 전체 임금에서 경영성과급의 비중이 높고 낮은 것이 근로의 대가성을 판단하는 기준이 될 수는 없을 것이다.

다섯째, 대법원이 특별생산격려금 사건 판결 등에서 판시한 바와 같이 그 지급사유의 발생이 불확정적이고 지급조건이 경영성과나 노사관계의 안정 등과 같이 근로자 개인의 업무 실적 등 근로 제공과 직접적 관련성이 없는 요소에 의하여 결정되도록 되어 있어 그 지급 여부 및 지급대상자가 유동적인 경우에는 임금으로 보기 어려울 것이다.¹⁹⁵⁾ 이와 같은 경우에는 지급사유나 지급조건이 존재하더라도 그것

거는 근로자복지기본법상의 선택적 복지제도(제3장 '기업근로복지' 중 제3절)인데, 근로복지기본법 제3조 제1항은 “근로복지(임금·근로시간 등 기본적인 근로조건은 제외한다. 이하 같다)정책은 근로자의 경제·사회활동의 참여기회 확대…”라고 규정하여 근로복지의 개념에서 임금을 명시적으로 제외하고 있다. 따라서 근로복지기본법상 선택적 복지제도를 근거로 도입된 복지포인트는 임금과 같은 근로조건에서 제외된다고 보는 것이 타당한 해석이라고 한다. 복지포인트의 임금성 여부를 판단할 경우 근로기준법 외에 다른 관련 법률의 규정도 충분히 고려하여 규범조화적으로 판단해야 한다고 보면, 근로복지기본법의 규정 내용에서 알 수 있는 선택적 복지제도에 대한 입법자의 기본적인 규율 내용은 복지포인트가 임금이 아니라는 점에 기초하고 있음은 분명하다고 보았다.

195) 대법원 2002.6.11. 선고 2001다16722 판결, 대법원 2006.5.26. 선고 2003다54322,



이 불확정적이고 유동적이기 때문에 지급의무가 존재한다고 볼 수 없기 때문이다.¹⁹⁶⁾ 특히 임금지급의무의 발생에는 원칙적으로 근로자의 근로제공이 필수적이지만, 경영성과급 지급을 위해서는 근로자가 전혀 통제할 수 없는 요소들, 예컨대 경영진의 경영전략적 판단, 전체 시장 상황, 경쟁업체의 동향, 원자재의 가격 등 다양한 요소들이 작용할 수밖에 없으며 근로를 제공하면 경영성과급 지급의무가 발생한다는 논리는 성립되기 어렵다고 보는 견해도 있다.¹⁹⁷⁾

설령 사전에 약정된 조건의 성취에 따라 사용자의 지급의무가 존재하더라도 그 지급의무만으로 근로의 대가성이 당연히 충족되는 것은 아니다. 예를 들어 경조사비와 같이 그 지급 근거가 취업규칙에 있고 그에 따라 지급사유가 발생하면 사용자에게 지급의무가 발생하지만 이는 근로의 대가성이 인정되지 않으므로 임금으로 보기 어렵다.

2. 경영성과급의 임금성 여부

기업마다 지급조건, 지급방식, 지급 내용이 다른 경영성과급의 법적 성격(임금인지 여부)을 일률적으로 판단하기는 어렵다. 개별 사례마다 계속적·정기적 급여인지 여부, 지급의무의 존부, 근로의 대가성 판단 등에서 모두 다른 결론에 이를 수 있기 때문이다.

지금까지 임금성 판단에 관한 통상적 기준에 따라 경영성과급의 임금성을 검토할 경우 i) 계속적·정기적 지급, ii) 지급의무, iii) 근로의 대가라는 세 가지 기준을 적용하게 된다. 이때 i) 계속적·정기적 지급 여부는 비교적 명확히 알 수 있는 경우가 많아 큰 이슈가 되기 어려울 것이다. ii) 지급의무의 경우 근로계약, 취업규칙

54339 판결, 대법원 2011.10.13. 선고 2009다86246 판결, 대법원 2013.4.11. 선고 2012다48077 판결 등.

196) 서울남부지법 2021.8.20. 선고 2020나72056 판결, 수원지법 2021.2.4. 선고 2020나55510 판결.

197) 같은 취지로 김희성/성대규, “성과배분으로서 경영성과급의 임금성 고찰”, 35면.



또는 단체협약에 관련 규정이나 약정 여부 및 그 내용을 살펴보아야 할 것이다. 예를 들어 회사의 이사회에서 지급 여부를 결정하거나 근로계약, 취업규칙 또는 단체협약에서 지급기준을 명시하지 않았다면 지급의무를 인정하기 어려울 것이다. 그러나 지급기준을 명시하지 않았더라도 노동관행으로도 지급의무를 인정할 수 있을 것이다.

다음으로 iii) 근로대가성을 검토해야 한다. 대법원은 복지포인트 사건 판결에서 계속적·정기적 지급 및 지급의무성이 인정된다고 해서 곧바로 “근로의 대가”라고 단정하기 어렵고, 근로제공과 금품지급 사이에 직접적 또는 밀접한 관련성이 있어야 근로의 대가로 인정될 수 있다고 보았다. 그에 따르면 경영성과급의 경우 성과 배분의 대상이 되는 기업의 이익과 근로자의 근로제공 사이에 직접 또는 밀접한 관련성이 있어야 한다. 물론 개별 사례마다 다르게 판단될 수 있기에 일률적으로 평가할 수는 없겠지만, 대법원의 입장에 따라 기업의 성과를 산정하는 지표로 활용되는 영업이익, EVA, 기업가치 등의 지표와 근로자 개인의 근로제공이 직접 또는 밀접한 관련성을 가지고 있는지 여부를 엄격하게 판단한다면 근로대가성이 인정되기는 어려울 것이다.

그렇지만 근로의 대가라는 문언이 가진 추상성과 포괄성을 감안하고, 근로자의 집단적 협업이 기업의 경영목표를 달성하고 경영실적을 향상시키는데 있어서 불가결한 요소라는 점을 고려하면, 기업의 경영환경이나 경영진의 경영전략 및 전반적인 시장상황 등이 경영성과의 달성에 주된 영향을 미친다고 하더라도, 근로자의 근로제공의 역할을 과소평가할 수는 없을 것이다. 이러한 이유로 직접성이나 밀접성이 약하더라도 어느 정도 관련성이 인정되면 근로대가성을 인정하는 것으로 해석하는 것이 타당하다고 판단된다.

그런데 임금에 관한 현행법의 규율구조를 보면 임금(근기법 제2조 제1항 제5호)은 근로자가 받는 보수의 본질에 관한 개념이고, 평균임금(근기법 제2조 제1항 제6호 및 동법 시행령 제2조 이하)은 특정 사안에 대하여 지급되는 수당의 산정방식을 정한 것이어서 양자는 서로 구별되는 개념이므로, 두 개념을 동일선상에 놓고 비교하는 것은 비교 범주가 잘못되었다고 할 수 있다. 하지만 현실에서 실제로 논란이



되는 것은 순수한 임금의 범위 그 자체라기 보다는 퇴직금 등의 산정 기준으로서 평균임금의 산입 범위에 관한 것이며, 통상의 생활임금으로 적절하지 않은 성격의 보수를 평균임금에 산입하지 않기 위해, 임금의 범위를 엄격하게 해석하는 것이 현실임을 고려하면 임금의 일반적 개념으로부터 평균임금에 산입되는 임금의 범위를 구별하기 위해서는, 두 개념 범주(임금 일반과 평균임금)가 서로 얹혀 동일한 것으로 판단되고 있는 문제점을 지적하지 않을 수 없다.

생각건대 근로자 보호 측면을 생각한다면 임금의 범위를 넓게 인정하고, 평균임금은 그 취지에 따라 통상의 생활임금을 반영할 수 있도록 그 산입 범위를 좀더 세밀하게 설정하는 것이 합리적일 것이다. 특정 금품이 평균임금에 산입되지 않더라도 임금으로 인정된다면, 임금보호의 관점에서 근로자에게 유리하고, 다른 한편으로 평균임금은 통상의 생활임금인지 여부를 기준으로 좀더 엄격하게 판단하는 것이 노사의 이익균형성은 물론 근로자 사이의 형평성 및 제도 취지에도 부합한다고 본다.

이를 경영성과급에 대해 적용하면 다음과 같다. 경영성과급도 포괄적인 근로의 대가로서 임금성을 인정하는 경우에도 경영성과급과 같이 변동성이 클 수밖에 없는 보상 부분을 근로자의 통상적인 생활임금으로 인정하여 평균임금에 포함시키는 것이 타당한지에 대하여 검토해야 한다. 평균임금이 근로자의 통상적인 생활임금을 객관적으로 산정하기 위한 도구개념이라고 한다면, 근로의 대가로서 즉, 대법원이 판시한 바와 같이 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 가지고 계속적·정적으로 지급되는 임금만이 평균임금 산입 대상에 포함되어야 할 것이다.

이 점은 일본과 독일의 사례를 보더라도 확인된다. 일본의 경우는 판례와 다수설이 대체로 노동의 대가를 엄격하게 해석하지 않고 사용자가 근로자에게 지급하는 것 중에서 임의적·은혜적 성격의 급여, 복리후생급여, 실비변상급여 등 3가지 유형을 소거법 방식으로 제외한 나머지를 노동의 대가로 해석하여 넓게 임금으로 인정하는데 비하여, 평균임금 산입 대상에는 그와 같은 임금 중에서 3개월을 초과하는 기간 단위로 지급되는 상여금(연 1회 또는 연 2회 지급되는 상여금)을 처음부터 평균임금에서 제외하는 방법으로 운영하고 있다(일본 노동기준법 제12조 제4항 참조). 독일의 경우는 임금에 대한 일반적 정의규정이 없고, 임금계속지급법(EFZG)에서 당



사자의 합의 방식으로 법정수당 지급 시 보너스와 같은 부가급여를 감축시킬수 있도록 하고 있다(두 나라 입법례에 대해서는 앞의 제2장 제3절 I.과 II. 참고).

우리나라의 경우도 평균임금의 산입 범위를 입법을 통해 개선하는 것을 생각해 볼 수 있을 것이다(입법론과 해석론에 관해서는 앞의 제2장 제4절 II 3. 참고). 예를 들어 경영성과급으로 지급되는 보상에 대하여 당사자의 합의에 따라 평균임금 산입 여부 및 그 반영 비율을 자율적으로 결정하도록 하거나, 일본 노동기준법이 규정하고 있듯이 일정 기간을 초과하여 지급되는 임금은 통상의 생활임금으로 보지 아니하여 평균임금에서 제외하는 입법론을 생각해 볼 수 있을 것이다. 다만 이와 같은 입법적 해결방법은 이해당사자들의 반발과 노동입법의 어려움을 고려하면 가까운 시일 내에 실현되기는 어려울 것으로 보인다.

그렇다면 그 다음으로는 법해석을 통한 합리적 해결방안이 모색되어야 한다. 다시 말해 법원이 포괄적 근로대가성을 인정하여 임금의 개념을 넓게 해석하되, 평균임금의 경우는 그 취지를 살려 해석을 통해 합목적으로 산입 범위를 결정할 수 있어야 할 것이다. 이러한 해석론적 접근방법이 불가능한 것도 아니다. 대법원은 이미 택시근로자의 초과운송수입금이 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 산입되는지 여부에 관한 판결에서 근로자의 통상적인 생활임금이라는 평균임금의 취지와 부합하지 않는다는 이유로 평균임금 산입 범위에서 제외하는 판단을 내린 바 있다.¹⁹⁸⁾ 이와 같이 평균임금이 통상의 생활임금 보장 취지에 맞게 산출되려면 적어도 계속적·정기적으로 지급되어야 하며, 근로제공과 어느 정도 밀접한 관련성이 있어야 하며, 임시적·우발적으로 지급되는 것이 아니라 그 지급이 예측가능한 것이어야 할 것이다.

앞에서 밝혔듯이(제2장 제4절 II. 3.) 대법원이 임금의 개념요소로 사용하고 있는

198) 대법원 2007.9.20. 선고 2007다32993·33002 판결 참고. 이 판결에서 대법원은 과거 사납금 제도 하에서 택시운송업에 종사한 근로자의 퇴직금 산정을 위한 평균임금 산정시 사납금을 초과한 초과운송수입금을 제외하였다. 반면에 대법원 2019.7.25. 선고 2016두42289 판결에서는 택시근로자의 산재보상금 산정과 관련한 평균임금 산정에 초과운송수입금을 포함하였다. 이처럼 대법원은 일반적인 임금성이 인정되는 금품이라도 사안에 따라 평균임금제도의 취지를 반영하여 탄력적으로 평균임금 포함 여부를 판단하고 있음을 알 수 있다. 이에 관해서는 박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 309면 참고.



계속적·정기적 지급 및 근로제공과의 직접 또는 밀접한 관련성이라는 판단기준은 평균임금의 산입 대상 범위를 결정하는 기준으로 보는 것이 타당하다. 임금 개념 그 자체에 대해서는 근로대가성의 의미를 비교적 넓게 해석하여, 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성까지는 아니더라도 어느 정도 관련성을 인정할 수 있다면 임금으로 인정해서 근로기준법상 보호를 받을 수 있도록 하는 것이 근로자 보호 취지에 부합할 것이다. 이러한 해석론에 따르면 집단적 경영성과급은 기업성과의 분배라는 관점에서 ‘노동의 몫’으로 할당된 것이고,¹⁹⁹⁾ 이에 대해서는 근로제공과의 포괄적 관련성을 인정할 수 있으므로 일반적인 임금이라고 할 수 있다. 다만, 이 경우에도 경영성과급이 평균임금 산입 대상이 되는지 여부는 그 금품이 계속적·정기적으로 지급되는지, 근로제공과 어느 정도로 밀접한 관련성이 있는지를 따져 사례별로 개별적으로 판단해야 할 것이다. 적어도 이렇게 해석하는 것이 평균임금 산입 범위와 관련하여 임금 개념에 대한 대법원의 입장과도 부합한다.

제2절 주식보상제도

I. 주식보상의 의의

최근에는 사용자가 종업원의 사기진작을 위하여 자사 주식 및 인센티브 형태의 보수를 지급하는 사례가 늘고 있다. 그렇다면 사용자가 종업원에게 지급하는 자사 주식이 임금인가? 원칙적으로 근로기준법에 따르면 임금은 통화로 지급되어야 한다. 다만, 법령이나 단체협약에서 정한 바가 있으면 통화가 아닌 현물로 지급할 수 있다. 따라서 사용자가 노동조합과 단체협약을 체결하여 종업원에게 임금 대신에 자사주의 지급을 약속하였다면 이는 임금으로 볼 수 있을 것이다. 다만, 자사주를

199) 박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 308면.



지급하는 방식은 매우 다양하므로 지급방식에 따라 그 법적 성격이 달라질 수 있다는 점에 유의해야 한다. 그 법적 성격을 판단함에 있어서는 임금에 대한 법적 규제와 주식보상의 목적, 그리고 지급방식 등이 종합적으로 고려되어야 한다.

사용자가 근로자에게 주식을 보상으로 지급하는 유형은 대체로 우리사주제도, 스톡옵션제도, 스톡그랜트제도, 양도조건제한부 주식보상(RSU) 등이 있다. 다음에서 구체적으로 검토한다.

Ⅱ. 주식보상제의 유형

1. 우리사주제도

“우리사주”는 주식회사의 소속 종업원 등이 그 주식회사에 설립된 우리사주조합을 통하여 취득하는 그 회사의 주식을 말한다(근로복지기본법 제2조 제5호). “우리사주조합”이란 주식회사의 소속 종업원이 그 회사 주식을 취득·관리하기 위하여 근로복지기본법에서 정하는 요건(근로복지기본법 제33조 이하 참고)을 갖추어 설립한 단체를 말한다(근로복지기본법 제2조 제4호).

이처럼 우리사주제도는 주식회사의 소속 종업원들에게 자기회사 주식을 취득 및 보유하게 하는 제도로써 종업원들이 우리사주조합을 설립하여 자사주를 취득 및 보유하는 제도이다. 우리사주제도는 근로자 재산형성뿐만 아니라 협력적 노사관계를 통한 기업생산성 향상에도 기여할 목적으로 도입된 것이며, 미국·영국 등 여러 나라에서 같은 목적을 가진 비슷한 제도가 활용되고 있다.

우리나라의 우리사주제도는 기업이 근로자의 자사주 취득·보유를 지원한다는 점에서 미국의 ESOP(Employee Stock Ownership Plan)제도와 비슷하다고 한다. 그러나 미국의 ESOP제도는 확정기여형의 기업연금제도(퇴직연금제도)이고, 우리사주제도는 성과급 형태로 운영된다는 점에서 차이가 있다. 영국도 근로자가 일정기



간을 의무예약한 후 처분할 수 있는 성과배분형으로 운영하고 있다. 우리의 경우도 영국과 같이 성과배분형으로 운영하고 있다.²⁰⁰⁾ 우리나라에서는 1968년 「자본시장 육성에 관한 법률」에 의한 우선배정제도로 처음 도입되었으며, 2001년 우리사주제도의 일반적 근거가 되는 「근로복지기본법」이 제정되면서 회사의 무상출연을 통한 주식취득 등 취득기회가 확대되었다.

2. 스톡옵션

스톡옵션(Stock Option)제도는 주식매수선택권 및 주식매입선택권이라고도 하는데, 자사주식을 미리 설정한 가격(권리행사가격)으로 장래에 구입할 권리를 종업원과 임원에게 부여하고, 종업원들이 이 가격으로 주식을 구입하여 그 가격보다 높은 주가로 매각함으로써 그 차액분을 이익으로서 획득하는 제도를 말한다(상법 제340조의2 제1항 참조).

다시 말해 스톡옵션은 기업이 임직원에게 일정 수량의 자기 회사 주식을 미리 정한 가격으로 매수할 수 있는 권리(달리 말하면 일정 한도 내에서 액면가 또는 시세보다 훨씬 낮은 가격으로 매입할 수 있는 권리)를 부여하는 제도인데, 스타트업 등 새로 창업한 기업이 자금 부족 상황에서 필요한 인재를 확보하기 위한 수단으로 이 제도를 도입하면서 널리 알려졌다. 즉, 사업성이 높은 스타트업 등에서 인재를 모으기 위해 사용하는 제도로써 채용 당시에는 재정적 어려움을 겪고 있는 벤처기업이나 스타트업기업들이 우수인력들이 기대하는 많은 임금을 지급할 수 없지만 유의미한 경영실적이 발생하여 주가가 오를 경우 스톡옵션 제공시 이미 결정된 행사가격으로 주식을 취득한 다음 오른 시장가격으로 주식을 매도할 수 있어 큰 시세차익을 얻을 수 있게 함으로써 인력유치를 위한 사후적 보상 제도라고 할 수 있다.²⁰¹⁾

200) 신범철 외, 「우리사주제도 실태조사와 외국제도 비교 연구」, 노동부 연구보고서, 2004, 52면 이하 참고.

201) 황보윤/양영석, “스타트업과 벤처기업의 우수인력유치 위한 주식연계형 보상연구연구: 양도제한조건부주식(RSU) 도입 중심으로”, 「벤처창업연구」, 제18권 제6호, 2023, 1면 참고.



스톡옵션의 장점은 해당 기업의 경영 상태가 좋아져 주가가 상승하면 자사 주식을 소유한 임직원이 보유 주식을 매각하여 상당한 차익금을 남길 수 있으므로 사업 전망이 밝고 주가가 상승하는 기업일수록 해당 임직원에게 큰 이익을 줄 수 있다는 점이다. 그러므로 스타트업이나 벤처기업뿐만 아니라 기존 기업들도 임직원의 근무 의욕을 높일 수 있는 주식보상수단으로 스톡옵션을 활용하기도 한다.

한국에서는 1997년 4월 개정 증권거래법이 시행되면서 이 제도가 법적으로 도입된 뒤 미래산업, 두인전자, 웹인터내셔널 등 벤처기업을 중심으로 급속히 확산되었다. 1999년 3월에 개최된 12월 결산 상장사들의 주주총회에서는 대기업을 비롯한 193개 기업이 이를 정관에 반영시킬 정도였다. 미국의 경우 스톡옵션이 거의 모든 주식회사에 일반화되어 있고, 전문경영인들은 스톡옵션 등 주식보상을 통해 고정급여보다 훨씬 더 많은 수입을 획득하는 것이 사실상 대부분이다.

스톡옵션은 임직원들에게 동기부여를 할 수 있는 효과적인 보상제도로 인식되었고 지금도 중요한 인사경영전략의 하나로 자리잡고 있다. 이 제도는 철저하게 능력 중심으로 제공되기 때문에 직급 또는 근속연수를 바탕으로 하는 우리사주제도와는 다르다.

상법상 주식매수선택권은 주식회사의 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의(상법 제434조 참조)에 의하여 해당 법인의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여했거나 앞으로 기여할 수 있는 회사 및 관계사 임직원에게 미리 정한 가격으로 해당 법인의 주식을 매수할 수 있도록 부여한 권리를 말한다. 향후 기업 가치가 상승할 경우 이에 기여한 임직원에게 기업가치의 증가분을 분배할 수 있으므로 미래지향적 보상수단이라고 평가받고 있다. 주식매수선택권 부여방식은 신주발행 교부, 자기주식 교부, 차액(시가에서 행사가격을 차감한 금액)의 현금 또는 자기주식 교부 등 4가지가 있으며, 부여한도는 상장법인의 경우 발행주식총수의 10% 이내로 규정되어 있다(상법 제340조의2 제3항).²⁰²⁾ 행사가격은 시가와 액면가 중에서 높은 금액으로 하되 부여 주체가 결정할 수 있으며, 행사기간은 정관에서 정하

202) 벤처기업의 경우에는 지급대상자가 임직원뿐만 아니라 회사에서 필요로 하는 전문성을 가진 외부 전문가 등에게도 지급할 수 있으며, 회사 발행 주식의 50%로 확대된다. 이와 같은 예외는 벤처기업법에서 규정하고 있다.



는 기간으로 하되, 통상 부여일로부터 최소 2년 이상 재직한 경우에만 행사할 수 있도록 하는 것이 일반적이다.

3. 스톡그랜트 등 협의의 주식보상제도

(1) 스톡그랜트

스톡그랜트(Stock Grant)는 ‘주식을 부여한다’는 의미인데, 필요한 인재 영입을 위해 스톡옵션(주식매수선택권) 대신 회사 주식을 무상으로 부여하는 인센티브 방식이다. 통상 스톡그랜트는 회사가 일정 시점에서 자기주식을 특별상여금 명목으로 임직원에게 무상 지급하는 성과보상방식으로서 성과급제도의 형태에 가장 부합한다.²⁰³⁾ 스톡그랜트는 임직원에게 즉시 회사의 주식을 지급하면서 아무런 제한을 두지 않는다. 특히 실무상으로는 기존에 현금으로 지급되던 성과급의 전부 또는 일부를 자사주로 지급하는 방식으로 활용되기도 한다.

스톡그랜트는 스톡옵션과 달리 정관변경 등 복잡한 절차를 거치지 않고 활용할 수 있다는 점에서 장점이 있다. 상법에 규정된 주식매수선택권(스톡옵션)과 달리 스톡그랜트는 법률용어가 아니고, 스톡옵션의 경우 주식매수대금을 임직원 본인이 부담하지만, 스톡그랜트에서는 회사가 부담하고 주식을 무상으로 교부하는 방식이라는 점에서 차이가 있다.

회사 임직원은 회사가 보유하고 있는 주식을 무상으로 직접 받기 때문에 지급받아야 할 보상을 확실하게 보장받을 수 있으며 또한 즉시 현금으로 교환할 수도 있고 일정기간 보유 후 현금화할 수도 있다(후자의 경우에는 근로자에게 이익이 늦게 실현된다는 점에서 스톡옵션과 크게 다르지 않을 것이다). 반면 스톡옵션은 일정기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 권리를 부여하는 것이기 때문에 현금화하는 데 상당

203) 기업의 이익 중 일부를 임직원에게 현금으로 지급하는가 아니면 주식으로 보상하는가의 문제이기 때문이다. 양자가 혼용되기도 하고 현금을 주식으로 전환하기도 한다. 기업들은 경영전략적 관점에서 함께 또는 선택적으로 사용할 수 있다. 그렇기 때문에 경영성과급과 마찬가지로 주식보상도 임금성이 문제될 수 있다.



한 기간이 필요하고 주가가치의 미래가 불확실하며, 경영상황이 악화하거나 대규모 유·무상 증자를 할 경우 주가가치의 하락이 불가피하다는 단점이 있다.

이와 같은 주식보상제도는 최근 일부 IT기업 소속 인재들의 인건비가 치솟으면서 나타난 현상 중 하나이며, 주식시장이 침체에 빠지면서 미래의 기대수익인 스톡옵션에 대한 매력度が 줄게 되자 스톡그랜트를 도입하는 사례가 늘어나고 있다. 스톡그랜트는 종래 스타트업 및 벤처기업에서 주로 볼 수 있는 현상이었지만 최근 일부 대기업의 경우에도 우수인력을 끌어들이기 위해 활용하기도 한다.²⁰⁴⁾

<임직원대상 스톡그랜트 도입 사례>²⁰⁵⁾

네이버	2021년부터 매년 1,000만원 상당의 스톡그랜트를 전 직원에게 지급
SKC	2021년 실적 상승에 따라 전체 임직원 및 자회사 임직원들에게 스톡그랜트 지급
현대차/기아차	2022년 매출 최대실적 달성에 대한 보상과 격려 차원에서 2023년 전 직원에게 자기주식 지급
카카오	우수 인재 리텐션 강화 및 임직원을 위한 인센티브를 자기주식으로 지급
한국캐피탈	희망자에 한하여 임직원 성과급을 자기주식으로 지급
SK하이닉스	주주참여 프로그램을 도입, 성과급에 해당하는 초과 이익분배금의 일부(최대 50%)를 해당 직원의 선택에 따라 자기주식으로 지급

스톡그랜트는 임직원에 대한 보상으로써 자기 회사의 주식을 교부하는 것이므로,

204) 한국경제신문 2021.4.19.자, 참고.

205) 윤소연, “주식연계보상의 법적 쟁점 - RSU와 스톡그랜트를 중심으로”, 「상사법연구」 42권 2호, 한국상사법학회, 2023, 75-76면.



회사의 자기주식의 취득과 처분에 관한 법령의 적용을 받는다. 상법상 자기주식의 취득방법으로 제341조에서 배당가능 이익의 한도 내(취득가액의 총액이 직전 결산 기의 대차대조표상의 순자산액에서 제462조 제1항 각호의 금액을 뺀 금액 내)에서 는 자기주식을 취득할 수 있다고 규정하고 있다. 구체적으로 (i) 취득가액의 총액은 배당가능이익을 초과하지 못하며, (ii) 자본금 또는 법정준비금 항목의 결손을 초래 할 우려가 있을 때는 취득하지 못한다는 제한을 두고 있다. 또한, (iii) 규정된 방식 에 의하지 아니하고 각 주주로부터 균등하지 않게 취득했거나, (iv) 제341조의 2의 특별한 목적에 해당하지 아니한 경우 자기주식의 취득은 위법하게 된다.²⁰⁶⁾

(2) 스톡퍼처스 제도

스톡퍼처스(Stock Purchase)는 임직원이 자기회사 주식을 매입하면 회사에서 일 정 비율의 주식을 무상지급하는 제도로써, 스톡옵션이나 스톡그랜트와 구별된다. 가 령 직원이 100만원어치 주식을 매수하면 사측이 그 절반인 50만원어치를 같이 사 들어 보관하다가 일정 기간이 지나면 직원에게 무상 양도하는 식이다. 스톡퍼처스 제도는 근로 의욕을 높일 뿐 아니라 자사주 매입을 통해 주가가 상승하고 다른 한 편 적대적 인수합병 시도를 방어하는 기능을 할 수도 있다. 스톡옵션과 스톡그랜트 는 인재 확보나 성과 인센티브를 제공하기 위해 대상 임직원을 한정하거나 특정 임 직원을 대상으로 하는데 비해 스톡퍼처스는 자사주를 취득한 모든 임직원을 대상으 로 한다는 점에서 차이가 있다.²⁰⁷⁾

(3) 양도제한조건부 주식제도 (RS, Restricted Stock)

이 제도는 특정 기간에 기업이 내건 목표를 달성하면 주식을 지급하는 성과보상 제도를 말한다.²⁰⁸⁾ 임직원에게 회사 주식을 특정 가격에 살 수 있는 권리를 주는

206) 대법원은 상법이 명시적으로 자기주식의 취득을 허용하는 경우를 제외하고 회사가 자 기주식을 취득하는 것은 허용되지 않고 당연히 무효라고 본다. 대법원 2021.10.28. 선고 2020다208058 판결 참고.

207) 한국경제신문 1997.4.28. 자 참고.



스톡옵션과 달리 RS는 회사가 제시한 조건을 충족할 경우 무상으로 주식을 지급하는 방식이다.²⁰⁹⁾²¹⁰⁾

RS는 다시 크게 두 가지 형태로 구별된다. 첫째, 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit: RSU)라고 하는데, RSU는 부여 시점에 특정 가득 조건을 설정하고 이를 달성하면 장래의 어느 시점에 일정량의 주식을 부여하며, 조건을 충족하지 못하면 주식을 받을 수 있는 권리가 소멸된다. RSU는 임직원에게 장래의 특정 시점(조건성취일)에 일정 단위의 회사 주식을 받을 수 있는 권리를 부여한다. 다시 말해

208) 성과보상제도에 관하여 그동안 대세였던 스톡옵션(Stock Option)의 자리를 RSU(Restricted Stock Units)가 대체하는 추세라고 할 수 있다. RSU는 이미 미국에서 오래전부터 활용되어 왔다. 글로벌 탐티어 기업들은 물론 스타트업 기업들은 주로 RSU를 성과보상제도로 활용하고 있다. 실제 미국에선 실리콘밸리를 중심으로 RSU가 보편적으로 활용되고 있다. 2011년 RSU를 도입한 애플은 임직원을 대상으로 지분 100만주를 2022년까지 두 번에 걸쳐 지급하였다. 또한 각 부서별로 '고성과자'를 선별해 5만~18만 달러 어치의 주식을 지급하기도 했다. 그 밖에 구글, 테슬라, 아마존, 페이스북 등 빅테크 기업들 모두 RSU를 활용하고 있다. 예를 들어 10만 달러의 연봉에 연 5만 달러어치의 자사주를 무상으로 지급하는 방식을 생각할 수 있다. 이제는 빅테크 외에 대형 제조사도 RSU를 활용하고 있다. 대표적인 곳이 2020년 RSU를 도입한 보잉이다.
<https://www.newspim.com/news/view/20230915000817>.

209) 우리나라에서는 대표적인 사례가 한화그룹이다. 한화는 2020년 2월 (주)한화를 필두로 국내 대기업으로는 처음으로 RSU를 도입했다. 현재는 (주)한화와 한화솔루션, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화생명, 한화투자증권, 한화손해보험 등 상장사부터 한화건설, 한화테크윈, 한화정밀기계, 한화파워시스템, 한화디펜스 등 비상장사까지 이 제도를 도입했다. 한화그룹은 임원급 이상만 RSU를 지급한다. 대상자는 이사회나 이사회 내 보수위원회에서 선별한다. 한화그룹은 RSU의 행사 가능 시점을 7년 뒤로 설정했다.
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=335812.

210) 두산밥캣은 매년 자사주를 매입하여 임원들에게 RSU를 지급한다. 하지만 이를 지급받은 임원들은 3년 후에나 이 주식을 팔 수 있다. RSU는 두산그룹이 2022년 그룹 공통으로 도입한 장기 성과급 제도다. 회사가 제시한 성과 조건을 충족할 경우 일정 기간 후 회사의 주식을 지급하는 방식이다. 특정 가격에 주식을 살 수 있는 권리를 부여하는 스톡옵션은 주가가 행사가격 밑으로 떨어지면 가치가 아예 사라지지만, RSU는 회사가 망하지 않는 한 최소한의 이익은 보장이 된다. 약속한 기간 전에 회사를 그만두면 받을 수 없어 인재 유출을 방지하는 효과도 있다. RSU는 실리콘밸리 등 글로벌 기업에서 일찌감치 채택한 성과보상 방식으로, 특히 인력 유출이 많은 IT기업에서 먼저 도입됐다. 국내에서는 한화그룹이 가장 먼저 도입했으며, 행사 가능 시점을 7~10년 뒤로 설정해 인재 유출을 방지하고 있다. 두산밥캣의 RSU는 3년 후로 설정돼 있다. 일반적으로 RSU는 주가에 연동해 성과급을 책정하는 방식으로 일정 기간 이후 수령이 가능하고 주가에 연동된다는 점에서 RSU를 부여받은 임원의 책임경영을 기대할 수 있다는 장점이 인정된다.
<https://www.news1.kr/articles/5000852>.



RSU는 부여 시점에 '주식'(stock) 자체가 아니라, '일정한 단위의 주식을 부여받을 권리'를 제공한다.²¹¹⁾ 회사 중에는 RSU를 주식 또는 그 가치 상당의 현금, 또는 주식과 현금을 혼합하여 제공하는 것으로 정산하기도 한다. 그리고 RSU를 부여받은 임직원은 회사 주식의 소유자가 아니므로 실제로 주식을 지급받을 때까지 주주로서의 권리를 갖지 않는다. RSU의 가득조건도 종전에는 기간에 연동된 가득조건(기간 연동형 가득조건이라고 하며 대체로 3년 또는 4년 또는 그 이상의 가득기간이 부여된다)이 부여되는 경우가 대부분이었는데, 점점 성과에 연동된 가득조건을 추가하는 경우가 늘어나고 있다. 성과연동형 가득조건은 예를 들어 재무지표, 주가, 타사 대비 상대적인 총주주수익률(Total Share Return, TSR)등을 조건으로 할 수도 있고, 그 외 특정한 목표(milestone) 달성을 조건으로 설정할 수도 있다. 개념적으로는 실 무상 기간연동형 가득조건이 붙은 것을 RSU라 하고, 성과연동형 가득조건이 추가된 RSU를 PSU(Performance Stock Unit)로 별도로 분류한다. PSU는 특히 경영진에 대한 보상방식으로 활용이 늘고 있다. PSU는 미리 정해진 성과목표의 달성을 가득조건으로 하는데, RSU에 성과연동형 가득조건이 붙은 형태라고 할 수 있다.²¹²⁾

둘째, 양도제한 조건부 주식 보상(Restricted Stock Award: RSA)이라고 하는데, RSA는 매각 등의 제한이 있는 주식을 부여 시점에 실제로 지급하되, 그 주식은 가 득(vesting)될 때까지는(통상 3년 또는 4년) 양도가 허용되지 않고, 가득기간 중에 임직원이 퇴사하는 경우에는 통상 회사에 의해 박탈되거나 환수된다는 제한을 받는다는 특징이 있다. RSA는 부여일에 해당 임직원이 그 주식의 소유자가 되고, 의결권, 배당을 받을 권리 기타 주주로서의 권리도 원칙적으로 모두 행사할 수 있다는 점에서 RSU와 구별된다.²¹³⁾

과거에는 대부분의 기업에서 스톡옵션이 대표적 주식보상제도로써 주로 활용되었으나, 2020년 한화그룹을 필두로 두산그룹 등 기존의 주요 그룹사뿐만 아니라 토스, 쿠팡, 위메프, 크래프톤 등 신생 IT기업 및 스타트업에서도 RS제도를 도입하는

211) 황보윤/양영석, “스타트업과 벤처기업의 우수인력유치 위한 주식연계형 보상연구연구: 양도제한조건부주식(RSU) 도입 중심으로”, 3면.

212) 윤소연, “주식연계보상의 법적 쟁점 - RSU와 스톡그랜트를 중심으로”, 53-54면.

213) 황보윤/양영석, “스타트업과 벤처기업의 우수인력유치 위한 주식연계형 보상연구연구: 양도제한조건부주식(RSU) 도입 중심으로”, 3면.



사례가 점차 늘고 있다.

<RSU 도입 주요 사례>²¹⁴⁾

(주)한화	7년 또는 10년 후 주식 및 주식가치연계 현금 지급
비바리퍼블리카	2~4년 근속조건 충족시 주식 지급
쿠팡	1년 근무시 50%, 2년 근무시 100% 지급, 총액 1,000억원 규모
CJ ENM	일정기간 근속조건 충족시 부여액의 50%는 주식으로, 나머지는 주식가치 연계 현금으로 지급
크래프톤	기간 및 성과조건 달성시 주식 지급 (1년 후 35%, 2년 후 35%, 3년 후 30%)
(주)두산	3년 재직조건 충족시 주식 지급 (만 2년 이상 재임 후 퇴직시, 3년차 재임기간 일수에 비례하여 지급)
네이버	KOSPI 200내 기업대비 상대적 주가상승률 백분위에 따라 0~150% 내에서 최종지급규모 결정; 부여일로부터 3년간 매년 30%, 30%, 40% 분할 지급
두나무	1~3년 근속조건 충족시 2회로 나누어 부여주식 수의 50%씩 지급
애플	고성과자 10-20%를 대상으로 최대 18만달러, 4년 가득기간 부여

4. 스톡옵션과 RS의 비교

214) 윤소연, “주식연계보상의 법적 쟁점 - RSU와 스톡옵션을 중심으로”, 74면; 황보윤/양영석, “스타트업과 벤처기업의 우수인력유치 위한 주식연계형 보상연구연구: 양도제한 조건부주식(RSU) 도입 중심으로”, 2면.



스톡옵션과 RS 모두에게 가장 중요한 계약조건은 주식을 받을 수 있는 권리가 충족되는 이른바 ‘가득조건’(vesting condition)이라고 할 수 있다. 가득조건은 주로 근무기간이나 특정 성과목표 달성이 되며, 두 조건을 동시에 걸 수도 있다. 예를 들어 회사가 요구하는 근무기간(평가기간)을 충족하거나(기간연동형 가득조건), 특정 성과목표로써 매출액 또는 영업이익 달성 등의 평가지표를 충족하는 경우(성과연동형 가득조건 또는 이벤트조건)²¹⁵⁾를 가득조건으로 하거나, 양자를 동시에 충족하는 경우를 내걸 수 있다(가득조건 내용에 대해서는 위의 (3) 참고).

결국 특정 조건을 달성할 것을 전제로 하여 주식으로 보상을 지급한다는 점에서 두 제도는 유사하지만, 스톡옵션은 임직원이 일정 주식을 행사가액에 구매할 수 있는 “권리”를 부여한다는 것과 달리, RS는 일정 요건 충족시 임직원이 주식을 법적으로 “소유”한다는 점에서 스톡옵션과 큰 차이가 있다.

또한 스톡옵션은 근거 법령이 존재하여 법적 절차와 제한 사항이 있고 추가적인 세제혜택²¹⁶⁾이 존재하는 것과 달리, RS는 근거법령이 없어 절차와 요구사항이 없고 세제혜택도 없다는 점이 양자의 차이라고 할 수 있다.²¹⁷⁾

RS의 경우는 스톡옵션과 달리 현행법상 제도 운영에 관한 근거법령이 없으므로 회사는 자기 주식을 자유롭게 처분할 수 있도록 규정한 상법 제342조와 사적 계약에 따라 지급한다. 따라서 상대적으로 현재로서는 부여방식이 간편하다. 또한 상법에 따라 이사회는 자기주식 처분방법, 수량, 가액, 일자 및 처분 상대방을 자유롭게 결정할 수 있으므로 RS는 부여대상(임직원의 범위), 수량, 최소 근무기간 등 조건에 대해서도 제한없이 그 내용을 정할 수 있다는 점에서 스톡옵션과 차이가 있다.

이와 같이 스톡옵션은 행사가액을 납입하여 기업의 주식을 매수할 수 있기 때문에 행사가액보다 주식가격이 높을수록 임직원의 보상도 커지므로 기업가치를 향상시키기 위한 임직원의 동기유발에 효과적이다. 그럼에도 불구하고 행사가액보다 주

215) 이에 비하여 스톡옵션의 경우 주식시장 상장을 이벤트 조건으로 하는 경우가 많다.

216) 다만, 스톡옵션에 대한 세제혜택은 벤처기업법에 따른 벤처기업이 적격하게 부여한 스톡옵션으로 제한된다.

217) 황보윤/양영석, “스타트업과 벤처기업의 우수인력유치 위한 주식연계형 보상연구연구: 양도제한조건부주식(RSU) 도입 중심으로”, 4면 참고.



식가치가 낮은 경우 스톡옵션은 아무런 경제적 가치가 없다는 문제가 발생한다. 또한 임직원으로서도 주식을 매수하기 위해서는 상당한 자금이 소요된다는 점에서 단점으로 지적된다.²¹⁸⁾

반면에 RS는 일정 조건 달성시 보통 무상으로 주식을 지급하기 때문에 주식을 받을 때 임직원의 매입자금이 필요하지 않아 임직원의 부담이 없고 주가가 하락하더라도 회사가 존재하는 이상 주식이 일정 수준의 가치를 가진다는 장점을 가지고 있다. 이러한 장점에도 불구하고 상법상의 제한으로 인하여 기업입장에서는 자기주식의 취득이 어렵고 RS를 지급받은 임직원입장에서는 세제혜택이 없다는 점은 단점으로 지적된다.

5. RS의 활용 가능성

벤처 투자가 극도로 제한되고 있는 빙하기에 스타트업·벤처기업이 고질적으로 안고 있는 우수인력 부족 현상에 대응하기 위해서는 주식보상제도의 도입이 불가피하다. 그런데 이와 같은 양도제한 조건부 주식 제도 도입을 위해서는 실무상 몇가지 장애물이 제거되어야 한다는 지적이 있다.²¹⁹⁾

중소기업연구원의 보고서에 따르면 국내 벤처기업 대상 설문 조사 결과, 기업의 RS에 대한 인식 수준은 58%에 달한다. 반면, 실제로 도입하고 있는 기업은 2%에 불과한 상황이며 도입을 검토하고 있는 기업은 18%에 그쳤다. 제도 도입 애로사항으로는 국내 세제 혜택의 미비와 비상장 주식의 가치 산정의 어려움, 그 밖에 복잡한 제도 및 행정 절차 등이 꼽혔다. 따라서 이 문제를 해결하기 위해서는 비상장 스타트업·벤처기업의 적절한 주식 가격 산정을 위한 객관적인 평가 방법 개발 및 도입, 배당 이익 한도 내에서만 자사주 취득이 가능한 현행 규제의 완화, 조세 혜택

218) 황보윤/양영석, “스타트업과 벤처기업의 우수인력유치 위한 주식연계형 보상연구연구: 양도제한조건부주식(RSU) 도입 중심으로”, 4면.

219) 강재원, 「스타트업·벤처기업 우수인력 유치를 위한 미국 주식 연계형 보상제도 현황 및 시사점」, 중소벤처기업연구원, 2023 참고.



부여와 행정 절차 간소화 등이 개선과제로 제시된다.²²⁰⁾

또한 제도가 활성화되기 위한 정책으로 세제관련 특례 설정, 배당 가능한 이익이 없어도 자기 주식을 취득할 수 있도록 규제 완화, 법률 컨설팅 제공 등이 필요하다고 본다.²²¹⁾ 하지만 RS를 임금으로 본다면 근로소득세 과제 시점에 대한 논란이 재연될 수 있다. 결국 이는 조세정책의 문제이기는 하지만 이를 평균임금 산정 대상으로 한다면 수령시점에 어느 정도 과세기준이 마련되어 있어야 한다는 점에서 복잡한 문제가 발생할 수 있다.

II. 주식보상제의 노동법적 쟁점

1. 주식보상의 임금성

미국 기업의 경우 우수 인력을 유치하기 위해 다양한 주식 연계형 보상제도를 운영하고 있으며, 기업의 상장 여부 및 기업 성장단계, 조세 혜택 등을 다양하게 고려해 근로자에게 혜택을 제공하기 위한 다양한 옵션을 제공하고 있다. 그 예로 위에서 이미 본 양도제한 조건부 주식(Restricted Stock), 주가차익보상권(Stock Appreciation Right, SAR), 가상주식(Phantom Stock) 등이 있으며,²²²⁾ 기본적으로 기업의 주가와 성과 보상이 연동돼 있다는 게 특징이다.

220) 2023년 7월부터 이익이 발생하지 않는 스타트업 기업도 직원들에게 RSU를 지급할 수 있도록 “벤처기업육성에 관한 특별조치법(벤처기업육성법)” 개정안이 공포되었다. 현행 상법은 배당 가능 이익 한도 내에서만 자사주를 취득할 수 있기 때문에 재정기반이 취약한 스타트업 기업들이 RSU를 활용하기 어렵다는 점을 고려한 입법이다. 개정 벤처기업육성법은 상법상 특례로 비상장인 벤처기업이 RSU를 도입하기 위해 자사주를 취득할 때는 배당 가능 이익 한도를 넘어 '자본잠식이 일어나지 않는 범위 내'까지 가능하도록 하였으며, 도입 절차 등을 규정해 초기기업들도 법을 준용해 도입하도록 허용하였다. <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024010209451984693>.

221) 황보윤/양영석, “스타트업과 벤처기업의 우수인력유치 위한 주식연계형 보상연구: 양도제한조건부주식(RSU) 도입 중심으로”, 7면.

222) 각 주식보상제도의 설명에 대해서는 윤소연, “주식연계보상의 법적 쟁점 - RSU와 스톡옵션을 중심으로”, 51-54면 참고.



주식보상이 임금에 해당하는지 여부에 대해서는 아직 일반적으로 검토된 바가 없다. 다만, 그중에서 스톡옵션에 대해서는 일부 견해가 제시되고 있다. 그에 따르면 스톡옵션에 의하여 근로자가 받는 이익은 그것이 발생한 시기와 금액 모두 근로자의 판단에 맡겨져 있기 때문에 근로의 대가로 인정될 수 없으므로 임금이 아니라는 견해가 있다.²²³⁾ 즉, 스톡옵션에서는 권리를 부여받은 근로자가 권리행사를 할지 여부, 권리행사를 하더라도 그 시기나 주식매각시점을 언제로 할 것인지, 금액은 어떻게 할 것인지 모두 근로자의 결정과 판단에 맡겨져 있으므로 이를 근로기준법상 임금으로 볼 수 없을 뿐만 아니라 스톡옵션의 부여를 취업규칙에서 정한 임금의 일부를 지급한 것으로 정하는 것은 근로기준법 위반이라고 할 수 있다.²²⁴⁾ 다만, 스톡옵션이 임금은 아니라 하더라도 근로조건의 일부에는 해당하기 때문에 이를 근로자에 대하여 하나의 제도로써 실시하는 경우에는 취업규칙에 기재해야 할 것이다. 이와 같이 스톡옵션은 근로자의 입장에서 임금으로서의 이익성을 결여하고 있으며 따라서 노동법적 보호의 필요성도 부족하다는 점에서 근로기준법상 임금에 해당하지 않는다.

반면에 소득세법상으로는 스톡옵션을 근로소득으로 보고 있고, 지급기준이 명확하고 평가에 의한 개별 지급부분에 대해서 상여금을 대신하여 자사주를 지급하는 내용을 서면으로 약정한 경우에는 임금성을 인정해야 한다는 견해도 있다.²²⁵⁾

단체협약을 통해 상여금의 일부로 지급된 스톡그랜트는 근로자가 지급받은 즉시 주식을 처분하여 환가할 수 있고 주주로서의 권리도 행사할 수 있으므로 사실상 현금상여와 차별성이 없다는 점에서 임금성이 인정될 수 있을 것이다.²²⁶⁾

223) 김형배/박지순, 「노동법강의」, 287면; 같은 취지로 土田道夫, 「労働契約法」, p.242.

224) 菅野和夫, 「労働法」, p.433.

225) 이 학설의 소개는 水町勇一郎, 「詳解労働法」, p.610 참고. 또한 현행 소득세법 시행령 제38조 제1항 제17호에 따르면 법인의 임직원이 해당 법인등으로부터 받은 주식매수선택권을 해당 법인등에서 근무하는 기간 중 행사함으로써 얻은 이익(주식매수선택권 행사 당시의 시가와 실제 매수가액과의 차액을 말하며, 주식에는 신주인수권을 포함한다)은 근로소득에 포함된다.

226) 최근 현대자동차 노사는 단체협약을 체결하면서 조합원들에게 자사주식 15주를 지급하기로 하였다. 이는 전형적인 스톡그랜트이며 성과급의 일부로서 임금으로 인정될 수 있다. 이 15주의 주식지급은 단체협약으로 정한 것이므로 통화지급의 예외로 인정된다. 그런데 여기에 일정기간 양도제한이 설정되면 RSU라고 할 수 있다.



이에 비하여 RS는 스톡옵션과 달리 이를 부여받은 근로자에게 추가적인 비용부담이 발생하지 않는다는 점, 일정한 요건(가득조건)이 충족되면 최소한의 재산적 가치가 발생한다는 점에서 임금성을 인정할 가능성이 없지 않지만, 앞에서 스톡옵션에 대한 임금성을 부인한 논거가 RS에 대해서도 해당될 수 있기 때문에 현재로서는 임금성을 인정하기 어려울 것이다. 그렇지만 점차 주식을 근로자에 대한 보상방법으로 활용하는 사례가 늘어나고 있다는 점, 주식보상의 방법으로 직접적이고 즉각적인 환가가 가능한 주식지급이 아니라 일정 기간 보유하도록 하는 등의 조건을 부여하여 근로자의 장기근속을 유도하고 있다는 점 등을 고려하면 향후에는 스톡옵션이든 RSU든 주식보상을 임금으로 인정하여 적극적으로 근로자를 보호하는 것이 필요하다고 볼 수 있다.

일본의 판결례 중에는 5년 뒤에 회사의 보통주를 취득할 수 있는 권리를 부여하는 ‘주식보상’에 대해, 그것이 보수에 포함된다는 것이 주식보상 프로그램과 고용계약상 명시되어 있음을 이유로 임금에 해당한다고 긍정한 사례가 있다.²²⁷⁾ 또한 종업원에게 자사주를 지급하는 것도 지급기준이 명확히 존재하고 근로와의 관련성이 있는 한 임금에 해당한다는 판결도 있다.²²⁸⁾ 당연하지만 이 경우에는 임금의 통화지급 원칙의 예외로 인정받으려면 단체협약의 체결이 필요하다(근기법 제43조 제1항 단서). 다만, 이 경우에도 해결해야 할 법적 과제가 있다. 이 점에 대해서는 다음 항에서 검토한다.

2. 주식보상과 임금지급의 원칙(통화지급의 원칙 위반 문제)

일반적으로 주식가격이라는 것은 계속해서 변동할 수밖에 없는 불명확성을 가지고 있으므로 이를 환가하는데 불편이 따를 뿐만 아니라 임금액의 실질적 가치가 저하됨으로써 근로자의 생활불안정을 초래할 가능성이 높다. 주식이 통화를 대체할

227) 東京地判 平成 24.4.10 勞判 1055号 p.8.

228) 東京地判 昭和 53.2.23 勞判 293호 p.52.



수 없는 이유이다. 따라서 주식으로 임금을 갈음하는 것은 일종의 현물급여에 해당하므로 근로기준법 제43조 제1항에 따른 통화지급의 원칙에 반한다고 볼 수 있다.

통화지급의 원칙은 보편적이면서 역사적으로도 오래된 임금지급의 대원칙이라고 할 수 있다. 통화란 강제통용력이 있는 화폐, 즉 법화(法貨)를 의미하는데, 한국은행법에 따르면 한국은행만이 화폐를 발행할 수 있으며(한국은행법 제47조 참조), 한국은행이 발행한 한국은행권은 법화(法貨)로서 모든 거래에 무제한 통용된다(한국은행법 제48조). 이로써 우리나라에서 통화란 한국은행이 발행한 화폐만을 의미한다. 그러므로 외국통화는 물론 수표, 식권이나 통근정기권, 상품권 등도 현물급여에 해당하므로 통화로 볼 수 없다. 자사주식을 지급하는 것도 전형적인 현물급여에 해당한다. 다만, 자기앞수표에 의한 임금지급은 통화에 준하는 것으로 보아 가능하다는 해석이 있다.²²⁹⁾

물론 단체협약에서 임금을 현물, 주식, 상품교환권 등으로 지급하기로 한 경우 조합원들의 개별적 동의와 상관없이 이러한 지급은 허용된다(법 제43조 제1항 단서). 이 경우에도 단체협약의 효력은 조합원에게만 미친다.²³⁰⁾ 근로자 과반수를 대표하는 자와 사용자가 한 서면 합의, 노사협의회에서의 합의는 단체협약이 아니므로 이를 근거로 통화 아닌 다른 것으로 임금을 지급할 수 없다는 견해도 있다.²³¹⁾ 성과배분제도를 시행하면서 주식을 지급하는 경우에 그 명칭이 성과급이라 하더라도 실질적으로는 임금이 아닌 경우에는 통화지급원칙 위반 문제가 발생하지 않을 것이다.²³²⁾ 하지만 주식보상을 임금의 일부로 본다면 통화지급원칙을 위반한 것으로 볼 수밖에 없다.

다만, 임금의 경우 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다고 예외를 인정하고 있다. 그에 따르면 첫째, 법령에서 정하는 경우에는 예외가 인정되는데, 아직 그에 관한 법령의 규정은 보이지 않는다.

229) 김형배, 「노동법」, 367면; 이상윤, 「노동법」, 223면; 하갑래, 「근로기준법」, 337면. 근로자의 동의가 있으면 가능하다는 견해는 임종률, 「노동법」, 427면.

230) 하갑래, 「근로기준법」, 337면.

231) 임종률, 「노동법」, 428면.

232) 하갑래, 「근로기준법」, 337면.



둘째, 단체협약에 특별한 규정을 두고 있는 경우에는 예외가 인정되는데, 단체협약에서 임금의 일부를 주식으로 보상하는 규정을 두고 있다면 주식보상은 통화지급의 원칙에 대한 예외로써 임금으로 지급된 것이라고 인정될 수 있다. 문제는 우리나라의 단체협약이 주로 제조업 생산직 근로자를 대표하는 경우가 많다는 점이고, 생산직 근로자의 직무성격이나 역할을 고려하면 주식보상제를 일반적인 임금지급방식으로 약정하는 것은 상상하기 쉽지 않다. 즉, 주식보상제를 선호하거나 주식보상이 활용되는 임직원들은 대체로 노조 가입자격이 없거나, 노조에 의하여 대표되지 않는 직군이나 직종에 종사하는 경우가 많은데, 단체협약에 의한 예외만을 인정하는 것은 이러한 현실과 부합하지 않을 수 있다는 점이다.

이처럼 단체협약에 의한 예외만을 인정하는 것이 한계가 있다면 근로자와 사용자 사이에 임금의 일부를 주식으로 보상한다는 특별한 합의가 있다는 경우에도 통화지급의 원칙에 대한 예외를 인정하는 것이 필요하다고 할 수 있다. 이 경우에도 해당 직무를 대표하는 근로자대표나 노사협의회, 근로자위원이 존재한다면 적어도 근로자대표와 서면합의를 통해 통화지급원칙의 예외를 인정할 것인지 아니면 개별근로자의 자유로운 의사에 터잡아 사용자와 합의할 경우, 또는 개별근로자에게 선택권을 부여하고 근로자가 그 선택권을 행사할 경우 주식으로 지급할 수 있도록 예외를 인정할 수 있는지 검토가 필요할 것이다. 일반 현물이 아니라 주식이나 가상화폐처럼 어느 정도 현금성이 인정되는 지급수단에 대해서는 그러한 보상방식의 장단점을 고려하고 근로자의 생활안정에 필요한 최소한의 통화지급의 범위를 마련한 후 당사자의 의사를 확인하여 그 유효성을 판단하는 것이 타당하다고 본다. 이때 담당 직무, 역할, 책임의 정도, 임금결정의 방법 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다. 이러한 경우에 대해서까지 통화지급의 원칙을 강제하는 것은 현실과 부합하지 않는 규제라고 할 수 있다. 최근 일본의 하급심판결 중에는 전액지급원칙의 예외로써 근로자의 자유의사에 의한 합의상계를 인정하고 있는 취지를 반영하여,²³³⁾ 근로자의 자유로운 의사에 의한 합의에 근거한 주식보상을 인정한 사례가 있다.²³⁴⁾ 물론 명문의 규정이 없이 이러한 예외를 인정할 수는 없을 것이다.

233) 대법원 2001.10.23. 선고 2001다25184 판결; 김형배/박지순, 「노동법강의」, 300면.

234) 일본 리ーマン 부라다す 証券 事件, 東京地判 平成 24.4.10 勞判 1055号 p.8 참조.



생각건대 향후 주식보상제의 활성화를 위해서는 근로자 보호의 관점도 고려하면서 통화지급의 원칙을 수정해야 할 것이다. 현행처럼 단체협약에 의한 예외만을 인정할 것이 아니라, 근로자대표, 노사협의회를 통한 합의 가능성도 열어놓고 근로자의 자유로운 의사에 터잡아 사용자와 합의를 하거나 근로자에게 선택권을 부여하는 방법 등을 통해 주식을 임금으로 지급받을 수 있도록 하는 것이다. 주식이나 가상화폐와 같이 현금성이 인정되는 지급수단에 대해서는 개별근로자에게 선택권을 부여하고 근로자가 그 선택권을 행사할 경우 통화 이외의 것으로 지급할 수 있도록 하는 것이다. 기본적으로 대등한 당사자관계가 인정되기 어려운 근로관계의 성격을 고려한 대안이라고 할 수 있다. 이 경우에도 근로자의 생활안정을 위해 통화로 지급되어야 할 최소한의 금액은 보장될 수 있도록 통화지급의 하한선이 정해져야 할 것이다.

3. 전체 임금에서 주식보상의 범위(지급액의 제한)

주식보상을 임금의 일부로 인정할 경우 또는 주식의 가액을 임금으로 인정한다면 근로자가 지급받는 전체 임금 중 주식보상의 비율은 어느 정도까지 인정될 수 있는지가 문제될 수 있다. 주식은 그 자체로서는 통화(通貨)가 아니므로 근로자의 생활안정을 위해서는 임금의 일정부분은 통화로 지급되어야 한다. 그러나 현행 근로기준법은 법령이나 단체협약으로 통화지급원칙의 예외를 정할 수 있도록 허용하면서도 그 한계를 규정하고 있지 않다.

근로기준법 제47조는 “도급이나 그 밖에 이에 준하는 제도로 사용하는 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하여야 한다.”라고 규정하고 있다. 이 규정이 여기에도 적용될 수 있는지 여부가 검토대상이 될 수 있다. 여기서 도급이나 이에 준하는 제도와 함은 전통적인 도급제, 즉 개수급제로 임금이 결정되는 경우뿐만 아니라 성과급제, 능률급제 등 도급제와 유사한 형태로 근무하는 근로자도 포함한다. 다만, 주식보상이 지급되는 근로자를 모두 도급제 근로자로 인정할 수는 없을



것이다. 따라서 주식보상제를 실시할 경우 최소한 통화에 의한 임금액 보장을 위해서 근로기준법 제47조를 적용하는 견해는 타당하지 않다고 생각된다.

그렇지만 이 규정의 취지는 주식보상제의 한계를 설정함에 있어서 참고될 수 있을 것으로 보인다. 근로기준법 제47조는 일정액의 임금을 보장한다고 규정하면서도 그 객관적 기준을 제시하지 않고 있다. 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 정한 것이 있으면 이에 따른다고 보는 것이 일반적인 견해이다.²³⁵⁾ 이러한 약정이 없는 경우에는 일반 근로자에게 보장되는 임금 수준을 보장해야 한다는 견해와 최저임금 수준 이상을 보장하여야 한다는 견해, 그리고 근로기준법 제46조가 규정하는 휴업수당 상당액인 평균임금의 70% 이상을 보장해야 한다는 견해가 있다.²³⁶⁾

생각건대 앞서 검토한 바와 같이 주식보상제의 실시 배경이나 필요성을 고려하면 벤처기업, 스타트업, 성장기업 등의 경우 주식보상제를 통해 근로자의 동기유발을 촉진하는 측면이 있으므로 당사자간에 주식보상액의 규모나 범위를 정할 수 있도록 하되, 통화로 지급되는 임금액을 최소한 최저임금액 이상 또는 근로기준법 제46조의 휴업수당(평균임금의 70%) 상당액 등 최저기준을 정함으로써 근로자의 생활안정도 보장해야 할 것이다.

4. 주식보상과 평균임금 산정 방식

주식보상을 임금으로 인정할 경우 해당 보상액은 평균임금에도 산입될 수 있다. 이 경우에 현행법에 따르면 그 주식보상의 평가액이 미리 정해져 있지 않으면 안된다. 평가액이 미리 확정되어 있어야 평균임금의 산정에 포함될 수 있기 때문이다. 따라서 단체협약이나 근로계약에 적어도 평가액 산정 방식이 구체적으로 규정되어 있어야 하며, 그렇지 아니한 경우에는 임금으로 인정하기 어려울 것이다. 특히 비상장 스타트업·벤처기업의 적절한 주식 가격 산정을 위한 객관적인 평가 방법 개발

235) 김형배, 「노동법」, 361면

236) 김형배/박지순, 「노동법강의」, 304면 참조.



및 도입이 필요하다.

물론 단체협약(또는 근로계약)에서 정한 평가액이 적당한지 여부에 대한 판단기준과 관련해서는 아직 구체적인 해석례가 나와 있지 않다. 하지만 사용자가 그 주식보상을 위해 투입한 실제 비용(자사주식의 취득비용)을 초과하는 금액을 평가액으로 정하는 것은 허용되지 않을 것이다.

만약 주식보상제가 일반적인 임금의 지급방식으로 인정되고 임금의 구성부분을 이룬다면 현행법상으로는 이를 평균임금 산입대상으로 검토할 수밖에 없을 것이다. 평균임금은 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 주식보상이 임금이라면 우선 평균임금의 취지에 따라 이를 평균임금에 산입하는 것이 타당한지 검토하고, 다음으로 어느 시점의 가액을 평균임금에 반영해야 할지 검토가 필요하다. 다른 특별한 약정이 없는 한 적어도 그 평가액(부여당시 주식가치)은 평균임금 산입 범위에 포함될 수 있을 것이다. 주식보상이 연간 성과로 지급되는 것이고 그 금액이 전체 임금에서 차지하는 비율이 상당하다면²³⁷⁾ 1년 중 3개월에 해당하는 비율만큼 평균임금에 포함시켜야 할 것이다.

반면에 주식보상을 평균임금에 산입하는 것이 적절한지 여부에 대해서 논란이 제기될 수 있다. 대부분 주식보상은 단기간에 현금화하는 경우가 없고, 중장기적인 가치실현과정을 거쳐 근로자의 재산으로 편입되는 것이 일반적이다. 그래서 주식보상을 장기인센티브라고 한다. 즉, 주식보상이 부여되는 시점과 실제로 환가화하는 시점이 다르다. 이러한 특징을 평균임금 산정 방식에 어떻게 반영되어야 하는지는 아

237) 예를 들어 전체 급여 중 주식보상이 50% 이상을 차지하고 현금으로 지급되는 급여가 최저임금 수준에 불과하다면, 주식보상을 제외하고 평균임금을 산정하는 것은 근로자 보호의 관점에서 타당하지 않을 것이다. 주식보상제가 자칫 근로자에 대한 적절한 법정수당의 보장을 잠탈하는 효과를 가질 수 있기 때문이다. 이에 비하여 근로자의 현금 연봉액이 동종 업계 평균 이상의 수준이고 이에 추가하여 일정액의 주식보상을 성과배분으로 지급받은 경우에도 이 주식보상액을 평균임금액에 포함하는 것이 타당한지 검토의 대상이 될 수 있다. 이를 평균임금에 포함한다면 기업의 인건비 부담이 증가하게 될 것이고 이로 인해 합리적인 주식보상제의 정착에 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 이러한 문제를 해결할 수 있는 방법의 하나는 근로자가 지급받는 전체 연봉 중 주식보상의 상한을 일정 비율로 제한하는 것도 생각해 볼 수 있다. 즉, 스톡옵션에 대한 상법상의 제한을 반영하는 것이다.



직 제대로 연구가 되어 있지 않다. 주식보상이 부여된 시점의 주식가치(아직 현금화 되지 않은 상황에서)를 근로자가 현금으로 지급받은 것으로 의제하고 평균임금 산정에 반영하는 것도 방법일 수 있지만, 그것이 얼마나 객관적이고 타당한지는 검증이 필요하다. 다만, 임금의 일부를 주식으로 받는 경우에 이를 평균임금 산입 범위에서 제외한다면 근로자에게 불이익이 될 수밖에 없으므로 위에서 설명한 바와 같이 적어도 부여 당시의 주식가치가 평균임금 산입 범위에 포함되어야 할 것이다.

제3절 소결

제3장에서는 임금 개념론에서 가장 논란이 되고 있는 구체적 사안인 경영성과급과 최근 대기업을 중심으로 확산되고 있는 주식보상제의 의의 및 노동법적 쟁점도 함께 검토하였다.

경영성과급은 기업마다 그 지급조건이나 지급방식, 산정방법이 다양하기 때문에 일률적으로 그 임금성을 평가하기 어렵다. 물론 경영성과급의 임금성 여부도 대법원이 판시한 임금의 일반적 요건을 기초로 판단될 것이다. 즉, 해당 금품이 계속적·정기적으로 지급되고 있는가, 사용자에게 단체협약이나 취업규칙 등에 의하여 지급의무가 부여되어 있는가, 그리고 경영성과급이 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 가지고 있는가에 따라 임금성 여부가 판단된다. 이 중에서 계속성·정기성 여부는 비교적 그 판단이 용이하기 때문에 쟁점화될 가능성은 높지 않을 것이다. 사용자의 지급의무에 대해서는 그 지급사유의 발생이나 지급조건이 불확정적이고 그 지급 여부 및 지급대상자가 유동적인 경우에는 ‘지급의무’가 존재한다고 볼 수 없기 때문에 임금으로 인정되기 어렵다.

사용자의 지급의무가 존재하더라도 그것만으로는 임금이라고 단정하기 어렵다.



대법원에 따르면 경영성과급의 지급이 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 가지고 있어야 하기 때문이다. 이 점과 관련하여 하급심에서는 직접적 관련성까지는 인정하기 어렵더라도 밀접한 관련성 정도는 인정할 수 있다는 입장(임금이라는 입장)과 그와 관련성을 인정하기 어렵다는 입장(임금이 아니라는 입장)이 대립하고 있다. 사건으로는 현재의 판례법리에 따르면 경영성과급이 임금으로 인정되기는 어려울 것이다. 그 지급이 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 가지고 있다고 보기 어렵기 때문이다. 그러나 기업이 목표로 삼은 경영성과(영업이익)의 달성에 근로자들의 공헌도 어느 정도 반영되어 있으며, 기업의 경영성과와 실적은 경영진의 경영능력과 근로자집단의 근로제공이 서로 협업함으로써 만들어 낸 것이라 할 수 있으므로 그 경영성과에 대한 몫으로 지급하는 경영성과급이 어느 정도는 근로제공과의 관련성을 가지고 있다고 볼 수도 있을 것이다. 따라서 경영성과급에 대하여 어느 정도 근로제공과의 관련성이 인정되므로 임금으로 볼 수 있을 것이다.

하지만 경영성과급과 같이 일정 조건의 충족 여부에 따라 지급여부가 달라지거나 그 지급금액이 매년 큰 편차가 있으며, 근로제공과 어느 정도 관련성을 가지고 있다고 하더라도 직접 또는 밀접한 관련성까지는 인정되기 어렵다면 이 금품이 근로자의 통상적인 생활임금을 반영하고 있다고 보기 어려우므로 평균임금 산입 대상으로서의 임금으로 보기는 어려울 것이다.

특히 매년 변동성이 큰 경영성과급을 평균임금으로 인정할 경우 그로 인한 부작용도 적지 않을 것이다. 평균임금 산정에 유리한 시점을 선택해 평균임금 산정 사유를 임의로 정하는 것이 그 예이다. 따라서 평균임금제도의 취지(근로자의 통상적 생활임금의 반영)를 고려하여 그 산입 대상 임금의 범위를 정하는 것이 필요하고, 이를 위해서는 현행 평균임금제도의 개선이 뒤따라야 할 것이다. 예를 들어 일본의 경우처럼 3개월을 초과하는 기간마다²³⁸⁾ 지급되는 성과급에 대해서는 평균임금 산입 범위에서 제외하는 입법례를 검토할 수 있다(일본 노동기준법 제12조 제4항 참고).

238) 우리나라의 경우 상여금 또는 성과급 지급 실태를 고려하여 기간에 대해서는 달리 검토할 수 있을 것이다.



최근에는 사용자가 종업원의 사기진작을 위하여 자사 주식을 지급하는 사례가 늘고 있다. 이를 주식보상제(스톡옵션, 스톡그랜트, 양도조건 제한부 주식(RSU)등이 여기에 해당된다)라 하는데, 이 주식보상이 임금인지 아닌지 논란이 될 수 있다. 원칙적으로 근로기준법에 따르면 임금은 통화로 지급되어야 하고, 법령이나 단체협약에서 정한 바가 있으면 통화가 아닌 현물로 지급할 수 있다. 따라서 단체협약을 체결하여 종업원에게 임금 대신에 자사주의 지급을 약속하였다면 임금으로 볼 여지가 있을 수 있다. 하지만 단체협약으로 이를 정했다고 언제나 곧바로 임금이라고 단정할 수는 없다. 그와 같은 주식보상이 임금이기 위해서는 근로대가성이 인정되어야 하기 때문이다.

구체적으로 특정 주식보상이 임금에 해당하는지 여부에 대해서는 아직 일반적으로 검토된 바가 없다. 일본에서는 스톡옵션의 임금성을 부정하는 견해가 다수라고 할 수 있다. 향후 RSU와 같은 새로운 주식보상방식이 널리 확산되고 있는 상황에서 계속적·정기적으로 부여되는 주식보상에 대하여는 임금성을 인정하여 적극적으로 근로자를 보호할 필요가 있을 것으로 생각된다.

주식보상을 임금으로 인정할 경우 발생하는 노동법적 쟁점으로, 우선 근로기준법상 임금의 통화지급의 원칙 위반 문제가 제기될 수 있다. 주식으로 임금을 갈음하는 것은 일종의 현물급여에 해당하므로 단체협약의 근거 없이 임금으로 지급한다면 근로기준법 제43조 제1항에 따른 통화지급의 원칙에 반한다. 향후 주식보상제의 활성화를 위해서는 통화지급의 원칙을 수정해야 할 것이다. 현행처럼 단체협약에 의한 예외만을 인정할 것이 아니라, 주식이나 가상화폐와 같이 현금성이 인정되는 지급수단에 대해서는 당사자의 합의가 있으면 통화 이외의 것으로 지급할 수 있도록 하는 것이다. 다만 이 경우 대등성이 결여된 당사자 간 합의의 문제를 보완하기 위하여 근로자에게 주식보상에 대한 선택권을 인정하는 것이 합리적인 방안이라고 생각된다.

또한 주식보상 또는 주식의 가액을 임금으로 인정한다면 근로자가 지급받는 전체 임금 중 주식보상의 비율이 어느 정도까지 인정될 수 있는지가 문제 될 수 있다.



주식은 그 자체로서는 통화(通貨)가 아니므로 근로자의 생활안정을 위해서는 임금의 일정부분은 통화로 지급되어야 한다. 그러나 현행 근로기준법은 법령이나 단체협약으로 통화지급원칙의 예외를 정할 수 있도록 허용하면서도 그 한계를 규정하고 있지 않다. 다만, 근로기준법 제47조는 “도급이나 그 밖에 이에 준하는 제도로 사용하는 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하여야 한다.”라고 규정하고 있을 뿐이다. 물론 주식보상제 실시가 근로기준법 제47조의 적용대상이 될 수는 없지만 임금액 감소로 인한 생활위협으로부터 근로자를 보호하는 이 규정의 취지는 주식보상제의 한계를 설정함에 있어서 참고될 수 있을 것으로 보인다. 이와 같이 주식보상제의 실시 배경이나 필요성을 고려하면 벤처기업, 스타트업, 성장기업 등의 경우 주식보상제를 통해 근로자의 동기유발을 촉진하는 측면이 있으므로 근로자의 생활보장을 위한 통화지급을 전제로 주식보상액의 규모나 범위를 정할 수 있을 것이다.

주식보상이 일반적인 임금의 지급방식으로 인정되고 임금의 구성부분을 이룬다면 이를 평균임금 산입대상으로 삼아야 하는지가 결정되어야 한다. 주식보상이 임금이라면 현재로서는 부여 당시의 주식가치를 평균임금 산입 범위에 포함하는 것이 일응 타당해 보인다. 평균임금 산입 방법에 대해서는 앞으로 논의가 필요한 부분이라고 생각된다.

임금의 개념은 근로의 대가라는 임금의 본질에 관한 것이고, 평균임금은 근로자의 통상적 생활임금을 산출하기 위한 도구적 개념이므로 양자를 분리해서 이해하는 것이 타당하다. 이처럼 두 개념은 서로 차원을 달리함에도 불구하고 대법원은 평균임금 산출을 위한 사안에서 임금 개념의 해석을 통해 결론을 도출하고 있다는 점에서 문제가 있다고 생각된다. 경영성과급이나 주식보상과 같은 “부가급여”에 대해서도 임금성 그 자체에 대한 판단과 이 금품들을 평균임금 산입 대상에 포함할 것인지 여부를 분리해서 이해한다면 실무적으로도 기여하는 부분이 클 것이다.



제4장 임금체계의 노동법적 쟁점

제1절 서설

제2장에서는 임금 개념에 대한 규범적 분석을 다루었고, 제3장에서는 임금 개념과 관련하여 최근 중요한 쟁점으로 떠오르고 있는 경영성과급의 임금성 여부와 앞으로 확산될 것으로 예상되는 주식보상제의 법적 성격 및 노동법적 과제에 대해서도 검토하였다.

제4장에서는 이러한 논의를 바탕으로 임금체계의 변동과 각 임금체계에 따른 노동법적 쟁점에 대해 검토하고자 한다. 먼저 임금체계의 의미와 변천과정을 검토하고 임금체계 변경으로 인한 임금 구성의 변화를 예상하면서 임금구성 변화가 근로대가의 해석에 미칠 수 있는 영향을 검토한다(제2절).

다음으로 노동법상 임금문제의 특성을 이해하기 위해서는 임금분쟁의 법적 쟁점이 임금청구권의 발생, 변동, 소멸에 관련된 것이며, 특히 임금청구권의 변동과 관련된 법률문제의 기본구조를 검토한다(제3절).

그리고 임금체계의 변화는 단순히 임금계산이나 지급조건 및 지급방법의 문제에 한 영향을 미치는 것이 아니라 인사관리분야에도 큰 영향을 미친다. 직무급제도의 경우 배치전환으로 인해 직무가치의 변동이 발생하게 되면 근로자의 임금 및 직업상 경력관리에도 불이익이 발생할 가능성이 크기 때문에 인사에 관한 사용자의 재량권 범위가 제한될 수밖에 없다. 성과주의 임금제도에서도 인사평가제도의 공정성은 근로자의 임금수준에 곧바로 영향을 주기 때문에 평가를 둘러싸고 법적 분쟁이 확산될 수밖에 없다. 이처럼 종전의 임금체계에서는 크게 문제시되지 않았던 인사관리의 운영방식이 임금체계의 변경으로 인하여 새로운 법적 분쟁이 야기될 수 있다는 점을 고려해야 한다(제4절).

또한 임금체계의 변경은 집단적 근로조건의 변경에 해당하므로 단체협약 또는 쟁



업규칙상 근로조건의 (불이익) 변경의 문제가 발생할 수 있다. 이와 관련된 법적 쟁점도 검토대상이라고 할 수 있다(제5절).

제2절 임금체계 개선의 방향과 내용

I. 임금체계의 변천과 특징

1. 의의

최근 임금체계라는 용어가 정부 정책과 기업실무에서 자주 사용되고 있으나, 임금체계는 법률용어는 아니다. 기업의 경영실무에서는 임금체계를 하나의 기업 내에 존재하는 다양하고 복잡한 임금의 구성요소와 결정방식을 총괄하는 개념으로 사용하거나, 임금을 구성하는 항목이 어떻게 되어 있는지를 보여주는 개념으로 사용되고 있다.

기본급의 지급 원리로서의 임금체계는 크게 연공급, 직무급, 그리고 직능급/능력급/숙련급으로 구분할 수 있다.²³⁹⁾ 직무급은 근로자가 담당하는 직무의 가치, 연공급은 해당 기업의 근속기간, 그리고 능력급/숙련급은 보유 지식이나 숙련의 정도에 따라서 기본급 및 그 인상이 결정되는 체계이다.²⁴⁰⁾

기업마다 특정 유형의 임금체계를 갖고 있지만 왜 그와 같은 임금체계를 갖게 되었는지 그 원인을 분석하는 것은 쉽지 않으며, 법적 관점에서 분석대상으로 보기 어렵다. 또한 한국, 일본, 미국, 유럽국가 등 각 국가를 대표하는 지배적 임금체계

239) 김동배/정진호, 「임금체계의 실태와 정책과제」, 한국노동연구원, 2006, 1면.

240) 노동법실무연구회(최은배), 「근로기준법주해 I」, 234면.



가 왜 다르게 전개되어 왔는지 그 원인을 분석하는 것도 쉽지 않다. 각 나라마다 중심적 산업(업종)과 기업의 조직문화 그리고 일하는 방식 등이 모두 다르기 때문이다. 예를 들어 일본은 연공급에 이은 직능급을, 미국은 직무급, 영국은 직종급을 채택하고 있는데 비하여, 우리나라는 아직도 호봉급으로 대표되는 연공급이 지배적이라고 할 수 있다.²⁴¹⁾ 그 이유는 임금체계 자체만으로 설명하기 어렵고, 주류적인 인사관리제도의 특징과 연계해서 이해해야 어느 정도 분석이 가능하다고 할 수 있다. 따라서 임금체계의 문제는 단순히 임금제도에 대한 기술적 분석이 아니라 인사제도 전반과 연계해서 이해해야 하며, 노동법적 쟁점도 그와 연관되어 나타나는 사례가 많다. 특히 노동법은 자유로운 임금체계 설계 및 운영에 대하여 근로자보호의 관점에서 일정한 제약을 가하는 법적 규제 영역이므로 기업의 보상정책수립과 운영 시 반드시 함께 고려되어야 할 요소라고 할 수 있다.

2. 연공형 임금제도의 특징

우리나라의 임금제도는 인사제도와 밀접한 관련을 가지고 전개되어 왔다. 대체로 산업화 단계에서 일본의 영향을 크게 받아 생활급을 기본으로 하여 형성된 연공서열형 임금제도가 다수의 기업에서 지금까지도 주류적 임금제도를 구성하고 있다.

그렇지만 그동안 노동개혁의 주요 과제로 언제나 임금체계 개편이 화두가 되었고, 그중에서도 연공형 임금제도를 직무와 성과를 중심으로 하는 직무급제 또는 성과주의 임금제도로 변경해야 한다는 요구가 늘 있어 왔다.²⁴²⁾ 그리고 실제로 직무급제 또는 직능급제를 도입한 사례도 없지 않다.²⁴³⁾ 그렇지만 대부분 남성으로 이루어진 세대주로서 가족의 생계를 책임지고 있는 종업원에게 고용안정을 보장하고, 기업과의 운명공동체를 강조함으로써 종업원의 장기근속을 장려하는 우리나라 전통적인 고용관행에서 벗어나지 않는 한 제도 형태가 직무급이나 직능급을 기본으로

241) 김동배/정진호, 「임금체계의 실태와 정책과제」, 5면 참고.

242) 노사정위원회, 「2016 임금보고서」, 20면 이하.

243) 노사정위원회, 「2016 임금보고서」, 52면 이하.



하더라도 실제 운영은 연공급을 벗어나기 어렵다는 것이 현실이다.

그렇다면 기업은 왜 연공형 제도와 운영에서 벗어나기 어려운 것일까? 결론부터 말하면 연공서열방식으로 임금을 결정하는 것에 대하여, 기업경영상 이론적으로는 문제가 있다가나 장기근속자에 대한 인건비 부담을 감내하기 어렵다는 등 문제가 있지만 결과적으로 지금까지 종업원이나 기업 모두 치명적인 불만이나 문제가 없었기 때문에 유지되어 왔다고 할 수 있다. 좀 더 구체적으로 검토하면 다음과 같다.

연공형 임금제도는 연령이나 근속기간이 누적되면 임금이 오르고, 정년퇴직하면 다액의 퇴직금이 지급되는 구조를 가지고 있다. 따라서 퇴직금을 포함한 임금곡선을 보면 연령이 높을수록 연공성이 훨씬 높아지게 된다. 그렇지만 실제 종업원의 공헌도는 그만큼의 수준에 이르지 않는 것이 문제가 된다. 반대로 젊은 세대의 근로자로서는 실제 공헌도에 비해 임금액이 낮다는 문제가 발생한다. 즉, 연공형 임금액과 실제 공헌도의 괴리가 발생한다. 젊은 세대의 근로자는 이를 불공정의 문제로 인식하고 있다.

반면에 우리나라에서는 취직(就職)이 아니라 입사(入社)라는 단어가 상징하는 것처럼, 근로자와 회사 모두 정년까지 종신고용이 당연시되고, 경제발전을 전제로 젊었을 때는 임금이 낮더라도 나이가 들면 승급 및 승진이 이루어지고 선배나 상사와 같은 급여를 받을 수 있다는 확신적 기대가 있었기 때문에 강한 불만을 가진 사람은 거의 없었다. 또한 월급이 나이가 들면서 인상되는 연공급은 생계비의 지출 곡선과도 맞아 떨어지는 것이므로 안심하고 일할 수 있는 조건이라고 할 수 있다. 뿐만 아니라 연령과 근속기간이라는 기준은 인사평가 결과와는 달리 누구도 불평할 수 없는 객관적인 차이라고 할 수 있으므로 근로자로서는 이해하기 쉬운 기준이 된다.²⁴⁴⁾

연공형 임금제도는 기업측에서도 장점이 있다. 직원의 연령구성이 이른바 피라미드형인 경우 임금이 실제 공헌도보다 낮은 젊은 직원이 많고 실제 공헌도보다 높은 고령자가 적다는 점에서 전체 인건비 차원에서 총 공헌도에 대비하여 낮은 수준에 머무르고 이러한 여유자금으로 투자를 확대하여 기업의 발전에 기여할 수 있기 때

244) 經團連編, 「人事賃金制度」, 2017, p.17.



문이다. 이점이 산업화 과정에서 고도성장을 촉진하는 요인의 하나라고 할 수 있다. 또한 근로자가 낮은 임금 때문에 전직을 시도하더라도 전직 대상인 다른 기업도 대부분 연공형 임금이기 때문에 종전보다 높은 임금을 지급하는 회사를 찾는 것이 쉽지 않다는 점도 기업으로서는 인재확보의 관점에서 유리한 측면이었다고 할 수 있다.²⁴⁵⁾

3. 임금제도 개선의 배경과 방향

이와 같이 연공형 임금제도는 임금이론적 측면에서는 문제가 있었다 하더라도 산업화 단계의 고용관행이나 기업의 경영환경에 적합했기 때문에 크게 문제되지 않았다.

하지만 최근에 이른바 급속한 저출생 고령화의 진행으로 인구구성에 큰 변화가 초래되고, 역피라미드형으로 전개되고 있다. 그에 따라 기업에서도 직원의 연령구성이 역피라미드형으로 전환될 수밖에 없을 것이다. 그럼에도 만약 연공형 임금제도가 그대로 유지된다면 실제 공헌도보다 임금이 낮은 젊은 직원은 줄어 들고, 실제 공헌도보다 높은 임금을 받는 고령자의 비중이 늘어나 인건비는 전체 공헌도 대비 매우 높은 상태가 될 수밖에 없다. 요컨대 연공형 임금은 고령자가 많은 인원 구성에서는 적정한 인건비를 유지하는 것이 불가능한 시스템이라고 할 수 있다.²⁴⁶⁾

노무구성의 고령화의 진행으로 인건비가 계속 팽창하는 연공형 임금은 기업이 성장·확대를 계속하는 고도성장기라면 다소 인건비가 늘더라도 지급능력에 큰 부담을 주지 않는다. 그러나 저성장이 일반화되고 기업 경쟁력이 떨어지는 등 경영환경이 어려워지면 연공형 임금은 본격적으로 개혁대상이 될 수밖에 없다. 나아가 글로벌 경쟁 체제하에서 외국인을 적극적으로 채용하게 되면 우리나라 특유의 연공형 임금으로는 우수한 외국인력을 채용하는데 곤란을 겪게 된다. 그 때문에 처우제도

245) 經團連編, 「人事賃金制度」, p.18.

246) 經團連編, 「人事賃金制度」, p.20.



도 글로벌 스탠다드를 고려할 수밖에 없다.

경영환경의 변화에 수반하여 직원들의 연공형 임금에 대한 의식도 크게 변화하고 있다. 과거 고도성장기의 산업화 단계에서는 연령과 근속기간에 의한 승급·승진에 대하여 확신적 기대가 있고, 생계비 곡선을 바탕으로 설계된 연공형 임금에 큰 불만이 없었으나, 저성장기에 접어들고 기업경쟁력에 비상이 걸린 상황에서는 장래에 대한 확신적 기대를 갖기 어렵다. 특히 젊은 직원들은 회사가 정년까지 존속한다는 기대조차 갖기 어렵다. 그 때문에 젊은 시기의 임금도 실제 공헌도를 반영해 줄 것을 요구하게 되고, 자신의 업무와 성과·업적을 현재 시점에서 적정하게 평가하고 처우에 반영하는 것이 공정하다는 인식이 확산되고 있다.

이와 같은 경영환경의 변화를 배경으로 연공형 임금제도는 경영의 관점은 물론 직원들의 납득성의 관점에서도 유지하기 어렵게 되고 있다. 그렇다면 향후 어떤 방향으로 개선되어야 할 것인가?

그 첫 번째 포인트는 직무(업무) 가치에 따른 임금체계이다. 직무의 가치는 우리나라의 경우 회사 횡단적으로 외부 노동시장에서 직무의 임금이 결정되는 것은 아니기 때문에 어디까지나 기업 스스로 독자적 판단에 기초한 가치기준이 된다. 그러나 각각의 직무가치가 공표되고, 자신은 이 직무를 담당하고 있기 때문에 이만큼 임금을 받을 수 있다는 것이 분명해지면 다른 사람과 임금액이 차이가 발생하는 이유도 명확해지고 더 가치있는 직무를 하기 위한 능력개발의 동기가 부여되기도 한다. 따라서 업무의 중요도, 책임, 난이도와 같은 직무가치에 따라 임금을 지급하는 체계는 공정성이나 수용성이 높은 제도라고 할 수 있다.

다만, 같은 직무이기 때문에 같은 임금이 지급되어야 한다는 것은 언제나 공정한 것은 아니다. 예를 들어 택배상자에 수신인 라벨을 부착하는 업무를 생각해보면, 1시간에 100개의 택배상자에 라벨을 붙일 수 있는 사람과 200개의 택배상자에 라벨을 붙일 수 있는 사람은 그 성과 차이가 2배에 이른다. 이 성과의 차이를 무시하고 임금을 같게 하는 것은 공정성이 결여될 수밖에 없다. 또한 라벨을 잘못 붙이면 수취인을 불편하게 하거나 붙이는 방법이 약하면 벗겨질 수 있으므로 붙이는 방법의 정확도도 성과의 차이로 당연히 고려되어야 한다. 이처럼 성과에 기초한 임금체계



일 것, 이것이 두 번째 포인트이다.²⁴⁷⁾

요약하면 각 종업원의 회사에 대한 공헌도는 어떤 직무를 담당하고 있는가, 그 직무에서 어느 정도 성과를 창출했는가라는 “직무”와 “성과”라는 두 개의 축으로 평가가 이루어져야 한다.

직무와 성과로 평가되는 공헌도는 근속기간이나 연령에 관계없이 개별 근로자마다 다르다. 이 제도에서는 공헌도(기여도)보다 근속기간이나 연령을 중시하는 연공형 임금제도와 달리 기업의 노무구성이 아무리 고령화되더라도 이론적으로는 인건비가 증가하지 않는다. 임금의 결정요소는 직무와 성과이며 근속기간이나 연령은 관계없기 때문이다.²⁴⁸⁾

이와 같이 임금체계가 고령화 등에 의하여 유지되기 어려운 연공형에서 각 근로자들의 공헌도, 즉 직무나 역할, 성과를 토대로 하는 제도로 전환되기 위해서는 인사제도 자체를 개혁하여 연공에서 직무에 기초한 조직으로 변경하는 것이 대전제가 된다. 몇가지 새로운 임금제도로써 직무, 역할 또는 직능을 토대로 하는 직무급, 역할급, 직능급을 도입하더라도 그 지급기준이라고 할 수 있는 인사제도가 연공적인 방식을 유지한다면 실질적으로 연공급과 다를 바 없기 때문이다.

이와 같이 임금체계의 변경에서 고려할 점은, 인사서열 등급의 기준이 되는 요소를 무엇으로 할 것인지 결정해야 한다. 그 요소를 “직위”에 둔다면 “직무등급제도”²⁴⁹⁾, “직무수행능력”에 둔다면 “직능자격제도”²⁵⁰⁾가 된다. 또한 직위의 내용을

247) 經團連編, 「人事賃金制度」, p.21.

248) 經團連編, 「人事賃金制度」, p.22.

249) 직무등급제이란 기업이 가장 효율적으로 경영활동을 할 수 있도록 한사람몫의 업무량(작업량)에 해당하는 하나 또는 몇 개의 과업을 배분한 “직위”를 설정하여 경영활동을 수행한다. 이와 같은 직위를 설정함에 있어서는 직종의 특성, 채용의 난이도, 직원육성의 개념, 종사자 인원수 등에 따라 과업 배분이 이루어진다. 직무등급제도는 이와 같이 설정된 직위에 대하여 직무분석 및 평가를 실시하여 기업 내부에서 서열화를 실시하고, 원칙적으로 그 직위의 서열을 기준으로 운영하는 업무기준 인사제도라고 할 수 있다. 그러나 기업내부의 모든 직위를 개개의 직무가치에 따라 인사를 운영하는 하는 것은 승진이나 배치전환, 직위내 과업배분의 변경 등 기업의 고용 및 인사관행을 크게 저해하는 요인이 될 수 있다는 점에서 적절한 인사관리를 위하여 허용가능한 범위에서 유의미한 차이를 인정하는 그룹핑하는 서열구분(직무등급)을 행하고 동일 그룹에 속하는 직위는 동일가치 직위로서 인사운명을 하게 된다. 이에 대해서는 經團連編, 「人事賃金制度」, p.32.



고정적으로 파악하지 않고 “역할”이라는 개념을 직무를 파악하고 역할을 인사서열 등급의 기준으로 삼는 “역할등급제도”²⁵¹⁾도 활용되고 있다. 이와 같이 임금체계 개선은 인사제도를 어떤 틀에서 설계할 것인지에 대한 기본적 구상을 정하는 것과도 연계된다.

연공형 임금제도를 실제로 합목적으로 운영할 수 있는 임금체계, 즉 직무급제 등으로 변경이 될 경우 이 변경이 초래하는 구체적인 법적 쟁점을 검토하는 것이 중요한 과제라고 할 수 있다. 이에 대해서는 후술한다(다음의 제4절 이하 참고).

II. 임금체계 변경과 임금 구성의 변화

1. 기본급의 구성요소와 변경

근로자에게 지급되는 근로의 대가는 여러 항목으로 나누어 지급되지만, 그중에서도 기본급이 가장 기초가 되는 임금항목이다. 이러한 기본급은 연령이나 근속기간에 따라 정기적으로 승급되는 연공서열형 방식과, 직무나 직능 또는 역할에 의하여

250) 직능자격제이란 직무(경영상 필요한 업무)의 수행을 통하여 발휘할 것이 요구되는 능력의 정도에 따라 단계화된 직능자격에 의하여 운영하는 인사제도를 말한다. 여기서는 직위를 구성하는 과업은 담당자의 직능수준과 조직 내의 조직 내 직능구성, 팀원 수에 의하여 제각각이어서 일정하지는 않지만 담당자의 직무수행능력 수준이 인사서열이 되고 그에 대응하는 직능급이 임금서열이 된다. 이에 대해서는 經團連編, 「人事賃金制度」, p.46.

251) 역할등급제이란 직무등급제도와 마찬가지로 연공이나 능력이 아니라 업무를 기준으로 한 인사제도이긴 하지만, 직무등급제도처럼 직위를 구성하는 과업이 미리 다 설정되어 있는 것도 아니고 직무기술서가 모두 작성되어 있는 것도 아니다. 수행해야 할 과업은 경영이 요구하는 수행해야 할 역할의 복잡도, 난이도, 책임도에 따른 역할단계 구분을 행하고 이를 기준으로 운영하는 것이다. 그 때문에 직위담당자에 따라 또는 그때그때 경영 실태에 따라 직위의 과업내용 중 일부가 해당 역할에 입각한 범위 내에서 바뀔수도 있지만 기본적으로 주어진 역할은 바뀌지 않으며, 당초 설정된 역할 서열이 기업 내 인사 서열이 되고 그에 대응하는 역할급이 기업 내 임금 서열이 된다. 따라서 배치전환, 승급, 승진 등을 운영하는 기준은 직원이 수행해야 할 역할이기 때문에 역할등급이 바뀌지 않는 한 원칙적으로 승진, 승급은 발생하지 않는다. 이에 대해서는 經團連編, 「人事賃金制度」, p.40.



그 액수가 정해지는 직무급 등으로 대별된다. 그러나 연공서열형이라 하더라도 연령과 근속기간만 고려하는 것은 아니고 어느 정도 직무, 직능, 자격, 직종, 역할도 기본급산정에 고려하는 것이 현실이다. 반대로 직무급제라 하더라도 직무만을 산정 기초로 하는 것이 아니라 연령이나 근속기간도 반영할 수 있다. 즉, 몇가지 요소를 조합해서 기본급이 구성된다. 그중에서 무엇이 주된 반영요소인가를 따져 임금제도의 성격을 판단하는 것이 중요하다.

연공서열형 임금제도에서 기본급의 핵심요소는 당연히 연령 또는 근속기간이다. 그 반영 방법이 매우 용이하고 간명하며 산정방식도 간단하다. 따라서 논란의 여지가 없다. 예컨대 근속급의 경우는 근속기간 1년마다 정기적으로 승급하는 방식이다. 우리가 일반적으로 보는 호봉제가 대표적인 모습이다. 또한 임금 감액 시에도 임금 피크제처럼 일정 연령에 도달하면 기본급의 일부를 감액한다.

이와 달리 직무, 능력을 반영한 기본급 형태는 직능급, 직무급, 역할급 등이다. 직능급부터 설명하면, 직능급의 직능이란 직무수행능력을 말한다. 요컨대 직무수행능력의 높고 낮음에 따라 기본급의 금액이 결정된다. 직능급이란 능력평가에 의하여 승급의 격차를 발생시키는 임금제도라고 할 수 있다. 직능급은 연령이나 근속과 결합하는 방식도 있고, 순수하게 직능 하나로 기본급을 결정하는 방식도 있을 수 있다.

직무급에서 직무란 근로자 1인에게 할당된 과업이라는 의미이고, 근로자 1인의 직무 난이도(직무가치)에 가격을 붙이는 것을 직무급이라고 할 수 있다. 직무급의 발상은 다른 회사의 경리직원은 얼마를 급여로 받는지 파악하고 이를 토대로 자기 회사도 그 수준으로 결정하고자 하는 산업 및 업종별(초기업별) 급여 결정방식에서 비롯된 것이라고 할 수 있다.²⁵²⁾

2. 수당제도의 재편 및 폐지

252) 高原暢恭, 「賃金、賞與制度の教科書」, p.75 이하 참고.



일반적으로 임금은 기본급과 제 수당 그리고 상여금으로 구성된다. 그리고 여러 수당은 직무관련수당과 생활관련수당으로 구성된다. 직무관련수당으로 대표적인 것은 직책수당, 직무수당, 특수작업수당, 특수근무수당 등이 있고, 생활관련수당으로는 가족수당, 통근수당, 식대, 주택수당, 지역근무수당 등 다양한 명칭이 있을 수 있다. 이러한 수당들은 대체로 연공형 임금체계에서 전개된 임금내역이라고 할 수 있다.

그렇다면 예를 들어 연공형 임금을 직무급제로 전환하는 경우 직무관련수당은 어떻게 되는가? 직무관련수당이란 일정한 직무내용의 대가로서 지급되는 수당을 말한다. 직책수당이란 부장, 과장이라는 회사 내의 직책에 대응하는 수당을 말한다. 특수작업수당이란 업무의 위험도나 직업환경을 고려하여 지급되는 수당을 의미한다. 특수근무수당은 일반적으로 교대제 등 특수한 근무형태에 보상하는 수당이라고 할 수 있다. 이와 같은 특별하거나 특수한 직무에 대한 대가는 각 근로자가 담당하고 있는 직무내용과 책임에 대한 대가이기 때문에 수당으로서 설정되는 것은 타당하지 않고 직무급이라는 기본급의 구성요소로 기본급에 포함되는 것이 타당하다. 그 때문에 직무급을 채택하는 경우에는 직무관련수당을 설정하지 않는 것이 일반적이다.

생활관련수당은 종래 회사에 대한 소속감, 생활안정 요구에 대한 부응 등 인사정책적 관점에서 기본급만으로는 불충분하다고 판단되는 경우에 근로자의 생활을 지원할 목적으로 지급해왔다.

또한 대체로 생활관련수당의 경우 통상임금의 산입대상에서 제외되는 경우가 많아 기본급을 그대로 둔 채 이러한 항목의 수당을 신설하면 법정수당의 증대를 방지하면서 지급되는 임금총액을 높이는 효과를 가지고 있었다. 물론 이에 대해서는 별도로 통상임금 해당성이 개별적이고 구체적으로 판단되어야 할 것이다.

이와 같은 생활관련수당은 반드시 설정해야 할 법적 의무가 없으며, 어디까지나 기업의 자율적 판단 내지 노사 간 합의에 의하여 설정되는 것이다. 따라서 직무급제가 도입되더라도 생활관련 수당은 그대로 존치될 수도 있고, 기본급에 포함되거나 폐지될 수도 있을 것이다.²⁵³⁾

253) 高原暢恭, 「賃金、賞與制度の教科書」, p.199 이하 참고.



그러나 생활관련수당도 그 실질은 근로제공의 대가로서 임금이므로 직무급의 기본급으로 편성되어야 하는 것은 아닌지 의문이 제기될 수 있다. 예컨대 통근수당이나 식대가 그 명목과 달리 임금에 해당한다면 직무급 전환 시 기본급에 포함될 수 있을 것이다. 생활관련수당이 직무급 하에서 기본급으로 편성될지 아니면 생활관련수당으로 유지될지는 결국 해당 수당의 성격을 어떻게 파악하느냐에 달려 있을 것이다.

기업이 임금체계를 직무급 또는 직능급으로 개편하는 경우 기업은 원칙적으로 근로자측과의 협의나 합의를 통해 생활관련수당의 운명을 결정할 수 있을 것이다. 물론 수당을 폐지하는 것도 가능하다. 다만, 제수당의 폐지로 근로자가 받는 임금액이 감소한다면 근로자에게는 불이익변경에 해당하고 따라서 취업규칙의 변경인 경우 근로기준법 제94조에 따라 근로자의 집단적 동의를 얻어야 한다.

다른 한편, 우리나라의 경우 기업이 각종 수당을 복리후생 명목으로 지급해 온 역사가 길고, 민간기업의 복지기여도가 높다고 할 수 있다. 그러나 이러한 수당의 상당수는 근로의 대가가 아닌 경우가 많고, 그 제도화도 법적 구속력이 없다는 점에서 기업 간 보상의 격차를 초래하는 원인이 되기도 한다. 즉, 동일기업 내에서 정규직 근로자와 비정규직 근로자의 차별이 시정되더라도 대기업과 중소기업의 근로자 사이에는 직무가치와 관계없이 임금격차가 발생할 수 있다. 이와 같이 비임금적 복리후생수당의 규모를 어떻게 할 것인가가 향후 근로자 간 격차 완화를 위한 중요한 포인트라고 할 수 있다. 다른 한편으로 복리후생급여들을 성과급으로 통합하여 업적에 연동시키는 방법도 고려될 수 있을 것이다. 이렇게 되면 복리후생급여는 더 이상 비임금적 급여가 아니라 근로의 대가성을 가진 임금으로 분류될 수 있다. 이처럼 직무급제도의 임금체계 변동은 사용자가 지급하는 금품의 법적 성격도 변화시키는 파급력을 가질 수 있다. 이러한 의미에서 임금체계 문제는 임금 개념과도 일정 정도 관련성을 갖게 된다.

3. 상여금제도 및 성과급제도의 개선



일반적으로 정기상여금은 기본급과 함께 통상임금의 구성요소를 이루는 것으로 사실상 기본급의 일부라고 할 수 있다. 따라서 직무급제가 도입되면 정기상여금도 기본급과 함께 직무급으로 재편되는 것이 바람직하다.

문제는 경영성과급과 같이 기업의 경영성과, 영업이익에 연동하여 지급하는 특별성과급이다. 특별성과급도 다양하게 설계될 수 있는데, 예를 들어 순수한 보너스로서, 정기 또는 임시로 근로자의 근무성과와 관계없이 지급되며, 그 지급액이 미리 정해져 있지 않은 금품인 경우도 있다. 이와 같은 특별성과급은 매월 지급하는 임금과 달리 그 지급을 취업규칙(보수규정)에 명시하지 않은 이상 사용자에게 지급의 무가 부과되지 않는다.²⁵⁴⁾

이와 같은 특별성과급의 설정 여부는 기본적으로 기업의 재량적 결정영역에 속한다. 직무급을 도입할 경우 직무와 임금의 대응관계를 명확히 하면서, 성과급 지급규정을 두지 않는 것도 가능하다. 한편, 직무급은 연공형 임금과 달리 기본적으로 정기승급이 예정되어 있지 않기 때문에 성과급이 근로자에게는 단기적인 인센티브로서 중요한 의미를 가지고 있다는 점도 그 지급 여부를 검토하는데 고려되어야 할 점이라고 할 수 있다.

그런데 지금까지 취업규칙 등에 지급규정을 두어 경영성과급을 매년 정기적으로 지급해 온 기업이 기본급을 연공형에서 직무급으로 변경하면서 직무와 임금의 대응관계를 명확히 하고, 취업규칙을 변경하여 기본급에 성과급 지급분을 반영한 다음 그 성과급을 폐지하는 것이 가능한지 문제될 수 있다.

직무급을 기본으로 하는 서구에서는 성과급을 기업의 경영성과 또는 근로자나 집단(팀, 부서 등)의 업적 평가에 따른 부가급여로서 지급하고 있다.²⁵⁵⁾ 이러한 부가급여는 비록 구체적인 수당 산정시 산입되는 임금에서 제외될 수 있지만 넓은 의미

254) 久保原和也 外, 「職務給の法的論點」, 2021, p.137 이하 참고.

255) 독일에서는 이를 보너스(Gratifikation)라고 하고, 특별급여 또는 부가급여라고 부르며, 넓은 의미의 임금이라고 하기도 한다. 이에 관해서는 앞의 제2장 제3절 1. 참고. 미국의 경우 비재량적 보너스가 이에 해당한다. 이에 관해서는 제2장 제3절 Ⅲ. 2. 참고.



의 임금이라고 할 수 있다. 연공형에서 정기적·임시적으로 지급되는 상여금이나 성과급은 직무급제 하에서는 업적에 연동되는 변동형 성과급으로 재편함으로써 부가급여로 재편할 수 있을 것이다. 이 경우 성과급의 산정기준이나 방식이 기업의 경영성과를 대상으로 하더라도 이 또한 노사 간 합의의 결과로서 포괄적 근로대가성을 인정할 수 있을 것이다.

취업규칙에 지급 근거를 둔 경영성과급을 폐지하는 경우(취업규칙의 변경), 그 임금전체 총액을 감소시키지 않더라도 각 근로자에게 있어서 연간 임금총액을 감소시킬 가능성이 있다면 근로조건의 불이익변경에 해당한다고 볼 수 있으므로 근로자측의 집단적 동의가 필요하다고 해석된다.

직무급은 기본적으로 정기승급이 예정된 것이 아니므로 성과급은 근로자에게 단기적 인센티브로서 중요한 의미를 갖는다. 다른 임금 인상 요인이 없는 경우 성과급의 지급액수가 임금 인상의 범위를 결정하기 때문이다. 따라서 변동형 성과급을 통해 근로자에 대한 근로의욕 고취 및 근로성과에 대한 보상이 강화될 수 있다. 이는 성과급이 근로의 대가로서 중요한 역할을 맡고 있음을 의미한다. 이러한 의미에서 근로의 대가라는 것은 그 지급의 원인, 산정 기준만을 놓고 판단할 것이 아니라 성과급의 기능과 역할을 함께 볼 필요가 있으며, 근로관계의 당사자가 이를 보수(임금)로서 합의하였는지 여부가 근로대가성을 판단하는데 중요한 역할을 수행한다고 할 수 있다.

제3절 임금청구권의 변동과 소멸

I. 논의 필요성

근로자는 근로계약에 터잡아 사용자에게 근로를 제공하고 그에 대한 대가로 사용



자에 대하여 임금지급청구권을 취득한다. 반대로 사용자는 근로자의 근로제공을 수령하고 그에 대하여 임금지급의무를 부담한다. 임금의 지급을 둘러싼 대부분의 법률문제는 임금청구권의 발생·변동·소멸에 관한 것이다. 즉, 근로자는 지급받아야 할 임금을 제대로 지급받지 못한 경우 그 지급을 청구하고, 사용자는 지급의무의 부존재를 항변하게 된다. 특히 임금제도는 인사제도와 밀접한 관련성을 가지기 때문에 이에 관한 법률분쟁의 내용을 이해하는 것은 노동법상 임금문제의 특수성을 이해하는데 있어서도 중요한 의미를 갖는다. 따라서 임금제도의 노동법적 쟁점을 탐구함에 있어서 임금청구권을 중심으로 그 법률문제의 기본적 구조를 이해하는 것도 중요한 과제라고 할 수 있다. 이 주제는 다음 제4절 이하에서 검토하는 임금체계론과도 밀접한 관련성을 갖는다.

특히 일반적으로 임금이란 근로자의 근로제공의무에 대한 포괄적 반대급부를 의미하는 것인데, 구체적으로 임금청구권이 언제 발생하는지, 어떤 경우에 감액되는지, 감액의 근거와 범위는 어떻게 결정되는 것인지도 검토가 필요하다.

본절에서 다루는 임금청구권의 변동 유형으로는 임금 인상을 의미하는 승급(昇給)과 임금 감액을 의미하는 감급(減給)이 있다.

II. 승급과 노동법적 쟁점

기업에서 일반적인 임금 인상(승급)의 형태는 호봉제 하에서 호봉승급, 정기승급과 베이스업 등이 있다.

승급(昇給)이란 연령·근속연수·고과성적 등 임금의 결정요소의 변화에 따라 기본급을 인상시키는 것을 말한다. 승급은 연령이나 근무기간의 증가 등 자연적 현상을 기준으로 자동적으로 이루어지기도 하고(자동승급), 인사평가 성적(근무성적)을 기준으로 이루어지기도 한다. 그리고 승급이 실시되는 시기에 따라 정기승급과 임시승급이 있다. 승급의 이유라는 관점에서 직무수행능력 향상 등과 같은 일반적 이유에 따른 통상적 승급과 특수 직무에서의 공로 등 특별이유에 따른 특별승급으로



나누는 분류방법도 있다.²⁵⁶⁾

승급제도를 두는 이유는 ① 연령·근속연수·직무수행능력 등 근로자의 주관적 변화와 임금수준의 조정기능 ② 정액급이 갖은 동기부여 결여를 보충하는 사기진작 기능 ③ 근로자 생활수준 상승에 따른 생활비의 증가에 대응하는 생활수준 유지기능 ④ 임금의 계획적 증액을 가능하게 하는 기업경영의 안정기능 등이 있다.

정기승급은 노사 간의 교섭 및 단체협약의 체결을 통해 구체적인 승급기준이 정해진다. 또한 승급 및 정기승급에 있어서는 일정한 근무성적 요건이나 성적불량, 장기 결근 등 결격사유가 마련되는 경우가 있는데, 그 경우 승급은 사용자의 인사평가를 토대로 하게 된다. 물론 노동조합이 없는 사업장에서는 사용자의 일방적 결정 또는 노사협의회에서의 협의를 통해 결정되는 경우도 있다. 이때 노사협의회의 결정은 그 자체가 단체협약이 아니기 때문에 그 결정이 강행적·직접적 효력을 갖는다고 볼 수는 없다. 다만, 사용자가 그 결정에 스스로 구속되겠다는 약속(Gesamtzusage)을 함으로써 채무를 부담하게 될 수 있다.

이와 같이 승급에서는 노사 간 합의나 사용자의 결정에 의하여 승급률이나 승급액이 근로계약의 내용이 되어야 하므로 승급률이나 승급액이 결정되기 이전 단계에서 승급청구권이 인정될 수는 없다.²⁵⁷⁾ 예를 들어 회사의 보수규정에 “승급은 매년 3월 1일 자에 실시된다”라는 규정이 있더라도 구체적인 승급률이나 승급액이 확정되지 않았다면 이 규정만으로 직접 승급청구권이 발생하는 것은 아니다.²⁵⁸⁾

승급 중에는 인사평가를 거쳐 행해지는 부분이 있을 수 있는데, 이는 기본적으로 사용자의 재량권(인사평가권)에 맡겨진다. 이 경우 인사평가가 사용자의 권리남용으로 평가되면 불법행위가 성립할 수 있다(이에 대해서는 다음 제5장 제3절 참고). 하지만 이 경우에도 승급 그 자체에 대한 청구권은 사용자가 승급의 의사표시를 하지 않은 이상 계약내용이 되지 않는다는 점에서 원칙적으로 인정되기 어렵다.²⁵⁹⁾

256) 西谷民外 編(土田道夫), 「労働基準法・労働契約法」, p.85 참고.

257) 東京地判 平成 7.12.25 勞判 689호 p.31.

258) 土田道夫, 「労働契約法」, p.256.

259) 大阪地判 平成 13.6.27 勞判 809호 p.5.



승급의 결정에 대해서는 균등대우원칙과 남녀동일임금의 원칙, 비정규직 근로자에 대한 불합리한 차별의 금지, 부당노동행위로서 불이익취급 금지의 원칙 등이 적용된다. 따라서 사용자가 이러한 강행규정을 위반하여 승급시키지 않은 경우에는 불법행위로서 손해배상책임이 발생한다.²⁶⁰⁾

물론 이와 같은 승급은 기본급을 올리는 가장 중요한 방법이기도 하지만 유일한 방법은 아니다. 또 다른 임금인상 방법으로서 임금수준 그 자체를 개정해 전체 근로자 임금을 일제히 올리는 베이스업(Base-up)도 있다. 베이스업은 전체적인 임금수준의 상향조정 내지 임금인상률을 의미한다. 즉, 연령, 근속년수, 직무수행능력이라는 관점에서 동일 조건에 있는 자에 대한 임금의 증액으로 임금곡선 자체를 전체적으로 상향이동 시키는 것이다. 베이스업도 위의 승급과 마찬가지로 노사 간 합의나 사용자의 결정에 의하여 인상률 및 금액이 확정되고 그에 따라 청구권이 발생한다.²⁶¹⁾ 이 승급이나 베이스업은 매년 노사 간 교섭에 의하여 차년도 임금인상률을 결정하는 방식으로 이루어진다. 일반적으로는 임금인상률을 일률적으로 인상하거나 평균적 인상률을 결정한 다음 근로자 개인별로 인사평가를 통하여 배분하는 방식을 택하기도 한다. 이처럼 후자의 경우(인사평가에 따라 구체적인 승급액이 결정되는 경우)에는 구체적으로 승급액을 결정하는 명시적 또는 묵시적인 계약상의 근거가 없는 한 근로자는 구체적인 승급청구권을 갖지 못한다. 다만, 사용자의 인사평가권의 행사가 법령을 위반하거나 권리남용에 해당하는 경우에는 불법행위로서, 인사평가가 취업규칙 등의 규정을 위반한 경우에는 채무불이행으로써 손해배상을 청구할 수 있다.

일반적으로 사용자는 전체 근로자의 임금 총액을 대폭적으로 증가시키는 베이스업(Base-up)보다 계획적으로 구간을 정하여 임금을 증액시킴으로써(이른바 Pay Band 시스템) 임금 총액을 장기적으로 안정화할 수 있는 승급 쪽에 방점을 두고 임금 정책을 추구한다. 따라서 대부분의 기업은 가급적 베이스업(Base-up)을 억제하고 승급에 중점을 두고 있다.²⁶²⁾

260) 西谷民外 編(土田道夫), 「勞働基準法・勞働契約法」, p.85

261) 土田道夫, 「勞働契約法」, p.256.

262) 이 때문에 노사 간 임금협상에서 큰 쟁점이 발생하기도 한다. 일률적인 베이스업을 요



Ⅲ. 임금의 감액(감급)

기업실무에서는 임금을 장래에 대하여 감액시키는 경우에 그 감액의 효력을 다투는 경우(감액 전후의 차액 및 그에 대한 지연손해금의 지급을 청구하는 소송)가 적지 않게 발생하고 있다. 근로자는 그 청구원인으로 감액 이전의 임금 발생 원인 사실을 주장하고, 사용자는 항변으로써 임금 감액의 법적 효과를 발생시키는 구체적 사실을 주장하게 된다.

그런데 임금액은 근로계약의 일방 당사자인 사용자가 마음대로 변경할 수 있는 것이 아니고 또한 임금을 감액할 수 있는 경우가 매우 제한적이다. 임금감액의 법적 효과를 주장할 수 있는 법률구성은 대체로 근로자에 대하여 집단적으로 행해지는 것과, 근로자 개인에 대하여 개별적으로 행해지는 것으로 구별된다. 전자의 경우는 취업규칙이나 단체협약의 변경에 의한 임금감액이 문제되고, 후자의 경우는 근로자에 대한 인사명령이나 평가에 의한 감액 또는 징계처분으로써 감액(감봉)을 들 수 있다.

1. 집단적 임금 감액

기업은 경영악화 등을 이유로 전체 종업원을 대상으로 인건비를 일정 비율로 감액하기로 하고, 이를 기본급과 제수당에서 일률적으로(예를 들어 기본급의 10% 일률적 감액) 또는 연령 등에 따라 배분비율을 결정하여 실시할 수 있다. 이와 같은 집단적(일률적) 임금감액을 베이스업의 반대개념으로 베이스다운(Base-down)이라 한다.

구하는 노동조합과, 직무와 역할을 중심으로 임금제도를 설계함으로써 고정비인 인건비의 안정적 총액관리를 희망하는 사용자의 입장이 충돌하기 때문이다.



베이스다운은 주로 취업규칙 불이익 변경이라는 형태로 행해지는데, 그 불이익변경이 유효하려면 근로자과반수(과반수노조)의 동의를 얻어야 하며, 다만 근로자과반수(과반수노조)의 동의없이 불이익변경을 하였더라도 근로자측이 동의하지 않은 것이 집단적 동의권 남용²⁶³⁾에 해당될 경우에는 예외적으로 동의를 없더라도 불이익변경이 유효하다. 예를 들면 경영상 어려움을 겪고 있는 기업이 베이스다운을 행하는 취업규칙 변경을 행한 일본의 사례에서, 일률적으로 25%를 감액 조치한 것과²⁶⁴⁾ 3년간 50%를 감액한 것을 합리성이 없다고 한 사례,²⁶⁵⁾ 반면에 2년간 한정해서 10% 정도 감액한 것을 합리성이 있다고 인정한 사례²⁶⁶⁾ 등이 있다.

또한 단체협약의 체결 또는 변경에 의하여 집단적인 임금감액이 행해지는 경우에는 협약자치의 한계를 벗어나지 않도록 노동조합의 협약체결권의 범위 내에서 행해질 필요가 있다. 일본에서는 예를 들면 55세 이상의 직원에 대한 임금을 일정비율 내지 일정금액 삭감한다는 내용의 임금피크제를 단체협약으로 체결(근로조건 불이익 변경)하는 경우 집단적 근로조건의 유지·개선이라는 노동조합의 목적을 일탈하여 체결된 것인지 여부에 따라 그 규범적 효력 여부가 결정된다고 한다. 또한 특정연령대 이상의 근로자의 기본급을 20% 이상 삭감하는 내용의 단체협약을 체결한 사례에서 노동조합의 총회 의결을 거치지 않은 절차상 하자가 있다는 이유로 감액조치의 무효를 판단한 사례도 있다.²⁶⁷⁾ 또한 희망퇴직에 따르지 아니한 56세 이상의 직원의 기본급을 30% 대폭 삭감하는 내용의 단체협약을 체결한 것에 대해 그 내용

263) 최근 대법원은 전원합의체 판결을 통해 종전 근로자의 집단적 동의없이도 취업규칙 불이익변경의 유효성을 긍정하기 위한 요건으로 인정된 사회통념상 합리성 이론을 집단적 동의권남용이론으로 대체하였다(대법원 2023.5.11. 선고 2017다35588 전원합의체 판결). 그에 따르면 사용자가 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하면서 근로자의 집단적 의사결정방법에 따른 동의를 받지 못한 경우, 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 해당 취업규칙의 작성 또는 변경에 사회통념상 합리성이 있다는 이유만으로 그 유효성을 인정할 수는 없다. 근로기준법상 취업규칙의 불이익변경 과정에서 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 행사할 때도 신의성실의 원칙과 권리남용금지 원칙이 적용되어야 한다. 따라서 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 그 동의를 없더라도 취업규칙의 불이익변경을 유효하다고 볼 수 있다.

264) 東京地判 平成 14.7.31 勞判 835号 p.25.

265) 神戸地判 平成 14.8.23 勞判 836号 p.65.

266) 東京地判 平成 19.2.14 勞判 938号 p.39.

267) 東京高判 平成 12.7.26 勞判 789호 p.6.



의 불합리성 및 절차의 불충분성을 이유로 규범적 효력을 부정한 사례가 있다.²⁶⁸⁾

(1) 취업규칙의 변경에 의한 임금감액

임금의 지급기준이 취업규칙(또는 그 일부인 보수규정)에서 정해지고, 그 규정에 근거하여 임금액이 결정되고 있는 경우에 취업규칙상의 지급기준을 변경하여 임금 감액이라는 결과를 초래하는 조치(취업규칙의 불이익변경)가 행해질 수 있다.²⁶⁹⁾ 이때 취업규칙의 변경에 동의하지 아니하는 근로자에 대하여 변경후 취업규칙이 효력을 가지는지가 문제된다.

이는 우리나라의 경우 이른바 “취업규칙의 불이익변경시 집단적 동의” 문제로 다루어지고, 이에 대하여 우리 대법원은 과반수노조의 경우 그 노조의 대표자, 과반수 노조가 없는 경우에는 사용자측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 근로자 상호 간에 의견을 교환하여 찬반의견을 집약한 후 전체적으로 취합하는 방식도 허용된다고 판시하고 있다.²⁷⁰⁾²⁷¹⁾ 다만, 경우에 따라서는 매우 제한적이지만 집단적 동의권 남용이론에 의하여 불이익변경의 효력을 판단해야 할 사례도 있을 수 있다.²⁷²⁾

취업규칙이 이와 같은 요건을 갖추어 유효하게 변경되었다면 사용자는 취업규칙 변경으로 임금을 감액할 수 있다. 다만, 이 경우에도 불이익변경에 대하여 소급

268) 水町 勇一郎, 「詳解労働法」, p.602 참고.

269) 그 대표적인 사례는 정년연장 또는 정년보장을 위한 임금피크제의 도입이라고 할 수 있다.

270) 대법원 2003.11.14. 선고 2001다18322 판결 외 다수.

271) 이에 비하여 같은 취업규칙 제도를 두고 있는 일본 노동계약법 제10조는 취업규칙의 변경에 관한 판례법리를 명문화하여, “사용자가 취업규칙의 변경에 의하여 근로조건을 변경하는 경우에 변경 후의 취업규칙을 근로자에게 주지시키고, 또한 취업규칙의 변경이 근로자가 입게 될 불이익의 정도, 근로조건 변경의 필요성, 변경후 취업규칙의 내용의 상당성, 노동조합등과의 교섭 상황 그 밖에 취업규칙의 변경에 관련된 사정에 비추어 합리적인 것일 때는 근로계약의 내용인 근로조건은 당해 변경후 취업규칙에 정한 바에 따른다.”고 규정하고 있다. 즉, 취업규칙의 변경에 의한 근로계약 내용의 변경을 위해서는 실체적 요건으로서 합리성(취업규칙 그 자체의 변경 내용과 당해 변경에 관한 프로세스 전체에 걸친 종합판단으로서의 합리성)과 절차적 요건으로서 주지(周知)가 요구된다고 규정하고 있다.

272) 대법원 2023.5.11. 선고 2017다35588 전원합의체 판결. 김형배/박지순, 「노동법강의」, 159면 이하 참고.



효²⁷³⁾가 인정될 수 없으므로 취업규칙 변경은 언제나 임금감액에 선행되어야 한다.

취업규칙 변경에 따른 임금감액은 취업규칙에서 정한 수당 등을 폐지함으로써 임금을 감액하는 경우, 일정 연령 또는 일정 직급 근로자의 기본급을 일률적으로 감액하는 경우, 임금체계를 변경하여 근로자의 등급 등을 조정한 결과 당해 근로자의 임금이 감액되는 경우 등이 발생하게 되는데, 이에 해당하는 근로자로서는 절차적 요건을 갖추어 변경된 취업규칙의 내용에 대하여 그것이 차별 등 강행법규에 위반한다는 등을 이유로 무효를 다툴 수 있을 것이다(아래 (3) 임금피크제 사례 참고).

(2) 단체협약에 의한 임금감액

단체협약 중 근로조건 그 밖에 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효로 하고, 근로계약 중 위의 규정에 의하여 무효로 된 부분 또는 근로계약에 규정하지 아니한 사항은 단체협약에서 정한 기준에 의한다(노조법 제33조 참조). 또한 근로자에게 불리하게 정한 단체협약의 규정도 규범적 효력이 인정되고,²⁷⁴⁾ 사용자는 임금 차액의 지급을 주장하는 근로자에게 단체협약에 기한 임금감액을 가지고 항변할 수 있다. 반대로 서면으로 작성되지 않은 단체협약은 단체협약으로서 규범적 효력을 가질 수 없고, 조합원 개인에게 구체적으로 발생한 임금청구권 등 이미 발생하고 있는 권리의 처분 또는 변경은 해당 조합원 개개인의 특별한 수권(授權)을 받지 않으면 노동조합의 일반적인 협약체결권한의 범위에 속하지 않는다.²⁷⁵⁾

이와 같이 단체협약에 근거한 임금감액을 항변으로 주장하는 사용자는 ① 근로자의 임금청구 기간에 앞서, 사용자와 노동조합 사이에 임금을 감액하는 내용의 단체협약을 체결하였을 것(이 경우 단체협약은 당연히 서면으로 작성되어야 한다)과, ② 해당 근로자가 단체협약을 체결한 노동조합에 가입하였을 것(협약의 구속력 범위)을

273) 단체협약 불이익변경의 소급효 불인정에 관해서는 김형배/박지순, 「노동법강의」, 614면 참고.

274) 대법원 2000.9.29. 선고 99다67536 판결 참고.

275) 대법원 2010.1.28. 선고 2009다76317 판결.



주장해야 한다. 이에 비하여 이미 발생된 임금청구권을 감액할 경우에는 관련 단체협약만으로는 효력이 발생하지 않고, 해당 조합원이 노동조합에 관련 사항에 대하여 수권(授權)하였는지 확인해야 한다.

한편, 단체협약은 원칙적으로 그 단체협약을 체결한 노동조합의 조합원에 대해서만 효력이 있으며, 그 조합원 이외의 근로자에 대해서는 효력이 발생하지 않는다. 이는 단체협약의 구속력 범위의 문제라고 할 수 있다.²⁷⁶⁾ 다만, 노조법은 그와 같은 단체협약의 구속력 범위에 관하여 사업장 단위의 일반적 구속력(제35조)과 지역단위의 일반적 구속력(제36조) 등 2개의 예외를 마련해 놓고 있다.

여기서는 사업장 단위의 일반적 구속력에 대해서만 검토하기로 한다. 노조법 제 35조에 따르면 “하나의 사업 또는 사업장에 상시 사용되는 동종의 근로자 반수 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때에는 당해 사업 또는 사업장에 사용되는 다른 동종의 근로자에 대하여도 당해 단체협약이 적용된다.”²⁷⁷⁾라고 규정하고 있다. 이와 같은 일반적 구속력에 의하여 단체협약이 확장 적용되는 대상자(비조합원)에 대하여 해당 근로조건의 유리·불리를 묻지 않고 단체협약의 규범적 효력이 미치는지 여부가 문제된다.²⁷⁸⁾ 다만, 확장 적용이 현저히 불합리하다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는 확장 적용을 인정하기 어렵다. 그와 같은 특별한 사정의 유무는 단체협약에 의하여 비조합원에게 초래되는 불이익의 정도·내용, 단체협약 체결에 이른 경위, 당해 근로자가 노동조합의 조합원자격을 인정받을 수 있는지 여부 등을 기초로 판단될 것이다.²⁷⁹⁾

276) 이에 관해서는 김형배/박지순, 「노동법강의」, 590면 참고.

277) 우리와 유사한 규정을 두고 있는 일본 노동조합법(제17조)은 그 요건이 하나의 공장, 사업장에 상시 사용되는 동종 근로자의 “4분의 3 이상의 근로자”가 하나의 단체협약을 적용받고 있는 경우에 확장적용을 인정한다.

278) 대법원 2005.5.12., 선고 2003다52456 판결 참고. 일본 最高裁判所 平成 8.3.26 勞判 691号 p.16는 이를 긍정하고 있다. 반면에 비조합원인 근로자의 근로조건을 저하시키는 내용의 단체협약은 그보다 유리한 근로계약에 의하여 적용될 수 없다는 견해가 있다. 유리한 조건 우선의 원칙이 적용되기 때문이다. 김형배/박지순, 「노동법강의」, 607면.

279) 대법원은 종전 단체협약의 근로조건을 새로운 단체협약에 의하여 불이익변경하는 경우 현저히 합리성을 결여한 경우에 예외적으로 그 효력을 인정하지 않을 수 있다는 입장에서 있었다(대법원 2000.9.29. 선고 99다67536 판결; 대법원 2002.4.12. 선고 2001다41384 판결 등 참고). 그렇다면 아직 이를 인정한 판례는 없지만 노동조합에 가입한 적도 없고 협약내용에 관여하지도 않은 비조합원에게 단체협약의 효력을 확장 적용할 경우에는 이



따라서 근로자로서는 단체협약의 일반적 구속력을 근거로 한 사용자의 임금감액에 대하여 단체협약의 효력확장이 현저히 불합리하다고 인정될 만한 특별한 사정을 재항변으로써 주장해야 한다.

(3) 집단적 임금감액으로써 임금피크제의 유효성

임금피크제는 일정한 연령에 달한 근로자에 대해 집단적으로 임금을 감액하는 것을 내용으로 하는 임금제도를 말한다. 임금피크제는 과거에도 종종 실시되었으나, 고령자고용법의 개정으로 2016.1.1.부터 법정 정년제가 시행되면서 본격적으로 도입되고 있다.

임금피크제의 유효성에 관한 주요 쟁점으로는 기존에는 절차적 정당성이 주로 다루어졌다. 즉, 임금피크제 도입이 취업규칙의 불이익변경에 해당되어 그에 따른 동의절차를 거쳤는지 여부가 핵심 쟁점이었다. 하지만 대법원은 적법한 동의절차를 거친 임금피크제라도 실제적 정당성의 측면에서 고령자에 대한 연령차별에 해당될 수 있다는 점을 지적하였다.

대법원은 이른바 “정년유지형 임금피크제 사건”에서 고령자고용법상 연령차별금지는 강행규정이므로 적법한 변경절차를 거친 임금피크제라도 연령차별에 해당하여 무효가 될 수 있다고 판시하였다.²⁸⁰⁾ 그에 따르면 고령자고용법상 연령차별금지는 강행규정이고, 정년유지형 임금피크제의 경우 연령을 이유로 한 불이익 부과로써 차별적 처우에 해당할 수 있지만, 그에 대하여 합리적 이유가 있다면 연령차별에 해당하지 않는다고 보았다. 이때 (적법한 변경절차를 거쳤다는 전제하에) ‘합리적 이유’의 존부에 관해서는 ① 임금피크제 도입 목적의 타당성, ② 임금피크제 대상 근로자들이 입는 불이익의 정도, ③ 임금삭감에 대한 대상 조치의 도입 여부 및 그 적정성, ④ 임금피크제로 감액된 재원이 임금피크제 도입 목적을 위하여 사용되었

러한 제한이 더욱 필요할 수 있을 것이다. 이에 대해서는 노동법실무연구회(마은혁), 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」, 제2판, 2023, 550-551면. 또한 이에 대한 일본의 논의에 대해서는 佐々木宗啓/伊藤由紀子, 「労働関係訴訟の實務 I」, p.98 참고.

280) 대법원 2022.5.26. 선고 2017다292343 판결



는지 여부 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 보았다. 이후 하급심 법원은 정년유지형이든, 정년연장형이든 가리지 않고 대법원이 제시한 위의 4가지 판단요소를 토대로 임금피크제의 유효성을 판단하는 경향을 보여주고 있다.²⁸¹⁾

위의 대법원 판결 이후의 판결들은 대법원이 제시한 4가지 판단요소 중에서 임금피크제 대상 근로자들이 입는 불이익의 정도와 임금피크제로 인한 임금삭감에 대응하는 대상 조치의 도입 여부를 주된 판단 근거로 보고 있다. 즉 임금피크제의 도입 목적이나 그 목적의 충실 이행 여부는 다른 두 요소의 인정 여부에 따라 그 비중이 달라지고 있다. 결국 법원은 임금피크제의 도입으로 인하여 근로자들이 얼마나 불이익을 입었는지, 그러한 피해를 줄이기 위해 회사가 어떤 노력을 하였는지를 비교 교량하는 것으로 볼 수 있다. 특히 대법원은 정년연장형 임금피크제의 경우 정년연장 그 자체가 가장 중요한 대상 조치라는 입장을 제시하고 있다. 반면 정년유지형의 경우 정년연장이라는 핵심적 대상 조치가 없기 때문에 이를 상쇄할 수 있는 다른 대상 조치가 충분히 이행되어야 그 유효성을 인정하는 태도를 취하고 있다고 생각된다.

이처럼 연령을 이유로 하는 집단적 임금 감액(임금피크제)은 고령자고용법상 연령차별에 해당할 수 있다. 만약 연령 기준이 아니라 모든 근로자를 대상으로 집단적·일률적으로 임금감액이 이루어진다면 차별문제는 발생하지 않고 해당 보수관련 규정의 불이익변경의 문제로서 절차적 정당성이 주로 문제시될 뿐이다.²⁸²⁾ 임금피

281) 대법원 판결을 제외하고 하급심판결은 선고시기 순으로 정리함: 대법원 2022.6.30. 선고 2021다241359 판결; 대법원 2022.12.16. 선고 2022다268757 판결; 서울남부지법 2022.5.27. 선고 2020가합103192 판결; 서울중앙지법 2022.6.10. 선고 2020가합571690 판결; 서울중앙지법 2022.6.16. 선고 2019가합592028 판결; 서울고법 2020.8.19. 선고 2021나2049858 판결; 서울남부지법 2022.9.2. 선고 2018가합115208 판결; 청주지법 2022.9.23. 선고 2021나57524 판결; 서울고법 2022.10.16. 선고 2021나2042239 판결; 서울동부지법 2022.10.27. 선고 2020가합113172 판결; 대구지법 경주지원 2022.11.11. 선고 2020가합2618(병합) 판결; 대전고법 2022.12.7. 선고 2022나50254 판결; 서울중앙지법 2023.1.10. 선고 2020나76165 판결; 대구지법 2023.1.12. 선고 2020가합201648 판결; 서울고법 2023.1.18. 선고 2022나2025057 판결; 서울중앙지법 2023.1.19. 선고 2020가합575470(병합) 판결; 서울중앙지법 2023.1.19. 선고 2020가합604507 판결; 서울중앙지법 2023.2.2. 선고 2021가합529238 판결; 서울중앙지법 2023.2.14. 선고 2020가합525079 판결 등 다수.



크제가 연령차별에 해당하지 않으려면 차별적 취급의 합리적 이유가 인정되어야 한다. 위 대법원 판결은 차별 여부를 판단하는데 있어 합리적 이유의 판단기준을 제시한 것으로써 매우 의미있는 판결이라고 할 수 있다.

위의 대법원 판결과 그 이후 같은 취지로 판단하고 있는 하급심 판결을 종합하면 결국 임금피크제 도입에 대한 합리적 이유의 존부는 임금피크제 도입에 따른 집단적 임금감액의 “대상 조치”가 적절한지 여부에 달려 있다. 특히 정년연장형이 아닌 정년유지형 임금피크제의 경우에는 그 유효성은 사실상 대상 조치의 적절성에 따라 판단된다. 한편, 정년연장형 임금피크제라 하더라도 늘어나는 정년연령에 비하여 임금 감액의 폭과 정도가 합리성을 잃을 정도로 과도하다면 그 유효성을 인정하기 어려울 것이다.

2. 개별적 임금감액

근로자에 대하여 개별적으로 행해지는 임금감액조치가 적법한지 여부를 판단하는데 있어서 그 이론적 포인트는 ① 감급이 임금제도상 예정된 것인가(감급에 대하여 취업규칙 등 계약상의 근거가 있는가), ② 사용자의 조치에 위법한 차별이나 권리남용 등 강행법규에 위반한 점은 없는가 등 2가지라고 할 수 있다. 개별적 감급조치가 행해지는 사례는, 직무나 직위·등급이 변경되어 임금이 인하되는 경우와, 연봉제 등 능력이나 성과의 평가에 기초하여(직위·직무·등급 변경 없이) 임금이 감액되는 경우가 있다.

(1) 직무와 직위, 등급의 변동에 의한 감급

근로자가 배치전환이나 직무변경에 의하여 임금이 감액되는 경우와, 직위·등급

282) 불이익변경 시 근로자과반수의 동의를 얻어 절차적 정당성 요건을 갖추었다 하더라도 그 불이익변경이 합리성을 현저히 벗어난 경우까지 유효하다고 볼 수 있는지가 논란이 될 수 있다.



이 변경(강등, 강급)되고 그에 수반하여 임금이 감액되는 경우 등, 직무·직위·등급의 변화에 수반하는 감급조치의 적법성에 대해서는 다음과 같은 세가지 임금제도 유형으로 나누어 검토할 필요가 있을 것이다.

첫째, ① 직무·직위·등급과 연동한 임금제도(직무급, 직무수당, 직무 및 역할등급제 등)의 경우이다. 이 경우, 직무와 직위·등급이 적법하게 변경되었을 때에는 그에 연동하여 임금액도 변동하게 된다. 임금제도가 그와 같이 설계·합의되어 있기 때문이다. 다만, 이 경우에도 직무·직위·등급의 변경 그 자체가 취업규칙 규정 등을 따르고 있는지, 강행규정이나 권리남용 등에 위반한 것은 아닌지는 사법적 심사의 대상이 될 수 있다. 권리남용 여부의 판단에서는 임금감액의 범위(감액되는 임금액수)를 근로자가 입게 되는 현저한 불이익의 하나로 고려할 수 있다.

둘째, ② 직무·등급과 직접 연동하지 아니하는 임금제도(예를 들어 연공급의 경우)의 경우이다. 이 경우에는 직무·등급이 변경되더라도 임금은 당연히 변동되는 것은 아니다. 임금제도상 예정되지 아니한 감급에 대해서는 특별한 근거가 있어야 하며, 그와 같은 근거가 없다면 임금감액을 행할 수 없다.

셋째, ①과 ②의 성격이 혼합된 임금제도(예를 들어 직능급 등)의 경우이다. 이 경우에는 당해 임금제도의 구체적인 운영실태, 관행 등에 비춰 당해 임금이 직무·직위·등급과 연동하여 변동할 것이 예정되어 있는지 여부가 판단 대상이 된다. 다시 말해 당해 임금에 대한 당사자 간의 진정한 합의내용이 ① 또는 ② 중 어디에 해당하는지 판단해야 한다. 따라서 직무·직위·등급의 변동에 의하여 임금도 당연히 변동하는 것으로 예정되어 있지 아니한 경우(②)에는 임금을 감액하는 조치가 유효하려면 당사자의 동의가 있거나 취업규칙에 관련 규정이 있어야 할 것이다.

(2) 능력과 성과의 평가에 기한 감급의 경우

연봉제 등 근로자의 능력이나 성과를 평가하여 개별적으로 임금액을 결정하는 임금제도의 경우에는 평가가 낮은 것을 이유로 임금이 감액될 수도 있다. 이와 같은 감액조치가 적법하게 행해지기 위해서는 ① 능력·성과의 평가와 임금결정의 방법



이 취업규칙이나 관행 등을 통해 제도화되어 근로계약의 내용이 되고, ② 그 평가와 임금액의 결정이 위법한 차별이나 권리남용 등 강행법규 위반에 해당하지 않아야 한다.

일본의 판례 중에는 연봉제에서 차년도의 임금액에 대한 합의가 성립되지 않은 경우에 연봉액 결정을 위한 평가기준, 결정절차 등이 제도화되어 취업규칙 등에 명시되고, 또한 그 내용이 공정한 경우에 한하여 사용자에게 평가결정권이 있다고 한 사례가 있다.²⁸³⁾ 여기서 말하는 평가기준, 결정절차 등의 명시, 내용의 공정성은 해당 취업규칙의 규정이 유효하다고 인정되기 위한 요건으로 볼 수 있다.

한편, 임금액에 대한 합의가 성립되지 않고, 사용자가 일방적으로 임금을 결정할 수 있는 근거도 없는 경우에는 합리적 의사해석(묵시적 합의 인정이나 신의칙 등)에 의하여 계약내용의 보충을 행하게 되는데, 특히 구체적인 참고기준이나 관행 등이 없는 경우에는 종전 임금액이 계약내용이 된다는 해석도 있다.²⁸⁴⁾

연봉액이 구체적으로 합의된 후에는 당해 연도의 도중에 사용자가 일방적으로 연봉액을 인하시킬 수 없다고 해석된다. 연단위로 연봉액을 정한 이상, 그것을 도중에 일방적으로 감액하는 권한은 특별한 사정이 없는 한 근로계약상 사용자에게 부여되지 않는다고 보는 것이 타당하기 때문이다.

(3) 동의 여부

사용자에 의한 임금감액에 대하여 근로자가 명시적 또는 묵시적 동의를 하였다면 합의에 의한 근로계약 내용의 변경이라고 할 수 있다. 이 경우 사용자가 일방적으로 인하한 임금을 근로자가 아무런 이의를 제기하지 않은 채 수령한 경우에 임금 인하에 대한 근로자의 묵시적 동의가 있었는지 여부가 문제된다.

일본의 판례 중에는 특별히 이의를 제기하지 않고 임금을 수령함으로써 근로자의 묵시적 동의의 존재를 인정한 경우도 있지만, 다수의 판례는 근로자의 묵시적 동의

283) 東京高判 平成 20.4.9 勞判 959号 p.6.

284) 水町勇一郎, 「詳解労働法」, p.604.



의 인정을 신중하고 엄격하게 판단하고 있다. 사용자에게 의한 일방적 변경의 경우에는 그 내용이 불명확하거나 근로자가 그에 대한 정확한 인식을 가지고 있지 않은 경우도 적지 않고 또한 회사의 분위기 등 사용자에게 의한 유형·무형의 압력에 의하여 근로자가 진의에 의하지 않고 그와 같은 행동(이의제기 없는 수령)을 할 수밖에 없는 상황도 있을 수 있기 때문이다.²⁸⁵⁾

최근 일본의 판결 중에는 사용자로부터 임금감액의 설명이나 제안에 대해 “아, 알겠습니다”라고 응답하고 그후 11개월 간 이의제기 없이 감액된 임금을 수령하고 있던 근로자가 1년이 경과한 시점에서 감액된 내용의 근로조건 확인서에 서명·날인한 사안에서, 확인서에 서명·날인한 시점에 비로소 자유의사에 따라 동의한 것으로 인정된다고 한 사례가 있다. 이 사례는 계약의 해석(의사표시의 존재)이 문제된 것인데, 근로자가 사용자에게 의한 근로조건 변경(임금감액)의 제안 내용을 정확히 인식하고, 자유로운 의사에 기하여 이에 동의하는 의사표시를 행한 것으로 인정될 수 있는지가 쟁점이라고 할 수 있다.²⁸⁶⁾

일본 최고재판소는 근로자와 사용자의 개별 합의에 의하여 취업규칙상 규정된 근로조건(이 사례에서는 퇴직금)을 불리하게 변경할 수 있는지가 다투어진 사례에서 개별합의에 의하여 불리하게 변경될 수도 있다고 하면서²⁸⁷⁾ 그와 같은 합의의 유무는 근로자의 자유로운 의사에 기한 것으로 인정될 수 있을 정도로 합리적 이유가 객관적으로 존재하는지 여부를 가지고 판단할 수 있다고 한 다음, 구체적인 불이익의 내용과 정도에 대해서는 사용자의 정보제공이나 설명이 행해질 필요가 있다고

285) 札幌高判 平成 24.10.19 労判 1064号 p.37.

286) 菅野和夫, 「労働法」, p.455.

287) 일본은 우리와 달리 취업규칙 불이익변경의 요건으로 근로자측의 집단적 동의절차를 요구하지 않는다. 위의 각주 271) 참고. 일본에서는 사용자와 근로자의 개별적 합의에 의하여 취업규칙상 근로조건을 변경할 수 있으며, 합의 없이는 취업규칙의 불이익변경이 허용되지 않는다(일본 노동계약법 제8조 및 제9조). 다만, 노동계약법 제10조는 사용자와 근로자 사이에 합의가 없는 경우에도 “사용자가 취업규칙의 변경에 의하여 근로조건을 변경하는 경우에 변경 후의 취업규칙을 근로자에게 주시시키고, 또한 취업규칙의 변경이 근로자가 입게 될 불이익의 정도, 근로조건 변경의 필요성, 변경후 취업규칙의 내용의 상당성, 노동조합 등과의 교섭 상황 그 밖에 취업규칙의 변경에 관련된 사정에 비추어 합리적인 것일 때는 근로계약의 내용인 근로조건은 당해 변경후 취업규칙에 정한 바에 따른다.”고 규정하고 있다.



판시하였다.²⁸⁸⁾ 이 판결은 퇴직금 감액에 대한 근로자의 명시적 동의(동의서에 서명 날인)가 있는 사례인데, 임금감액에 대한 묵시적 동의의 사안에서도 이론적으로는 근로자의 묵시적 동의를 인정하기 위한 전제조건으로 사용자에게 의한 충분한 정보제공 및 설명이 중요한 요소가 된다고 해석된다. 특히 근로자의 불이익이 큰 경우에는 사용자에게 의한 구체적인 불이익의 내용이나 정도에 대한 정보제공 및 설명이 필요하며, 사용자가 이를 행하지 않는 경우에는 “근로자가 자유의사에 기하여 동의할 것”이라는 요건을 충족하지 않게 된다.

이와 같이 임금감액에 대한 근로자의 묵시적 동의 여부는 매우 엄격하게 판단되어야 한다. 또한 임금감액에 대한 근로자가 동의가 존재하더라도 그 합의 내용이 취업규칙의 급여 규정에 위반하는 경우에는 당해 합의는 무효가 되고 근로자는 취업규칙에 기한 임금 지급을 구할 수 있다. 취업규칙이 근로계약에 대하여 강행적 효력을 갖기 때문이다.

3. 징계처분으로써 임금감액

근로기준법 제23조 제1항에 따르면 “사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌을 하지 못한다.” 또한 동법 제95조는 “취업규칙에서 근로자에 대하여 감급(減給)의 제재를 정할 경우에 그 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다.”라고 규정하고 있다. 이와 같이 근로기준법은 근로자에 대한 징벌의 하나로 임금감액(감봉 또는 감급의 제재)을 인정하고 있으며, 다만 임금이 근로자의 중요한 생활자원임을 감안하여 임금감액시 그 상한을 규정하고 있다.

징계처분으로서 임금감액(감급)은 업무수행 중 업무 해태나 복무규율 위반에 대한 제재로서 본래부터 당해 근로자가 현실적으로 행한 노무제공에 대응하여 지급받아야 할 임금액 중에서 일정액을 감액하는 것을 말한다.²⁸⁹⁾ 징계처분은 복무규율과

288) 日本 最高裁判所 平成 2.11.26 民集 44卷 8号 p.1085.



기업질서를 유지하기 위하여 종업원의 기업질서 위반행위에 대한 제재벌로써 부과되는 근로관계상의 불이익조치이다. 사용자의 징계권의 법적 근거에 관해서는, 통상 근로자는 근로계약의 체결을 통해 기업질서 준수 의무를 부담하고, 사용자는 근로자의 기업질서 준수 의무 위반에 대한 제재벌로써 징계처분을 부과할 수 있으며, 그러한 범위에서 사용자는 기업질서의 정립 및 유지를 위해 징계권을 가지고 있다. 다만, 취업규칙에 이를 명시하여야 비로소 행사할 수 있는 것이라고 해석된다.

더욱이 감급은 근로자에게 일단 발생한 임금채권을 일부 소멸시켜 근로자의 생활에 영향을 미치기 때문에 과도한 임금감액을 억제할 필요가 있다. 따라서 징계처분의 하나로 임금감액을 하기 위해서는 징계의 한 방법으로 임금을 감액할 수 있다는 사실(감봉, 감급)과, 그 요건과 효과에 대해 취업규칙에 규정할 필요가 있다. 또한 과도한 감액을 방지하기 위해 근로기준법 제95조는 감급의 제재시 그 한도액을 규정하고 있으므로 한도액을 초과하는 감급은 당연히 무효가 된다.

한편, 임금감액을 수반하는 징계처분으로 강급(降級)이나 강격(降格)이 있다. 강급이나 강격은 흔히 실무상으로는 강등이라고 총칭하는데, 근로자의 직급·직위·등급을 낮추는 것을 말하며, 그로 인해 임금 감액이 뒤따르게 되는 경우가 있다. 이와 같은 처분도 당연히 취업규칙에 규정되어 있어야 하며, 그 처분에 의하여 임금감액이 발생할 수 있음을 명시해 두어야 한다. 이러한 징계처분은 위에서 본 감급(減給)과는 다른 것임은 두말할 나위 없다.

IV. 임금청구권의 소멸

민법에 따르면 임금청구권은 일반채권과 마찬가지로 변제, 시효, 상계, 포기 등에 의하여 소멸한다. 물론 상계와 포기에 대해서는 다시 근로기준법에 따라 임금 전액 지급의 원칙이 준수되어야 한다.²⁸⁹⁾ 또한 임금청구권의 소멸시효에 관해서는 근로

289) 김형배/박지순, 「노동법강의」, 188면; 土田道夫, 「勞働契約法」, p.478. 근로자가 결근, 지각, 조퇴 등 근로의무를 이행하지 않아 임금이 지급되지 않는 것은 일반적으로 무노동 무임금 원칙의 결과이므로 징계처분으로서 감급과는 다르다.



기준법 제49조는 3년으로 규정하고 있으며 이에 따라야 한다.

임금청구권의 소멸시효와 관련하여 실무상으로는 근로계약상의 지위확인 소(근로자성 판단)가 시효중단의 효과를 가지는지 문제가 된다. 임금청구권은 계약상 지위라는 기본적 법률관계로부터 파생되는 권리이고, 지위확인의 소는 파생적 청구권인 임금청구권의 주장의 의사도 포함하는 것이므로 재판상 청구에 의한 시효중단이 인정되어야 할 것이다.²⁹¹⁾

사용자측에 의한 소멸시효의 원용에 대해서는 사용자가 신의에 반하는 방법으로 임금채무를 면탈하기 위한 공작을 하는 등 근로자의 권리행사를 저해한 경우에는 권리남용이 될 수 있다. 다만, 사용자가 근로기준법 위반의 형사책임을 우려하여 노무관계 자료를 처분한 것만으로는 근로자의 권리행사를 저해한 것이라고 할 수 없다고 한 사례가 있다.²⁹²⁾

V. 소결

임금을 둘러싼 법적 분쟁이 결국 임금청구권의 성립, 변동 및 소멸과 직결된다. 특히 감급(기업실무에서 임금을 장래에 대하여 감액시키는 경우)에 있어서 그 효력을 다투는 경우(감급 전후의 차액 및 그에 대한 지연배상금의 지급을 청구하는 소송)가 적지 않게 발생하고 있다. 임금액은 근로계약의 일방 당사자인 사용자가 마음대로 변경할 수 있는 것이 아니고 또한 임금을 감액할 수 있는 경우가 매우 제한적이다. 임금감액은 대체로 근로자에 대하여 집단적으로 행해지는 것과, 근로자 개인에 대하여 개별적으로 행해지는 것으로 구별된다. 전자의 경우는 취업규칙이나 단체협약의 변경에 의한 임금감액이 문제되고(이른바 불이익변경), 후자의 경우는 근로자에 대한 인사명령이나 평가에 의한 감액 또는 징계처분으로써 감액(감봉)을 들

290) 허용되는 상계와 허용되지 않는 상계에 관해서는 김형배/박지순, 「노동법강의」, 300면 참고.

291) 土田道夫, 「勞働契約法」, p.262

292) 土田道夫, 「勞働契約法」, p.262



수 있다. 전자의 경우는 집단적 근로조건의 불이익변경 법리에 따라 판단하면 되지만, 후자의 개별적 임금감액조치가 적법한지 여부를 판단하는데 있어서 그 이론적 포인트는 ① 감급이 임금제도상 예정되어 있는 것인가(감급에 대하여 취업규칙, 근로계약 등에 근거가 있는가), ② 사용자의 조치에 위법한 차별이나 권리남용 등 강행법규에 위반한 점은 없는가 등 2가지라고 할 수 있다. 개별적 감급조치가 행해지는 사례는, 직무나 직위·등급이 변경되어 임금이 인하되는 경우와, 연봉제 등 능력이나 성과의 평가에 기초하여(직위·직무·등급 변경이 없이) 임금이 감액되는 경우가 있다. 이처럼 집단적이건 개별적이건 일정한 불이익을 수반하는 임금지급조건의 변경은 법률 소정의 절차 또는 당사자의 합의가 없다면 유효하지 않다.

결론적으로 근로자의 임금청구권을 불리하게 변경하는 것은 당사자의 합의가 전제되지 않으면 안된다. 마찬가지로 임금청구권의 성립 및 그 내용도 당사자의 합의가 중요한 역할을 할 수밖에 없다. 이 경우 당사자는 임금액의 결정을 고정적이고 집단적인 임금표상의 기준에 의할 것인지(연공형), 근로자가 수행하는 직무가치 또는 근로자가 보유한 포괄적인 능력과 자격을 기초로 할 것인지(직무형, 직능형), 구체적인 근로제공의 결과 및 성과에 대한 평가에 따를 것인지(성과주의형) 아니면 앞의 요소와 함께 기업의 경영성과(실적)를 토대로 한 배당 형식을 가미하여 지급할 것인지(혼합형) 자유롭게 설계할 수 있다. 이렇게 설계되고 합의된 임금형태 및 지급방식에 대하여 근로의 대가성을 부인할 이유는 없을 것이다.

제4절 직무급제의 도입과 노동법적 쟁점

I. 서설

본 절은 최근 임금체계 개편의 핵심에 있는 직무급제의 운영 및 도입을 둘러싼



법률문제에 대하여 노동법적 관점에서 고찰하는데 목적이 있다. 직무급이란 근로자가 담당하는 직무의 중요도, 책임정도, 난이도(직무가치)에 따라 결정되는 임금을 말한다. 또한 직무등급제도는 직무가치에 따라 등급을 매기는 제도를 말하고, 직무급제 운영시 불가결한 제도라고 할 수 있다.²⁹³⁾ 직능급제도(직능자격제도)가 사람의 능력을 기준으로 기본급을 결정하는 제도임에 비해 직무급제도는 직무를 기준으로 기본급을 결정하는 제도이다. 직무급을 도입하는 목적은 대체로 업적이나 공헌도가 높은 직원에 그에 부합하는 보상을 하기 위한 것이라거나, 인건비의 적정화를 목적으로 한다거나, 기업의 활력을 높이고 생산성을 향상시키는데 기여하거나 근로자의 인센티브를 강화하는데 기여한다는 응답이 다수 나타난다.²⁹⁴⁾ 직무급제도에서는 객관적인 직무평가(직무분석을 포함한 직무기술서에 의하여 행해지는 평가)가 필수이며, 또한 근로자의 직무수행능력과 직무달성도가 임금 및 처우의 기준이 되기 때문에 이러한 요소를 반영한 인사평가가 중요한 의미를 가질 수밖에 없다.

특히 순수한 직무급제를 채택할 경우 직무가치의 수에 비례하여 직무등급의 수가 증가하기 때문에 임금관리가 복잡하게 되고, 배치전환에 의하여 임금이 변동되고 인사 유연성이 떨어질 위험이 있다는 점도 제기된다. 실제로는 직무급만으로 기본급을 결정하는 경우는 많지 않고 대체로 직능급, 역할급을 함께 활용하는 경우가 많다.

이와 같이 직무급제도는 인접한 여러 임금제도를 포함하여 다양하게 설계될 수 있는데, 대체로 성과주의 임금 및 인사제도로써 그 의미가 부각되고 있다는 점에서, 인사평가·임금결정뿐만 아니라 인사이동(배치전환)과 해고 등 관련문제에 대해서도 새로운 관점에서 검토해야 할 필요가 제기된다. 기업의 인사·법무의 관점에서도 법적으로 유의해야 할 점들이 적지 않다.

293) 다수의 글로벌기업들이 직무가치에 기반한 임금정책을 채택하면서 전문기관에서 개발한 직무가치평가 정보를 활용하고 있다. 그에 관한 정보로는 특히 인사조직전문 컨설팅회사인 머서(Mercer)가 개발한 직무평가 방법론(International Position Evaluation, IPE)가 대표적인데 미국에서만 매년 3,500개 이상의 회사가 이를 이용하고 있다고 한다. 머서의 IPE에 대한 설명으로는 이장원/송민수/김윤호/이민동, 「임금직무체계 변화실태와 직무급의 과제」, 한국노동연구원, 2015, 63면 참고.

294) 직무급 도입의 장단점에 대한 설명으로 유규창, “한국기업의 임금체계: 직무급이 대안인가?”, 「월간 노동리뷰」, 2014. 2, 37면 이하 참고.



이하에서는 이러한 관점에서 직무급의 법적 의의, 인사평가, 능력개발, 인사이동(배치전환, 승진, 승급), 해고 등 직무급제의 운영을 둘러싼 법적 논점을 고찰한다.

II. 직무급의 법적 의의

1. 직무급의 뜻

직무급은 연공급이나 직능급과 달리 사람에 대한 임금이 아니라 직무(작업)에 대한 임금이므로 직종(직무)별 임금의 불공평을 시정하고 조직에서 각 직무의 상대적 가치, 즉 임금을 결정하는 방법으로서 직무평가를 필요로 한다.²⁹⁵⁾

직무급에서는 객관적인 기준에 근거한 직무평가로 임금이 결정되므로 그 평가가 적절하게 이루어진다면 근로자 사이에 불합리한 임금의 차이가 발생할 수 없게 된다. 또한 근로자 사이에 발생하는 기본적인 임금의 차이는 직무평가에 기초한 직무등급에 의하여 발생한 것이기 때문에 근로자에 대하여 임금의 차이를 객관적으로 설명하기 쉽고, 근로자가 용이하게 수용할 수 있다는 장점이 있다. 그 때문에 직무급을 도입하는 기업은 처우(임금) 격차가 과연 공정한가에 대한 근로자들의 의심을 제거하여 생산성 높은 직장 실현을 목적으로 한다.²⁹⁶⁾

2. 직무급과 인사제도의 변화

직무급의 법적 의의와 관련하여, 다음과 같은 세 가지 부분이 인사제도에서 중요

295) 노사정위원회, 「임금보고서」, 2016, 47면 이하.

296) 노사정위원회, 「임금보고서」, 2016, 61면 이하는 반대로 직무급 도입 시 우려하는 문제점 내지 오해를 설명하고 있다.



한 변화 요인이라고 할 수 있다.

첫째, 직무급제도에서는 직무와 임금이 강하게 연결되어 있기 때문에 직무내용의 변화는 임금의 변동으로 직결된다. 따라서 직무내용의 변경을 의미하는 사용자의 배전명령권은 그 정당성 판단이 엄격하게 이루어질 수밖에 없다. 사용자의 배전명령에 의하여 임금이 감액되는 경우(기본급의 인하)에는 임금감액의 정도에 따라 현저한 생활상 불이익이 인정되어 정당성을 상실할 수 있다. 기존 연공급 체계 하에서 사용자의 배전명령권은 직종이나 직무에 한정되지 않고 비교적 광범위하게 인정되었다. 연공형이나 직능형 임금제도에서는 배치전환으로 직무가 변경되더라도 기본급의 변동이 발생하지 않으므로 직종을 한정하지 아니하고 광범위한 재량권을 행사할 수 있다는 것이 일반적 인식이었다.

그러나 직무급 체계 하에서는 직무 전환이 곧 임금 수준 변화와 직결되기 때문에, 사용자의 배전명령권은 축소되고, 배치전환을 둘러싼 법적 이슈들이 증가할 것으로 예상된다.²⁹⁷⁾

둘째, 직무급제도 하에서는 직종이나 직무를 한정하는 계약(직종 또는 직종(직무) 한정특약)이 활성화될 수 있다. 임금에 대응하는 직무가 한정된다는 점에서 명시적 특약이 없더라도 근로자가 수행해야 할 직무가 한정되는 직종(직무)한정특약이 해석상 인정될 가능성도 있다. 또한 직종(직무)한정특약이 인정되지 않는 경우에도 일정한 직종이나 직무를 유지할 수 있는 근로자의 법률상 이익을 인정할 수 있고, 이는 지금까지 사용자에게 인정된 비교적 광범위한 인사권이 축소되는 결과를 가져온다.

셋째, 기존(연공급 중심 인사제도)에 비해 평가의 공정성과 교육 기회의 확보가

297) 이에 비하여 연공급이나 직능급의 경우는 임금이 근속기간(호봉)이나 자격에 의하여 결정되고, 배치전환은 기본급을 변경시키지 않는 것을 원칙으로 하고 있다. 따라서 배치전환과 임금은 별개의 문제이고 법적으로 서로 아무 관련이 없다. 사용자는 상대적으로 낮은 임금이 지급되는 직종(직무)으로 근로자를 배치전환시키는 경우에도 특별한 사정이 없는 한 임금은 종전대로 지급해야 할 계약상의 의무를 부담한다.(東京地判 平成 9.1.24 判時 1592号 p.37). 다만, 특정 직무에 대해서 지급되는 특별수당(예를 들어 직무수당, 위험수당 등)이 배치전환에 의하여 더 이상 지급되지 않는 것은 직무전환에 따른 당연한 효과이므로 그러한 한에서 임금 변동이 발생할 수 있을 것이다. 이와 같이 배치전환에서 임금감액의 불이익이 발생하지 않도록 하는 것이 직능자격제도, 연공형 임금제도에서 사용자의 광범위한 인사권(배치전환명령권)을 인정한 근거라고 할 수 있다.



중요하게 다뤄질 것이다. 직무급은 직무가치를 평가하여 결정된 임금²⁹⁸⁾으로서 임금결정에 있어서 직무가치의 비중이 높을 수밖에 없다. 임금결정의 핵심요소인 인사평가는 직무수행능력과 직무달성도에 따라 공정하게 이루어져야 하며, 객관적인 직무가치에 대한 평가도 마찬가지로 공정하게 이루어져야 한다. 근로자가 높은 직무수행능력을 보유하고 직무달성도를 높이는 것이 근로제공의무의 내용이 되며, 따라서 근로자가 직무가치에 입각한 능력을 습득할 수 있도록 교육훈련이나 능력개발의 기회가 보장되어야 한다. 관련하여 평가 및 교육기회 제공에 있어 공정정보장(법적으로는 특히 절차적 공정성), 차별금지, 권리남용금지 등이 문제될 수 있다.

3. 직무급제도의 해석을 둘러싼 법적 관점

이상에서 본 바와 같이, 순수한 직무급제가 도입될 경우 직종(직무)한정특약이 인정되기 쉽고, 직무변경(배치전환)에 의하여 임금액도 변동한다는 점에서 인사(배치전환)권이 제한된다는 효과가 발생한다. 특히 직종(직무)한정특약이 있으면 포괄적 인사권이 인정되는 경우와 달리 당사자의 동의가 없으면 다른 직종(직무)으로의 배치전환이 어려우므로 인사권의 범위가 제한된다. 따라서 해당 근로자가 동의하지 않는 한 배치전환을 해고회피를 위한 방법으로 사용하는데도 제약이 따를 수밖에 없다. 그 결과 직무급제도에서는 근로자의 직종(직무) 부적격성을 이유로 하는 해고가 비교적 넓게 인정될 수 있을 것이다.

그렇지만 이러한 결론이 우리나라와 같이 정년까지 고용을 보장하고, 해고할 경우에는 정당한 이유가 있어야 하는 장기고용시스템 하에서는 근로자의 직무 간 이동이 불가피하게 발생할 수 있다는 점에서 갈등을 빚을 가능성이 있다. 이와 같은 인사권한의 경직이 예상되면 직무급제를 채택하기 용이하지 않다.

법적 관점에서도 직무급제도에 내재하는 법적 문제점을 명확히 파악하여 기업과

298) 그 때문에 직무급은 구체적인 근로의 대가, 즉 근로제공과 직접적 관련성을 가진 임금이라는 성격을 가지고 있다.



노사의 주의를 환기시킴으로써 직무급제도의 도입 시 적법한 임금 및 인사제도가 설계될 수 있도록 하는 것이 중요하다.

Ⅲ. 인사평가제도

1. 문제의 소재

인사평가란 근로자의 능력이나 성과를 평가하여 임금을 결정하는 제도를 말하며, 성과주의 임금 및 인사제도의 열쇠가 되는 제도이다. 인사평가의 항목은 통상 ① 성과(output=직무달성도), ② 능력(input=지식·기능, 이해·판단력 등), ③ 의욕 및 직무행동(throughput)으로 나누어진다.

법적으로 보면 인사평가는 사용자의 권리(인사평가권)라고 할 수 있으며 광범위한 재량권이 인정된다. 다만, 성과주의의 정착에 수반하여 인사평가의 요소로서 “공정한 평가”가 요구되고 이는 인사평가권 남용의 판단요소로 인정된다. “공정한 평가”로서는 인사평가의 프로세스 전체의 정비가 요구되고, 사용자는 i) 공정하고 객관적인 평가제도를 정비·개시하고(제도 및 절차의 공정성), ii) 그에 기하여 공정한 평가를 행하며(적용의 공정성), iii) 평가결과를 개시·설명하고, iv) 근로자의 이의 제기에 대응하는 분쟁처리절차를 정비할 책무(주의의무)를 부담한다.

특히 중요한 것은 위의 i) 제도설계·절차의 정비인데, 이것이 명확하더라도 실제의 평가(ii)가 현저하게 자의적이라면 불공정한 평가라고 해석될 수 있다. 인사평가가 공정성이 부정되고 인사평가권의 남용으로 평가되면 불법행위가 성립하고, 사용자는 손해배상책임(통상은 평균적인 평가를 받은 종업원의 임금과의 차액 상당분)을 부담한다.²⁹⁹⁾

299) 土田道夫, “職務給・職務等級制おめぐる法律問題”, p.181.



2. 직무급제도와 인사평가

(1) 제도설계 및 절차의 정비

직무급제도에서의 인사평가의 법적 취급도 다른 직능급제나 연공급제와 사뭇 다를 것이다. 우선 공정한 평가의 포인트를 파악하는 인사평가제도 중 평가항목에 대하여 직무급제의 경우 직무수행능력과 직무달성도가 중요하기 때문에, 위에서 본 ①의 성과와 ③의 직무행동의 비중이 높을 것으로 보인다. 물론 직군등급제나 역할 등급제에서도 마찬가지일 것이다. 직능자격제도와 직무급이 혼합되어 있는 경우에는 각각의 제도 취지에 입각하여 평가항목의 중요도가 결정된다.

직무급제도에서의 인사평가는 직능자격제도 이상으로 공정성이 요구된다고 해석된다. 즉, 직무급제에서는 구체적인 직무가 임금과 연동되고 직무의 변경이 임금변동으로 이어진다. 또한 승격이나 강격, 직무등급이 수정될 때 특히 중시되는 데이터가 인사평가이다. 따라서 인사평가는 근로자의 직무수행능력·직무달성도 및 직무행동에 비추어 공정하고 엄격하게 행해질 필요가 있다.

구체적으로는 먼저 제도·절차의 정비로서, 직무급제도의 생명선에 해당하는 직무등급을 정치하게 설계하고 직무분석 및 직무기술서를 구체적으로 작성할 필요가 있다. 물론 이러한 제도는 엄밀하게 말하면 인사평가제도는 아니고 그 설계는 기업의 재량에 맡겨지며, 직무평가의 당부가 인사평가의 당부로 직결되는 것은 아니다. 그러나 과도하게 애매하거나 막연한 직무등급제나 직무분석을 기초로 인사평가를 행할 경우에는 인사평가의 객관성과 정확성이 결여되기 때문에 구체적인 인사평가의 공정성이 부정될 가능성이 높다.

또한 사용자는 제도설계 및 절차의 정비로서 직무급제에서 중요한 직무관련요소의 평가항목을 가능한 한 세밀하고 투명하게 설계하여야 하고, 인사평가의 공정성을 확보하기 위한 관련제도(근로자에 대한 평가 피드백, 분쟁처리제도)를 정비할 필요가 있다. 특히 이러한 제도는 공정한 인사평가의 요소이고, 그 어느 것 하나라도 결여할 경우 인사평가의 불공정성으로 직결된다는 의미에서 “요건”이라고 할 수는



없지만, “공정한 평가” 자체는 인사평가의 정당성 요건을 구성하는 것이고 직무가치 중시 및 직무와 임금의 대가성이 강한 직무급제에서는 인사평가의 공정성을 높일 필요가 있다.

[구체적 사례] 東京地判 平成 16.3.31 勞判 873号 p.33 300)

이 판결은 직무등급제와 유사하게 운영되는 급여밴드제에서의 인사평가에 대하여 제도의 공정한 설계와 운영을 요건으로 명시한 사례이다. 이 사건에서 급여제도는 각 개인이 소속된 밴드별로 급여범위를 결정하고, 매년 기본급 개정 시에 승급매트릭스표(인사평가와 밴드 내부의 급여 범위를 서로 연관지어 표시한 표)에 따라 평가가 이루어지고, 인사평가에 따라 승급의 지수가 상하로 변동되는데, 지수가 낮으면 승급이 동결되거나 강급이 이루어질 수 있다. 반기마다 행해지는 인사평가 항목은 처음에 각 사원에게 설정된 목표달성도의 업적 평가와 각인에게 예정된 역량 발휘의 평가로 이루어지며 인사평가시에는 근로자들은 자기평가를 행하고, 상사와 면담하여 의견을 진술하고 조정하는 과정을 거친다.

이 사건은 급여밴드제에 기초하여 강급조치를 받은 근로자들이 임금차액분의 지급을 요구한 사안인데, 법원은 “근로계약의 내용으로서 성과주의에 의한 기본급의 강급이 정해져 있더라도 사용자가 자의적으로 기본급의 강급을 결정하는 것은 허용되지 않으며, 강급이 허용되려면 취업규칙 등에 강급이 규정되어 있어야 할 뿐만 아니라 강급이 결정되는 과정에 합리성이 있어야 하며, 그 과정이 종업원들에게 주지되는 등 공정한 절차를 갖추어야 한다.”라고 하면서, “강급제도 자체는 합리적이고 공정성이 인정되고, 그 제도에 따라 강급조치가 내려진 경우에는 개개 근로자의 평가 과정에 특별히 불합리하거나 불공정한 사정이 인정되지 않는 한 당해 업무에 기초하여 행해진 것으로서 허용된다.”라고 판단하였다. 그리고 본 사건의 구체적 판단으로서도 강급의 결정 과정의 합리성(목표면접제도, 다면평가제도의 존재 등) 및 공정한 절차(이의신청제도의 존재)를 인정하여 제도설계 및 절차의 공정성을 긍정하면서 인사평가·강급제도의 효력을 인정하고 있다. 이와 같이 위 사건은 급여밴드

300) 土田道夫, “職務給、職務等級制おめぐる法律問題”, p.183.



제에서의 인사평가제도가 유효하다고 판단된 것인데, 반대로 위 판시내용에서 제시된 요건을 결여한 인사평가제도에서는 그 제도에 따라 이루어진 인사평가 및 강급 조치는 인사권남용으로 무효라고 평가될 것이다. 이 판결은 직무급·직무등급제에 있어서 인사평가의 제도설계가 얼마나 중요한지 보여주는 사례라고 생각된다.³⁰¹⁾

(2) 인사평가의 공정성

다음으로 직무급제에서는 인사평가제도에 근거한 종업원 개인의 인사평가에 대해서도 직무수행능력, 직무달성도 및 직무행동에 비추어 엄밀하고 공정하게 행할 필요가 있다(위의 ② 적용의 공정성). 즉, 직무급제는 근로자의 직무가치에 착안한 임금제도이므로 인사평가는 이러한 직무관련요소에 입각하여 보다 엄격하게 행해지지 않으면 안된다. 이에 관해서는 다음에 후술한다(다음 제5절 참고).

3. 능력개발 및 교육훈련

직무급제하에서는 근로자에 대한 능력개발·교육훈련의 권리와 의무가 강화되어야 한다. 즉, 직무급제도는 근로자의 직무가치 평가를 토대로 임금처우를 결정하는 제도로서, 근로자가 높은 직무수행능력을 가지고 직무달성도를 높이는 것이 근로계약의 내용(근로제공의무)이라고 할 수 있다. 따라서 근로자에게 능력개발·교육훈련은 근로조건 개선을 위하여 필수적인 권리로써 강화되어야 한다.

사용자는 근로자에게 다양한 방식으로 능력개발·교육훈련을 실시하고 있다. 기업에서 이루어지는 능력개발·교육훈련은 근로자의 ‘업무수행 과정 내에서 이루어지는 직업훈련’(OJT)과 ‘업무수행 과정 밖에서 이루어지는 직업훈련’(OffJT)으로 구성된다. 특히 최근 우리나라는 능력개발에 대한 중요성을 강조하면서 2021년 “근로자 직업능력 개발법”을 “국민 평생 직업능력개발법(평생직업능력법)”으로 고치고, 근로

301) 土田道夫, “職務給、職務等級制おめぐる法律問題”, p.184.



자를 대상으로 직업능력개발훈련을 실시하고, 직업능력개발훈련에 많은 근로자가 참여하도록 하며, 근로자에게 직업능력개발을 위한 휴가를 주는 등 직업능력개발훈련 여건을 조성하기 위한 의무를 사업주의 책무로 규정하고 있다(제4조 제2항).

OJT의 경우는 업무의 일환으로 수행되는 것이라는 점에서 근로자는 근로제공의무의 내용으로 교육훈련의무를 부담하고, 사용자는 교육훈련명령을 내릴 수 있다고 해석된다. 특히 직무급제도에서는 직무수행능력의 중요성이 높기 때문에 근로자는 근로제공의무의 일부로서 교육훈련의무를 부담하고 사용자는 업무명령으로써 교육훈련을 받도록 명령할 수 있다고 보는 견해가 있다.³⁰²⁾

이와 같이 직무급제에서는 근로자는 한편으로는 능력개발에 관한 권리를 갖지만 다른 한편으로는 그와 같은 교육훈련의무를 부담하는 등 능력개발 및 교육훈련의 중요성이 한층 더 강화된다고 볼 수 있다.

그런데 OffJT는 직무과정 밖에서 행해지는 것으로서 그 의무 여부와 관련해서는 다소 미묘한 문제가 있다. 일반적으로는 근로자의 본래적 의무(근로제공의무)와 관련성이 있고, 수단 및 방법상 상당성이 있다면 교육훈련을 받도록 명령할 수 있다고 해석되는데,³⁰³⁾ 직무급제에서는 직무수행능력이 중요하다는 점에서 현재 종사하고 있는 직무에 필요한 OffJT의 의무는 당연히 발생한다고 할 수 있다. 이에 대해 장래에 종사할 것이 예정된 업무에 관한 OffJT(자격취득을 위한 강좌에 대한 참여 등)에 참여할 의무가 있는지 여부는 문제될 수 있다.

한편, 직무급제도에서는 능력개발·교육훈련에 대한 권리도 강화되어야 할 것이다. 직무급제에서는 근로자의 직무가치가 중요하고 일정한 직종(직무)을 유지함으로써 발생하는 이익도 존중되어야 하기 때문에 직무가치를 높이기 위한 능력개발의 권리가 중시되어야 한다. 이점은 특히 사용자의 인사평가 내지 인사이동 시 인사권 남용 문제와 연계되어 중요한 판단요소가 될 수 있다. 위에서 설명한 대로 직무급제에서는 근로자에게 높은 직무수행능력과 직무달성도가 요구되기 때문에 근로자가 그 능력을 축적할 수 있는 기회를 보장하지 않으면 공정성의 문제가 발생할 수 있

302) 菅野和夫, 「勞働法」, p.404.

303) 菅野和夫, 「勞働法」, p.404; 이승길, 「성과주의인사와 임금제도」, 59면 참고.



다. 따라서 능력개발기회를 보장하지 않은 채 낮은 평가를 내린다면 불공정한 평가로써 권리남용이 성립할 수 있다. 이 점은 근로자의 배치 및 배치전환에서도 마찬가지로 적용될 수 있다.

구체적으로는 전문적 직무에 취업하고 있던 근로자를 합리적 이유 없이 본인의 능력을 발휘할 수 없는 직무로 배치전환하는 사례, 고도의 직무능력을 요하는 직무로 배치전환함에 있어서 능력개발의 기회를 충분히 제공하지 않는 사례, 사내공모제 등을 형식적으로 채택하면서 실제로는 상명하복식 인사를 강행하는 경우에는 인사권남용이 성립할 수 있다.³⁰⁴⁾

4. 배치전환, 승진 및 강등

(1) 배치전환

배치전환(이하 “배전”이라 한다)이란 근로자의 직종이나 직무내용 또는 근무장소를 동일 기업 내부에서 장기에 걸쳐 변경시키는 것을 말한다. 법적으로는 배치전환 명령권(이하 “배전명령권”이라 한다)의 근거와 한계가 문제된다.

먼저 배전명령권의 법적 근거에 대하여, 근로계약은 근로자가 노동력의 처분을 포괄적으로 사용자에게 맡기는 계약이므로 직종이나 근무장소에 대한 합의가 없는 한 사용자는 노동력처분권(노무지휘권)을 행사하여 배전명령을 내릴 수 있다는 견해(포괄적 합의설)와, 사용자는 근로계약이 정하고 있는 범위 내에서 노무지휘권을 행사하여 배전명령을 내릴 수 있다고 이해하고, 그 범위를 개별 근로계약의 해석에 따라 판단하는 견해(계약설)가 대립하고 있다. 하지만 양 견해의 실질적 차이는 그리 크지 않다.³⁰⁵⁾

한편, 사용자에게 인사권으로서 배전명령권이 인정된다 하더라도 이를 무제한 행

304) 이에 관해서는 土田道夫, “職務給・職務等級制おめぐる法律問題”, p.187 참고.

305) 이에 대해서는 김형배/박지순, 「노동법강의」, 165면 이하; 土田道夫, 「勞働契約法」, p.411 참고.



사할 수 있는 것이 아니다. 즉, 이에 대해서는 다음과 같은 한계가 있다. ① 근로계약 등에 직종 한정에 관한 합의(직종(직무)한정특약)가 존재하는지 여부가 문제되고, 그와 같은 특약이 인정되면 배전명령권(인사권)이 부정된다. 또한 ② 직종(직무)한정 특약 등이 없어 사용자의 배전명령권이 긍정되는 경우라도 그 남용은 허용되지 않으며, 배전명령권이 권리남용에 해당하는지 여부에 대해서는 다시 (i) 업무상 필요성 여부, (ii) 업무상 필요성이 있더라도 다른 부당한 동기나 목적을 가지고 있거나, 근로자가 통상 감수해야 할 범위를 넘어서는 현저한 생활상의 불이익을 부담해야 하는 경우 등 특단의 사정이 있는지 여부를 가지고 판단하게 된다. 그리고 (iii) 신의칙에 따라 해당 근로자와 성실한 협의절차를 거쳐야 한다. 이때 위 (i)의 업무상 필요성에 대해서는 해당 배전이 다른 직원으로 대체하기 어려울 정도의 고도의 필요성으로 한정되는 것은 아니고 노동력의 적정배치, 근로자의 능력개발, 근무의욕 고양, 업무운영의 원활화 등 기업의 합리적 운영에 기여한다고 인정되면 긍정될 수 있을 것이다.³⁰⁶⁾

그런데 직무급제 하에서는 직종(직무)한정특약을 약정할 가능성이 상대적으로 높다. 다만, 직종(직무)한정특약의 존부는 근로계약의 내용에 대한 해석을 통해 판단되는 것이므로 직무급제라고 해서 곧바로 직종이나 직무가 한정된다고 단정할 것은 아니다.

직종(직무)한정특약 등의 제한이 없어 사용자의 배전명령권이 인정되더라도 사용자가 배전명령권을 유효하게 행사하려면 근로기준법 등 강행법률을 위반하지 않아야 하고, 권리남용으로 평가되지 않아야 한다. 특히 직무급제에서는 ① 직무가치의 중요성이 높아지고, 근로자의 직종 및 직무유지의 이익이 중요시될 수밖에 없으며, ② 직무와 임금의 연동성이 강화되어 직무의 변경이 곧 임금(기본급)의 변동과 연계된다. 이 때문에 직무급제에서 사용자의 배전명령권은 더욱 더 제한을 받을 수 있다. 구체적으로는 다음과 같은 기준에 따라 권리남용 여부가 판단될 것으로 생각된다.

첫째, 업무상 필요성 판단과 관련하여, 사용자가 근로자를 당해 직무에 부적격하

306) 김형배/박지순, 「노동법강의」, 169면.



다고 판단한 것이 타당한지(능력이나 적격성의 결여 등 근로자측의 귀책성), 인원 선정의 상당성이 인정되는지를 엄격하게 판단해야 한다. 특히 근로자의 직무수행능력이나 직무달성도에 관한 인사평가의 공정성과 능력개발기회 부여 유무 등이 문제 시된다.

둘째, 근로자가 입는 생활상 불이익과 관련하여, 새로 부여받은 직무와 근로자의 능력·적성과의 적합성 심사가 요청되고 그 결과 불충분하다고 판단되면 인사권 남용이 성립될 수 있다. 또한 직무급제도에서는 배치전환(직무변경)과 임금이 연계되어 있어 배치전환이 기본급의 감액에 직결될 수 있으므로 임금 감액의 유무 및 그 정도가 생활상 불이익 판단에 중요한 요소가 된다.

셋째, 절차적 관점에서, 배치전환이 임금의 불이익을 가져오는 이상, 근로자 본인의 의사를 청취하고 의견을 수렴하는 절차가 중요하며, 사내공모제도³⁰⁷⁾ 등 근로자의 이니셔티브를 중시하는 제도의 정비가 필요하다.

일본에서는 이와 같은 직무급제의 특성을 감안하여 배전명령권의 남용을 판단한 판결이 있다. 이 사안에서는 기본급이 직무의 종류와 책임 및 요구도에 따라 정해진 직무밴드에 의하여 결정되고, 밴드1에서 시작하여 밴드6으로 승진하는 시스템에서, 시장조사업무에서 단순사무업무로 배치전환되고, 밴드를 3에서 2로 낮춘 배전명령의 효력이 쟁점이 되었다. 이 사건 직무밴드제는 직무권한과 직책이라는 직무수준에 대한 명확한 가이드라인을 설계하고, 각 밴드에 대하여 각각의 레벨(수준) 부여하여 직무내용과 승진의 기준을 명확히 하는 등 직무등급제에 가까운 제도라고 할 수 있다. 판결은 본건 배치전환에 대하여 취업규칙의 배전 관련 조항을 근거로 회사측의 인사권(배전명령권)을 긍정하면서, 배전명령의 효력에 대해서는 근무성적 불량 등의 부득이한 이유가 인정되지 않는다는 점, 원고 근로자의 불이익에 대해서는 밴드 하향에 의하여, 당장 급여의 감액이 없다 하더라도 급여 범위의 차이에 의하여 장래 승급 가능성이 제약된다는 점, 직무권한이 축소된다는 점, 스톱옵션을 받을 자격을 상실하게 된다는 점 등을 열거하면서 원고가 입을 불이익은 통상 감소해

307) 기업 내 주요 직무에 공석이 발생할 경우 외부 경력자로 채우기 전에 사내 구성원들에게 먼저 개방하고, 지원하도록 하는 제도를 말한다.



야 할 정도를 초과하는 것으로서 인사권 남용을 인정하고 있다.

이상과 같이 직무급제에서는 직무의 변경과 임금이 연동하는 것이 원칙이지만, 실제 운영 측면에서 직무와 임금의 관계가 약한 경우에는 배전의 효력과 임금감액의 효력을 분리하여 판단할 필요가 있다. 일본의 하급심 판결 중에는 각 직종마다 그 전문성·직무책임·난이도에 따라 1에서 9까지 등급을 정하고, 각 등급 내에서 경험과 기능에 따라 호봉을 부여하여, 이 등급과 호봉에 따라 기본급을 결정하는 직무등급이 채택된 사례에서, 실제로는 직무기술서 등이 없고, 실태적 측면에서도 기본급이 감액된 경우 근로자와 합의에 의하여 기본급 테이블에 없는 기본급을 정하여 불이익을 완화하는 등 등급호봉과 직무가 관련되지 않는 사례가 발생하고 있다는 점을 인정한 다음, “원칙적으로 직종에 따라 등급호봉을 결정하려고 노력은 하였지만... 종업원이 받은 불이익을 고려하거나 종업원과의 합의를 통해 등급호봉제를 탄력적으로 운영해 온 점을 인정해야 하고... 직종의 변경과 기본급의 변경은 별개로 당해 종업원과 합의되고 결정된 것”이라고 하여, 배전에 수반하는 (자동적) 임금감액을 위법하다고 판단한 사례가 있다.³⁰⁸⁾

(2) 승격

승격이란 직능자격제도에서는 기본급을 결정하는 직능자격을 상승시키는 것을 말하고, 직위 상승을 의미하는 승진과는 구별된다. 승격은 기본적으로는 사용자의 인사권에 맡겨진 조치로써, 누구를 승격시킬 것인지에 대하여 광범위한 재량권이 인정된다. 다만, 성과주의 인사·임금제도가 확산됨에 따라 공정한 인사평가가 요청되고 있음을 고려하면 사용자가 공정한 인사평가를 게을리하고 그 결과 불승격 조치를 계속하고 있는 경우에는 인사권의 남용으로서 불법행위가 성립할 수 있다. 이때, 그 법률효과로서 ‘승격청구권’(일정한 자격으로 승격할 지위에 있음을 확인 청구하는 것)이 인정되는지 여부에 대해서는 승격은 어디까지나 사용자의 발령(의사표시)이 있을 때 계약내용이 되는 것이므로 발령행위가 없는 단계에서 이를 인정하기는 어려울 것이다. 즉, 위법한 불승격 조치의 구제수단은 원칙적으로 손해배상청구로

308) 東京地判 平成 11.11.26 勞判 778号 p.40.



한정된다.³⁰⁹⁾

이와 같이 합리적 이유가 없는 불승격조치에 대해서는 불법행위가 성립할 수 있지만, 이는 직능자격제도를 모델로 하는 해석이라고 할 수 있다. 직무급제도에서는 불승격조치가 위법하게 되는 범위가 협소해진다고 해석된다. 근로자의 능력 향상에 따라 승격이 이루어지는 직능자격제도에 대하여, 직무급제도에서는 승격은 더 높은 고도의 직무를 할당받아 직무등급을 상승시킴으로써 이루어지는 것인데, 직무가 변경되지 않는 한 승격도 이루어지지 않는다. 그리고 어떤 근로자를 어떤 직무에 종사 시킬지는 기본적으로 사용자의 인사권에 속하는 사항이므로 직무배치의 판단에 문제가 없는 한 불승격조치에 대하여 인사권남용이 성립할 여지가 적고 불법행위도 성립하지 않는다.

그러나 직무급제도는 객관적인 직무분석·직무평가와 직무수행능력·직무달성도를 중심으로 한 엄밀한 인사평가에 의하여 운영되는 것을 기본으로 한다. 따라서 이와 같은 인사평가를 게을리하여 불승격조치를 계속하는 것은 인사권의 일탈·남용으로서 불법행위를 성립시킨다. 구체적으로는 직무등급 재평가가 문제될 수 있다. 직무등급 재평가란 근로자의 직무등급의 고도화에 수반하여 직무등급을 수정하는 것을 말한다.³¹⁰⁾ 근로자 내지 그 상사가 재평가를 신청하였음에도 불구하고 합리적 이유 없이 재평가를 실행하지 않으면서 불승격조치를 계속 유지하는 것은 직무급제도의 취지에 비추어 위법하다고 평가받을 가능성이 있다. 사용자로서는 상세한 직무등급 재평가를 실시해야 할 필요가 있을 것이다.

또한 직무급제도의 취지에 따르면 직무관련성과 관계없는 요소에 의하여 근로자를 승격시키지 않는 것이 인사권의 일탈·남용으로서 불법행위를 성립시키는 것은 당연하다. 일본의 하급심 판결 중에는 직능자격제도 사례인데, 기혼여성에 대한 일률적인 저평가와 불승격 조치에 대해 개별 근로자의 능력과 업적에 기한 평가가 이루어져야 하는 인사평가제도의 취지에 반하는 것으로서 위법이라고 해석하고 해당 직무에서 표준적 지위에 있는 근로자와 임금 차액 상당액 및 위자료를 지급하라고

309) 菅野和夫, 「労働法」, p.681; 土田道夫, 「労働契約法」, p.402.

310) 土田道夫, “職務給・職務等級制おめぐる法律問題”, p.191 참고.



한 사례가 있다.³¹¹⁾

(3) 강등(降等), 강급(降級), 강격(降格)

일반적으로 근로자의 직급이나 자격 또는 직위를 하향 조정하는 것을 강등(降等), 강급(降級), 강격(降格이라고 하는데, 승격 또는 승진의 반대개념으로 사용된다. 강격에 대한 법적 취급도 직능자격제도와 직무급제에서 다르다.

우선 직능자격제도에서의 강격은 직위를 낮추는 강등과 자격을 낮추는 강격으로 나뉘진다. 직위 강등은 경영의 중심축을 담당하는 인재의 배치문제이므로 사용자에게 광범위하게 재량권이 인정되고, 취업규칙에 근거가 없더라도 인사권에 기한 강등명령이 인정된다. 다만, 이 경우에는 인사권 남용의 규제가 적용된다. 예컨대 업무상·조직상의 필요성이 없는 경우, 현저히 하위의 직위로 강등하는 등의 경우에는 권리남용으로서 무효가 될 수 있다. 그렇지만 그 밖의 경우 대체로 넓게 재량권이 인정된다. 이처럼 직위 강등으로 직책수당이 부지급되는 것은 근로제공의무의 변경에 수반하는 당연한 감액으로서 유효하다고 평가될 수 있다.

한편, 자격을 낮추는 인사명령인 강격은 직능자격과 연계된 기본급(직능급)을 인하하는 조치로써, 계약내용의 변경을 의미하므로 일방적 강격명령은 허용되지 않는다. 즉, 근로자의 동의나 취업규칙상의 근거규정이 필요하다. 취업규칙에 근거규정이 있더라도 인사권 남용의 규제가 미치므로 강격사유 해당성이 인사평가의 공정성에 비추어 엄격히 판단되어야 하고, 기본급의 인하를 초래한다는 점에서 강격의 폭이나 임금 감액의 정도가 엄정하게 판단되어야 할 것이다.

직무급제도에서의 강격은 근로자에게 부여한 직무(직무등급)를 수정하는 것과, 등급 그 자체를 하향시키는 것이 있는데 직능자격제도에서 자격 하향으로서 강격에 유사하다고 판단된다. 즉, 직무급제도에서는 직무급을 결정하는 기준이 직무등급이기 때문에 직무등급의 하향은 기본급(직무급)의 감액에 직결되고, 임금(근로조건)의 불이익변경이라는 성격을 가진다. 따라서 우선 강격의 법적근로로서는 사용자에게 의

311) 大阪地判 平成 13.6.27 勞判 809号 p.5.



한 일방적 강격은 허용되지 않고, 근로자의 동의 또는 취업규칙상 근거 규정이 요구된다고 해석된다. 또한 취업규칙에 근거규정이 있는 경우에도 강격명령권(인사권)의 정당성 여부에 대해서는 엄격하게 판단할 필요가 있다. 즉, 직무급제도에서는 근로자의 직종(직무) 유지에 대한 이익이 중요하기 때문에 직종·직무의 변경에 직결되는 강격에 대해서는 강격사유 해당성을 인사평가의 공정성에 비추어 판단하고, 동시에 강격의 폭이나 임금감액의 정도를 인사권 남용의 요소로 고려해야 한다. 또한 강격제도에 정해진 절차(본인의 의견 청취, 만회 기회의 부여 등)가 있다면 이를 준수해야 한다.³¹²⁾

일본의 하급심 판결에는, 시설관리부장의 부정행위로 어시스턴트 매니저로 강격(직위 인하)하고, 그에 수반하여 등급을 낮춰 급여를 감액한 조치에 대해 인사권에 기한 강격을 인정하면서, 강격의 불이익이 과도하게 큰 경우에는 인사권 남용이 된다는 일반론을 서술한 다음, 관리직으로서의 부적격성에 비추어 강격을 상당하다고 판단하고, 급여 감액도 직종·직위에 상응하여 등급 및 호봉을 부여한 급여규정의 취지(직무급제도)에 따르면 상당성이 인정되어 유효하다고 판단한 사례가 있다.³¹³⁾ 또한 법령이나 사내규칙의 준수 등 능력부족을 이유로 취업규칙상 강격규정에 기하여 점포매니저를 점장으로 강격시킨 사례(직위 강등)에 대해 성과주의 임금체계에서 직무수행능력에 따라 직위가 결정되고, 직위에 따른 직무급과 직무수당이 지급되고 있다는 점 외에 특히 자격요건이 규정되지 않은 본건 임금제도에서는 강격에 의하여 곧바로 직무급 및 직무수당도 감액할 수 있다고 판단한 사례가 있다.³¹⁴⁾

한편, 직무급제도를 전제로 하는 강급(降級)의 효력에 대해 사용자가 임금규정(취업규칙)상 강급의 기준으로 “본인의 현재능력과 업적이 속한 자격(급여등급)에 기대하고 있는 것과 비교하여 현저히 열등한 경우”라고 규정하고 있는 것을 전제로, 사용자가 강급을 행하기 위해서는 근거가 되는 구체적 사실을 열거하고, 근로자의 현재능력과 업적이 현재의 등급에 기대하는 것과 비교하여 현저히 열등하다는 것을 주장 및 입증해야 한다고 하면서, 그에 관한 주장 및 입증이 없는 경우에는 인사권

312) 土田道夫, “職務給・職務等級制おめぐる法律問題”, p.194 참고.

313) 東京地判 平成 13.8.31 勞判 820号 p.62.

314) 大阪高判 平成 17.1.25 勞判 890号 p.27.



의 일탈을 인정하고 강급 전의 등급의 지위확인 청구를 인용한 사례가 있다.³¹⁵⁾

5. 해고

(1) 서설

해고는 정당한 사유가 없이는 할 수 없으며, 이때 정당한 사유는 취업규칙이나 단체협약에서 정해지는데, 해고가 근로자의 실업을 초래한다는 점을 고려할 때 그 정당한 사유의 존부는 엄격하게 판단되어야 한다. 즉, 해고가 정당하다고 할 수 있기 위해서는 근로자에게 채무불이행의 사실이 있다는 것만으로는 불충분하고, 그 사실이 근로관계를 종료시키지 않을 수 없다고 인정될 수 있을 정도에 이르러야 한다. 구체적으로는 근로자의 해고사유가 중대하고 업무수행에 지장을 초래하거나 반복을 계속해서 시정이나 개선의 여지가 없을 것, 사용자가 사전에 주의나 지도를 주어 시정하도록 노력하였을 것, 사용자가 휴직·배전·전출 등의 조치에 의하여 해고회피의 노력을 다했을 것 등을 요건으로 한다.³¹⁶⁾

직무급제와의 관계에서는 근로자의 능력부족·적격성 결여를 이유로 하는 해고가 가능한지를 둘러싸고 주목을 받고 있는데, 이러한 해고에 대해서도 앞에서 본 해고 요건이 원칙적으로 적용된다. 그 결과 문제가 되는 능력·성적은 앞으로 시정되기 어려울 정도로 불량할 것을 요건으로 하고, 설령 이 점이 긍정되더라도 지도나 교육 그리고 배치전환에 의하여 능력을 활용할 여지가 있다면, 그러한 조치에 의하여 고용을 계속할 수 있도록 노력할 것이 요구된다.³¹⁷⁾

(2) 직무급제에서의 해고의 판단

315) 東京高判 平成 19.2.22 勞判 937号 p.175.

316) 土田道夫, “職務給・職務等級制おめぐる法律問題”, p.196 참고.

317) 대법원 2021.2.25. 선고 2018다253680 판결 참고



직무급제에서는 근로자의 능력부족·적격성 결여를 이유로 하는 해고의 정당성 판단이 상대적으로 완화될 가능성이 있다. 직무급과 연결된 직종(직무)한정특약이 체결되어 있는 경우 배치전환 등에 의한 해고회피노력의무가 발생하지 않는다는 점에서, 당해 직종(직무)에 대한 부적격성이 입증되면 해고가 유효할 것이다. 이러한 해석은 지위나 직종을 특정하여 중도 채용된 관리직·전문직 근로자에게 적용될 수 있다. 직무급제가 적용된 직종(직무) 한정 직원에 대해서도 마찬가지로 해석될 수 있다. 동일한 이유로 직무 부적격성이 명확한 근로자에 대하여 사용자가 다른 직무로 배전을 청약하고, 근로자가 이를 거부한 경우에 해고가 원칙적으로 유효하다고 해석된다.

또한 직종(직무)한정특약이 인정되지 않는 경우에도, 직무급제에서는 근로자가 직무수행능력과 직무달성도를 높이는 것이 근로계약의 내용(근로제공의무의 내용)이므로 그와 관련된 능력·적격성의 부족이 긍정된다면 해고사유의 중대성 요건이 인정될 수 있다. 직무급제에서는 직무수행능력과 직무달성도에 기초한 인사평가에 의하여 능력과 적격성의 부족 여부가 객관적으로 파악되기 때문에 그 입증이 용이하다고 할 수 있다. 물론 이 경우에도 사전에 주의·지도 및 경고나 직종 전환에 의한 계속고용의 노력이 요구되는데 이때에도 근로자의 직무·직책에 비추어 합리적 범위 내에서 행해지면 족하다. 이러한 해석은 특히 전문직 근로자의 해고에 관해서 적용될 수 있을 것이다.

이와 같이 직무급제에서는 해고규제는 완화될 수 있지만 한편으로는 공정한 인사평가와 능력개발 기회의 부여가 강력하게 요구되고 이를 무시한 채 해고할 경우 해고의 효력이 부정될 것이다.

제5절 성과주의 임금제와 노동법적 쟁점



I. 성과주의 임금제도 및 연봉제의 의의

1. 성과주의 임금제도의 의의

우리나라는 종래 장기고용체제에서 대학을 갓 졸업한 청년을 채용한 후 기업의 다양한 직무를 경험시키면서 숙련과 능력을 높여가는 연공적 인사제도가 일반적이었다. 이 제도는 근속기간과 능력·공헌도가 일치하는 것을 전제로 설계된 것이기 때문에 임금제도는 당연히 연공형 임금제도가 채택되어 인사제도의 중심을 담당하였다.

그러나 우리 경제가 글로벌 경제체제에 편입되고, 저성장 기조가 장기화되며, 인구고령화로 중고령 근로자가 늘고, 기술혁신의 영향으로 청년근로자의 적응능력이 향상되면서 연령과 근속기간만으로 임금제도를 유지하는 것은 불공정하거나 객관성을 갖추기 어렵게 되고, 능력과 성과를 중시하는 방향으로 궤도 수정이 요구되었다. 특히 글로벌경제체제 및 경제의 저성장화에 수반하는 경영환경의 변화, 국내외 경쟁의 격화, 청년 및 중년층의 의식 변화(근속기간이나 연령보다는 업무의 질과 성과에 따른 보수지급을 공정하다고 인식) 등을 배경으로 성과주의 임금제도가 널리 확산되고 있다. 성과주의 임금제도란 “근로자의 연령이나 근속기간에 관계없이 자신의 능력·성과·업무가치를 기준으로 임금과 처우수준을 결정하는 제도”라고 할 수 있다.³¹⁸⁾ 구체적으로는 기본급에서 연령급의 축소와 성과급·직무급의 확대, 직무수당의 확대와 생활수당의 축소, 승격·승급·상여의 결정에 있어서 인사평가 부분의 확대, 고령자의 인건비를 억제하기 위한 임금곡선의 하방수정 등이 거론된다. 또한 직무자격제도 자체를 개편하여 직무와 임금의 연계성을 강화하는 제도로 변경하는 움직임도 나타나고 있다.

2. 연봉제의 의의와 법적 쟁점

318) 西谷民外編(土田道夫), 「勞働基準法、勞働契約法」, p.88.



연봉제는 ① 1년의 임금액을 (연단위의 임금설정), ② 근로자의 성과와 능력에 입각하여(비근로시간관리) 지급하는 임금제도를 말한다. 성과주의 임금을 공고화 하는 제도로써 관리직을 중심으로 하는 화이트칼라를 대상으로 도입되고 있다. 그 형태는 대체로 “기본연봉 + 업적연봉(업적성과급) 형태”가 많다. 이 경우 기본연봉은 전년도 성적에 중심으로 근로자의 역할과 차년도에 대한 기대감을 고려하여 결정하고 업적연봉은 전년도 업적을 평가하여 결정한다.³¹⁹⁾

연봉제는 주로 근로시간 규제를 받지 않는 근로자(근기법 제64조 제4호 참조)나, 재량근로 방식으로 근무하는 근로자(근기법 제58조 제3항 참조)를 대상으로 실시된다. 여기에 해당하는 근로자는 연장근로에 대한 규제(할증임금지급)가 없기 때문에 연봉액을 일괄하여 사전에 결정하는 것이 가능하기 때문이다. 이에 비하여 일반근로자는 할증임금 지급규정이 있기 때문에 연봉제 도입이 어려운 측면이 있다.

연봉도 임금인 이상 매월 1회 이상 정기적으로 지급되어야 한다(근기법 제43조 제2항). 따라서 연봉제라도 실제로는 연봉액이 분할되어 매월 월급제 형태로 지급된다. 예를 들어 연봉액을 16분하여, 그중 16분의 1을 매월 지급하고, 16분의 4를 업적연봉으로 지급하는 경우가 있다.

연봉제에서 업적연봉은 업적성과급으로도 부르는데, 전년도의 성적을 평가하여 확정되어 있는 경우에는 이 성과급 부분은 임금(통상임금)으로 보아야 한다.³²⁰⁾ 따라서 업적성과급을 할증임금의 산정기초로부터 제외하거나 평균임금 산정기초에서 제외할 경우에는 위법하게 된다.

319) 西谷民 外 編(土田道夫), 「勞働基準法・勞働契約法」, p.92.

320) 대법원 2021.6.10. 선고 2017다52712 판결. 이 판결은 원심인 서울고등법원(2017.9.1. 선고 2015나31393 판결)이 "업적연봉이 비록 전년도 인사평가 결과에 따라 인상분이 달라지기는 하지만, 전년도 인사평가 결과가 나오고 인상분이 정해질 경우 월 기본급 700%에 그 인상분을 더한 금액이 '해당 연도의 근무실적과 관계 없이' 지급되는 것"이라며 "이는 소정근로를 제공하기만 하면 지급이 확정된 것으로 정기적, 일률적으로 지급되는 고정적 임금인 통상임금"이라고 판단한 것을 정당하다고 보았다.



II. 인사평가의 공정성

1. 인사평가의 근거와 요건 및 효과

위에서 이미 인사평가가 직무급제나 성과주의 임금제도의 핵심 열쇠로서 기능한다는 점을 설명하였기 때문에 여기서는 인사평가의 법적 근거와 요건 및 그 효과를 중심으로 설명한다.

특히 성과주의 임금제도를 둘러싼 법적 분쟁은 주로 인사평가제도의 운영을 둘러싼 분쟁이라고 할 수 있다.

일반적으로 인사평가는 취업규칙에 제도화되어 근로계약의 내용이 되고 있으며, 사용자는 그에 따라 근로계약상 인사평가권을 가진다. 인사평가가 임금결정이라는 기업의 자원배분에 직결되는 절차인 이상 인사평가권한은 기업운영에 책임을 부담하는 사용자에게 인정되어야 하기 때문이다. 특히 일본의 하급심판결 중에는 “인사고과의 방법, 자격요건 등에 대하여 취업규칙에서 정해지고 이에 기하여 각 인사사고과가 행해지고 있다면 개개 근로자의 어떠한 업적이나 능력 등에 대해 어떻게 평가를 내리는가는 기본적으로는 사용자의 인사권의 재량 범위 내의 문제이다.”라고 한 사례가 있다.³²¹⁾

이와 같이 인사평가의 법적 근거를 사용자의 인사평가권 또는 재량권에서 구하고 있는 것이 일반적이라고 할 수 있다. 그렇지만 동시에 성과주의 임금제도에서는 인사평가의 공정성이 인사평가권 행사의 불가결한 요건이라고 할 수 있다. 특히 임금은 근로의 대가임과 동시에 근로자의 중요한 생활자원이고 인사평가는 임금결정의 선행절차라는 점에서 이를 공정하게 행하는 것은 사용자의 임금지급의무에 내재하는 책무라고 해석된다.³²²⁾

321) 大阪地判 平成 13.6.27 勞判 809号 p.5; 廣島高判 平成 13.5.23 勞判 811号 p.21; 東京地判 平成 20.9.2 勞經速 2016号 p.11.

322) 이승길, 「성과주의인사와 임금제도」, 2005, 149면 이하 참고. 공정한 인사평가를 사용



또한 성과주의 임금제도에서는 인사평가는 임금과 처우를 결정하는 가장 중요한 절차이며 임금의 단기적 변동성을 높이는 제도로 기능하기 때문에 능력·성과에 관한 공정한 평가의 요청이 한층 더 강조된다. 즉, 성과주의 임금제도에서의 인사평가는 절대적인 사용자의 재량권이라고 할 수 없고, 사용자는 근로자가 납득할 수 있도록 공정하게 평가할 책무를 부담한다고 해석된다.³²³⁾

일본 하급심 판결 중에는 인사평가에 기초한 강격이나 강급에 대해 “인사고과는 인사관리의 기초로서 공정하게 행사되어야 하고, 평가자의 개인적·자의적 판단이 허용되지 않는 것은 당연하며, 이러한 점에 비추어 보면 인사고과가 소정의 평가방법에 기초하지 않은 경우 등 사회통념에 비추어 현저히 불합리한 경우는 재량권의 남용으로서 위법하다”라고 판단한 사례가 있다.³²⁴⁾ 또한 인사평가를 근거로 한 강격이나 강급에 대해, 인사평가에 상당한 이유가 없고, 강급이나 강격에 의하여 근로자가 입게 되는 불이익이 큰 경우에는 당해 강급 및 강격 인사는 인사권의 남용으로 무효라고 일반론을 서술한 다음, 인사평가의 공평성·상당성을 부정하고 인사권의 남용을 인정한 사례가 있으며,³²⁵⁾ 인사평가제도에서 복수의 평가(다면적 평가)를 결여한 점과 이의신청절차가 없다는 점을 중시하면서 인사평가 중 종업원에게 큰 불이익을 초래한 1차 평가와 2차 평가를 동일인이 행한 부분에 대하여 위법하다고 판단한 사례³²⁶⁾가 있다.

따라서 사용자가 이와 같은 공정평가의무에 반하여 인사평가를 자의적으로 행하여 근로자에게 경제적 손해를 끼친 경우에는 인사평가권의 남용으로서 불법행위가 성립하고, 사용자는 손해배상책임을 부담하게 된다. 손해액은 통상 위법한 인사평가가 없었다면 받게 될 임금과의 차액분이 된다. 일본 하급심 판례 중에는 승급의 일부 불실시에 관한 인사평가의 결과에 대하여 불법행위의 성립을 인정하면서 손해에 대해서는 회사에서의 평균승급률과의 차액을 손해로 한 원고의 주장을 배척하고,

자의 재량권으로 이해할 것인가, 아니면 근로계약에 내재하는 사용자의 의무로 이해할 것인가가 법체계적 논점이라고 할 수 있다.

323) 土田道夫, 「労働契約法」, p.292.

324) 大阪地判 平成 25.9.12 Journal 21号 p.28.

325) 札幌地判 平成 27.3.18 Journal 39号 p.13.

326) 名古屋地法岡崎支判 平成 30.4.27 判時 2407号 p.97.



본래라면 C등급의 인사평가를 받았을 것이라고 하여 그에 기한 승급분과의 차액 상당액을 손해로 인정한 사례가 있다.³²⁷⁾ 상여금의 부지급 또는 감액에 대해서도 마찬가지로 판단하고 있다. 즉, 당해 인사평가가 없었다면 지급받을 수 있었던 상여액과의 차액청구를 인용한 사례가 있고,³²⁸⁾ 상여금(성과급)과 연계된 근무성적 평가가 단체협약에 규정된 경우에 대해 단체협약의 규범적 효력에 기한 차액청구를 긍정적인 사례도 보인다.³²⁹⁾

또한 인사평가가 위법한 차별에 해당하는 경우와, 고의·악의에 의하여 낮은 평가가 이루어진 경우에는 부당하게 낮은 평가를 받은 것을 이유로 하는 정신적 손해에 대한 위자료청구도 인정한 사례가 있다.³³⁰⁾

2. 공정한 평가의 법적 구조

인사평가의 요건(공정한 평가)에 대해서는 인사평가의 제도 및 절차 측면과, 그 적용(실제의 평가행위)의 적정성이라는 측면에서 검토할 필요가 있다.

사용자는 인사평가의 프로세스 전체의 공정성을 정비해야 한다. 즉, 사용자는 ① 공정하고 투명한 평가제도를 설계·고지하고, ② 그에 기하여 공정한 평가를 행하며, ③ 평가결과를 고지 및 설명할 책무를 부담한다고 해석된다. 법적으로는 특히 위의 ①과 ③과 같은 절차적 공정성이 중요하다. 구체적으로는 투명성과 구체성을 가진 평가항목 및 기준을 정비하고 공개할 것, 평가의 납득성 및 객관성을 보장하기 위한 평가방법의 도입, 평가를 처우(승급 및 강급 또는 인사이동 등)에 반영하기 위한 명확한 규칙의 정비, 분쟁처리절차(제도)의 정비, 이와 같은 규칙을 근로자에게 고지할 것 등이 중요하다고 할 수 있다. 이와 같은 내용을 담은 인사평가제도는 취업규칙에 규정되는 것이 일반적이다.

327) 廣島高判 平成 13.5.23 勞判 811号 p.21.

328) 東京高判 平成 29.10.18 勞判 1179号 p.47.

329) 大阪地判 平成 29.3.30 Journal 66号 p.55.

330) 大阪地判 平成 13.6.27 勞判 809号 p.5.



인사평가가 제도·절차에 입각하여 행해지지 않았음을 이유로 인사평가권의 남용을 인정한 사례는 다음과 같다. 근로자의 경영비판을 이유로 하는 승급 상의 낮은 평가 및 상여금의 감액 지급에 대해, 인사평가 규정에 정한 평가기간이 아닌 기간에 이루어진 근로자의 언동을 포함하여 낮게 평가한 것을 규정 위반으로 보아 재량권 일탈을 인정하고 불법행위의 성립을 긍정한 사례가 있다.³³¹⁾

급여규정에 정한 평가를 거치지 않고 직능급·업적급과 상여금을 감액하고, 특히 규정상으로는 감액 평가의 대상이 될 수 없는 연령급과 생활보조급에 감액 평가를 행하여 감액시킨 것은 근로계약 및 취업규칙 위반에 해당하여 위법이라고 한 사례도 있다.³³²⁾

육아휴직 기간(9개월)을 포함한 1년간의 인사평가에서 육아휴직 취득자의 성과보수를 “0”으로 평가한 것에 대해 휴업 전의 기간(3개월)에서의 업무실적을 고려하지 않은 평가는 평가제도상 고려해야 할 사정을 고려하지 않은 것으로 재량권의 남용을 인정하고, 불법행위를 긍정한 사례가 있다.³³³⁾

근로자가 업무에 종사하지 않는 자택대기 기간 동안에 관하여 낮은 평가를 내린 사례에서 이를 재량권의 남용으로 판단하고 위의 낮은 평가와 연계된 손해(예를 들어 상여금의 저하)에 대하여 중위평가에 기한 지급을 명령한 사례가 있다. 또한 월급의 감액에 대하여 인사평가의 기준과 감액의 관계를 보여주는 기준이 전혀 명백하지 않다고 하여 평가의 정당성을 부정하고 무효라고 판단한 사례가 있다.³³⁴⁾

인사평가제도가 잘 정비되고 절차가 준수되더라도 실제 평가가 현저히 자의적이라면 불공정한 평가로 해석되어 인사평가권의 남용이 성립하게 된다. 평가상 인사평가권 남용이 문제되는 유형은 다음과 같다.

첫째, 인사평가는 각종의 차별금지 및 균등처우 규정에 반해서는 아니된다. 이 규

331) 廣島高判 平成 13.5.23, 大阪地判 平成 14.3.29 勞判829号 p.91 참고.

332) 東京地判 平成 15.5.9 勞判 858号 p.117.

333) 東京地判 平成 23.3.17 勞判 1027号 p.27; 東京高判 平成 23.3.17 勞判 1042号 p.15.

334) 東京地判 平成 31.3.28.



정을 위반한 인사평가는 권리남용 여부를 판단할 것까지도 없이 강행법규 위반으로서 위법하다.

둘째, 성과주의 임금제도를 표방한 이상 능력·성과와 무관하게 근로자의 인적 속성(성별, 학력, 고용형태 등)을 이유로 낮은 평가를 하는 것은 인사평가권 남용이 된다.³³⁵⁾

셋째, 인사평가가 제도에 입각하여 행해지더라도 실제 평가가 기준을 잘못 적용하여, 종업원에게 경제적·정신적 불이익을 미치고 있는 경우에는 권리남용이 성립할 수 있다. 일본 하급심 판결 중에는 직능자격제도(취업규칙)가 개정되기 이전의 인사평가에서 근로자가 B 이상의 평가를 받았음에도 불구하고 개정 이후의 평가에서 같은 평가자가 낮은 평가를 행한 것 등에 대하여, 인사평가의 방법을 현저하게 일탈하고 있다고 하면서 인사평가권 남용을 인정한 사례가 있다.³³⁶⁾

인사평가제도 자체는 합리성을 가지고 있지만 상급자에 의한 실제 인사평가가 사실에 근거하지 아니하고 객관적 평가기준에 위반하여 주관적이고 자의적으로 행해진 것이라고 하여 인사평가권의 남용을 인정한 사례가 있다.³³⁷⁾

괴롭힘이나 본보기 등 부당한 목적으로 인사평가가 행해졌다고 하여 권리남용을 인정한 사례,³³⁸⁾ 권고사직에 응하지 않은 근로자를 인사·총무부 분실로 배치전환한 다음 거의 유례가 없는 낮은 평가를 한 것에 대해 평가의 정당성에 의문이 있다고 하여 무효라고 판단한 사례³³⁹⁾ 등이 있다.

물론 인사평가를 근거로 하여 행해진 강급이 평가제도의 기준과 절차에 따라 행해진 경우, 특별히 불합리하거나 불공정하다고 인정해야 할 사정이 없는 한 유효하다고 한 사례가 있지만, 개별 근로자에 대한 평가에 있어서 과오가 있으면 제도 자체는 공정하더라도 적용 단계에서 인사평가권의 남용이 성립할 수 있다는 점을 인

335) 大阪地判 平成 13.6.27 勞判 809号 p.5.

336) 東京地判 平成 15.12.12 勞判 869号 p.35.

337) 札幌地判 平成 27.3.18 Journal 39号 p.13.

338) 大阪地判 平成 21.10.8 勞判 999号 p.69.

339) 東京地判 平成 31.3.28.



정한 것이라고 해석되고 있다.³⁴⁰⁾

능력개발이나 직무선택의 기회 보장도 중요하다. 특히 성과주의 임금제도는 근로자에게 높은 직무수행능력의 발휘를 요구하는 제도이므로 근로자에게 능력을 높이기 위한 기회를 보장하지 않으면 불공평하며, 근로자에게 능력개발의 권리가 중요한 의미를 가진다. 따라서 능력개발제도의 정비와 적절한 운영을 게을리한 채 인사평가를 행하는 것은 공정한 평가로 인정받을 수 없고 인사평가권의 남용이 될 수 있다.³⁴¹⁾ 또한 능력개발을 행하지 않은 채 달성 불가능한 목표를 정하고 그 미달성을 이유로 낮은 평가를 행한 경우에도 마찬가지로 해석되어야 한다.³⁴²⁾

성과주의 임금제도에서는 단기적인 업적에 의하여 임금이 변동할 수 있지만, 그것을 무제한 인정하는 것은 근로자에게 소득이 안정적으로 보장되어야 한다는 점에서 임금의 안정성과 확정성 요청에 반한다. 물론 이러한 경우에 근로기준법 제47조(사용자는 도급이나 그 밖에 이에 준하는 제도로 사용하는 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하여야 한다)를 그대로 적용할 수는 없지만 근로자에 대한 소득보장의 관점에서 임금감액에 일정한 한도를 정하고 극단적인 감액은 인사평가권의 남용으로 인정할 수 있을 것이다.³⁴³⁾

Ⅲ. 연봉제와 근로계약

1. 고용기간과 임금결정기간

연봉제는 임금을 연간 단위로 지급하는 제도이므로 법적으로는 임금의 결정기간

340) 大阪地判 平成 17.11.16 勞判 910号 p.55; 西谷民 外 編(土田道夫), 「勞働基準法・勞働契約法」, p.91.

341) 西谷民 外 編(土田道夫), 「勞働基準法・勞働契約法」, p.91.

342) 大阪地判 平成 17.11.16 勞判 910号 p.55.

343) 土田道夫, 「勞働契約法」, p.298. 같은 취지로 이승길, 「성과주의인사와 임금제도」, 157면.



및 지급기간이 연 단위로 하는 것을 의미하며, 연봉제를 도입하였다는 이유만으로 고용기간(계약기간)을 1년으로 합의한 것이라고 할 수는 없다. 근로자는 통상 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하면서 임금에 대해서는 연봉제를 특약으로 합의할 수 있다. 따라서 고용기간(계약기간)과 임금결정기간을 혼동해서는 안되며, 계약기간의 존부에 대해서는 별도 당사자의 의사를 확인해야 한다.

2. 연봉청구권의 발생

연봉제에 대하여 특별히 문제되는 것은 연봉액이 어느 시점에 확정되고, 또한 임금청구권이 어느 시점에 발생하는가이다. 이 점은 근로자가 특정 연도 도중에 퇴직하는 경우 임금청구권의 유무나, 연도 도중에 임금감액의 적법성에 관한 문제이다.

먼저, 업적상여금이 포함된 확정연봉제의 경우 연봉액은 전년도 업적평가 등에 의하여 확정된다. 그러나 구체적인 연봉청구권에 대해서는 연봉도 임금이므로 무노동무임금 원칙이 적용된다. 임금청구권은 현실의 취업을 전제로 발생하는 것이 원칙이다. 따라서 연봉제 적용 근로자가 당해 연도에 퇴직하거나 해고된 경우 그 이후의 임금청구권은 발생하지 않는다.

한편, 연도 도중에 연봉액의 감액이 행해지는 경우에는 연봉액이 이미 확정되어 임금청구권의 내용이 되고 있는 이상, 사용자는 일방적으로 감액(조정)할 수 없다. 연봉제에서는 차년도에 대한 기대를 결정요소로 삼는 경우가 많은데, 근로자가 그 기대에 부응한 성과를 거두지 못하더라도 이는 연도 도중에 조정 사유가 되는 것이 아니라 다음 연도의 연봉에 반영시켜야 한다고 해석된다.³⁴⁴⁾ 당해 연도의 성적에 따라 연봉액을 조정한다는 취지의 약정이 있는 경우는 임금을 과도하게 불안정한 상태로 만들기 때문에 공서(公序)에 반한다고 해석될 수 있기 때문이다.³⁴⁵⁾

207) 일본 하급심 판결의 견해: 東京地判 平成 12.2.8 勞判 787号 p.18.

345) 西谷民外編(土田道夫), 「勞働基準法・勞働契約法」, p.93.



3. 연봉액의 결정

연봉액의 결정은 일반적으로 성과관리제도 또는 목표관리제도와 연계되어 이루어진다. 당해 연도에 근로자와 관리자(상급자)가 대화를 통하여 목표(성과지표)를 설정하고 해당 연도 말에 그 달성도를 서로 평가한 다음 합의에 의하여 임금액을 결정하는 것이 통상적이다. 이 경우 연봉액은 사용자에 의한 일방적인 인사평가보다는 노사의 개별적 협의와 합의에 의하여 결정된다. 따라서 다음 해 이후 임금이 감액될 수 있는 가능성에 대하여 근로자가 개별적으로 동의한 경우에는 당해 합의를 근거로 감액이 정당화될 수 있다.³⁴⁶⁾

다음 해의 연봉액에 대하여 노사가 합의에 이르지 못한 경우에는 사용자가 이를 결정한다는 취지의 당사자의 합의 또는 취업규칙의 관련규정이 존재한다면 그에 따르면 되고, 이러한 합의 또는 취업규칙의 관련규정이 없다면 사용자가 협의 과정에서 제안한 금액을 최저연봉액으로 한다는 내용의 합의가 있다고 인정할 수 있다는 견해가 있다.³⁴⁷⁾ 다만, 이 경우에도 연봉제는 성과주의임금제도를 실현하는 제도라는 점에서 공정한 인사평가가 필수적 요건이고 자의적인 연봉결정은 인사평가권의 남용이 된다는 점이 고려될 수 있을 것이다.³⁴⁸⁾ 또한 연봉액 결정에 관하여 사용자의 재량권을 인정한 취업규칙의 관련규정이 있더라도 공정한 인사평가제도가 정비되어야 비로소 사용자의 연봉액 결정권이 발생한다고 해석하고 그러한 제도가 없는 경우에는 전년도 연봉액이 다음 해의 연봉액이 된다고 하는 견해도 있다.³⁴⁹⁾

346) 일본 東京地判 平成 19.3.26 勞判 943호 p.41는 합의 여부를 판단함에 있어서 신중하게 행해야 한다는 점을 지적하고 있다.

347) 西谷民 外 編(土田道夫), 「勞働基準法・勞働契約法」, p.93.

348) 土田道夫, 「勞働契約法」, p.303. 같은 취지로 이승길, 「성과주의인사와 임금법제」, 178면 이하 참고.

349) 東京高判 平成 20.4.9 勞判 959号 p.6.



제6절 임금체계 변경 절차에 관한 쟁점

I. 개설

임금체계 개편 과정에서 직무급제를 도입할 경우 유의해야 할 법적 쟁점은 다음과 같다. 기업으로서는 직무급제도를 도입할 경우 취업규칙을 개정하는 것이 일반적이다. 그리고 취업규칙의 개정에 의한 근로조건(임금제도)의 불이익 변경에 대해서는 과반수 근로자의 동의를 얻어야 그 효력이 인정된다. 불이익 변경이 아닌 경우에는 근로자 과반수의 의견을 듣는 것으로 충분하다. 직무급제의 도입이나 성과주의 임금제도의 도입 시 이 요건을 어떻게 해석할 것인지가 쟁점이다.

서론(제1장)에서 본 바와 같이 계속되는 경기침체와 기업의 경영환경 악화에 대한 대책으로 능력 및 성과를 바탕으로 하는 이른바 임금체계 개선 이슈가 제기되고 있다. 이와 관련하여 직무급, 성과주의 연봉제 등 새로운 형태의 임금체계가 계속 등장하고 있으며, 임금의 산정기준에 대한 노사의 인식도 상당히 변화하고 있다. 그러나 근로기준법 등 기존 노동관계법상 임금제도의 획일성·경직성은 이러한 새로운 임금체계 도입을 어렵게 만드는 걸림돌이 되고 있다.³⁵⁰⁾ 또한 임금체계의 합리화 방안, 예를 들어 직무급이나 성과주의 임금체계 등의 도입을 원활하게 하기 위해 취업규칙 변경절차 간소화 문제³⁵¹⁾ 등 입법과제가 법제도개혁이라는 이름으로 끊임 없이 제기되고 있다.

따라서 근로자의 능력·성과에 연동되는 임금체계의 도입, 다시 말해 기존의 연공급 내지 호봉급제의 임금체계를 직무급제나 연봉제 등 성과주의 임금체계로 전

350) 앞의 제2장 제4절 Ⅲ. 3.에서 통상임금의 고정성 요건은 성과를 중시하는 임금체계와 충돌될 수 있다는 점을 설명한 바 있다.

351) 취업규칙 변경절차를 현행처럼 근로자과반수 동의에 맡기지 말고 민주적으로 선출된 근로자대표와 사용자의 교섭을 통해 결정할 수 있도록 한다든지, 과반수노조의 대표성을 제한하여 노조에 의하여 대표되지 아니하는 직종이나 직무에 대해서는 별도의 근로자대표를 선출하여 교섭할 수 있도록 허용하자는 부분근로자대표제가 대표적인 개혁의제라고 할 수 있다.



환하기 위하여 근로관계상 임금청구권의 법적 근거인 근로계약, 취업규칙 및 단체협약 등을 변경할 경우에 발생하는 법적 쟁점들을 검토할 필요가 있다.

II. 근로계약의 변경을 통한 임금체계 변경

사용자가 개별 근로자의 동의를 전제로, 다시 말해 근로계약의 내용 변경에 관한 합의를 통하여 임금체계 변화를 도모하는 방안이 있을 수 있다. 근로계약 체결 시 임금, 근로시간 등 중요한 근로조건은 명시하도록 되어 있고 특히 임금의 구성항목, 계산방법 및 지급방법에 대해서는 서면으로 명시하도록 되어 있으며(근기법 제24조 및 동법 시행령 제8조), 근로조건을 핵심 부분이라고 할 수 있는 임금의 산정방식(구성항목 및 계산방법)에 관한 당초 약정 내용을 변경하여 노사가 다시 합의할 수 있기 때문이다.

그러나 근로계약의 변경을 통한 임금체계 변경은 용이하지 않을 것이다. 왜냐하면 성과주의 임금제도로의 변경이 근로자에게 불리하다고 가정할 경우 통상적으로 취업규칙에 임금에 관한 규정을 두고 있다는 점에서, 임금제도의 변경은 근로기준법상 “취업규칙에 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약”에 해당하게 되어 그 효력이 인정되지 않으며, 무효로 된 근로계약의 내용은 취업규칙에서 정한 기준에 따르기 때문이다(근기법 제97조 참조). 또한 단체협약을 가지고 있던 사업(장)의 경우, 근로계약의 변경을 통한 임금체계의 변경 가능성 역시 매우 희박하다. 현행 노조법 제33조는 “① 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효로 한다. ② 근로계약에 규정되지 아니한 사항 또는 제1항의 규정에 의하여 무효로 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 의한다.”고 규정하고 있다. 즉, 단체협약에 의하여 급여에 관한 규정이 존재하고 있다면 개별 근로자가 임금체계 변경에 동의하였다 하더라도 그 합의의 효력이 인정되기 어렵기 때문이다. 따라서 임금체계의 변경이 종전의 단체협약을 위반한다면 그 근로계약상 합의는 무효이며, 이는 다시 연공급 등 종전 단체협약의



내용으로 대체되고 만다.

여기서 검토가 필요한 사항은 ① 새로운 임금체계 변경이 종전의 취업규칙 또는 단체협약에 의한 임금체계보다 모든 근로자에게 유리하다면 근로계약을 통한 연봉제의 도입도 가능할 것인가의 문제와, ② 취업규칙 또는 단체협약에 “미달”하거나 “위반”하지 않는 새로운 임금체계의 내용을 어떻게 구성할 것인가의 문제이다.

먼저 근로계약 변경을 통해 새로 도입된 성과주의 임금체계가 종전 취업규칙 상 임금지급방식보다 근로자에게 유리하다면 근로계약을 통한 임금체계의 변경도 얼마든지 가능할 수 있다. 취업규칙에 “미달”하지 않는다는 규정의 의미는, 근로자의 입장에서 “유리한 근로조건”으로 이해되기 때문이다. 따라서 근로자 간의 이해관계가 상충됨이 없이 모든 근로자에게 유리하다면 근로계약을 통한 연봉제의 도입도 가능할 것으로 보인다. 다만, 예를 들어 새로 도입된 성과주의 임금체계가 종전의 취업규칙보다 불리하거나 일부 근로자에게는 유리하고 일부 근로자에게 불리하다면 연봉제에 관한 합의는 취업규칙의 불이익변경의 법리에 따라 해결되어야 할 것이다.

한편, 근로자에게 개별적으로 유리한 근로조건이라 하더라도 단체협약에 “위반”하는 경우에 유리조건을 인정할 것인가가 문제된다. 이에 관한 문제는 단체협약의 규범적 효력의 성격(양면적 강행설과 편면적 강행설)에 따라 그 효력 여부가 달라질 것이다(이에 대해서는 다음의 IV. 2.를 참고).

취업규칙 또는 단체협약에 “미달”하거나 “위반”하지 않는 성과주의 임금체계 즉, 모든 근로자에게 종전 임금체계보다 유리한 임금체계의 변경 내용을 어떻게 구성할 것인가의 문제에 대해서는 다양한 측면에서의 검토가 필요하다. 예를 들어 임금체계 변경을 통하여 근로자가 받게 되는 근로조건 변화를 개별 근로자의 입장에서 각각 판단할 것인가 아니면 근로자 전체의 입장에서 판단할 것인가, 또한 개별 근로자의 입장에서 보더라도 당장의 임금수준 저하만을 가지고 불이익 변경으로 볼 것인가 아니면 장래의 기대수입 저하 내지 증가를 포함하여 종합적으로 평가할 것인가, 나아가 임금수준 저하만을 기준으로 불리한 근로조건으로 평가할 것인가 아니면 그 밖의 근로조건(예를 들어 정년보장이나 정년연장 등 고용조건 변화)을 포함하여 종합적으로 평가할 것인가 등의 문제가 발생한다. 그런데 예를 들어 성과주의



임금체계는 그 본질상 종래의 호봉급 내지 연공급과 같이 근로자의 근속기간에 연동되는 임금제도가 아니라 근로자의 능력·성과에 연동되는 임금체계이다. 따라서 zero-sum 방식의 성과급과 같이 임금총액 내지 인건비 총액을 고정시킨 전제 위에서 근로자에게 그 성과를 배분하는 경우에는 일반적으로 근속기간이 짧거나 능력·성과가 높은 근로자에게는 상대적으로 유리할 수 있지만, 근속기간이 길거나 상대적으로 능력·성과가 낮은 근로자에게는 불리할 수 있는 임금체계이다. 임금피크제의 경우에도 정년보장형 임금피크제와 정년연장형 임금피크제로 나누어지면서 근로자의 정년보장 또는 정년연장에 대한 평가에 따라 유·불리가 달라질 수 있을 뿐 아니라, 당장 그 적용을 받게 될 중간관리직 이상의 중고령 근로자와 어느 정도 여유가 있는 청·장년 근로자 간의 이해관계가 상반될 여지가 크다. 결국 성과주의 임금체계가 모든 근로자에게 유리한 경우는 예를 들어 plus-sum 방식의 성과급제도(즉, 임금총액 또는 인건비 총액을 증가시킨다는 전제하에 근로자에게 그 성과를 배분하되, 개별 근로자의 종전 임금수준을 어떤 경우에도 저하시키지 않는 방식)와 같이 극히 예외적으로 인정될 수 있는 경우라고 할 수 있을 것이다.

Ⅲ. 취업규칙을 통한 임금체계 변경

이상과 같이 임금체계의 변경은 취업규칙의 변경이나 단체협약의 체결을 통하지 아니하고 개별 근로자와의 합의를 통해 도입될 가능성은 매우 희박하다고 보아야 할 것이다. 따라서 이하에서는 먼저 취업규칙 변경에 의한 성과주의 임금체계의 도입과 관련한 문제점 특히, 성과주의 임금체계 도입의 불이익변경 여부 및 근로자측 동의의 주체와 관련한 쟁점을 중심으로 검토한다.

1. 불이익 변경의 일반원칙



취업규칙의 변경을 통하여 성과주의 임금체계를 도입하는 경우에는 우선적으로 그것이 취업규칙의 불이익한 변경에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다. 예컨대 성과주의 임금체계의 도입이 취업규칙의 불이익변경에 해당한다면 근로기준법 제94조 제1항 단서에 의하여, 사용자는 근로자집단(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수)의 동의를 얻어야 하기 때문이다.

이와 관련하여 판례는 성과주의 임금체계의 도입이 취업규칙의 불이익변경에 해당하는지 여부는 결국 “대가관계나 연계성이 있는 제반 상황(유리하게 변경된 부분 포함)을 종합적으로 고려”하여 판단해야 한다고 보는 것이 일반적이다.³⁵²⁾ 다만, 취업규칙의 변경이 “일부의 근로자에게는 유리하고 일부의 근로자에게는 불리한 경우 그러한 변경에 근로자집단의 동의를 요하는지를 판단하는 것은 근로자 전체에 대하여 획일적으로 결정되어야 할 것이고, 또 이러한 경우 취업규칙의 변경이 근로자에게 전체적으로 유리한지 불리한지를 객관적으로 평가하기가 어려우며, 같은 개정에 의하여 근로자 상호간의 유리·불리에 따른 이익이 충돌되는 경우에는 그러한 개정은 근로자에게 불이익한 것으로 취급”하여야 한다고 보고 있다.³⁵³⁾ 이에 대해서는 학설과 행정해석도 거의 같은 입장이라고 할 수 있다.

그러나 일반적으로 성과주의 임금체계가 모든 근로자에게 유리하게 작용하는 경우는 드물다. 대가관계나 연계성이 있는 제반 상황(유리하게 변경된 부분 포함)을 종합하여 판단할 때, 성과주의 임금체계의 도입이 근로자에게 전체적으로 유리한지 불리한지를 객관적으로 평가하기 어려운 경우나, 근로자 상호 간의 유리·불리에 따른 이익이 충돌되어 근로자 전체에 대하여 획일적으로 결정되기가 곤란한 경우에는 근로기준법 제94조의 불이익변경에 해당하는지 여부를 객관적으로 명확히 판단하기 어렵기 때문에, 결과적으로 취업규칙 변경을 통해 성과주의 임금체계를 도입하려면 근로자에게 불리한 것으로 취급하여 근로자의 집단적 동의를 요구하는 것이 타당하다는 결론에 이르게 된다.

352) 대법원 1984.11.13. 선고 84다카414 판결, 대법원 1995.3.10. 선고 94다18072 판결 등 참조.

353) 대법원 1993.5.14. 선고 93다1893 판결 등 참조.



2. 불이익 변경 원칙의 예외

위에서 본 바와 같이, 취업규칙 변경이 일부 근로자에게는 유리하고, 일부 근로자에게는 불리하여 전체적으로 불이익한지 확실적으로 결정하기 곤란한 경우에는 불이익변경으로 보고, 과반수노조(근로자 과반수)의 동의를 받아야 한다는 것이 판례의 태도이다.³⁵⁴⁾ 따라서 해당 취업규칙 변경이 상당수 근로자들에게 유리하다 하더라도 근로자측이 변경에 동의하지 않으면 적어도 기존 근로자들에게는 변경의 효력이 인정되지 않는다.

다만, 대법원은 극히 제한적으로나마 “사회통념상 합리성”이 인정될 경우 근로자 집단의 동의를 받지 않아도 취업규칙 불이익변경을 유효한 것으로 볼 수 있다고 하여 예외를 인정할 여지를 두었다.³⁵⁵⁾ 그러나 최근 대법원 전원합의체 판결에서 근로기준법 제94조 제1항 단서는 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 근로자의 집단적 동의를 받아야 한다고 명시적으로 규정하고 있으며 이는 강행규정이라는 점을 들어, “노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 해당 취업규칙의 작성 또는 변경에 사회통념상 합리성이 있다는 이유만으로 그 유효성을 인정할 수는 없다.”고 하여, 기존의 사회통념상 합리성 이론을 폐기하고, 이를 대체하는 이론으로 집단적 동의권의 남용이론을 제시하였다.³⁵⁶⁾

354) 대법원 1993.5.14 선고 93다1893 판결; 대법원 2012.6.28 선고 2010다17468 판결. 그에 따르면 취업규칙의 일부를 이루는 급여규정의 변경이 일부의 근로자에게는 유리하고 일부의 근로자에게는 불리한 경우 그러한 변경에 근로자집단의 동의를 요하는지를 판단하는 것은 근로자 전체에 대하여 확실적으로 결정되어야 할 것이고, 또 이러한 경우 취업규칙의 변경이 근로자에게 전체적으로 유리한지 불리한지를 객관적으로 평가하기가 어려우며, 같은 개정에 의하여 근로자 상호 간의 유리·불리에 따른 이익이 충돌되는 경우에는 그러한 개정은 근로자에게 불이익한 것으로 취급하여 근로자들 전체의 의사에 따라 결정하게 하는 것이 타당하다.

355) 대법원 2001.1.15. 선고, 99다70846 판결; 대법원 2002.6.11. 선고, 2001다16722 판결; 대법원 2004.5.14. 선고, 2002다23185 판결 등 참조.

356) 대법원 2023.5.11 선고 2017다35588 전원합의체 판결.



이하에서는 성과주의 임금체계 도입에 관한 취업규칙의 변경을 둘러싸고 근로자 측의 집단적 동의가 이루어지지 않은 경우 그 유효성을 인정하는 예외로써, 사회통념상 합리성 이론과 집단적 동의권 남용이론을 검토한다. 적어도 아직까지는 집단적 동의권남용이론의 구체적 적용례가 명확해지지 않았기 때문에 사회통념상 합리성 이론과 비교·검토가 필요하기 때문이다.

3. 성과주의 임금체계 도입과 “사회통념상 합리성”

성과주의 연봉제의 장점으로 근로형태 다양화, 노동시장 유연화 경향의 확산 및 이에 따른 기업경쟁력 제고 요청에 대응하여 종래 연공급 임금체계가 갖는 경직성 및 한계의 극복, 기형적이고 복잡한 임금체계의 합리적 조정, 임금관리상의 혼란 최소화, 재량근무 종사자 및 고령인력에 대한 대응 필요성, 근로자의 역량강화 및 효율적 인력운영 필요성, 변화된 근로자의 가치관 및 의식에 대한 대응 및 동기부여 강화 등이 제시되고 있다. 이러한 이유로 우리나라에서도 연봉제 도입 사업체가 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다.³⁵⁷⁾ 이러한 장점과 함께 그 필요성 및 효과성 측면에서 성과주의 연봉제 도입에 관해 사회통념상 합리성이 인정될 여지도 있을 것이다.

그러나 연봉제의 장점이 모든 기업에, 그리고 모든 상황에 일반적으로 적용될 수 있는 것은 아니다. 예를 들어, 대부분의 연봉제 도입은 근로조건의 불이익변경에 해당될 가능성이 높다. 즉, 연봉제를 zero-sum의 형태로 도입한다면, 이는 일부 근로자에게 임금의 감액이 발생할 수도 있으므로 불이익한 변경으로 보아야 한다. 다만, plus-sum의 경우에는 연봉제의 실시로 인해서 종전의 임금이 감소하는 마이너스의 결과가 발생하지 않으므로 불리한 변경이라고 할 수는 없을 것이다.³⁵⁸⁾ 그러

357) 연봉제의 유형, 특성 및 실태 등에 관해 자세한 것은 근로기준국 임금정책과, 연봉제, 성과배분제 실태조사 결과, 노동부, 2003; 橋元秀一, “일본 임금제도의 변화: 연공임금은 어떻게 변화하고 있는가”, 「국제노동브리프」, 한국노동연구원, 2005. 7, 31면 이하 각 참조.



나 이러한 변경은 현실적으로 쉽지 않을 것이다.

따라서 연봉제로의 변경에 “사회통념상 합리성”이 인정되어 근로자들의 집단적 동의를 필요하지 않을 정도가 되기 위해서는 구체적이고 실질적인 필요성이 요청되고, 관련 근로조건의 개선과 공정하고 객관적이며 신뢰성 있는 평가제도의 정비 및 적용대상의 명확한 설정 등이 요구되는 것으로 엄격히 해석해야 할 것이다.

4. 집단적 동의권 남용이론의 적용

대법원은 위에서 본 것처럼 최근 전원합의체 판결에서 사용자가 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하면서 근로자의 집단적 동의를 받지 못한 경우 노동조합이나 근로자들의 집단적 동의 거부가 동의권 남용에 해당하는 등 특별한 사정이 없는 한 해당 취업규칙의 변경에 사회통념상 합리성이 있다는 이유만으로 그 유효성을 인정할 수 없다고 하여 종전의 사회통념상 합리성 이론을 폐기하였다. 그 핵심논지는 근로기준법이 명문으로 집단적 동의를 요건으로 규정하고 있음에도 취업규칙의 내용에 사회통념상 합리성이 있다는 이유만으로 근로자의 집단적 동의를 받지 않아도 된다고 보는 것은 취업규칙의 본질적 기능과 불이익변경 과정에서 필수적으로 확보되어야 하는 절차적 정당성 요청을 도외시하는 것이라는 점, 종래 대법원 판례의 해석은 근로자의 집단적 동의가 없더라도 특정 사례에서 사용자의 일방적 취업규칙 변경으로 기존 근로조건의 저하를 인정하는 것이어서 강행규정인 근로기준법 제94조 제1항 단서의 명문규정을 위반하는 해석이라는 점을 들고 있다. 그러면서 동시에 취업규칙 불이익변경 과정에서 근로자들이 집단적 동의권을 행사할 때도 신의칙과 권리남용 금지 원칙이 적용되어야 하므로, 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의를 남용하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 그 동의가 없더라도 취업규칙의 불이익변경은 유효하다고 보았다.

이때 집단적 동의권이 남용된 경우란 (i) 관련 법령이나 근로관계를 둘러싼 사회

358) 박우성/유규창/박종희, 「연봉제」, 한국노동연구원, 2000, 76면 참조.



환경의 변화로 취업규칙 변경 필요성이 객관적으로 명백히 인정되고, (ii) 근로자의 집단적 동의를 얻기 위해 사용자의 진정성 있는 설득과 노력이 있었음에도 노동조합이나 근로자들이 합리적 이유나 근거를 제시하지 않고 취업규칙 변경에 반대하였다는 등의 사정이 있는 경우를 말한다고 하여 집단적 동의권 남용의 판단기준을 제시하였다.

대법원이 제시한 집단적 동의권 남용의 판단기준은 사회통념상 합리성 판단기준과 비교해 볼 때 개별 기업이 안고 있는 문제에 대한 구체적 대안으로서 의미를 갖는지 여부를 판단하는데 한계가 있다는 점에서 구체적 타당성이 제대로 반영될 수 없다는 문제가 있다. 즉, 대법원이 제시한 사회통념상 합리성의 판단요소 중에는 근로자측이 입게 될 불이익의 정도, 사용자측의 변경 필요성의 내용과 정도, 변경 후 취업규칙 내용의 상당성, 대상조치 등을 포함한 다른 근로조건의 개선 상황 등을 중심으로 판단하도록 하고 있는 것과 비교하면 변경된 판례법리에서는 이와 같은 구체적 타당성보다는 관계법령 및 사회환경 변화만을 고려하도록 하고 있어서 개별 기업의 구체적 사정이나 여건은 고려 대상이 아니다. 이러한 이유로 사실상 직무급제나 성과주의 임금제도, 연봉제의 도입은 노동조합이나 근로자측이 반대하면 아무리 그 필요성이 크다고 할지라도 도입할 수 없게 될 것이다.

이 점이 향후 새로운 대법원 판결을 적용하는 과정에서 논란이 될 것으로 보인다. 집단적 동의권 남용의 요건과 관련하여 각 개별 사안의 객관적 사정을 넓게 고려하여 구체적 타당성이 확보될 수 있도록 해석할 필요가 있다.

5. 동의의 주체

취업규칙을 통하여 임금체계를 변경하는 것이 불이익변경에 해당하는 경우, 집단적 동의권 남용에 해당되어 예외로 인정받는 경우가 아니라면 근로자의 집단적 동의를 반드시 얻어야 한다. 그런데 동일한 사업 또는 사업장에 근무하는 근로자들 중 일정한 직급 또는 직역에 속하는 자들에 대해서만 취업규칙의 변경을 통해 성과



주의 임금체계를 도입하려고 한다면, 집단적 동의를 얻어야 할 과반수의 산정기준이 전체 근로자인지 아니면 성과주의 임금체계의 구체적인 적용대상인 해당 직급 또는 직역의 근로자인지가 문제된다.

이에 대하여 판례는 사원과 노무원으로 이원화된 개정 퇴직금 규정이 개정 전의 그것보다도 퇴직금 지급일수의 계산 및 퇴직금 산정 기초임금의 범위에 있어 근로자에게 불리하게 변경된 경우에는 이에 관하여 종전 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자집단의 동의가 있어야 유효하다고 할 것인바, 노동조합원인 총 근로자 중 85%가 넘는 수를 차지하는 노무원이 퇴직금 개정안에 완전히 동의하였다 하더라도 개정 퇴직금 규정이 노무원에 대한 부분에 국한하여 효력이 있는 것일 뿐, 당해 노동조합이 사원에 대해서도 과반수노조라고 인정하기 어려우므로 사원에 대해서 별도의 동의가 없다면 개정에 동의하지 아니한 사원에 대한 부분은 효력이 없다고 하고 있다.³⁵⁹⁾

한편, 학계의 입장은 대체로 ‘사업장 내에 근로자가 여러 집단으로 구분되어 있고 그 근로자집단별로 근로조건을 달리 정하고 있거나 별도의 취업규칙이 작성되어 있는 경우에는, 변경될 취업규칙의 적용을 받는 해당 근로자집단만이 동의의 주체가 될 뿐이고 해당 사업장 내의 모든 근로자가 동의의 주체가 되는 것은 아니다’라는 견해를 취하고 있는 것으로 이해된다.³⁶⁰⁾ 한편, 직급에 따른 범위가 승진과 같은 인사이동에 의해서 변동이 예상될 수 있는 경우에 근로자들은 서로 동질성을 갖고 있는 범위 내에 있는데도 특정 근로자들을 제외시키는 것은 문제가 있다고 지적한다. 따라서 “근로자들이 입사와 인사이동에 의해서 교류가 없고 입사 시부터 별도의 취

359) 대법원 1990.12.7. 선고 90다카19647 판결, 대법원 1991.1.15. 선고 90다6170 판결, 대법원 1991.2.12. 선고 90다15952·15969·15976(병합) 판결 등 참조. 대법원은 “취업규칙의 작성 또는 변경이 근로자가 가지고 있는 기득의 권리나 이익을 박탈하여 불이익한 근로조건을 부과하는 내용일 때에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자집단의 집단적 의사결정 방법에 의한 동의를 요한다”고 판시하고 있다(대법원 1993.1.26. 선고, 92다49324 등). 또한 “사용자가 취업규칙을 불리하게 변경하는 경우에 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 얻지 않은 이상, 취업규칙의 변경에 대하여 개인적으로 동의한 근로자에게도 변경의 효력이 발생하지 아니 한다”고 하였다(대법원 1991.3.27. 선고 90다3031 판결; 대법원 1992.12.8. 선고 91다38174 판결 등).

360) 김지형, 「근로기준법해설」, 1999, 453면 이하; 박우성/유규창/박종희, 「연봉제」, 80면; 정진경, “근로조건에의 불이익변경”, 「노동법연구」, 제13호, 20면 참조.



업규칙을 적용 받는 등 이원화된 집단으로 볼 수 있는 특별한 사정이 없다면, 해당 사업장에 근무하는 전체 근로자를 기준으로 집단적 동의를 받도록 하는 것이 현행 법리에 충실한 해석”이라는 견해도 있다.³⁶¹⁾

위의 판례와 학설의 견해를 정리하자면, 변경된 임금체계의 적용을 받는 근로자 뿐 아니라 그에 따른 직접·간접적 영향을 받는 근로자들의 집단적 동의를 받도록 할 것인지가 쟁점이라고 할 수 있다. 취업규칙은 본질적으로 근로자들의 근로조건을 통일적·집단적으로 규율하는 제도이므로 가급적 전체 근로자의 집단적 동의가 필요한 것이 사실이다. 다만, 경우에 따라서는 보수규정을 이원화하여 일반 생산직 근로자와 사무직근로자에게 각각 적용되는 급여규정을 둘 수도 있다. 이 경우에는 동의주체가 이원화될 수도 있다.

6. 소결

이상에서 취업규칙에 의한 임금체계 변경과 관련된 쟁점을 살펴보았다. 연봉제 등 성과주의 임금체계의 도입은 개별 근로자의 입장에서는 근로기준법 제94조 제1항 단서의 “불이익 변경”에 해당될 가능성이 높다. 따라서 이 경우에는 근로기준법 제94조 제1항 단서가 요구하는 근로자들의 집단적 동의가 없는 한 그 변경이 유효한 것으로 인정되기 어려울 것이다. 경영상 해고에서 요구되는 정도의 ‘긴박한 경영상의 필요성’이 인정되고 불이익변경에 따른 대상조치, 관련 근로조건의 개선 및 공정하고 객관성·신뢰성 있는 평가제도의 정비, 적용대상의 명확화 등이 이루어져 성과주의 임금체계의 도입에 대해 구체적이고 실질적인 필요성이 인정될 수 있는 경우라 하더라도 전체 근로자의 집단적 동의(과반수노조의 동의)가 없으면 불이익변경은 원칙적으로 효력이 없으며, 대법원의 입장에 따르면 집단적 동의권 남용에 해당하지 않는 한 예외가 인정되지 않는다.³⁶²⁾

361) 박수근, “연봉제의 실시에 있어 몇 가지 문제점”, 「노동법학」, 제13호, 177면 이하.

362) 이에 대하여 근로자의 집단적 동의가 없더라도 불이익변경의 유효성을 인정할 수 있는 예외 규정을 두자는 견해도 있다(이정, “취업규칙 불이익변경과 사회통념상 합리성-대법



IV. 단체협약의 변경을 통한 임금체계 변경

1. 과반수노조의 단체협약 체결의 효력

단체협약은 노동조합의 대표자와 사용자가 체결하며(노조법 제29조), 단체협약을 불이익변경할 경우에도 노동조합의 대표자가 사용자와 체결하면 그 단체협약은 유효하게 성립한다. 따라서 추가로 개별 조합원의 동의를 구할 필요가 없다.

그런데 노동조합과 사용자가 단체협약에서 성과주의 임금체계 도입에 합의하는 경우 그 단체협약은 조합원에게만 적용되는 것이 원칙이기 때문에, 비조합원에게는 적용되지 않는다(이를 단체협약의 구속력범위라고 한다). 그런데 근로자 과반수로 조직된 노동조합(과반수노조)이 단체협약을 체결하는 경우에는 해당 단체협약의 내용이 비조합원에게 확대 적용될 수 있는 가능성이 있다. 먼저 과반수노조는 근로기준법 제94조 제1항에 따라 사실상 전체 종업원들의 이익을 대표하여 취업규칙 불이익 변경의 동의주체가 되므로 과반수노조에 의한 단체협약의 체결 이후 다시 취업규칙을 변경함으로써 비조합원을 포함한 전체 종업원에게 변경된 근로조건을 적용할 수 있다.

한편 과반수노조가 체결한 단체협약은 일반적 구속력 확장을 통해 비조합원에게 적용될 수 있다. 다만, 일반적 구속력 확장은 동종근로자에게만 미치므로 처음부터

원 2023. 5. 11. 선고 2017다35588, 2017다35596 병합 판결”, 「KEF 주간 e-경제·정책 리포트», 2023-30호, 한국경영자총협회 참고). 이 견해는 특히 일본 노동계약법 제10조의 영향을 받은 것으로 보이는데, 일본 노동계약법 제10조는 취업규칙에 의한 근로조건 변경은 그것이 합리적인 것일 때 근로계약의 내용이 되고, 근로자와 사용자를 구속한다고 규정하면서, 취업규칙 변경의 합리성 판단기준으로 ① 근로자가 받는 불이익의 정도, ② 근로조건 변경의 필요성, ③ 변경후 취업규칙 내용의 상당성, ④ 노동조합 등과의 교섭 상황, ⑤ 그 밖에 취업규칙 변경에 관련된 사정을 열거하고 있다. 그렇지만 이와 같은 입법론은 근로자의 집단적 동의를 불이익 변경의 요건으로 정하고 있는 우리 근로기준법과는 부합하지 않는다는 문제가 있다.



조합가입자격이 없는 근로자(예: 간부직원)는 일반적 구속력 확장에 의해서도 단체협약의 적용을 받기 어렵다. 그러므로 전체 종업원에게 변경된 근로조건을 적용하기 위해서는 취업규칙의 변경이 수반되어야 한다.

그 결과 과반수노조가 조합원 자격이 없는 근로자에 대해서도 취업규칙 불이익변경의 주체가 됨으로써 그들의 의사에 반하여 근로조건을 불리하게 만드는 결과를 초래할 수 있다. 예를 들어, 임금피크제의 적용을 받는 자의 대부분이 일정한 직위 이상에 해당하는 자로서 조합원 자격이 인정되지 않는 경우에 과반수노조라는 이유로 비조합원인 이들의 근로조건에 대해서까지 취업규칙을 통한 불이익변경의 동의 주체가 될 수 있는지 논란이 있었다.³⁶³⁾

이러한 이유로 전체 근로자 과반수로 조직된 노동조합이라 하더라도 단체협약 체결 시 당해 조합원뿐 아니라 이해관계 당사자인 비조합원의 의사도 반영할 수 있는 방법이 필요한지 논란이 제기될 수 있다. 과반수노조 자체가 전체 근로자에 대한 대표성을 가지므로 비조합원인 근로자의 의견수렴이 별도로 필요하지 않다고 할 수도 있고, 반대로 전체 종업원에게 그 효력이 미치게 될 임금체계 개편에 대해서는 비조합원의 의견을 반영해서 결정해야 한다는 견해도 있을 수 있을 것이다. 다만 후자는 임의적, 재량적 방법일 뿐 의무적인 절차가 아니다.

2. 단체협약·취업규칙·근로계약의 불일치와 효력관계

과반수노조가 체결한 단체협약은 노조법 제35조에 따라 “당해 사업 또는 사업장에 사용되는 다른 동종의 근로자”에 대해서도 적용된다(일반적 구속력). 이에 따라

363) 박종희, “임금피크제의 허와 실 - 노동법적 검토 및 정책적 평가를 중심으로 -”, 38-39면. 이에 따르면 만약 불이익 변경에 대한 유효성의 본질을 기득권자의 동의에 둔다면 인정할 수 없게 될 것이며, 유효성의 본질을 근로자의 집단적 동의에 초점을 두거나 기득의 권리뿐만 아니라 장래에 발생하게 되는 권리까지 함께 포함하여 이해하는 입장에 설 경우, 그리고 실제로 노동조합이 비조합원의 이익도 현실적으로 대변하는 역할을 수행한 것으로 볼 수 있는 경우에는 과반수 노동조합에 대한 동의 주체성을 인정할 수 있다고 한다.



“동종의 근로자”³⁶⁴⁾가 아닌 경우에는 해당 단체협약의 적용을 받지 않지만, “동종 근로자”에 대해서는 단체협약과 취업규칙 또는 단체협약과 근로계약의 불일치 문제가 제기될 수 있다. 이는 노조법 제33조 제1항(단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효로 한다)의 적용 문제로서, 취업규칙이나 근로계약이 단체협약보다 유리한 조건을 정하고 있는 경우 단체협약보다 취업규칙이나 근로계약이 우선 적용되는지(편면적 강행설) 아니면 단체협약의 규범적 효력이 우선 적용되어 취업규칙이나 근로계약의 내용을 무효로 하는지(양면적 강행설)의 문제이다. 다시 말해 단체협약과 취업규칙 및 근로계약 간에 유리조건 우선 원칙이 적용되느냐 하는 문제이다.

이와 관련하여 먼저 편면적 강행설³⁶⁵⁾에 의하면 비조합원인 동종 근로자는 종전 취업규칙 또는 근로계약이 단체협약보다 유리하다면 유리조건 우선 원칙에 따라 취업규칙이나 근로계약의 임금체계가 계속 적용될 것이다. 이에 반하여 양면적 강행설³⁶⁶⁾에 의하면, 단체협약에 위반하는 취업규칙과 근로계약은 모두 무효가 되므로 단체협약의 내용이 비조합원인 동종 근로자에 대해서도 적용될 것이다. 한편 절충설³⁶⁷⁾에 의하면 단체협약을 체결한 노동조합이 산별노조인 경우에는 편면적 강행설과 같은 결과(무효)를, 기업별 노조인 경우에는 양면적 강행설과 같은 결과(유효)가 되는 등 사안에 따라 효력이 달라질 수 있다고 한다.³⁶⁸⁾ 근로조건의 통일화 또는 노동조합의 단결력 약화 방지 등의 취지를 고려할 때 양면적 강행설로 해석하는 것

364) 이에 대하여 판례는 “하나의 단체협약의 적용을 받는 근로자가 반수 이상이라는 비율을 계산하기 위한 기준이 되는 근로자의 총수란 근로자의 지위나 종류, 고용기간의 정함의 유무 또는 근로계약상의 명칭에 구애됨이 없이 사업장에서 사실상 계속적으로 사용되고 있는 동종의 근로자 전부를 말한다”고 판시하고 있다(대법원 1992.12.22. 선고, 92누13189 판결 참조).

365) 김치선, 「노동법강의」, 1988, 358면; 김형배, 「노동법」, 1082면; 박상필, 「한국노동법」, 1989, 448면.

366) 김유성, 「노동법 II」, 1996, 162면.

367) 이병태, 「최신 노동법」, 2005, 273면; 이상윤, 「노동법」, 712면.

368) 이철수, 「노동법」, 522-523면은 편면적 강행설(유리원칙)과 양면적 강행설 어느 하나를 원칙으로 채택하기 보다는 여러 사정을 고려하여 근로자의 이익과 노동조합의 이익 간 이익형량에 따라 구체적으로 판단되어야 한다고 본다. 일반적 구속력에 있어서 비조합원에 대하여는 일반 조합원과 달리 이익형량의 필요성이 높지 않으므로 유리원칙(편면적 강행설)을 적용할 수 있다고 본다.



이 타당해 보인다.



제5장 요약 및 결론

본 논문의 내용은 다음과 같이 요약할 수 있다.

제2장에서는 임금 개념과 평균임금 개념의 관계를 중점적으로 다루고 있다. 고용계약(근로계약)상 보수란 당사자 간 합의에 의하여 사용자가 반대급부로 지급하기로 한 모든 금품이라고 할 수 있지만, 임금에 대한 강행적 보호규정을 정한 근로기준법은 그와 같은 반대급부 중 ‘근로의 대가’로 지급하는 것을 임금으로 정의하고 있다. 대법원은 어떤 금품이 근로기준법상 임금에 해당하기 위해서는 근로의 대가로서, 그것이 계속적·정기적으로 지급되어야 하고, 사용자에게 지급의무(당사자의 합의)가 있어야 하며, 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성을 가지고 있어야 한다고 판시하고 있다.

현실적으로 임금성을 둘러싼 대부분의 법적 분쟁은 어떤 금품이 평균임금 산입 범위에 포함되는 임금인지 여부에 집중되어 있는데, 임금과 평균임금이 본질적으로 다른 개념임에도 대법원은 퇴직금 지급 등 평균임금 관련 소송에서 평균임금의 특성을 반영하여 임금 개념을 해석함으로써 평균임금 산입 범위를 제한하는 법해석을 해왔다고 할 수 있다.

그러나 평균임금 산입 범위에 속하는 임금과 본래적 의미의 임금은 서로 별개의 개념으로서 차이가 있으며, 그 차이는 다음과 같은 점에서도 확인된다. i) 근로기준법 시행령 제2조 제2항은 ‘임시로 지급된 임금 및 수당’ 등을 평균임금에서 제외한다고 규정하고 있는 점, ii) 통상적 생활임금 보장이라는 평균임금 취지에 부합하지 않는 임금은 산출 시 배제한다는 점, iii) 특수하고 우연한 사정으로 통상의 경우보다 현저하게 많거나 적은 경우 평균임금의 취지를 반영하여 산정해야 한다는 점, iv) 부당해고 시 임금상당액 청구 등과 같이 평균임금이 문제되지 않고 임금성만 문제되는 사례도 있다는 점 등만 봐도 평균임금과 임금의 판단 요건은 구별될 수 있다.



임금은 근로자에게 응당 지급되어야 할 근로제공의 대가인데, 사안에 맞는 평균 임금 산정을 위하여 임금 개념을 좁게 해석함으로써 임금의 범위가 축소되는 문제가 발생한다. 이 문제를 해결하기 위해 먼저 입법을 통한 개선을 생각해 볼 수 있다. 예를 들어 일본의 경우처럼 법률로 3개월을 초과하여 지급되는 임금(상여금, 성과급)은 통상의 생활임금으로 보지 아니하여 평균임금에서 제외하는 방법 등을 생각해 볼 수 있을 것이다. 하지만 입법적 해결방법은 이해당사자들의 반발과 노동입법의 어려움을 고려하면 가까운 시일 내에 실현되기는 어려워 보인다.

다음으로 법해석을 통해 이 문제를 해결하는 방안도 있다. 법원이 임금의 개념요소인 ‘근로의 대가’는 넓게 해석하고, 평균임금은 통상적 생활임금 보장이라는 취지를 고려하여 사안에 적합하게 합목적적으로 산입범위를 결정할 수 있어야 한다. 실체적 개념인 임금과 달리, 평균임금은 본래 산정을 위한 도구적 개념이므로 시도할 수 있는 방법이라고 생각한다. 대법원은 이미 택시근로자의 초과운송수임금이 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 산입되는지 여부에 관한 판결에서 근로자의 통상적인 생활임금이라는 평균임금의 취지와 부합하지 않는다는 이유로 평균임금 산입 범위에서 제외하는 판단을 내린 바 있다.

또한 대법원이 임금의 개념요소로 제시하고 있는 계속적·정기적 지급 및 근로제공과의 직접 또는 밀접한 관련성이라는 판단기준은 평균임금의 산입 대상 범위를 결정하는 기준으로 보는 것이 타당하다. 이렇게 되면 임금 개념 그 자체에 대해서는 근로대가성의 의미를 비교적 넓게 해석하여, 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성까지는 아니더라도 어느 정도 관련성을 인정할 수 있다면 임금으로 인정하여 노동법적 보호를 받을 수 있도록 하는 것이 타당하다.

제3장에서는 임금 개념론에서 논란이 되고 있는 구체적 사례로서 경영성과급의 임금성과 최근 대기업을 중심으로 확산되고 있는 주식보상제의 법적 성격 및 노동법적 쟁점을 검토하였다.

사용자가 지급의무를 부담하는 경영성과급의 임금성을 판단함에 있어서 대법원



이 제시한 판단기준(계속적·정기적 지급, 지급의무의 존재, 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성의 존재)을 적용할 경우 현재의 판례법리로는 경영성과급은 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성의 부존재로 인하여 임금으로 인정되기 어려울 것이다.

하지만 기업의 경영목표를 달성하고 경영실적을 개선하는데 있어서 근로자의 집단적 협업이 불가결한 요소라는 점을 고려하면 기업의 경영성과 달성에는 대내외적 경영환경이나 경영진의 경영전략 및 전체적인 시장상황 등이 많은 영향을 미친다고 하더라도 근로제공의 역할을 과소평가할 수는 없을 것이다. 따라서 경영성과급은 기업이 거둔 경영성과의 일부를 노동의 몫으로 종업원에게 할당한 것이고, 근로제공과 어느 정도 포괄적 관련성을 인정할 수 있으므로 임금성을 가진다고 할 수 있다.

다만, 경영성과급에 대하여 포괄적인 근로의 대가로서 임금성을 인정하더라도 곧바로 평균임금의 산입 범위에 포함되는 임금이라고 단정할 수는 없다. 경영성과급처럼 지급조건의 충족이 불확정적이고 변동성이 큰 임금을 근로자의 통상적인 생활임금을 산정하는 평균임금에 포함시키는 것은 타당하지 않기 때문이다. 평균임금의 취지가 특정 사유 발생 시 근로자의 통상적인 생활임금을 사실적으로 산정하는데 있다면 임금 중에서도 계속적·정기적으로 지급되고 근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성이 있어야 통상적인 생활임금으로서 예측가능성이 있으므로 평균임금 산입 범위에 포함될 수 있을 것이다. 이러한 요건을 충족하지 못하는 경영성과급은 임금성이 인정되더라도 평균임금에는 포함되지 않는다고 볼 수 있다.

최근에는 사용자가 임직원들에게 자사 주식을 교부하거나 일정한 조건 하에서 자사주를 취득·처분할 수 있는 권리를 보장하는 이른바 주식보상이 확산되고 있다. 하지만 주식보상의 임금성 여부와 관련해서는 아직 일반적으로 검토된 바가 없다.

주식보상의 지급대상자 및 지급액이 점차 늘어나고 있는 상황을 고려하면 향후 임금성을 인정함으로써 근로자를 적극적으로 보호할 필요가 있을 것으로 생각된다. 주식보상을 임금으로 인정할 경우 발생할 수 있는 노동법적 쟁점으로는, 먼저 근로기준법 제43조 제1항이 정하고 있는 임금의 통화지급원칙 위반 문제를 들 수 있다. 주식으로 임금을 갈음하는 것은 일종의 현물급여에 해당하므로 단체협약의 근거 없



이 주식을 임금으로 지급한다면 통화지급의 원칙에 반한다. 주식보상제가 활성화되기 위해서는 통화지급원칙을 수정해야 할 것이다. 현행법은 단체협약에 의한 예외만 인정하고 있으나, 주식보상제를 선호하거나 주식보상이 활용되는 임직원들은 대체로 노조 가입자격이 없거나, 노조에 의하여 대표되지 않는 직군이나 직종에 종사하는 경우가 많은데, 단체협약에 의한 예외만을 인정하는 것은 이러한 현실과 부합하지 않을 수 있다. 따라서 예를 들어 근로자대표와 합의, 근로자의 자유로운 의사에 의한 합의, 근로자에게 선택권을 부여하는 방법 등을 추가로 고려해 볼 수 있을 것이다.

또한 임금의 일부를 주식(자사주)으로 지급할 경우 근로자에게 지급되는 임금 중 어느 정도까지 주식으로 지급할 수 있는지 문제 될 수 있다. 생각건대 근로자의 생활안정을 위해서는 임금의 일정부분은 통화로 지급되어야 한다. 그런데 현행 근로기준법은 단체협약으로 통화지급원칙의 예외를 정할 수 있도록 허용하면서도 그 한계를 정하고 있지 않다. 근로자의 실질적 생활보장을 위해서는 전체 임금액 중 통화로 지급되어야 할 임금(현금)에 대한 최저 보장액이 마련되어야 할 것이다.

그리고 주식보상의 임금성이 인정된다면 평균임금 산입 대상이 될 수 있는지가 문제된다. 주식보상이 근로자에게 지급되는 임금의 일부를 주식으로 대체하는 것이라면 부여 당시 주식가치 평가액이 평균임금 산입 범위에 포함될 수 있을 것이다. 하지만 주식이 1회 적인 이벤트로 부여된다면 계속적·정기적 지급이라고 할 수 없으므로 평균임금 산입 범위에 포함하기 어려울 것이다.

제4장에서는 임금청구권의 변동과 임금체계 개편의 노동법적 쟁점을 다루었다. 임금을 둘러싼 법적 분쟁의 다수가 임금청구권의 변동 및 소멸과 연계되어 있다는 점에서, 임금 개념을 체계적으로 이해하기 위해서는 당사자(집단, 개별 모두 포함)가 그 지급조건이나 방식 등에 대하여 어떻게 약정했는지가 중요한 의미를 갖는다. 또한 집단적이건 개별적이건 일정한 불이익을 수반하는 임금지급조건의 변경은 법률상 절차를 준수하지 않거나 또는 당사자의 합의가 없다면 유효성을 인정하기 어려울 것이다. 이 경우 당사자는 임금액의 결정을 고정적이고 집단적인 기준에 의할



것인지(연공형), 근로자가 수행하는 직무가치 또는 근로자가 보유한 능력과 자격을 기초로 할 것인지(직무형, 직능형), 구체적인 근로제공의 결과 및 성과에 대한 평가에 따를 것인지(성과주의형) 또는 앞의 요소와 함께 기업의 경영성과(실적)을 토대로 한 배당 형식을 가미하여 지급할 것인지(혼합형) 자유롭게 설계할 수 있다.

또한 급속한 사회경제적 환경 변화로 혁신을 하지 않으면 경쟁력을 유지하기 어려운 현실과 맞닥뜨린 기업의 상황에서 임금체계 개편이 최우선 과제가 되고 있다. 그 결과 기업의 법적 리스크가 점차 확대되고 있어 보상 및 인사관리 등에서 노동법의 역할이 점점 더 중요해지고 있으며, 기업 HR실무에 대하여 노동법의 역할이 불가결한 시대가 되고 있다. 본 논문에서는 기업이 전통적인 연공형에서 직무급, 성과주의 연봉제 등 임금체계 변경을 적극적으로 추진하고 있는 상황에서 임금체계와 인사관리에 관한 노동법적 이슈를 살펴보았다.

먼저 직무급제와 관련한 노동법적 쟁점 중 하나는 사용자의 인사권으로서 배치전환 명령권의 정당성 판단 및 그 한계에 관한 것이다. 직무급제에서는 직무내용과 임금이 강하게 연동되어 있어 배치전환은 임금 상승 또는 감액에 직결되기 때문에 사용자의 재량권인 배전명령권에 대한 권리남용 여부를 다투는 사례가 점차 늘어날 것으로 예상된다.

성과주의 임금체계에서 중요한 노동법적 이슈는 인사평가제도의 공정성 문제라고 할 수 있다. 이에 대비하려면 사용자는 인사평가 프로세스 전체의 공정성을 정비해야 한다. 객관적이고 구체적인 평가항목 및 기준을 정비하고 공개할 것, 평가의 수용성 및 객관성을 보장하기 위한 평가방법을 도입할 것, 평가를 구체적 처우(승급 및 강급 또는 인사이동 등)에 반영하기 위한 명확한 규칙을 정비할 것, 평가를 둘러싼 분쟁처리 절차를 정비할 것, 이와 같은 규칙을 근로자에게 통지·설명할 것 등이 중요하다고 할 수 있다.



[참고문헌]

[단행본]

강재원, 「스타트업·벤처기업 우수인력 유치를 위한 미국 주식 연계형 보상제도 현황 및 시사점」, 중소벤처기업연구원, 2023

김동배/정진호, 「임금체계의 실태와 정책과제」, 한국노동연구원, 2006

김동원/유규창, 「집단성과분배제도」, 한국노동연구원, 2000

김상률, 「임금의 개념과 제도상 문제점에 관한 연구」, 박사학위 논문, 경북대학교, 2011.

김영문/이상윤/이정, 「임금 개념과 평균임금·통상임금의 산정범위」, 법문사, 2004.

김유성, 「노동법 I」, 법문사, 2005.

김형배, 「노동법」, 제26판, 박영사, 2018

김형배/박지순, 「노동법 강의」, 제12판, 신조사, 2023.

노동법실무연구회, 「근로기준법 주해 I」, 제2판, 박영사, 2020.

문무기/윤문희/이철수/박은정, 「임금제도 개편을 위한 노동법적 과제」, 한국노동연구원, 2006.

박영범, 「주요 선진국의 성과배분제도」, 한국노동연구원, 1994.

박우성/유규창/박종희, 「연봉제」, 한국노동연구원, 2000.

박은규, 「임금의 개념에 관한 연구」, 박사학위 논문, 한양대학교, 2013.

신범철 외, 「우리사주제도 실태조사와 외국제도 비교 연구」, 노동부 연구보고서, 2004

양재현, 「민법상 고용계약에 관한 연구」, 박사학위 논문, 숭실대학교, 2010.



이병태, 「최신노동법」, 제8전정판, 중앙경제, 2008,

이선신, 「임금의 유연성 제고에 관한 법리 연구」, 박사학위 논문, 고려대학교, 2010.

이장원/김동배/이상준, 「성과배분제도의 실태와 발전방안」, 한국노동연구원, 2020.

이철수, 「노동법」, 현암사, 2023.

임종률, 「노동법」, 제18판, 박영사, 2020.

하경효, 「임금법제론」, 신조사, 2013

[논 문]

권오성, “경영 성과급의 임금성”, 「월간 노동법률」, 346호, 중앙경제, 2020.

권 혁, “임금의 개념으로서 근로 대가성 판단에 관한 소고”, 「노동법포럼」, 제28호, 노동법이론실무학회, 2019.

김기선, “개인실적에 따라 지급되는 성과급의 임금성”, 「월간 노동법률」, 280호, 중앙경제, 2014.

김도환, “경영성과급의 임금성”, 「중앙법학」, 제24집 제1호, 중앙법학회, 2022.

김동욱, “사기업 경영성과급의 임금성에 관한 판결”, 「월간 노동법률」, 388호, 중앙경제사, 2023

김영문, “임금 개념과 평균임금·통상임금의 산정범위”, 「기업법연구」, 제18권 제2호, 한국기업법학회, 2004.

김재훈, “성과금은 임금에 포함되는가?”, 「월간 노동법률」, 180호, 중앙경제, 2006.

김홍영, “성과급의 임금성 여부”, 「노동법연구」, 17호, 서울대노동법연구회, 2004.

김홍영, “지난 20년간 임금 법제의 해석과 입법의 동향”, 「노동법연구」, 제26호, 서



울대노동법연구회, 2009.

김희성/성대규, “성과배분으로서 경영성과급의 임금성에 대한 고찰”, 「노동법포럼」, 제35호, 노동법이론실무학회, 2022.

김희성, “성과배분으로서 경영성과급은 근로의 대가인 임금에 해당하는가”, 「월간 노동법률」, 371호, 중앙경제사,

김희성/이준희, “경영성과급의 근로 대가성 인정요건에 관한 판례 검토”, 「노동법논총」, 제54집, 한국비교노동법학회, 2022.

노상헌, “임금의 법리와 쟁점-한국과 일본의 비교법적 검토”, 「노동법학」, 제31호, 한국노동법학회, 2009.

박수근, “연봉제의 실시에 있어 몇 가지 문제점”, 「노동법학」, 제13호

박종희, “복지포인트의 임금성”, 「노동법포럼」, 제28호, 노동법이론실무학회, 2019.

박종희/강선희, “비정규근로자에 대한 차별시정제도의 현황과 몇 가지 쟁점에 대한 검토”, 「산업관계연구」, 제22권 제2호, 한국고용노사관계학회, 2012.

박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 「노동법포럼」, 제38호, 노동법이론실무학회, 2023

박지순/이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 「노동법논총」, 제49집, 한국비교노동법학회, 2020.

박진호, “현행법상 임금의 본질과 통상임금에 관한 연구”, 「노동법학」, 제61호, 한국노동법학회, 2017.

신동윤/성대규, “경영성과급의 임금성 판단기준에 관한 고찰”, 「사회법연구」, 제46호, 2022.

심재진, “공공기관 경영평가성과급의 임금성”, 「산업관계연구」, 제29권 제3호, 한국고용노사관계학회, 2019.

심재진, “집단적 경영성과급의 임금성”, 「월간노동리뷰」, 2021년 8월호, 한국노동



연구원, 2021.

유성재, “경영평가성과급의 임금성”, 「월간 노동법률」, 343호, 중앙경제, 2019.

이달휴, “최근 대법원 전원합의체 판결과 임금·통상임금의 판단요소”, 「법제논단」 (2014. 4), 법제처, 2014.

이섿별/권오성, “임금에 관한 최근 판결 경향의 검토”, 「노동법포럼」, 제36호, 노동법이론실무학회, 2022.

이선신, “「근로기준법」상 임금정의규정의 합리적 해석방안” 「노동법학」, 제46호, 한국노동법학회, 2013.

이수정/박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 법적 성격”, 「노동법포럼」, 제37호, 노동법이론실무학회, 2022.

이영면, “이익분배제에 대한 노사의 입장변화 : 미국의 경험과 시사점”, 「산업관계연구」, 제12권, 한국고용노사관계학회, 2002.

이장원/김동배/이상준, 「성과배분제도 실태와 발전방안」, 한국노동연구원, 2020

이장원/송민수/김윤호/이민동, 「임금직무체계 변화실태와 직무급의 과제」, 한국노동연구원, 2015

이 정, “상여금(경영성과급)의 법적 성격에 관한 연구”, 「외법논집」, 제44권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2020.

이정현, “공공기관 경영평가성과급의 임금성 여부”, 「월간 노동법률」, 343호, 중앙경제, 2019.

정명현, “근로의 대가의 의미론적 고찰을 통한 임금의 개념 정립에 관한 연구”, 「저스티스」, 제155호. 2016.

정종철, “변동성과급은 평균임금에 포함되어야 하는가?”, 「월간 노동법률」, 340호, 중앙경제, 2019.

조상욱, “경영성과급 임금성의 법적 쟁점”, 「월간 노동법률」, 367호, 중앙경제,



2021.

최진수, “임금의 양대 요건으로 본 경영성과급”, 「월간 노동법률」, 371호, 중앙경제, 2022.

한광수/김희성, “복지포인트의 임금해당성”, 「노동법논총」, 제48집. 한국비교노동법학회, 2020.

황보운/양영석, “스타트업과 벤처기업의 우수인력유치 위한 주식연계형 보상연구연구: 양도제한조건부주식(RSU) 도입 중심으로”, 「벤처창업연구」, 제18권 제6호, 2023

[외국문헌]

土田道夫, 「労働契約法」, 有斐閣, 2016

土田道夫, “職務給、職務等級制おめぐる法律問題”, 「経営と労働法務の理論と実務」(安西愈先生古稀記念論集), 2009

西谷民, 野田進 外, 「注釋 労働基準法、労働契約法」, 제2판, 日本評論社, 2020(労働基準法、労働契約法)

水町勇一郎, 「詳解労働法」, 東京大學出版會, 2019

菅野和夫, 「労働法」, 제11판, 弘文堂, 2016

山口浩一郎, 菅野和夫 外, 「経営と労働法務の理論と實務」, 中央經濟社, 2009

野川忍, 「労働法」, 2018

高原暢恭, 「賃金、賞與制度の教科書」, 勞務行政, 2014

經團連編, 「人事賃金制度」, 2017

日本 厚生労働省, 「労働基準法(上)」, 令和3年版, 2021



Moll/Hexel, *Münchener Anwaltshandbuch Arbeitsrecht*, 5. Aufl., 2021

Müller-Glöge/Preis/Schmidt, *Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht*, 22.
Aufl., 2022

Reichold, *Arbeitsrecht*, 6. Aufl., 2019

Ricken, *Gewinnbeteiligungen im Arbeitsverhältnis?*, NZA 1999, 236

Salamon, *Entgeltgestaltung*, 2019

Schaub, *Arbeitsrechts-Handbuch*, 19. Aufl. 2021

